



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

دراسات في أصول الفقه الحنفي

مقرر مادة أصول الفقه لطلاب الفرقة الرابعة

إعداد

أ.د / نايل عبد الجيد محمد
أستاذ أصول الفقه المساعد المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بأسسيوط

أ.د / مدحت مصطفى أحمد
أستاذ أصول الفقه المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بأسسيوط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى،
وأصلي وأسلم على حبيبه المُنْتَقَى وصفيه المُنْتَقَى سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن اهتدى".

أما بعد،

فهذه مُحاضرات في أصول الفقه، ذلك العلم الذي يُعد من أعظم
العلوم الشرعية قدراً، وأعلاها منزلة وشرفاً، وأجلها نفعاً، إذ هو عماد
الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه بناؤه، فهو من العلوم التي لا غنى
للمُجتهد عنها، من أجل ذلك وغيره اعتنى به علماء المسلمين - على مر
العصور - عناية فائقة، فألفوا فيه المصنفات المختلفة، بعضها مطولاً
وبعضها مختصراً موجزاً، ولا يخفى على المتخصصين في هذا الفن مدى
صعوبة استيعاب الطالب لهذه المصنفات دون شرح وبيان، الأمر الذي
دعاني إلى كتابة هذه المحاضرات وتدوينها، مُراعياً في ذلك سهولة
التعبير، وتوضيح الأفكار، مُبتعداً عن الخلافات والمناقشات ما أمكنني إلى
ذلك سبيلاً.

وهذه المحاضرات وضعتها لطلاب الفرقة الرابعة بكليات الشريعة
والقانون بجامعة الأزهر.

والله أسأل أن تكون تلك المحاضرات وافية بالغرض ومُحققة
للهدف المرجو منها. فافتح اللهم لنا أبواب الرضا والخير والتيسير،
وأغلق عنا أبواب السخط والشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم
النصير.

د/ نايل عبد الجيد محمد

المنهج المقرر

أولاً: الدراسة الموضوعية:

- أركان الحكم الشرعي.
- الحاكم.
- المحكوم فيه وأقسامه (باعتبار ذاته - وباعتبار الصحة والفساد - وباعتبار وصفه).
- الحكم الشرعي وأقسامه (تكليفي - ووضعي).
- الحكم التكليفي وأقسامه.
- الحكم الوضعي وأقسامه.
- المحكوم عليه.
- الأهلية وأقسامها (أهلية وجوب - وأهلية أداء).
- الأمور المعترضة على الأهلية (عوارض سماوية - وعوارض مكتسبة).

ثانياً: الدراسة النصية:

- دفع العلل المؤثرة.
- دفع العلل الطردية.
- الحُجج الفاسدة.
- باب المعارضة والترجيح.
- باب الاجتهاد.

أولاً: الدراسة الموضوعية

سبق لأبنائنا الطلاب في سنوات الدراسة السابقة دراسة مباحث الأدلة (الكتاب - السنة - الإجماع - القياس) وفي هذا العام الدراسي نتناول بالدراسة مباحث الأحكام التي تثبت بهذه الأدلة.

ومباحث الأحكام تشتمل على الآتي:

- الحكم.
- الحاكم.
- المحكوم فيه.
- المحكوم عليه.

فالمباحث الثلاثة الأخيرة من التعلقات الضرورية التي يجب توافرها في كل حكم، سواء أكان تكليفيًا أم تعلقيًا، وسوف نتناول بعون الله تعالى المباحث الأربعة تفصيلًا؛ لأن النظر فيها من المقاصد الأصلية في مقرر الفرقة الرابعة.

أولاً: الحاكم

وهو الله سبحانه وتعالى^(١) لا العقل، وقولنا: لا العقل إشارة إلى الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية في الحُسن والقُبْح، وفيما يلي نوضح الخلاف.

قبل ذكر محل النزاع ينبغي الإشارة إلى أن الاتفاق واقع بين العلماء على أن مصدر الأحكام ومنشأها هو الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾^(٢) إذا علمت ذلك فأليك بيان محل النزاع وآراء العلماء في ذلك: الحُسن والقُبْح يُطلقان على ثلاثة معانٍ، هي:

١- كون الشيء مُلائماً للطبع أو مُنافراً له فالحُسن ما كان مُلائماً للطبع، والقبيح ما كان مُنافراً له، كقولنا: الحلو وشكر النعم حَسَن، والمر الكفر قبيح.

٢- كون الشيء صفة كمال أو نُقصان، فالحُسن صفة كمال كالإحسان والعلم، والقُبْح صفة نُقصان كالإساءة والجهل.

فهذان الإطلاقان للحُسن والقُبْح محل اتفاق بين العلماء على أنهما عقليان، ويستقل العقل بإدراك ما فيهما من حُسن أو قُبْح دون توقف على الشرع.

٣- ما يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة، كقولنا: الطاعة حسنة، والمعصية قبيحة، وهذا المعنى هو محل الخلاف، هل يثبت ذلك عقلاً أم شرعاً؟.

(١) قد يعترض على ذلك: بأن الحُكم يتناول القياس المحتمل للخطأ، فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ ويجاب عن ذلك بأن الحاكم في المسائل الاجتهادية هو الله تعالى، إلا أنه لم يحكم إلا بالصواب، فالحكم المنسوب إليه تعالى هو الحق الذي لا يحوم حوله باطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة، بل ظاهراً، والمُكلف معذور في ذلك (التلويح، ١٢٢/٢).

(٢) سورة الأنعام، من الآية (٥٧).

واختلفوا إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مذهب الأشاعرة وكثير من المتكلمين وبعض الحنفية: أن ذلك يثبت بالشرع لا بالعقل.

المذهب الثاني: مذهب المعتزلة والكرامية والخوارج: أن ذلك يثبت بالعقل، بمعنى: أن العقل يستقل بإدراك حُسن بعض الأشياء وقُبْحها، إلا أنه لا يحكّم، لأن الحاكم عندهم هو الله تعالى، كما هو مذهب أهل السُّنة.

المذهب الثالث: مذهب الماتريدية وأكثر الحنفية التوسط بين المذهبين السابقين: فلا يُهمل العقل كُلية كما قالت الأشاعرة، ولا يُهمل الشرع كُلية كما قالت المعتزلة.

وفحوى مذهب الماتريدية: أن أفعال المُكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حُسْنها أو قُبْحها، وأن العقل بناءً على هذه الخواص والآثار يستطيع الحُكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسناً فهو حسن، وما رآه العقل السليم قبيحاً فهو قبيح، ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - حيث قال: "لا عُذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض"^(١). ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله تعالى في أفعال المُكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حُسن أو قُبْح، لأن العقول مهما نضجت قد تُخطئ.

وعلى هذا: لا سبيل إلى معرفة حُكم الله إلا بواسطة رُسله، فهؤلاء وافقوا المعتزلة في أن حُسن الأفعال وقُبْحها مما تدركه العقول، بناءً على ما تدركه من نفعها أو ضررها، وخالفوهم في أن حُكم الله لا بد أن يكون وفق حُكم العقل، وفي أن ما أدرك العقل حُسْنه فهو مطلوب لله فعله، وما أدرك العقل قُبْحه فهو مطلوب لله تركه.

(١) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢٣٤/٤؛ فواتح الرحموت شرح مُسلم الثبوت ٢٨/١.

ووافقوا الأشاعرة في أن حُكَمَ الله تعالى لا يُعرف إلا بواسطة رُسُلِهِ وَكُتِبَ، وخالفوهم في أن الحُسْنَ والقُبْحَ للأفعال شرعيان لا عقليان، وفي أن الفعل لا يكون قبيحاً إلا بطلب الله تركه، لأن هذا ظاهر البُطلان، فإن أمهات الفضائل يُدرك العقل حُسْنُهَا لما فيه من نفع، وأمهات الرذائل يُدرك العقل قُبْحُهَا لما فيه من ضرر، ولو لم يرد بهذا شرع^(١).

أدلة الأشاعرة:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى نفى التعذيب قبل البعثة، وهو يستلزم نفي الوجوب قبلها، لأن التعذيب لازم لترك الواجب، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فلا عذاب إلا حيث يبعث الرُّسُل، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(٣)، فلو كان حسن الفعل مُدركاً بالعقل لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام، ورد الشرع أم لا^(٤).

أدلة المعتزلة

أن العقلاء متفقون على حُسْنِ الصدق النافع وقُبْحِ الكذب الضار، وكذلك حُسْنِ الإيمان وقُبْحِ الكُفْران، مع قطع النظر عن كل حالة تُقَدَّر من عُرْفٍ أو شريعة أو غير ذلك، وعليه فيمكن للعقل أن يعرف حُكَمَ الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رُسُلِهِ وَكُتِبَ.

(١) راجع: الأحكام للآمدي ١١٣/١-١١٤؛ التوضيح والتلويح ١٧٢/١-١٧٣؛ أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ٩٩.

(٢) سورة الإسراء من الآية (١٥).

(٣) سورة النساء من الآية (١٦٥).

(٤) الإحكام للآمدي ١٤/١؛ وكشف الأسرار للبخاري ٢٣١/٤؛ غاية الوصول للدكتور/ جلال الدين عبد الرحمن ص ٢٠٠.

هذا وقد أسهب الآمدي في الإحكام، والبخاري في كشف الأسرار في ذكر حُجج المعتزلة، والرد عليها^(١).

أما أدلة الماتريدية فتُعرف من سياق ما ذكرناه في مذهبهم. **الراجع:** والراجع مما سبق هو مذهب الماتريدية، إذ إنه سلك مُسلَكًا وسطًا فجعل للعقل نصيبًا من إدراك حُسن بعض الأفعال أو قُبْحها، لكن الشرع قد يجئ مؤيدًا للعقل فيتطابق العقل والشرع، وقد يجئ على ضد ما أدركته العقول، فلا إهمال لأحدهما بالكُلّية.

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف فيما سبق فيمن لم تبلغه الدعوة (أهل الفترة) فهل هم مكلفون فيثابون ويعاقبون، أم غير مكلفين بشيء، ومن ثم فلا ثواب ولا عقاب؟

فعلى مذهب الأشاعرة والماتريدية، أنهم غير مكلفين؛ إذ التكليف يكون بإرسال الرُّسل، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢).

وعلى مذهب المعتزلة، هم مكلفون من الله تعالى على فعل ما تراه عقولهم، ولا يتوقف ذلك على إرسال الرُّسل، فما رآه العقل حسنًا استحق عليه الثواب من الله تعالى، وما رآه العقل قبيحًا استحق عليه العقاب من الله تعالى إن اقترفه^(٣).

على أنه ينبغي التنبيه على أنه لا حاجة إلى إطالة الكلام في مثل هذه المسائل، فالعقل وإن كان يُدرك حُسن بعض الأفعال وقُبْح بعضها، لكنه لا يُدرك حُسن وقُبْح كل الأفعال؛ لأن عقل الإنسان قاصر ومحكوم عليه بكثير من الأهواء والأغراض.

(١) راجع: الإحكام ١٢٠/١-١٢١؛ كشف الأسرار ٢٣٢/٤؛ أصول الفقه لخلاف ص ٩٨.

(٢) سورة الإسراء من الآية (١٤).

(٣) راجع: كشف الأسرار للبخاري ٢٣١/٤؛ وفواتح الرحموت ٢٨/١.

الأسئلة

- س١: للحسن والقبح إطلاقات، اذكرها مع بيان محل اتفاق العلماء ومحل اختلافهم فيها.
- س٢: وافق الماتريديّة الأشاعرة في أمر، وخالفوهم في آخر في مسألة التحسين والتقييح، وضح ذلك بالتفصيل.
- س٣: اذكر آراء العلماء في مسألة التحسين والتقييح، مع ذكر الأدلة، والرأي الراجح، ثم بين ثمرة الخلاف في هذه المسألة.

ثانياً: المحكوم فيه

تمهيد:

اختلفت عبارة الأصوليين في ذلك، فبعضهم عبر بقوله: "المحكوم فيه" ومن هؤلاء العضد، والآمدي، والكمال بن الهمام. وبعضهم عبر بقوله: "المحكوم به"، ومن هؤلاء: صدر الشريعة، والتفتازاني والبدخشي.

والراجع من التعبيرين هو الأول؛ لأمرين:

الأول: أن الشارع لم يحكم به على المكلف، بل حكم في فعل المكلف بالوجوب أو بالمنع... إلخ^(١).

الثاني: لأن التعبير بالمحكوم به قد يلتبس بالمحكوم عليه، إذ قد يُقال: إذا قال الشارع: الصلاة واجبة، فالمحكوم عليه هنا هو الصلاة وليس المكلف، والمحكوم به هو الوجوب وليس فعل المكلف.

وقد يُجاب عن ذلك: بأن هذا اصطلاح المناطقة، وهو ليس مُراداً ههنا، وإنما المُراد بالمحكوم عليه من وقع الخطاب له، والمُراد بالمحكوم به ما تعلق به الخطاب، كما يقال: حكم الأمير على زيد بكذا.

تعريف المحكوم فيه:

عرفه سعد الدين التفتازاني بأنه الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع^(٢).

وعرفه البدخشي بأنه: المأمور به من أفعال العباد^(٣).

ونميل إلى تعريف التفتازاني؛ لأن فعل المكلف لا بد أن يتعلق به خطاب

(١) التقرير والتحبير ١١٣/٢؛ وتيسير التحرير ١٨٤/٢-١٨٥.

(٢) التلويح ٣١٤/٢.

(٣) شرح البدخشي ١٤٤/١.

الشارع، أما تعريف البدخشي فقد قيدهُ بالمأمور به، مع أن فعل المُكلف منه ما هو مأمور به كالواجب والمندوب، ومنه ما ليس بمأمور به كالمباح والمكروه والحرام فضلاً عن أن أفعال العباد يدخل فيها المجنون والصبي والمعتوه وليس هؤلاء مُكلفين.

وعليه فالمراد بالمحكوم فيه: فعل المُكلف الذي تعلق به حُكم الشارع، ولتوضيح ذلك نقول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^(١). فإن الإيجاب المُستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المُكلفين، هو طاعة الله ورسوله، فجعل هذه الطاعة واجبة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٢) فالتحريم المُستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المُكلفين، هو قتل النفس فجعل القتل مُحرمًا. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾^(٣). فالندب المُستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المُكلفين، هو كتابة الدين، فجعله مندوبًا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾^(٤) الكراهة المُستفادة من هذا الخطاب تعلقت بفعل من أفعال المُكلفين، هو إنفاق المال الخبيث، فجعلته مكروهًا.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾^(٥) فإن الخطاب في الآية تعلق بالمرض والسفر فجعل كلا منهما مُبيحًا للفطر، فكل حُكم من أحكام الشارع لابد أن يكون مُتعلقًا بفعل من أفعال المُكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع، ومن هنا قالوا: إنه لا

(١) سورة النساء من الآية (٥٩).

(٢) سورة الأنعام من الآية (١٥١).

(٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

(٤) سورة البقرة من الآية (٢٦٧).

(٥) سورة البقرة من الآية (١٨٤).

تكليف إلا بفعل، أي إن حكم الشارع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المُكلف^(١).

شروط صحة التكليف بالفعل:

يُشترط في الفعل الذي يصح شرعاً التكليف به عدة شروط هي:

الأول: أن يكون معلوماً للمُكلف علماً تاماً، حتى يستطيع المُكلف القيام به كما طلب منه، وعليه فلا يصح تكليف المُكلف بنصوص القرآن المجملة إلا إذا لحقها بيان من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٢) مُجمل، إذ لم يُبين فيه أركان الصلاة ولا شروطها ولا كيفيتها، فكيف يكلف المُكلف بالصلاة وهو لا يعرف أركانها وشروطها إلى آخره، ولهذا أعطى الله تعالى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلطة التبيين بقوله ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٣) فإذا ما بين - عَلَيْهِ السَّلَامُ - المُجمل، يصير معلوماً للمُكلف، فيصح التكليف به.

ويُلاحظ أن المراد بعلم المُكلف بما كلف به: إمكان علمه به، لا علمه به فعلاً، فمتى بلغ الإنسان عاقلاً قادراً على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنها، اعتبر عالماً بما كلف به، ونفذت عليه الأحكام وأُزِمَ بآثارها ولا يقبل منه الاعتذار بجهلها، ولذا فقد قال الفقهاء: لا يُقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي، لأنه لو شرط لصحة التكليف علم المُكلف فعلاً بما كلف به ما استقام التكليف، واتسع المجال للاعتذار بجهل الأحكام، ومن ثم فيكفي إمكان العلم بما كُلف به، ولا يشترط العلم فعلاً.

الثاني: أن يكون معلوماً أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المُكلف اتباع أحكامه، لأنه بهذا العلم تتجه إرادته

(١) راجع: أصول الفقه لخلاف ص ١٢٧.

(٢) سورة البقرة من الآية (٤٣).

(٣) سورة النحل من الآية (٤٤).

إلى امتثاله.

الثالث: أن يكون الفعل المُكلف به ممكنًا، أي يكون في قدرة المُكلف أن يفعلَه أو أن يكف عنه.

وعليه: فلا يصح شرعًا التكليف بالمُستحيل سواء أكان مُستحيلًا لذاته أم مُستحيلًا لغيره، فالمُستحيل لذاته أي المُستحيل عقلاً وهو ما لا يتصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين، كإيجاب الفعل وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد، أو الجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة في وقت واحد.

أما المستحيل لغيره أو العادي، فهو ما يتصور العقل وجوده، ولكن لم تجر سنن الكون ولا العادة على وجوده، كطير الإنسان في الهواء بغير طائفة، وخروج زرع بدون بذرة، وذلك أي ما لا يتصور وجوده عقلاً أو عادة لا يُمكن للمُكلف فعله، وهو ليس في وسعه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها^(١).

الرابع: أن يتعلق بالفعل حُكم شرعي، سواء تكليفيًا أو وضعيًا، فمثال الحُكم التكليفي: كما سبق^(٢)، ومثال الوضعي: كالطهارة، فإنها فعل للمُكلف جعلها الشارع شرطًا للصلاة، وكالقتل، فإنه فعل المُكلف جعله الشارع مانعًا من الميراث، والطهارة والقتل هاهنا من فعل المُكلف.

أما مثال ما ليس من فعل المُكلف: دلوك الشمس فإنه سبب لوجوب الصلاة، والحيض والنفاس مانعان من الصلاة والصوم.

الخامس: أن يكون الفعل المُكلف به معدومًا؛ لاستحالة التكليف بالموجود؛ إذ إيجاد الموجود محال، كما يُقال إن بنى حائطًا أو كتب كتابًا: ابنه أو اكتبه بعينه مع بقاءه مبنياً مكتوباً مرة أخرى.

(١) راجع: أصول الفقه لخلاف ص ١٢٨-١٣٠.

(٢) راجع هذه الأمثلة ص.

وقد نص ابن قدامة على هذا الشرط فقال: "أن يكون - أي فعل المكلف - معدومًا، أما الموجود فلا يُمكن إيجاده، فيستحيل الأمر به"^(١).

(١) روضة الناظري لابن قدامة؛ ومعها نُزهة الخاطر العاطر لابن بدران الدمشقي ١/١٧٧.

أقسام المحكوم فيه:

للمحكوم فيه أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة:

أولاً: أقسامه باعتبار ذاته (الوجود):

(١) ماله وجود حسي: وهو مُتعلق بحُكم شرعي، وسبب لحُكم شرعي آخر:

مثاله:

(أ) الزنا: فإن له وجوداً حسيّاً، وتعلق به حُكم شرعي، هو الحرمة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا﴾^(١)، وسبب لحُكم شرعي، هو وجوب الحد.

(ب) شُرب الخمر: له وجود حسي، وهو مُتعلق بحُكم شرعي، وهو الحرمة، وسبب لحُكم شرعي، وهو وجوب الحد.

(ج) قتل النفس عمداً بغير حق: له وجود حسي، وتعلق به حُكم شرعي، هو الحرمة، وسبب لحُكم شرعي، هو وجوب القصاص.

(٢) ما له وجود حسي: وهو مُتعلق بحُكم شرعي، لكنه ليس سبباً لحُكم شرعي:

مثاله: الأكل، له وجود حسي، وهو مُتعلق بحُكم شرعي؛ لأنه قد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وليس سبباً لحُكم شرعي؛ فإن الشارع لم يجعله بالتعيين سبباً لبُطلان الصوم مثلاً؛ بل جعل الإمساك من أركان الصوم، فيلزم بطلانه بانتفائه.

(٣) ما له مع الوجود الحسي وجود شرعي: وهو مُتعلق بحُكم شرعي، وسبب لحُكم شرعي:

مثاله: البيع، فإنه بالإضافة إلى وجوده الحسي له وجود شرعي؛ لأن الشارع اعتبر فيه أركاناً وشروطاً يوجد البيع بوجودها، وينتفى بانتفائها،

(١) سورة الإسراء الآية (٣٢).

وتعلق به حُكم شرعي هو الإباحة، كما أنه سبب لحُكم شرعي هو المُلْك.

٤) ما له مع وجوده الحسي وجود شرعي: ومُتعلق بحُكم شرعي، وليس سبباً لحُكم شرعي:

مثاله: الصلاة، فإن لها وجوداً حسيّاً ووجوداً شرعيّاً؛ لأن الشارع اعتبر فيها أركاناً وشروطاً توجد بوجودها وتنتفى بانتفائها، وقد تعلق بها حُكم شرعى هو الوجوب، لكنها ليس سبباً لحُكم شرعي آخر.

معنى الوجود الحسى والشرعى وسببية الفعل لحُكم شرعي:

تردد في الكلام السابق الوجود الحسى والوجود الشرعى، والسببية لحُكم شرعى، وإليك بيان معانيها:

معنى الوجود الحسى: الوجود الحسى يعنى أنه لا بد من وجوده في الواقع بحيث يُدرك بالحس أو بالعقل، لأن الخطاب لا يتعلق بما لا يكون له وجود أصلاً.

والوجود الحسى يشمل مدركات العقل بطريق التغليب، فيدخل فيه مثل تصديق القلب والنية فى العبادات والخطأ والعمد، لأنها تُدرك بالعقل.

معنى الوجود الشرعى: هو أن يعتبر الشارع أركاناً وشروطاً يحصل من اجتماعها مجموع مُسمى باسم خاص يوجد بوجود تلك الأركان والشروط، وينتفى بانتفائها، فالصلاة مثلاً اعتبر الشارع أركانها كالقراءة والركوع والسجود، وشرائطها كالطهارة والاستقبال، فيحصل من ذلك وجود الصلاة.

معنى سببية الفعل لحُكم شرعي: هو أن يجعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سبباً لحُكم شرعى هو صفة لفعل المُكلف، كالزنا لوجوب الحد. أو أثراً له، كالبيع للملك. بخلاف الأكل فإن الشارع لم يجعله بالتعيين سبباً لبُطْلان الصوم. كما ذكر في القسم الثاني للمحكوم فيه باعتبار ذاته^(١).

(١) التلويح على التوضيح ٣١٤/٢.

ثانياً: أقسامه باعتبار الصحة وعدمها:

ينقسم المحكوم فيه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

١- الصحيح: وهو أن يوجد الفعل بجميع أركانه وشروطه، مع أوصاف أخرى اعتبرها الشارع في ذلك الفعل، لكن لا من حيث إنها ذاتية لها، فإذا تحقق ذلك فهو الفعل الصحيح بالأصل والوصف، وهو المراد عند الإطلاق.

مثال: بيع المتجانسين، كالقمح بالقمح مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا وجد العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة - أركان العقد - واستوفيت الشرائط والصفات الزائدة، وهى التماثل كيلاً، والتقابض في المجلس من غير غش ولا تدليس ولا خيار ممنوع، مع استيفاء شرائط الأهلية والملكية والرضا في العاقلين.... إلخ فالبيع صحيح.

وكذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، فالشارع اعتبر المماثلة التى هى وصف زائد في بيع الجنس بالجنس.

٢- الفاسد: وهو أن يوجد الفعل مستوفياً للأركان والشروط دون الأوصاف المعتبرة غير الذاتية.

وسُمي فاسداً من قولهم: فسد الجوهر، إذا ذهب رونقه وطرأته وبقي أصله، ويسمى الصحيح بأصله دون وصفه.

مثاله: بيع المتجانسين مع الزيادة فى أحدهما، كبيع مثقال من الذهب بمثقالين منه، فالذهب من حيث ذاته قابل للبيع. والفساد عرض له من عدم الوصف الذي اعتبره الشارع، وهو المماثلة في بيع الجنس بالجنس.

٣- الباطل: وهو أن يوجد الفعل غير مستوفٍ لشيء من الأركان أو الشروط.

مثاله: بيع الملاقيح^(١)، وإنما كان باطلاً؛ لانتفاء الركن. ومثاله أيضاً: النكاح بلا شهود؛ لانتفاء الشرط^(٢).

ملحوظة: التفريق بين الفاسد والباطل منصوص عليه في كتب الأصول عند الحنفية، وكثيراً ما يتسامح الفقهاء في إطلاق أحدهما على الآخر، والأمر بالعكس عند غير الحنفية، ففي كُتب الأصول يسوون بين الباطل والفاسد (أى إنهما لفظان مترادفان) وفي كُتب الفقه يفرقون بينهما (أى إنهما لفظان متباينان) كما هو الحال في الحج والكتابة والعارية والخلع. ويمكن أن يقال: إن ذلك اصطلاحى، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ثالثاً: أقسامه من حيث الحقوق:

الكلام في أقسام المحكوم فيه من هذه الحيثية يتناول نقطتين الأولى من حيث انقسامه انقساماً أولياً. والثانية من حيث تنوع حقوق الله تعالى. النقطة الأولى:

من حيث تقسيمه تقسيماً أولياً ينقسم إلى أربعة أقسام هي:

الأول: حقوق الله الخالصة.

الثاني: حقوق العباد الخالصة.

الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد. وحق الله غالب.

الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد غالب^(٣).

وقبل التمثيل لكل قسم نوضح أموراً.

الأمر الأول: إنما كانت الأقسام أربعة لا غير. لأنه لا يتصور قسم

(١) جمع ملفوحة، وهي ما في بطون النياق من الأجنة، المصباح المنير ص ٤٥٣-٤٥٤.

(٢) راجع: التلويح على التوضيح ٣/٣١٤-٣١٥.

(٣) أصول البزدوي ج٢ ص ١٣٤؛ التنقيح وشرحه التوضيح ج٢ ص ١٥١.

يجتمع فيه حق الله وحق العبد على التساوي^(١).

الأمر الثاني: لما ترددت كلمة حق كان لأبد من تعريف الحق.

ف قيل: إنه الموجود من كل وجه لا ريب في وجوده. ومنه: السحر حق، والعين حق، أي موجود بآثره. وهذا الدين حق، أي موجود صورة ومعنى، ولفلان حق في ذمة فلان، أي شئ موجود من كل وجه^(٢).

وإطلاق الحق حقيقة إنما هو على الله وصفاته، لأنه الموجود من كل وجه بأن لم يسبقه عدم ولم يطرأ عليه عدم. أما على غيره فمجاز^(٣).

الأمر الثالث: المراد بحق الله ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد. وينسب إلى الله تعالى تعظيماً ولئلا يختص به أحد من الجبابرة، كحُرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذة قبلة لصلواتهم ومثابة لاعتذار أجرامهم، وكحُرمة الزنا لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الإنسان وصيانة الفرش. وارتفاع السيف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة. وإنما ينسب إلى الله تعظيماً. لا باعتبار الضرر أو الانتفاع؛ لأنه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشئ، لأنه الغنى وغيره فقير إليه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فلا يجوز أن يكون شئ حقاً له باعتبار الضرر والانتفاع، فثبت أن الإضافة إليه لتشريف ما عظم خطره وقوى نفعه وشاع فضله بأن ينتفع الناس كافة^(٤).

الأمر الرابع: المراد بحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحُرمة مال الغير، فإنه حق العبد لتعلق صيانة ماله بها، فهذا يُباح مال الغير بإباحة

(١) التلويح على التوضيح ج٢ ص١٥١.

(٢) كشف الأسرار ج٤ ص١٣.

(٣) فتح الغفار ج٣ ص٦٠.

(٤) كشف الأسرار ج٤ ص١٣٥-١٣٥؛ التلويح ج٢ ص١٥١.

المالك، ولا يباح الزنا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها^(١).

فإن قيل: حُرمة مال الغير مما يتعلق به النفع العام وهو صيانة أموال الناس.

يُقال: لم تشرع تلك الحُرمة لصيانة أموال الناس أجمع، ألا ترى أن الكفار يملكون أموالنا بالاستيلاء. ونحن نملك أموالهم بذلك، وأموال المؤمنين تباح لنا عند وجود التراضي^(٢).

وبعد هذا الإيضاح الذي لا بد منه نرجع إلى التمثيل لكل قسم من الأقسام الأربعة.

الأمثلة

مثال القسم الأول: وهو الحق الخالص لله تعالى: الإيمان والصلاة والحدود والكفارات، فكل من هذه الأشياء يتعلق به النفع العام لكل الناس لا يختص به أحد منهم. وإنما تُنسب إلى الله تشريعاً وتعظيماً لا على جهة الضرر والانتفاع، لما بينا سابقاً.

مثال القسم الثاني: وهو الحق الخالص للعبد، بدل المتلف وبدل المغصوب والديات وملك المشتري للمبيع، وملك البائع للثمن. وملك النكاح. وملك الطلاق وحُرمة مال الغير.

فكل واحد من هذه الأشياء مصلحة خاصة لأحد الناس. لا لكل الناس ولهذا يباح مال الغير بإباحة المالك، ولا يباح الزنا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها.

مثال الثالث: وهو ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب. حد القذف. فحق العبد فيه من حيث إنه شرع لصيانة عرضه ولدفع العار عنه. وحق الله من حيث إنه زاجر شرع لإخلاء العالم عن الفساد فيعود نفعه

(١) التلويح على التوضيح ج٢ ص١٥١؛ كشف الأسرار ج٤ ص١٣٥؛ شرح المنار ص٨٦.

(٢) أنوار الحلك ص٨٦.

إلى عامة العباد وكان حق الله غالبًا لوجوه:

الأول: إن هذا الحد يجب بسبب القذف بالزنا. وحُرمة الزنا خالصة لله تعالى، والحد الواجب عليه خالص لله تعالى أيضًا، وهذا يوجب أن يكون الحد على القذف بالزنا خالصًا لله تعالى من هذا الوجه.

ومن وجه آخر فيه حق الله وحق العبد، إذ هتك حُرمة عرض المقدوف حق الله وحق المقدوف.

فلما كان له وجهان أحدهما حق خالص لله. وثانيهما فيه حق الله وحق العبد، أوجب ذلك أن يكون معظم الحق فيه الله تعالى، فثبت أن حق الله فيه غالب.

الثاني: أن حد المقدوف يتنصف بالرق، وتنصيفه بالرق دليل على غلبة حق الله فيه، لأن ما يجب للعباد لا يتنصف بالرق، كإتلاف المال، وإنما يتنصف ما يجب حقًا لله تعالى من العقوبات التي تقبل التنصيف.

الثالث: أن الشارع اعتبر المماثلة في حقوق العباد بالنص ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(١) واعتبار المماثلة في حقوق العباد يدل على غلبة حق الله فيه، إذ لا مُمَاثِلَة بين النسبة إلى الزنا وبين ثمانين جلدة لا صورة ولا معنى، كما لا مُشَابَهَة بين الحد والزنا.

ولغلبة حق الله فيه جرى فيه التداخل. فلو قذف جماعة بكلمة واحدة. أو بكلمات متفرقات لا يقام عليه إلا حد واحد ولا يجرى فيه الإرث. ولا يسقط بعفو المقدوف^(٢).

(١) سورة البقرة الآية ١٩٤.

(٢) مُذَكَّرَة الدكتور محمد حسن فايد ص ٨، ص ٩؛ فتح الغفار ج ٣ ص ٦٠؛ وكشف الأسرار

وقال الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حق العبد فيه غالب فيجربى فيه العفو والإرث ولا يجرى فيه التداخل^(١). كما أن صدر الإسلام من الأحناف صحح أن الغالب فيه حق العبد.

ولكننا نرجح الرأى الأول لأمرين: الأول: قوة أدلته. الثاني: لأنه الذى عليه الكافة كما ذكر ذلك فى فتح الغفار.

ومثال الرابع: وهو ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب. القصاص أما اجتماع الأمرين فيه، فلأن سببه ليس إلا القتل الذى هو جناية على النفس وقد اجتمع فى النفس حق الله تعالى وهو الاستعباد. وحق العبد وهو الاستمتاع ببقائها. فكانت العقوبة الثابتة بسببه وهو القصاص مشتملة على الحقين أيضاً.

وأما غلبة حق العبد فبالإجماع، لأن وجوبه ثبت بطريق المماثلة المبنية على معنى الجبر بقدر الإمكان. والجبر لا يكون إلا فى حق العبد فثبوته مشعر برجحان حق العبد فيه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ...﴾^(٢) فإن قوله لكم. إشارة إلى حق العبد. وفى اسم القصاص المبنى على المماثلة إشارة إلى معنى الجبر، ولأن الإرث جار فيه. ويقع الاعتياض عنه بالمال بطريق الصلح. ويصح عفو الولى عنه بالإجماع.

وهذه الأحكام تدل على رجحان حق العبد، لأن خواص حق العبد أكثر من خواص حق الله تعالى فى السقوط بالشبه وغيره.. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين حد القذف^(٣).

حد قاطع الطريق من أى قسم؟

اختلف فى حد قاطع الطريق. فقال الأحناف: إنه حق خالص الله تعالى كالقطع فى السرقة والرجم فى الزنا. وسواء أكان الحد قطعاً أم

(١) كشف الأسرار ج٢ ص١٥٩.

(٢) سورة البقرة الآية ١٧٩.

(٣) حاشية الرهاوي على شرح المنار ص٨٨٦-٨٨٧.

قتلاً.

ودليلهم أن سبب حد قاطع الطريق، محاربة الله ورسوله، وقد سماه الله جزاء فقال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا...﴾^(١) والجزاء المطلق مما يجب حقاً لله تعالى بمقابلة الفعل.

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: إن كان الحد قتلاً، فهو مُشْتَمِل على الحقيين، أما حق الله فمن جهة أنه يستوفيه الإمام دون الولي ولا يسقط بالعفو، وأما حق العبد فمن جهة أن فيه معنى القصاص، حيث لا يجب إلا بالقتل، والقتل المُسْتَحَق بالقتل يكون قصاصاً. ومعنى القصاص غالب عنده في أصح القولين.

والدليل على أن معنى القصاص غالب، أن القتل معصوم يجب القصاص بقتله في غير حال المحاربة، ففي المحاربة أولى، ثم القصاص حق العبد فيكون مقدماً على حق الله تعالى، لما عرف.

ويتفرع على هذا القول: أنه لو قتل حر عبداً، أو مسلم ذمياً، أو قتل الأب ابنه في قطع الطريق لا يجب القتل، وتجب الدية وقيمة العبد، ولو قتل الواحد جماعة، قتل بالأول وللباقيين الدية، وإن قتله أجنبي غير الإمام يجب عليه الدية لورثته، وإن مات، تؤخذ الدية من تركته، وإن قتل في قطع الطريق بمثل أو قطع عضو يقتل بذلك الطريق^(٢).

(١) سورة المائدة الآية ٣٣.

(٢) كشف الأسرار ١٦١/٤.

أنواع حقوق الله تعالى

هذه هي النقطة الثانية فيما يختص بالتقسيم، وهي تنوع حقوق الله تعالى، فحقوق الله تعالى تتنوع بحُكم الاستقراء إلى ثمانية أنواع هي:

- ١- عبادات خالصة كالإيمان وفروعه.
- ٢- عقوبات خالصة كالحدود.
- ٣- عقوبات قاصرة.
- ٤- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كال كفارات.
- ٥- عبادات فيها معنى المؤنة كصدقة كالفطر.
- ٦- مؤنة فيها معنى العبادة كالعشر.
- ٧- مؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج.
- ٨- حق قائم بنفسه كالخمس^(١).

وإليك تفصيل كل نوع:

النوع الأول: وهو العبادات الخالصة للإيمان وفروعه:

والمُرَاد بالفروع ما سوى الإيمان من العبادات، وهي الصلاة والزكاة

والصوم والحج والجهاد.

وإنما كان الإيمان أصلاً وهذه العبادات فروعاً، لأنها تبتني على

الإيمان، كما أنها تحتاج إليه بالضرورة، لأن من لم يُصدق بالله لم يتصور

منه التقرب إليه، والإيمان يصح بدونها.

وكون الطاعات من فروع الإيمان لا ينافي كونها في نفسها مما له

أصل وملحق به وزوائد^(٢) فالإيمان له أصل وملحق به وزوائد، كما أن

الفروع كذلك بمعنى أن في جملة الفروع أصلاً وملحقاً به وزوائد، لا

بمعنى أن كل واحد من الفروع مشتمل على الثلاثة.

(١) التنقيح وشرحه التوضيح ٣١٦/٢.

(٢) فتح الغفار جـ ٣ صـ ٦٠؛ والتلويح ٣١٦/٢.

أصل الإيمان: التصديق بلا خلاف:

اتفق الجميع على أن أصل الإيمان هو التصديق الذي هو إذعان القلب وقبوله لوحداية الله تعالى وسائر صفاته ولنسبة سيدنا محمد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وجميع ما علم بالضرورة.

لا حق الإيمان: اختلفوا في لاحق الإيمان على رأيين:

الرأي الأول: قال شمس الأئمة وفخر الإسلام وكثير من الفقهاء: إن الإقرار باللسان ركن زائد ملحق بالتصديق وليس بأصل؛ لأن الإقرار باللسان ترجمة عما في الجنان، ولهذا يسقط عند التعذر كما في الأخرس أو عند التعسر كما في المكره.

وقد ترتب على قولهم هذا أن شنع عليهم بعض الناس فقالوا: إن تقسيم الحنفية للركن إلى أصلي كالاعتقاد في الإيمان، وغير أصلي كالإقرار باللسان في الإيمان، بعد تعريفهم للركن بما يكون داخلاً في الشئ يستلزم أن يكون رُكناً وغير رُكن، وهذا تضاد، لأن الركن داخل وغير الركن زائد.

وقد أجابوا عن هذا: بأنه لا يريد الحنفية بالزائد الخارج عن الشئ بحيث لا ينتفى بانتفائه حكم الشئ. فالركن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى لا ينتفى حكم الشئ، بل يكون موجوداً حكماً بحسب اعتبار الشارع، وهذا إذا كان الجزء ضعيفاً، فيكون شبيهاً بالأمر الخارج، وضعفه إما بحسب الكيفية كالإقرار في الإيمان. أو بحسب الكمية كالأقل في المركب منه ومن الأكثر^(١). ومثل ذلك أعضاء الإنسان فالرأس ركن ينتفى الإنسان بانتفائها، واليد ركن لا ينتفى بانتفائها.

الرأي الثاني: وعليه جمهور المحققين من الأشعرية والماتريدية. إن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، حتى لو صدق بقلبه ولم يقر

(١) كشف الأسرار ج٤ ص١٣٥؛ والتلويح ٢/٣١٧.

بالنسان مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله تعالى، وليس مؤمنا في أحكام الدنيا. وهذا أوفق باللغة والعرف والنصوص معاضدة له.

هذا وقد اتفق الفريقان على أن الإقرار أصل في أحكام الدنيا، لانتفائها على الظاهر؛ لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعرف المنافقين بالوحي وكان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا بناء على الإقرار المجرد، ولذلك لو أكره الحربي أو الذمي على الإيمان فأقربه صح منه وقبل إيمانه مع قيام القرينة على عدم التصديق؛ لأن في اعتبار مجرد الإقرار أعلاء للإسلام وتكثير سواد المسلمين وحملًا للكافر على الإيمان الحقيقي، فإنه لما منع عن إظهار الكُفر بعد الإقرار بطريق الجبر مما يحمله ذلك على الإيمان بطريق الإخلاص. كما أن الجزية وضعت عليه لتحمله على الإسلام إذا عاين عزته ومذلة الكُفر.

أما المؤمن فإنه لو أكره على الكُفر فتكلم بكلمة الكُفر بلسانه لا يصير مرتدًا، لقيام المعارض وهو الإكراه. والركن في الردة تبديل الاعتقاد لا غير. لأننا لو جعلنا الإقرار في الردة ركنا لكان ذلك سعيًا منا في إثبات الكُفر. وذلك لا يجوز.

أما لو اعتقد الكُفر بقلبه فإنه يكون كافرًا وتبين منه امرأته فيما بينه وبين ربه، وكان من أهل النار^(١).

زوائد الإيمان: هي الأعمال، لما ورد في الأحاديث أنه لا إيمان بدون الأعمال. والمُرَاد نفي صفة الكمال، فتكون الأعمال من مُثمرات الإيمان ومُكملاته الزائدة عليه وكذلك ترديد الشهادة مرة بعد أخرى^(٢).

الأصل في الفروع:

أما الأصل في الفروع فهي الصلاة، لأنها النوع الثاني من العبادات

(١) راجع: التلويح على التوضيح ٣١٧/٢؛ وحاشية الزهاري ص ٨٨٧.

(٢) التلويح ج ٢ ص ٣١٧؛ وكشف الأسرار ١٣٥/٤.

ولم تخل منها شريعة من شرائع المرسلين. كما أنها عماد الدين قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"^(١).

وكان الإيمان أصلاً والصلاة من فروعه، لأن الإيمان فيه تقرب إلى الله بلا واسطة، وفي الصلاة تقرب بواسطة البيت فكانت من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان^(٢).

وكانت الصلاة أصلاً للفروع، لأنها وجبت شكرًا لنعم البدن الظاهرة والباطنة فنعم البدن الظاهرة هي الأعضاء السليمة التي يحصل بها التقلب من حالة إلى حالة من القيام والقعود والانحناء.

ونعمه الباطنة النية والإخلاص والخضوع؛ لأن أركان الصلاة التي هي بمنزلة الصورة لها تعلق بظاهر البدن.

والدليل على أنها شرعت بطريق الشكر ما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه ف قيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا"^(٣)، فقد أخبر أنه يصلى شكرًا لله على ما أنعم عليه. ولا ريب في أن ما شرع شكرًا لنعم البدن مقدم على غيره.

لواحق الفروع:

أما لواحق الفروع فهي الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد. وسنبين في كل فرع لم كان مقدمًا على الذي يليه.

فالأول من اللواحق: الزكاة. وقد جاءت الزكاة تالية للصلاة، لأن

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان برقم (٢٦١٦) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

(٢) أصول البزدوي ج٢ ص١٣٦؛ كشف الأسرار ج٢ ص١٣٦.

(٣) الحديث مروي عن السيدة عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ومُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رياض الصالحين ص١١٨ ط بيروت تصحيح وضبط الدكتور صبحي الصالح).

العبادات مشروعة لإظهار شكر النعمة بها في الدنيا، ونيل الثواب في الآخرة. والنعمة بدن ومال، فنعمة البدن يؤدي شكرها بعبادة تؤدي بجميع البدن وهى الصلاة، ونعمة المال يكون شكرها بعبادة تؤدي من جنس النعمة فصارت الزكاة دون الصلاة في الرتبة لأمر أبرزها أمران.

الأول: أن نعمة البدن أصل ونعمة المال فرع. لأن المال وقاية للنفس ولا ينتفع به دونها، وينتفع بالنفس بدون المال، فكان ما تعلق بالنعمة التي هي أصل أعلى رتبة مما تعلق بالنعمة التي هي فرع.

الثاني: أن الصلاة صارت قرينة بواسطة القبلة التي هي جماد لا استحقاق لها في التوجه إليها. وقد يسقط التوجه إليها عند خوف العدو والسبع والصلاة على الدابة. والزكاة صارت قرينة بواسطة الفقير الذى ضرب له استحقاق فى الصرف إليه فإن المؤدى يجعل المال المؤدى خالصاً لله تعالى في ضمن صرفه إلى المحتاج ليكون كفاية من الله تعالى.

فيتلخص من هذا أن الزكاة دون الصلاة بدرجة؛ لأن الخلوص في الصلاة أزيد منه فى الزكاة لأن معنى العبادة فيها أكمل، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(١).

مسألة: هل للفقير ضرب استحقاق فى الزكاة أم فى حق كامل له؟

للإجابة عن هذا نقول: إنه قد اختلف الأحناف والشافعية في هذه المسألة:

قال الأحناف: إن للفقير ضرب استحقاق، بمعنى أنه ليس بمستحق حقيقة ولكن له صلاحية أن يصرف إليه ويستحق هذا القدر على صاحب المال على معنى أنه إذا أراد الأداء يجب عليه أن يصرفه إلى الفقير دفعاً لحاجته.

(١) سورة البينة من الآية (٥) .

قال الشافعية: إن للفقير حقاً كاملاً فله أن يأخذ مقدار الزكاة من المال إذا ظفر به.

ودليلهم: أنه لما وجب الصرف إليه لفقره كان المال حقه، فيكون مُستحقاً له حقيقة.

وقد رد الأحناف هذا الدليل بأن ما يجب للفقير لفقره يجب رزقاً له على الله تعالى، لأنه تعالى هو الضامن للرزق دون العبد، إلا أن الله تعالى أمر بصرف هذا الواجب إليه فلا يصير المال حقه قبل الصرف إليه، ولا يخرج الزكاة عن كونها عبادة خالصة^(١).

الترجيح: وأرى ترجيح رأي الشافعية لما يأتي:

أولاً: القرآن الكريم ناطق بأنه حق في أكثر من موضع فقال: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^(٢)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^(٣).

ثانياً: قول الأحناف. أن ما يجب للفقير يجب رزقاً له على الله تعالى.. إلخ.

يُرد عليه بأن الله تعالى قد ربط الأسباب بمسبباتها فمع ضمان الله للرزق لجميع الدواب بقوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾^(٤) فإنه أمر بالأخذ في الأسباب بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾^(٥).

واستيلاء الفقير على ما هو له أخذ في الأسباب - خاصة عند شح النفوس.

(١) كشف الأسرار ج٤ ص١٣٦، ١٣٧.

(٢) سورة الذاريات الآية (١٩) .

(٣) سورة المعارج الآيتان (٢٤، ٢٥) .

(٤) سورة هود من الآية (٦) .

(٥) سورة الملك من الآية (١٥)

الثاني من اللواحق: الصوم. وإنما كان أدنى رتبة من الصلاة والزكاة لأمر:

الأول: إن الصوم وإن كان عبادة إلا أنه يجب على العبد بطريق الرياضة للركوب لا مقصوداً بنفسه فيكون دون الصلاة والزكاة.

الثاني: أنه لا يشتمل على أفعال متفرقة على أعضاء البدن. بل يتأدى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشهوتين فكان دون الصلاة لأنها عبادة مقصودة بنفسها مشتملة على أركان تتأدى بجميع البدن.

الثالث: أنه يصير قرابة بواسطة النفس وهذه الوسطة دون واسطتي الصلاة والزكاة (البيت والفقير)، لأن البيت معظم بتعظيم صاحب الشرع إياه. والفقير مستحق للصرف إليه بقره. ولا قُبْح في صفة الفقر، لكن النفس تستحق القهر، لميلها إلى الشهوات ومخالفة أمر الله جل جلاله وكونها أمارة بالسوء، وهذه صفة قبح، فكانت هذه الوسطة دون الواسطتين من هذا الوجه، فيكون الصوم أدنى حالاً من الصلاة والزكاة.

هذا هو الرأي الراجح، وهناك قول بأن الصوم أعلى رتبة من الصلاة والزكاة، وهو ضعيف^(١).

الثالث من اللواحق: الحج، وإنما كان الحج دون الصوم، لأنه عبادة فيها هجر الأوطان ومجانبة الأهل والأوطان، وانقطاع عن دوافع الشهوات وقهر النفس بإزالة جموحها، فكان الحج من هذا الوجه بمنزلة الوسيلة إلى الصوم، فكان دونه.

فإن قيل: الوسائط في الحج جمادات ليست لها صلاحية الاستحقاق، والواسطة في الصوم مُستحقة للقهر، فكان ينبغي أن يكون الحج فوق الصوم ومثل الصلاة.

(١) كشف الأسرار ج٢ ص ١٣٧-١٣٨.

يُجاب: الوسائط وإن لم تكن صالحة للاستحقاق، لكن في هذه العبادة معنى التعظيم لتلك البقاع أكثر منه في الصلاة للكعبة، إذ التوجه إليها في الصلاة ليس لتعظيمها، وكذا معنى قهر النفس الذي في الصوم موجود في الحج مع هذه الوسائط، فلذلك كان دون الصوم^(١).

الرابع من اللواحق: الجهاد، وإنما كان دون ما تقدم لسببين:

أولهما: أنه من فروض الكفاية، وما تقدم من فروض الأعيان، وهو وإن كان في أصله فرضاً على الجميع لأن إعلاء الدين فرض على الكل، لكن الوساطة هنا وهى كسر شوكة المشركين ودفع شرهم هي المقصودة بالرد والإعدام الذى شرع الجهاد من أجله، وهو يحصل ببعض المسلمين، فكان من فروض الكفاية بمنزلة صلاة الجنازة.

ثانيهما: أن الكُفر جناية قائمة بالكافر ثابتة باختياره، فكان أمراً عارضاً، فالجهاد الذي شرع لأجله لم يكن عبادة أصلية بخلاف الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الوسائط فيها أصلية ثابتة بخلق الله تعالى لا اختيار للعبد فيها، فكانت تلك العبادات أصلية^(٢).

زوائد الفروع:

أما الزوائد فما سوى الفروع من نوافل العبادات وسننها، مثل الاعتكاف المؤدى إلى تعظيم المسجد وتكثير الصلاة حقيقة أو حكماً بالانتظار على شريطة الاستعداد، لأنها شرعت مُكملات للفرائض وزيادة عليها^(٣).

النوع الثاني من أنواع حقوق الله: العقوبات الخالصة

ويعبر عنها بالعقوبات الكاملة، والمُرَاد بكمالها أن تكون عقوبة

(١) كشف الأسرار ج٢ ص١٣٨.

(٢) أصول البزدوي وكشف الأسرار ج٢ ص١٣٨.

(٣) التلويح على التوضيح ج٢ ص١٥٢؛ شرح المنار ص٨٨٨.

محضة^(١). أى لم يشملها نقص، لترتبها على جنايات كاملة ليس فيها شائبة الإباحة.

ومثالها: الحدود حد الزنا، وحد الشرب، وحد القذف، وحد السرقة، لأنها شرعت لحفظ الأنساب والعقول والأعراض والأموال.

اعتراض وجوابه: إن قيل: سلمنا أن حد الزنا والشرب حق الله خالصاً، لأنه لم يشرع بجناية وقعت على حق العبد. أما الشرب فظاهر، وأما الزنا فلأنه ليس بجناية على الزاني ولا على المزنية بل فيه نفعهما وهو قضاء الشهوة، ولكن لا نسلم أن حد السرقة حق الله تعالى، بل لابد من دليل.

يُجاب: بأن العين المسروقة لا تبقى حقاً معصوما للعبد، إذ لو بقى الحق معصوما للعبد كان مُباحاً في نفسه، فلم يبق القطع بوجوده. لوجود الشبهة الدارئة للحد، لكن القطع ثابت بالإجماع، فعلمنا أن العصمة في العين انتقلت إلى الله تعالى ووقعت السرقة على جناية على حقه تعالى، فقلنا إنه حق الله تعالى^(٢).

النوع الثالث: عقوبات قاصرة

ومثالها الحرمان من الميراث. فالحرمان من الميراث حق الله تعالى وجب زاجراً عن ارتكاب ما حرم الله، ولا نفع فيه يعود على المقتول المعتدى عليه.

وكان هذا النوع عقوبة؛ لأنه غرم لحق القاتل بواسطة القتل، وكانت قاصرة لأنها عقوبة بدنية، فلم يلحق القاتل ألم في بدنه ولا نقصان في ماله.

وإنما امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول، ولا شك أنها قاصرة بالنسبة

(١) شرح المنار ص ٨٨٨.

(٢) حاشية الزهاوي ص ٨٨٩.

إلى البدنية.

وبعض أصحابنا يسمونها أجزئة فرقا بينها وبين الكاملة، لأن الجزء يطلق على ما هو عقوبة كما في قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا.....﴾^(١) وعلى ما هو مثوبة كما في قوله جل شأنه: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ)^(٢) فلقصور معنى العقوبة سميت جزاء، إذ مطلق العقوبة ينطبق على الكامل منها.

ويتفرع على هذا أن الصبي إذا قتل هل يحرم من الميراث؟

اختلف الأحناف والشافعية في حرمان الصبي القاتل من الميراث.

فقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يحرم؛ لأنه حُكِمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَتْلِ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا ميراث لقاتل" والصبي مثل البالغ في الأحكام المتعلقة بالأفعال، ومعنى العقوبة فيه غير لازم بدليل أنه يثبت في حق الخاطئ، والخطأ ينفي العقوبة كالصبا، وإذا كان كذلك أمكن إيجابه على الصبي، وإن عقل معنى العقوبة فيه في غير هذا الموضع.

ولئن سلمنا معنى العقوبة فيه فالصبا لا ينافي العقوبة المالية كالخراج؛ لأن ماله كامل بخلاف العقوبة البدنية لأن بدنه ناقص.

وقال الأحناف: لا يحرم، لأن الحرمان عقوبة تثبت جزاء على ارتكاب القتل المحظور في نفسه فلا يثبت في حق الصبي، كما لا يثبت جزاء الشرب والزنا، لأن ما يثبت بطريق الجزاء قاصراً كان أو كاملاً يستدعى حظراً لا محالة.

والحظر يثبت بالخطاب، ولا خطاب في حق الصبي، فلا يوصف فعله بالحظر ولا بالتقصير أصلاً، فلا يمكن تعليق الجزاء به.

بخلاف الخاطئ إن كان بالغاً عاقلاً، لأنه مخاطب، إذ الخطأ جائز

(١) سورة المائدة من الآية (٣٨) .

(٢) سورة السجدة من الآية (١٧) .

المؤاخذه، لأنه لا يقع إلا عن تقصير منه، فكان الخطاب متوجها عليه في التثبت فيه. كما أخبر الله تعالى في قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾^(١) غير أنه تعالى رفع حُكم الخطأ في بعض المواضع تفضلاً منه ولم يرفع في القتل، تعظيماً لأمر الدم، فعلق به الدية والكفارة، فيجوز أن يتعلق به الجزاء القاصر، وهو الحرمان للتقصير في التثبت، كما تعلقت به الكفارة، ولا يتعلق به الجزاء الكامل وهو القصاص، لعذر الخطأ. فأما الصبا فبنا في الخطاب أصلاً، لقصور الآلة، فلا يوصف فعل الصبي بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه العقوبة الكاملة والقاصرة^(٢).

النوع الرابع: حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة

مثالها الكفارات، أما أن فيها معنى العبادة فلأنها تؤدي بما هو عبادة محضة كالصوم والإعتاق والصدقة، ولأن أدائها يجب بطريق العبادة، فإنها تجب بطريق الفتوى، ويؤمر من عليه الكفارة بالأداء بنفسه من غير أن تستوفى منه جبراً كالعبادة، والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة شئ من العقوبة على نفسه بل العقوبات مفوضة إلى الأئمة يستوفونها بطريق الجبر.

وأما أن فيها معنى العقوبة فلأنها لم تجب ابتداء بل وجبت أجزئة على أفعال توجد من العباد ويكون فيها معنى الحظر في الأصل كالعقوبات، فمن هذا الوجه فيها معنى العقوبة، لأن العقوبة هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحذور الذي يستحق المأثم.

- ثم هي على قسمين:

القسم الأول: ما غلب فيه جهة العبادة، وهو ما عدا كفارة الفطر والظهار، ومما يدل على أن جهة العبادة غالبية في هذا القسم.

(١) سورة البقرة من الآية (٢٨٦).

(٢) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ج٢ ص١٤٧-١٤٨؛ والتوضيح لمتن التنقيح مع التلويح ٣١٨/٢.

أولاً: أنها تجب على أصحاب الأعذار مثل المخطئ والمكره. وكذا المحرم المضطر، فإذا اضطر المحرم إلى الاصطياد لمخمة أصابته أو إلى حلق رأسه لأذى به، جاز له الاصطياد والحلق وتجب عليه الكفارة، فلو كانت جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر لأن المعذور لا يستحق العقوبة، وكذلك لو كانت مساوية، لأن جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين، فجأة العقوبة تمنع ذلك، والأصل عدم الوجوب فلا يثبت بالشك.

وإذا ثبت أن جهة العقوبة ليست غالبة ولا متساوية ثبت أن جهة العبادة غالبة.

ثانياً: أنها تجب على من ليس بجان في اليمين ولا في الحنث، فإن حلف لا يكلم هذا الكافر فإنه ليس بجان في اليمين لأن هجران الكافر وترك التكلم معه أمر حسن، فإذا أسلم هذا الكافر فكلمه حنث، وهو في الحنث غير جان أيضاً، لأن هجران المؤمن غير مشروع، ومع ذلك وجبت الكفارة، فعرنا أن جهة العبادة فيها غالبة.

القسم الثاني: ما غلب فيه معنى العقوبة وهو كفارة الفطر، وكفارة الظهار.

الأولى: كفارة الفطر:

وأما كفارة الفطر فإن جهة العقوبة فيها راجعة لوجوبها بمقابلة الجنائية الكاملة.

وهي هتك حرمة شهر رمضان عمداً، وذلك حرام محض فلا يصلح سبباً لوجوب العبادة، لسقوطها بالشبهة كالحمد. هذا من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فإن الأدلة التالية تدل على غلبة جهة العقوبة.

أولاً: عدم وجوب الكفارة على من أفطر خطأ بأن سبق الماء إلى حلقه في المضمضة، فلو لم يعتبر في سببها كمال الجنائية لما سقطت بالخطأ

ككفارة الخطأ، وفي كمال الجناية كمال العقوبة.

ثانيًا: أنه ليس في الإفطار عمدًا شبهة الإباحة بوجه، وهذا يدل على أن جنانيته كاملة^(١).

الثانية: كفارة الظهار:

بعد الكلام في كفارة الفطر، وإقامة الأدلة على أن جهة العقوبة فيها راجحة يأتي الكلام على كفارة الظهار من هذه الجهة وقد اختلف في رجحان إحدى الجهتين.

قال الأحناف: إن كفارة الظهار مثل كفارة الفطر، فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة مع رجحان جهة العقوبة، واستدلوا بأن الظهار مُنكر من القول وزور فتكون جهة الجناية غالبية فيلزم أن تكون في جزائها جهة العقوبة غالبية.

وقال الشافعية: إن كفارة الظهار جهة العبادة فيها غالبية.

ورد سعد الدين التفتازاني استدلال الأحناف بقوله: وهذا فاسد نقلا وحُكمًا واستدلالًا.

أما الأول: (نفلاً) فلأن السلف قد صرحوا بأن جهة العبادة في كفارة الظهار غالبية.

وأما الثاني: (حُكمًا) فلأن من حكم ما تكون العقوبة فيه غالبية أن يسقط بالشبهة ويتداخل ككفارة الصوم، حتى لو أفطر في رمضان مراراً لم يلزمه إلا كفارة واحدة، وكذا في رمضانين عند أكثر المشايخ، ولا تداخل في كفارة الظهار حتى لو ظاهر من امرأة مرتين أو ثلاثاً في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار كفارة.

وأما الثالث: (استدلالاً) فلأن كون الظهار منكراً من القول وزوراً.

(١) التنقيح مع شرحه التوضيح ٣١٩/٢.

إنما يصلح جهة لكونه جناية على ما هو مقتضى إيجاب الكفارة على أنه كان فى الأصل للطلاق، ويحتمل التشبيه للكرامة ولهذا يدخل قصور فى الجناية، فيصلح لإيجاب الحقوق الدائرة ولو لا ذلك لكان جزاؤه عقوبة محضة^(١).

الترجيح: ونحن، وبعد استعراضنا لأدلة الفريقين، نرجح قول الأحناف. ودليلنا على ذلك أن قول الله تعالى لا يتقدم عليه دليل نقلي ولا عقلي، وقد حكم الله تعالى بأن الظهار منكر من القول وزور قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُنَّ وَأِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾^(٢).

حكم الكفارة بالنسبة للكافر والصبي والمسبب:

قبل إنهاء الكلام فى هذا النوع نبين حكم الكفارة بالنسبة لهؤلاء الثلاثة:

١- أما الكافر فلا تجب عليه الكفارة، وذلك لوجود معنى العبادة فيها، والكافر ليس من أهلها.

٢- أما الصبي والمسبب (كحافر البئر وواضع الحجر) فقد اختلف فيهما.

قال الأحناف: لا تجب عليهما، أما الصبي فلأن فعله لا يوصف بالحظر لأنه يثبت بالخطاب وهو معدوم فى حق الصبي، وأما المسبب، فلأن الكفارة جزاء فتقتضى مباشرة فعل فيه معنى الحظر، والمسبب لم يوجد منه فعل أصلاً.

وقال الشافعى - رَحِمَهُ اللهُ -: تجب على الصبي والمسبب.

وحجته فى ذلك: أن كفارة القتل من ضمان المتلف كالدية فأدار وجوب الكفارة على وجوب الدية أو القصاص، وذلك لأن فى المحل حقين،

(١) التلويح على التوضيح ج١ ص٣٢٠؛ ويُراجع بقية الأقوال فيه.

(٢) سورة المجادلة من الآية (٢) .

حق الله تعالى من حيث الاستعباد. وحق العبد، فيجبر حق الله تعالى بالكفارة كما يجبر حق العبد بالدية، ولهذا جمع الشارع بينهما فقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾^(١) وهو كالصيد المملوك إذا قتل في الحرم تجب قيمة لماله جبرا لحقه، ودية أخرى لحُرمة الحرم، وإذا كان كذلك لا يفترق الحال بين أن يكون القتل بطريق السبب أو المباشرة.

أجاب الأحناف عن دليل الشافعي بالآتي: جعلها ضمانا للمتلف غلط في حقوق الله تعالى، لأن تفويت حق الله تعالى لا يوجب الضمان على سبيل الجبر، لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه جبران تقع الحاجة إلى جبره، لكن تفويت حقه يوجب جزاء مقابلا للفعل لا مقابلا للمحل، ولهذا تعددت الكفارة بتعدد الأفعال مع اتحاد المحل كالجناية على الصيد في الإحرام، بخلاف الدية فإنها وجبت بدلا عن المحل بطريق الجبر، ولهذا وجبت دية واحدة على الجماعة وإن تعددت الجناية كما في صيد الحرم^(٢).

النوع الخامس: عبادة فيها معنى المؤنة

والمؤنة. قيل: الثقل والكلفة^(٣) لكن الأصح أن تكون هنا بمعنى الثقل من: مَأْنَتِ القوم إيمانهم إذا احتملت مؤنهم أي ثقلهم وعلى هذا فوزنها إما فعولة أو مفعلة، لأنه إن كانت الميم أصلية فوزنها فعولة، من مان يمون، ومعنى مانه أى قام بمؤنته أي بكفايته فقلبت واوها همزة تخفيفا، وإن كانت ميمها زائدة فوزنها مفعلة من الأون وهو الثقل وأصلها مأونة فنقلت الواو إلى ما قبلها تخفيفا فيكون تسمية بقاء الشئ بالمؤنة، لكونه مستلزما للثقل^(٤).

(١) سورة النساء من الآية (٩٢) .

(٢) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ج٢ ص١٥٠-١٥١.

(٣) شرح المنار ص٨٩٠.

(٤) حاشية الرهاوي ص٨٩١؛ كشف الأسرار ج٢ ص١٣٩.

ومثالها: صدقة الفطر، وكانت صدقة الفطر عبادة، لأن فيها أوصاف العبادة ومشتملة على خواصها، فالشرع سماها صدقة وجعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث، واعتبر لوجوبها صفة الغنى، واشترط لصحة أدائها النية حتى لا تصح بدونها بحال، ولا يصح أدائها من غير المالك، حتى لو أدى المكاتب صدقة الفطر عن نفسه لا يجوز كما لو زكى ماله وعلق وجوبها بالوقت.

وأوجب صرفها إلى مصارف الزكاة، فلكل هذه الأسباب كانت عبادة. وفيها معنى المؤنة، لأنها تجب على الشخص بسبب رأس الغير، ولأن سببها الرأس وذلك من أوصاف المؤنة كالنفقة. وإلى معنى المؤنة أشار الرسول ﷺ في قوله: أدوا عمن تمونون^(١).

وكانت عبادة فيها معنى المؤنة ولم يكن العكس، لكثرة خواص العبادة فيها على خواص معنى المؤنة.

ويتضح من هذا أن معنى العبادة فيها أرجح لكنه قاصر، حيث لم تكن عبادة خالصة، ولهذا لم يشترط فيها كمال الأهلية كما اشترط في العبادات الخالصة، لذلك أوجبها أبو حنيفة وأبو يوسف في مال الصبي والمجنون الغنيين، كنفقة ذوى الأرحام، ويتولى الولي أدائها، فهما بذلك اعتبرا جانب المؤنة.

وقال محمد وزفر: لا تجب صدقة الفطر في مال الصبي والمجنون، وذلك لسقوط الخطاب عنهما، وعليه يبني الوجوب. بل تجب على الأب عنهما إن كان غنياً، فأدائها من مالهما - إن كان لهما مال - ضمن، وهما بذلك اعتبرا جانب العبادة.

(١) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر سُنن الدارقطني ١٤/٢؛ ك زكاة الفطر والسُنن الكبرى ١٦/٤، باب إخراج زكاة الفطر.

الترجيح: وقول محمد وزفر أوضح لأن جانب العبادة أرجح^(١).

النوع السادس: مؤنة فيها معنى العبادة. وهو العُشر

تمهيد: ذُكر في هذا النوع العشر وسيذكر في النوع الذي بعده الخراج وكل منهما وكل منهما قرن بالمؤنة والعقوبة، فلا بد من تمهيد يبين سبب كل منهما ويوضح الفرق بينهما فنقول:

سبب كل من العُشر والخراج هو الأرض النامية، إلا أنها سبب للعشر بالنماء الحقيقي، وللخراج بالنماء التقديرى. وهو التمكن من الزراعة والانتفاع. ذلك لأن العشر مقدر بجنس الخارج فلا بد من حقيقته، والخراج مقدر بالدراهم فيكفي النماء التقديرى؛ ثم كل من العشر والخراج مؤنة للأرض حتى لا يعتبر فيه الأهلية الكاملة؛ لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الحين الموعود وذلك بالأرض وما يخرج منها فيجب عمارتها والنفقة عليها كالعبيد والدواب، فلزم الخراج للمقاتلين الزادين عن الدار الحاميين لها من الأعداء، والعشر للمحتاجين والضعفاء الذين يستنزل بهم النصر على الأعداء، فتكون النفقة على الفريقين نفقه على الأرض تقديرًا، ثم باعتبار النماء الحقيقى كان العشر عبادة، لأن الواجب جزء من النماء أى الخارج من الأرض قليل من كثير بمنزلة الزكاة من المال النامي.

وباعتبار النماء التقديرى كان الخراج عقوبة، لما في الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن الجهاد الأصغر والأكبر. والإقبال على المبعوض المذموم بلسان الشرع والدنو من رأس الخطيئات، وهذا يصلح للذلة والصفار وضرب ما هو بمنزلة الجزية.

ولا خفاء في أن الأرض أصل والنماء وصف وتبع، فيكون كل منهما باعتبار الأصل مؤنة، وباعتبار الوصف العشر عبادة والخراج عقوبة^(٢).

(١) كشف الأسرار ج٢ ص١٣٩؛ حاشية الزهاوي ص٨٩١؛ التلويح ج٢ ص٣١٧.

(٢) التلويح على التوضيح، ج٢ ص٣١٧؛ وما قاله صدر الشريعة في اعتبار الاشتغال بالزراعة ذلة و صفارًا محل نظر خاصة في هذا الزمن الذي نحن فيه، أحوج ما نكون

ولا مانع أن يجب في حق المسلم ما هو عقوبة من وجه وعبادة من وجه، لأن الإسلام قد شرع في حق المسلم الحدود والقصاص وهى عقوبات محضة. فهذا من باب أولى.

وعليه فإن العشر مؤنة فيها عبادة، أما أنه مؤنة فباعتبار تعلقه بالأرض، لأن مؤنة الشئ سببه، والعشر سبب بقاء الأرض.

وباعتبار تعلق العشر بالنماء وهو الخارج كتعلق الزكاة به. أو باعتبار أن مصرفه الفقراء كمصرف الزكاة تحقق فيه معنى العبادة^(١).

فكان معنى المؤنة فيه أصلاً. ومعنى العبادة تبعاً، والأصل راجح على التابع.

مقارنة بين العشر وصدقة الفطر:

قد يُقال: ما الفرق بين صدقة الفطر والعشر، حيث جعلت العبادة في صدقة الفطر أصلاً بتقديم ذكرها وهنا بالعكس؟

الجواب: الفرق بينهما جلى، لأن ذات الصدقة مبنى على العبادة، لأنها تملك الشئ الفقير لمرضاة الله. وهو عبادة. أما العشر فلأن ذاته ليس إلا جزءاً واحداً من العشرة أجزاء وهو ليس بعبادة لكن العبادة فيه بواسطة تملك الفقير، وهو أمر عارض في العشر دون الصدقة^(٢).

ومما يتفرع على هذا النوع أن العشر لا يفرض على الكافر ابتداءً، لأن في العشر معنى العبادة، وهو وإن كان تابعاً لكن الكافر ليس أهلاً للعبادة بوجه ما، ولأن العشر ضرب كرامة ولا كرامة مع الكُفر^(٣).

إلى خيرات الأرض وهي من منن الله على عباده التي ذكرها في كتابه الكريم، خاصة سورة عبس الآيات من ٢٥-٣٢.

(١) كشف الأسرار ج٤ ص١٣٩.

(٢) حاشية الرهاوي ص٨٩٢.

(٣) التلويح ٢/٣١٨.

النوع السابع: مؤنة فيها معنى العقوبة. مثاله. الخراج.

ففي الخراج معنى المؤنة باعتبار تعلقه بالأرض، لأن مؤنة الشئ سبب بقاءه، والخراج سبب بقاء الأرض، لأن مصرفه المقاتلة، وهم يعمرّون الأرض بالدفاع عن الوطن وحفظه من الأعداء، والمصالح العامة من إقامة المصارف والجسور والقناطر والترع التي من شأنها الإبقاء على الأرض. وفيه معنى العقوبة؛ لأنه مُتعلق بالنماء التقديرى، حيث يفرض بمجرد التمكن من الزراعة وإن لم تنتج الأرض شيئاً.

ومما يتفرع على هذا النوع:

أولاً: الخراج لا يفرض على المسلم ابتداءً، لأن في الخراج معنى العقوبة والذل، والمسلم من أهل الكرامة والعز.

ثانياً: يصح إبقاء الخراج على المسلم، فلو اشترى مسلم من كافر أرض خراج كان عليهم الخراج لا العشر لدليلين.

الأول: لما تردد الخراج بين العقوبة غير اللاتئة بالمسلم والمؤنة اللاتئة به لم يصح إبطاله بالشك.

الثاني: في الخراج جهة المؤنة راجحة، لكونها باعتبار الأصل وهو الأرض، والمؤمن من أهل المؤنة فيصح الخراج بقاء وإن لم يصح ابتداءً^(١).

النوع الثامن: حق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن

ومعنى قيامه بنفسه أنه ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد، ومن غير أن يكون له سبب يجب باعتباره على العبد أدائه بطريق الطاعة، مثل الصلاة والزكاة وسائر حقوق الله تعالى وحقوق العباد.

والمغنم والغنيمة: ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار.

والمعدن: اسم لما خلقه الله في الأرض من الذهب والفضة وأمثالهما

(١) التلويح على التوضيح جـ ٢ ص ٣١٨.

سمى به، لأن الناس يقيمون به الصيف والشتاء، من عدن المكان أقام به. وإنما كان ثابتاً بذاته من غير أن يتعلق بذمة عبد يؤديه بطرق الطاعة، لأن الجهاد حق الله تعالى شرعه إعزازاً لدينه وإعلاءً لكلمته، فالمصاب به كله حق الله تعالى؛ إلا أنه جعل أربعة أخماس للغانمين منة منه وفضلاً، واستبقى الخمس حقاً له، وأمر نائب الشرع - وهو الحاكم - بأن يصرفه إلى من سماهم في كتابه نيابة عنه.

والدليل على وجوبه علينا على سبيل الطاعة: جواز صرف خمس الغنيمة إلى من استحق أربعة أخماسها من الغانمين وإلى آبائهم وأولادهم عند الحاجة، كما جاز صرف خمس المعدن إلى الواحد عند حاجته أيضاً.

بخلاف ما وجب على سبيل الطاعة مثل الزكوات والصدقات، فإن صرفها لا يجوز إلى من أداها وإن افتقر. فمثلاً من سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول وقبل صرفها إلى الفقير افتقر صاحب الزكاة لا يكون له أن يستردها من الساعي ويصرفها في حاجة نفسه.

ومن لزمته كفارة وهو فقير فملك من الطعام مقدار ما يؤدي به الكفارة لا يجوز له أن يصرفه إلى نفسه أو إلى أبويه أو أولاده؛ لأنها لما وجبت على سبيل الطاعة كان فعل الإيتاء هو المقصود، ولا يحصل الإيتاء ولا يتم بالصرف إلى نفسه أو إلى أبويه.

فأما ها هنا فالفعل ليس بمقصود، لأنه لم يجب على سبيل الطاعة. بل هو مال الله تعالى أمر بصرفه إلى جهة، فإذا وجدت تلك الجهة في الغانم كان هو وغيره سواء.

ولأنه ليس بحق لزمنا أدائه بطريق الطاعة. حل خمس الخمس لبنى هاشم لأنه لما كان حقاً قائماً بنفسه لله تعالى لم يصر من الأوساخ، فإن المال إنما يصير وسخاً بصيرورته آلة لأداء الواجب ومحلًا لانتقال الآثام التي هي بمنزلة الدرن في البدن فيصير خبيثاً كالماء المستعمل في البدن، فإنه يصير خبيثاً طبعاً وشرعاً، أما طبعاً فبانتقال الأوساخ إليه. وأما شرعاً

فبانتقال الحدث أو الآثام إليه. وهذا المال (الخُمس)، لم يؤد به واجب فبقى طيباً^(١).

العلة في استحقاق بني هاشم لخُمس الخُمس:

اختلف الأحناف والشافعية في علة استحقاق بني هاشم لخُمس الخُمس.

فقال الشافعية: علة الاستحقاق في حقهم، القرابة.

وقال الأحناف: العلة في حقهم هي النصرة.

وتظهر ثمرة الخلاف في سقوط سهم ذوي القربى فعند الأحناف يسقط بوفاة الرسول ﷺ، لانتهاء العلة بوفاته كما سقط نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانتهاء علة الاستحقاق التي هي ضعف الإسلام، لكن أبا الحسن الكرخي قال: يسقط هذا السهم في حق الأغنياء منهم دون الفقراء، وهو مختار القاضي الإمام أبي زيد، وقال أبو جعفر الطحاوي: يسقط في حق الأغنياء والفقراء جميعاً.

أما عند الشافعية: فهذا السهم ثابت، لبقاء العلة وهي القرابة.

كيف يقسم الخُمس؟

عند الأحناف يقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ويدخل من أتصف من ذوي القربى بهذه الصفات، عند المحققين منهم، أما سهم الرسول ﷺ فهو يسقط بوفاته كسهم ذوي القربى.

أما عند الشافعية يقسم على خمسة أسهم كما كان يقسم في عهد الرسول ﷺ سهم للإمام يصرفه إلى مصالح الدين، وسهم لذوي القربى يقسم بين بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، وسيم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء المسلمين^(٢).

(١) كشف الأسرار ١٤٢/٤.

(٢) كشف الأسرار ١٤٣/٤.

الأسئلة

- س١: (المحكوم فيه - المحكوم به) أي التعبيرين أدق؟ ولماذا؟
- س٢: اذكر تعريف التفتازاني لمحكوم فيه، ثم وازن بينه وبين تعريف البدخشي.
- س٣: (لا يصح التكليف بالمجمل قبل ورود البيان) ما مدى صحة هذه العبارة؟ وتحت أي شرط من شروط صحة التكليف تدخل؟
- س٤: لصحة التكليف بالفعل شروط، اذكرها بالتفصيل والتمثيل.
- س٥: اذكر أقسام المحكوم فيه باعتبار ذاته مع التمثيل لكل ما تذكر.
- س٦: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها: (الوجود الحسي - الوجود الشرعي - الصحيح - الفاسد - الباطل).
- س٧: اذكر أقسام المحكوم فيه باعتبار الصفة وعدمها، مع التمثيل لكل ما تذكر.
- س٨: اذكر أقسام المحكوم فيه باعتبار صاحب الحق مع التمثيل.

ثالثاً: المحكوم عليه

المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله، وهو المكلف.

شروط التكليف:

ويشترط لصحة التكليف شرطان أن يكون المحكوم عليه قادراً على فهم دليل التكليف، وأن يكون أهلاً للتكليف.

الشرط الأول - أن يكون المكلف قادراً على فهم دليل التكليف^(١):

واشترط كون المكلف قادراً على فهم ما يوجه إليه من كلام، حتى يستطيع الامتثال وتنفيذ ما يوجه إليه، وهذا مقصود الشرع، والقدرة على الفهم لا تتحقق إلا بالعقل، لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال، إلا أنه لما كان العقل أمراً خفياً لا يدرك بالحس، جعل الشارع له علامة ظاهرة حسية تدل عليه وهي البلوغ، فمن بلغ الحلم من غير أن يظهر عليه خلل في عقله، بأن كانت أقواله وأفعاله مألوفة بين الناس وعادية، تعلق خطاب الشارع بفعله، وأصبح مكلفاً لتوفر شرط التكليف وهو البلوغ عاقلاً.

وبناء عليه فلا تكليف للصبي والمجنون والنائم، لأن الصبي ناقص العقل، والمجنون عديمه، والنائم لا يفهم أدلة التكليف حين نومه فهؤلاء كلهم لا قدرة لهم على الفهم، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم"^(٢).

أما عن وجوب الزكاة ونفقة القريب وضمان المتلفات في مال الصبي

(١) راجع: الإحكام للآمدي ٢١٥/١؛ شرح مختصر ابن الحاجب ١٤/٢؛ فواتح الرحموت ١٤٣/١؛ إرشاد الفحول ١١.

(٢) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، انظر: تلخيص الحبير ١٨٣/١.

والمجنون، فليس من باب التكليف للصبي والمجنون، وإنما هو تكليف للولى عليهما بأداء الحقوق من مالهما.

وكذلك السكران فلا تكليف له أثناء سكره، لأنه لا عقل له، أما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾^(١)، فليس تكليفاً للسكاري، بل هو تكليف للصالحين، فقد أمرهم الله تعالى ألا يشربوا الخمر حال صحوهم إذا اقترب وقت الصلاة، حتى إذا أقبلوا على الصلاة، أقبلوا عليها وهم صاحون يعلمون ما يقولون، ويستطيعون أداءها على الوجه المشروع، فالآية تطلب منهم الامتناع عن المسكر حتى لا تقع صلاتهم أثناء سكرهم.

وأما وقوع طلاق السكران كما ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، فليس هذا من باب التكليف، بل من باب العقوبة والزجر عن السكر.

ولا يكفي أن يكون المكلف عاقلاً كي يتوجه إليه التكليف، بل لابد أن يكون فاهماً اللغة العربية حتى يمكنه فهم النصوص الشرعية.

وحيث كان الإسلام ديناً عاماً للناس جميعاً، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(٢)، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٣) وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً"^(٤)، كان لابد من نشره بين أنحاء العالم، وذلك إما بأن يتعلم الناس اللغة العربية ليستطيعوا فهم النصوص الشرعية، وإذا صعب هذا الأمر - وهذا هو الغالب - فإن الواجب ترجمة أدلة التكليف الشرعية إلى اللغات الأخرى، بحيث يجد الناس كتاباً دينياً يشرح ما كلفوا به من ربهم بلغتهم، والأفضل من ذلك تخصيص فئة من المسلمين عالمة بأحكام الدين تتعلم لغات تلك

(١) سورة النساء الآية (٤٣) .

(٢) سورة سبأ الآية (٢٨) .

(٣) سورة الأنبياء الآية (١٠٧) .

(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات، انظر: فيض القدير للمناوي ٢٠٢/٣.

الأمم الأخرى، حتى يتمكنوا من نشر أحكام الإسلام بين تلك الأمم عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١)، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب بدعوته إلى قيصر وكسرى والنجاشي وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، ولم ينتظر من يطلب معرفة أحكام هذا الدين.

الشرط الثاني - أن يكون المكلف أهلاً للتكليف (أهلية المكلف):

الأهلية في اللغة الصلاحية، يقال: فلان أهل لهذا العمل إذا كان صالحاً له وجديراً به، أما في اصطلاح الأصوليين فهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه^(٢).

وسياتي الكلام - تفصيلاً - عن الأهلية، وأقسامها، والأمور المعترضة عليها عقب الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه.

(١) سورة آل عمران الآية (١٠٤) .

(٢) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٢٣٨/٤.

الأسئلة

س١: عرف المحكوم عليه، وما هي شروط التكليف؟

س٢: ما معنى أن يكون المكلف قادراً على فهم دليل التكليف؟ وإلى أي

ركن من أركان الحكم الشرعي ينتمي هذا الشرط؟

س٣: هل يصح تكليف الصبي والمجنون والنائم؟ ولماذا؟

رابعاً: الحكم

الحكم لغة: القضاء والفصل، والجمع: أحكام، يقال: حكم القاضي بين المتخاصمين أي قضى وفصل بينهما، قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾^(١) أي إذا قضيتهم.

ويأتي أيضاً بمعنى المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه^(٢).

والحكم اصطلاحاً: إسناد شئ إلى آخر إيجاباً أو سلباً^(٣)، فمثلاً إذا قلت: محمد رسول الله، فقد أسندت الرسالة إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهذا جانب الإيجاب، ومسيلمة الكذاب ليس رسول الله، فقد سلبت الرسالة منه، وهذا جانب السلب.

أنواع الحكم: يتنوع الحكم إلى:

حكم عقلي: وهو ما كانت النسبة فيه مُستفادة من العقل، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، والله موجود فالحكم هنا عقلي، لأنه مُستفاد من جهة العقل.

حكم حسي: وهو ما كانت النسبة فيه مُستفادة من الحس كقولنا النار مُحرقة، والسماء فوقنا.

حكم عُرفي: وهو ما كانت النسبة فيه مُستفادة من العرف، كقولنا: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب.

حكم شرعي: وهو ما كانت النسبة فيه مُستفادة من جهة الشرع، كقولنا: الصلاة واجبة، والقتل حرام.

(١) سورة النساء من الآية (٥٨).

(٢) راجع: القاموس المحيط؛ ٤/٩٨ فصل الحاء باب الميم؛ المعجم الوسيط ص ١٩٠.

(٣) شرح البدخشي ٣٠/١.

وهذا الأخير - أعني: الحكم الشرعي - هو محل بحثنا، لذا سنذكر فيما يلي تعريفه وتقسيماته تفصيلاً.

تعريف الحكم الشرعي:

عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع^(١).

شرح التعريف:

قوله (خطاب الله) الخطاب: مصدر خاطب يخاطب خطاباً ومخاطبة، والخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، والمراد به هنا الكلام النفسي الأزلي الذي يقع به التخاطب وبإضافة الحكم إلى لفظ الجلالة خرج خطاب من سواه من الملائكة والجن والإنس، إذ لا حكم إلا الله تعالى.

اعتراض وجوابه:

إن إضافة الخطاب إلى الله تعالى تدل على أنه لا حكم إلا خطابه تعالى وقد وجب طاعة النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ وأولى الأمر و السيد، فخطابهم يعتبر حكماً كذلك.

أجيب بأن طاعة هؤلاء إنما وجبت بإيجاب الله تعالى إياها، وذلك في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٢) إذن لا حكم إلا حكمه تعالى^(٣).

وقوله (المتعلق) أى المرتبط، أو ما من شأنه أن يتعلق ولا شك أنه يُصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلقة مجازاً، لأنها تؤول إلى التعلق.

وقوله (بأفعال المكلفين) الأفعال: جمع فعل، وهو ما صدر عن المكلف

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣/١-١٤؛ نهاية السؤل ٣٠/١.

(٢) سورة النساء من الآية (٥٩) .

(٣) التلويح ١٣/١.

من قول أو فعل أو اعتقاد، فيشمل أفعال الجوارح الظاهرة، كقراءة الفاتحة والركوع في الصلاة، وكذلك أفعال الجوارح الخفية كالاعتقاد والنية، ويشمل كذلك القول باللسان كالغيبة والنميمة، فالأفعال ههنا أعم من أن تكون فعلاً أو قولاً أو اعتقاداً.

والمكلفين: جمع مُكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، ولم يحل دون تكليفه حائل، واحترز بقوله "المكلفين" عن الخطاب المتعلق بذاته تعالى، كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١)، وقوله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٢)، وخرج أيضاً الخطاب المتعلق بالجمادات والحيوانات، كقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ﴾^(٣)، وقوله: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾^(٤) فكل ذلك لا يعتبر حكماً، لأنه ليس بفعل للمكلف^(٥).

وقوله (بالاقتضاء أو التخيير) الاقتضاء هو الطلب مطلقاً، سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك، وكل منهما: إما أن يكون جازماً أو غير جازم، فيشمل الأحكام التكليفية الأربعة، فطلب الفعل الجازم يُسمى إيجاباً، وغير الجازم يُسمى ندباً، وطلب الترك الجازم يُسمى تحريماً، وغير الجازم يُسمى كراهة.

والمُرَاد بالتخيير: التسوية بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وهو الإباحة، وبذلك تكون فروع الحكم التكلفي مُحصرة في خمسة أقسام هي:

الإيجاب - الندب - التحريم - الكراهة - الإباحة.

هذا تقسيم الجمهور للحكم التكلفي، أما تقسيم الحنفية فسوف نشير

(١) سورة آل عمران من الآية (١٨) .

(٢) سورة الإخلاص الآية (١) .

(٣) سورة الكهف من الآية (٤٧) .

(٤) سورة سبأ من الآية (١٠) .

(٥) راجع: نهاية السؤل وشرح البدخشي ٣٠/١-٣١.

إليه فى موضعه.

ثم قوله (بالاقتضاء أو التخيير) قيد فى التعريف لإخراج القصص المبينة لأحوال المكلفين، كقوله تعالى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾^(١).

وأيضاً الأخبار المتعلقة بأعمالهم، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٢)، فمثل ذلك ليس تعلقاً بالاقتضاء والتخيير^(٣).

وقوله (أو الوضع) قيد لا للإخراج وإنما للإدخال، أي إدخال الحكم الوضعي فى المعرف، ليتناول التعريف الحكم بقسميه التكليفي والوضعي، وسوف نتناول كل قسم منهما تفصيلاً، مع ذكر الفرق بينهما إن شاء الله تعالى.

اعتراض وجوابه:

إن التعريف فيه كلمة "أو" وهي موضوعة للتردد والشك، والمقصود من الحد إنما هو التعريف، فيكون التردد منافياً للتحديد.

أجيب: بأن كلمة "أو" هنا ليست للترديد كما زعمتم بل لتقسيم المحدود وهو الحكم، كما تقول: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف.

وهذا الاعتراض ضمن عدة اعتراضات أوردتها المعتزلة على تعريف الحكم الشرعي المذكور^(٤).

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

يفرق بين الحكم التكليفي والوضعي بعدة فروق:

الأول: أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل أو طلب ترك، أو تخييره بينهما، بخلاف الحكم الوضعي فليس فيه طلب أو تخيير، وإنما

(١) سورة الروم الآية (٢) .

(٢) سورة الصافات الآية (٩٦) .

(٣) راجع: غاية الوصول للدكتور/ جلال الدين عبد الرحمن ص ١٣٧-١٣٨.

(٤) راجع: التوضيح والتلويح ١٣/١-١٤؛ نهاية السؤل مع البدخشي ٣٢/١-٣٩.

المقصود به بيان هذا الشيء سبب لهذا المسبب، أو أن هذا شرط لهذا المشروط.

الثاني: أن الحكم التكليفي لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف، وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، بخلاف الحكم الوضعي فهو لا يشترط فيه هذا الشرط، لأنه قد يكون مقدوراً للمكلف، كالسارق فإن السرقة سبب للقطع، وفي مقدور المكلف أن يمتنع عن السرقة فلا يقطع وكالزاني فإن الزنى سبب للجلد لغير المحصن، وللرجم للمحصن، وفي مقدور المكلف أن يمتنع عن الزنى فلا يحد، وقد يكون الحكم الوضعي غير مقدور للمكلف كشهود الشهر فإنه سبب لوجوب الصوم ولا دخل للمكلف فيه، وكدلوك الشمس فإنه سبب لوجوب الصلاة ولا دخل للمكلف فيه، فخالف الوضعي التكليفي^(١).

الثالث: أن الحكم التكليفي لا بد أن يتعلق بفعل المكلف - البالغ العاقل - إذ إن طلب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من المأمورات لا يتصور توجيهه لغير المكلفين كالمجانين والحيوانات، بخلاف الحكم الوضعي، فيمكن أن يتعلق بفعل المكلف، كالاستطاعة في الحج، فإنها شرط لوجوب الحج وهو لا يكون إلا من مكلف، ويمكن أن يتعلق الحكم الوضعي بغير المكلف، كإتلاف الدابة مال الغير، فإنه سبب للضمان.

الرابع: أن الحكم التكليفي لا بد أن يكون معلوماً للمكلف، كالصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات؛ لأنه لا يصح التكليف بمجهول، بخلاف الحكم الوضعي، فلا يشترط كونه معلوماً للمكلف، كالنائم إذا انقلب على آخر فقته، أو أتلف ماله، فالنوم سبب للإتلاف، والنائم لا يعلم بفعله حال نومه.

(١) راجع أصول الفقه لخلاف ص ١٠٣.

الخامس: أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة، فمن أدى المأمورات ممثلاً، فهو المثاب على ذلك، ومن ترك المأمورات وارتكب المنهيات، فهو المعاقب على ذلك وليس غيره، بخلاف الحكم الوضعي فيمكن ألا يتعلق بالكسب والمباشرة، وذلك كمن قتل غيره خطأ، وكان القاتل فقيراً فالقتل سبب لوجوب الدية فالمؤدي للدية وهنا العاقلة، وليس القاتل الذي باشر القتل؛ لأنه غير قادر على أداء الدية.

فائدة: وإذا كان قد وضع الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، فيجدر بنا أن نذكر الفرق بين الحكم الأصولي والحكم الفقهي لالتباسه على كثيرين، فنقول:

إن الحكم الأصولي: هو ذات الخطاب الصادر من الشارع، الدال على طلب أو تخيير، أو وضع.

أما الحكم الفقهي: فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحُرمة، ولتوضيح ذلك نذكر عدة أمثلة:

١- قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(١) يقتضي وجوب الإيفاء بالعقود، فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين ووجوب الإيفاء هو الحكم في اصطلاح الفقهاء.

٢- وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾^(٢) هو الحكم في اصطلاح الأصوليين وحُرمة قربان الزنى هو الحكم في اصطلاح الفقهاء.

٣- وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾^(٣) هو الحكم في وإباحة الاصطياد عقب التحلل هو الحكم عند الفقهاء^(٤) وهكذا يُقال في النذب والكراهة.

(١) سورة المائدة من الآية (١) .

(٢) سورة الإسراء من الآية (٣٢) .

(٣) سورة المائدة من الآية (٢) .

(٤) راجع أصول الفقه لخلاف ص ١٠٠.

وبعد أن وقفنا على شرح تعريف الحكم الشرعي، والفريق ل الحكم التكليفي والوضعي، والفرق بين الحكم الأصولي والفقهي، نشرع الآن في بيان تقسيمات الحكم الشرعي تفصيلاً.

الأسئلة

- س١: عرف الحكم لغة واصطلاحاً، واذكر أنواعه مع التمثيل.
- س٢: عرف الحكم الشرعي، ثم اشرح التعريف شرحاً وافياً.
- س٣: للحكم الشرعي أقسام، اذكرها، ثم اذكر الفرق بينها مع التمثيل.

تقسيم الحكم الشرعي

ذكر صدر الشريعة - رَحْمَةُ اللَّهِ - أنه اخترع تقسيماً للحكم الشرعي ليوافق بذلك مذهب الحنفية، وما هو مذكور في كتبهم فقال: "باب في الحكم أعلم أنني اخترعت تقسيماً حاصراً وفق مذهبنا، وعلى ما هو المذكور في كتبنا من الأقسام على المتفرقة....^(١).

ومعنى "الاختراع" أنه جمعها في مكان واحد، لأن غيره ذكرها متفرقة في مواطن متعددة، ومعنى الحصر: الضبط، أي ضبط هذه الأقسام، بمعنى أنها ليست دائرة بين النفي والإثبات ولا متباينة، لأن بعضها ليس مبايناً للبعض الآخر، بل هو متداخل، كالفرض مثلاً بالنسبة إلى العزيمة والرخصة، ومنها ما ليس دائراً بين النفي والإثبات، كالتقسيم إلى ما يكون صفة لفعل المكلف، وإلى ما يكون أثراً له^(٢).

وإليك إجمالي الحصر متبوعاً بجدول توضيحي، لتسهيل الإحاطة بهذا التقسيم:

ينقسم الحكم الشرعي - كما سبق - إلى قسمين رئيسيين حكم تكليفي، وحكم وضعي، لأنه إما أن يكون حكماً بتعلق شيء بشيء آخر تعلقاً زائداً عن التعلقات الضرورية (الحاكم، والمحكوم به، والمحكوم عليه كالحكم بأن هذا الشيء سبب لذلك، أو علة له، أو شرط فيه، فهذا هو الحكم التعليقي، أو الوضعي، أو الجعلي.

مثاله: قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾^(٣) فَإِنَّ الدُّلُوكَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ، إِذِ الدُّلُوكُ سَبَبٌ لِإِقَامَةِ

ومثال آخر: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

(١) التوضيح لمتن التنقيح ١٢٢/٢.

(٢) التلويح ١٢١/٢.

(٣) سورة الإسراء من الآية (٧٨).

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴿١﴾ فَإِنِ الْغَسْلُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ، لَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا الْمُتَعَلِّقُ زَائِدٌ أَيْضًا.

وإما أن لا يكون حُكْمًا بِتَعَلُّقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، لِأَنَّنَا مُكَلَّفُونَ مِنْ قَبْلِ الشَّارِعِ بِامْتِثَالِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَالْحُكْمُ التَّعْلِيقِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَى:

الركن، والعلة، والسبب، والشرط، والعلامة.

وجه الحصر:

أَنَّ الشَّيْءَ الْمُتَعَلِّقَ إِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي الشَّيْءِ، فَهُوَ الرُّكْنُ، كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا فِيهِ فَهُوَ الْعِلَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَثِّرًا فِيهِ، فَإِنْ أَفْضَرَ إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ السَّبَبُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَفْضِيًّا إِلَيْهِ، فَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وَجُودُهُ فَهُوَ الشَّرْطُ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ، فَلَا أَقْلَ مِنْ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعَلَامَةُ، كَالْإِحْصَانِ فَإِنَّهُ عِلَامَةٌ عَلَى وَجُوبِ الرَّجْمِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الزَّنْيَ، وَأَيْضًا كَالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ ^(٢).

فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الصَّلَاةِ - مَثَلًا - نَجِدُ أَنَّهَا جَمَعَتْ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ التَّعْلِيقِيِّ، فَرُكْنُ الصَّلَاةِ الْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، إِذْ هِيَ أَشْيَاءٌ دَاخِلَةٌ فِي مَاهِيَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَصْحَبُ دُونَهَا، وَسَبَبُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ هُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ، وَشَرْطُ الصَّلَاةِ هُوَ الطَّهَارَةُ، وَعِلَامَةُ الصَّلَاةِ هُوَ الْأَذَانُ.

أَمَّا الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فَلَهُ أَقْسَامٌ أَيْضًا، وَهِيَ:

١- مَا يَكُونُ صِفَةً لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ، فَإِنَّهُمَا صِفَتَانِ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّنْيِ، وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ مَحَلُّ بَحْثِنَا.

(١) سورة المائدة من الآية (٦).

(٢) راجع: التوضيح ١٣١/٢.

٢- ما يكون أثرًا لفعل المُكلف، كملك المبيع.

٣- ما يكون تابعًا للأثر، كثبوت الثمن دينًا في الذمة، وهذان القسمان الأخيران محل البحث فيهما هو علم الفقه لا علم الأصول.

وإذا كان ما يعنينا هو القسم الأول - صفة فعل المُكلف - فلنذكر وجه الحصر فيه فنقول:

إن ما يكون صفة لفعل المُكلف إما أن تعتبر فيه المقاصد الدنيوية اعتبارًا أوليًا، كالصحة والفساد والبطلان، وإما أن تعتبر فيه المقاصد الأخروية، وهذا قسمان:

الأول: الحكم الأصلي، وهو ما كان مشروعًا أولاً غير مبني على أَعذار العباد، ويشمل: الفرض، والواجب، والسُّنة والنفل، والحرام، والمكروه، والمُبَاح، فإن كان الفعل أولى من الترك مع المنع من الترك بدليل قطعي ففرض، أو كان المنع من الترك بدليل ظني فواجب وإن كان بلا منع من الترك، فإن كان طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإن لم يكن طريقة مسلوكة في الدين فالمندوب والنفل، وإن كان الترك أولى من الفعل مع المنع من الفعل فحرام، وبلا منع الفعل فمكروه، وإن استويا فمُبَاح^(١).

الثاني: الحكم غير الأصلي، وهو ما كان مشروعًا ثانيًا مبنيًا على أَعذار العباد، وهو الرُّخصة، وهي أنواع أربعة:

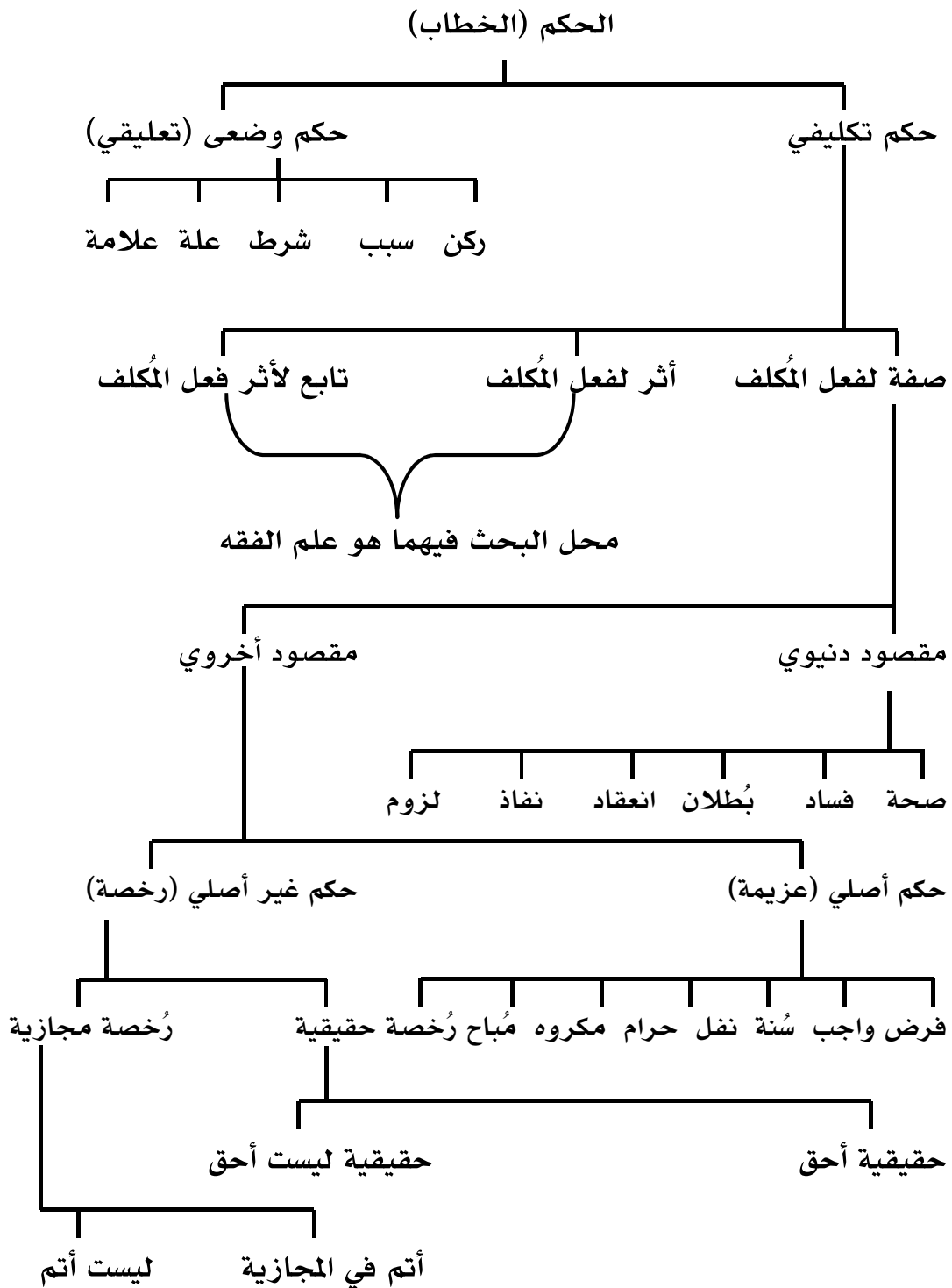
حقيقية أحق، وحقيقية ليست أحق، ومجازية أتم في المجازية، ومجازية ليست أتم^(٢).

ما سبق كان عرضًا إجمالياً الأقسام الحكم التعليقي، والحكم التكليفي، وسنتناول ذلك تفصيلاً فيما يأتي:

(١) راجع: التوضيح ١٢٣/٢-١٢٤؛ أصول السرخسي ١١٧/١؛ نسمات الأسفار ص ١٦٣.

(٢) المراجع السابقة.

ولسهولة الإحاطة بالتقسيم السابق للحكم إليك هذا الجدول التوضيحي.



وبعد ذكر أقسام الحكم إجمالاً، نتناول تلك الأقسام تفصيلاً.

أولاً: أقسام الحكم التكليفي

سبق أن قلنا: إن الحكم التكليفي ينقسم مبدئياً إلى ما هو صفة لفعل المُكلف، وإلى ما هو أثر لفعله، كملك المبيع وملك الثمن، فإنه أثر لفعل المُكلف وهو البيع، وكذلك ملك المتعة، لأنه أثر للنكاح، وهو فعل للمُكلف، وإلى ما هو تابع للأثر، كثبوت الثمن ديناً في ذمة المشتري، إذ بالبيع يملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن، فيصير الثمن حقاً في ذمة المشتري للبائع نظير ملكه للمبيع، وهذا تابع للأثر.

وسبق القول أيضاً بأن القسمين الأخيرين ليسا محل بحثنا وإنما محل البحث ههنا هو القسم الأول (ما هو صفة لفعل المُكلف).

والمُرَاد بما هو صفة لفعل المُكلف، أي أن أفعال المُكلفين تتصف بصفة الوجوب أو الحرمة أو الندب أو غيرها^(١) فالوجوب صفة الصلاة والزكاة في قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٢) وكذلك الصوم وسائر الواجبات.

والندب صفة لكتابة الدين في قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾^(٣) وغيره من المندوبات.

والحرمة صفة للزنى في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا﴾^(٤)، وغيره من المحرمات.

والكراهة صفة للصلاة في مبارك الإبل في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "لا تصلوا في مبارك الإبل" وغيرها من المكروهات.

(١) راجع: التوضيح ١٢٢/٢.

(٢) سورة البقرة من الآية (٤٣).

(٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٢).

(٤) سورة الإسراء من الآية (٣٢).

والإباحة صفة للاصطياد عقب التحلل من مناسك الحج في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾^(١) وغيره من المباحات.

فكل فعل يصدر من المكلف لابد من اتصافه بوصف هذا الوصف هو الحكم المنسوب إلى هذا الفعل، كما سبق توضيحه بالأمثلة. وبعد أن وقفنا على المراد بما هو صفة لفعل المكلف، نشعر في بيان أقسامه فنقول:

ينقسم ما هو صفة لفعل المكلف باعتبار الوقوع إلى قسمين:

الأول: ما أُعتبرت^(٢) فيه المقاصد الدنيوية اعتباراً أولياً:

المراد من المقاصد الدنيوية: أي الحاصلة في الدنيا، كتفريغ الذمة المُعتبرة في مفهوم صحة العبادات.

الثاني: ما أُعتبرت فيه المقاصد الآخروية اعتباراً أولياً:

والمراد بالمقاصد الآخروية: أي الحاصلة في الآخرة كالثواب على الفعل والعقاب على الترك في مفهوم الواجب.

وقيد الاعتبار بكونه أولياً في القسمين، للتنبيه على أن كلاً من القسمين يعتبر فيه المقصد الدنيوي والمقصد الآخروي معاً، لكن القسم الأول تعتبر فيه المقاصد الدنيوية بالذات، وتأتي المقاصد الآخروية ثانياً، والقسم الثاني تعتبر فيه المقاصد الآخروية بالذات، وتأتي المقاصد الدنيوية ثانياً.

توضيح ذلك:

أن المُعتبر في مفهوم صحة العادة هو تفريغ الذمة، وهو مقصود دنيوي، والمُعتبر في مفهوم الوجوب هو الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وهو مقصود آخروي، وهذا هو الأصل، لكن قد يُعتبر في مفهوم

(١) سورة المائدة من الآية (٢) .

(٢) الاعتبار ههنا يُراد به الاعتبار في المفهوم والتعريف - التلويح ١٢٢/٢.

الصحة الثواب، وفي مفهوم الوجوب تفريغ الذمة، لكن ليس اعتباراً أولياً^(١).

فصحة الصلاة مثلاً توجب تفريغ الذمة وهو مقصود دنيوي - ويتبع هذا التفريغ ثواب، وهو مقصود أخروي، وعدم صحتها لا يوجب تفريغ الذمة، ويترتب عليه العقاب وهو مقصود أخروي، لكنه أي المقصود الأخروي - غير مُعتبر في مفهومه اعتباراً أولياً، هذا مثال للمقصود الدنيوي في العبادات.

أما المقصود الدنيوي في المعاملات، فهو الاختصاصات الشرعية المترتبة، وهي الآثار المترتبة على العقود والفسوخ الشرعية، أي كل شئ جعله الشارع مُستفاداً من المقصود، فصحة البيع معناها: أنه يثبت بهذا البيع الصحيح الملك للمشتري في المبيع، ويثبت الملك للبائع في الثمن، وصحة النكاح معناها: ثبوت المتعة بعقد النكاح، وصحة الإجازة معناها: ثبوت المنفعة بعقد الإجازة، وصحة الطلاق معناها: ثبوت الفرقة بين الزوجين وصحة الشهادة معناها: ترتب لزوم القضاء عليها، فكل هذه الأمثلة مرجعها إلى المعاملات، فالفعل المتعلق بمقصود دنيوي إن وقع بحيث يوصل إليه فصحيح، وإلا فإن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه فباطل، وإلا ففساد، فالمتصف بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم^(٢).

وليس المراد باعتبار المقصود الدنيوي ابتناء الحكم على حكم أو غرض مُتعلق بالدنيا، كما أنه ليس المراد باعتبار المقصود الأخروي ابتناء الحكم على حكم أو غرض مُتعلق بالآخرة، لأنه من البعيد أن يقال: صحة الصلاة مبنية على حكمة دنيوية، وحُرمة الخمر مبنية على حكمة أخروية^(٣).

(١) راجع: التلويح ١٢٢/٢.

(٢) راجع: التلويح ١٢٢/٢-١٢٣.

(٣) التلويح ١٢٢/٢.

القسم الأول

ما أُعتبرت فيه المقاصد الدنيوية اعتباراً أولياً

ينقسم هذا القسم إلى شقين:

الأول: ما تشترك فيه العبادات والمعاملات، وهو ثلاثة:

أ- الصحة. ب- البطلان. ج- الفساد.

الثاني: ما تختص به المعاملات فقط، وهو ثلاثة أيضاً:

أ- الانعقاد. ب- النفاذ. ج- اللزوم.

وبناء على ذلك أي على التقسيم المذكور يصح أن نقول: صلاة صحيحة، أو باطلة، أو فاسدة، وكذلك بيع صحيح أو باطل أو فاسد، لأن هذه الثلاثة تجري في العبادات والمعاملات.

ويصح قولنا أيضاً: بيع منعقد، أو نافذ، أو لازم، لكن لا يصح أن نقول صلاة منعقدة، أو نافذة، أو لازمة، لأن هذه الثلاثة لا تجري إلا في المعاملات فقط^(١).

فصارت الأقسام ستة، إليك بيانها بالتفصيل:

أولاً: الصحة:

وهي لغة: السلامة وعدم الاختلال - وهي مقابلة للسقم - وهو المرض^(٢).

واصطلاحاً: هي ترتب المقصود الدنيوي، لاستيفائه الأركان والشروط الشرعية فالصحيح: ما شرع بأصله ووصفه.

ويمكن أن يقال: هو الفعل الذي ترتب فيه المقصود الدنيوي،

(١) التوضيح ٢٣/٢؛ ومُذكرة أستاذنا الدكتور/ دياب عبد الجواد ص٩.

(٢) راجع: حاشية النفحات للجاوي ص٢٢؛ وغاية الوصول لأستاذنا الدكتور/ جلال الدين عبد الرحمن ص١٧٣.

لاستيفائه الأركان والشروط، وذلك كالبيع التام المطلق، المستوفي للأركان والشروط المعتبرة شرعاً، فإنه يكون صحيحاً، والحكم الثابت به هو الصحة^(١).

وكما تقول في العبادة: إنها صحيحة، بمعنى أنها مُجزئة، ومُبرئة للذمة، ومُسقطه للقضاء فيما فيه قضاء.

ثانياً: البطلان:

وهو لغة: ما يُقابل الصحة.

واصطلاحاً: عدم ترتب المقصود الدنيوي، لعدم استيفائه الأركان والشروط الشرعية، فالباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه.

ويمكن أن يقال: هو الفعل الذي لم يترتب عليه المقصود لخلل في الأركان والشروط، فالباطل فانت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام معنى التصرف، كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف كبيع الصبي والمجنون، فهذه البيوع باطلة، والحكم الثابت بها البطلان^(٢).

ثالثاً: الفساد:

وهو لغة: الخلل، ويطلق ويراد به التلف والعطب، يقال: فسد اللحم، أنتن أو عطب^(٣).

واصطلاحاً: عدم ترتب المقصود الدنيوي لوصف خارجي، لا لعدم استيفاء الأركان والشروط الشرعية، فالفساد هو ما شرع بأصله دون وصفه، أو يُقال في تعريف الفاسد: الفعل الذي لم يترتب عليه المقصود لوصف خارجي كبيع الجذع في السقف، أو الطير في الهواء، فهو فانت المعنى من وجه المُلزمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال، مع تصور

(١) راجع: مُذكرة أصول الفقه للدكتور/ دياب عبد الجواد ص٧.

(٢) راجع: التلويح ١٢٣/٢؛ ومُذكرة أصول الفقه للدكتور/ دياب عبد الجواد ص٨.

(٣) راجع: المعجم الوجيز ص٤٧١.

الانفصال في الجُملة^(١).

وجُملة القول في الأقسام الثلاثة السابقة: أن الفعل المُتعلق بمقصود دنيوي إن وقع بحيث يوصل إليه فصحيح، وإن لم يوصل إليه، فإن كان عدم إيصاله إليه من جهة الخلل في أركانه وشرائطه فباطل، وإلا ففساد^(٢).

فائدة:

(أ) ذهب جمهور الأصوليين - غير الحنفية - إلى أن الباطل والفساد آسمان مترادفان لما ليس بصحيح، فنقول مثلاً: بطلت الصلاة وفسدت، وعلى هذا يكونان - البطلان والفساد - مقابلين للصحة.

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنهما لفظان متباينان - مُختلفان - كما سبق توضيحه من أن الباطل لم يشرع بأصله ولا وصفه وأن الفاسد ما يشرع بأصله دون وصفه.

وتوضيح ذلك: أن الشارع جعل للأعمال - عبادات ومُعاملات - أركاناً لا تتحقق بدونها، وشروطاً لا يعتد بها من غيرها، فإذا أتى المُكلف بعمل منها مع استيفاء أركانه وشروطه الشرعية، كان عملاً صحيحاً في نظر الشارع، وترتب عليه الآثار المقصودة منه، فإن كان العمل من العبادات: كالصلاة مثلاً، ترتب على الإتيان به براءة الذمة، واستحقاق الثواب في الآخرة، وإن كان من المُعاملات كالبيع مثلاً، ترتب عليه انتقال ملك المبيع إلى المشتري، وانتقال ملك الثمن إلى البائع، وحل انتفاع كل منهما بما انتقل ملكه إليه.

وإذا أتى المُكلف بعمل منها ولم يستوف ركناً من أركانه كان باطلاً باتفاق الفقهاء، ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار من غير تفرقة بين العبادات والمُعاملات فإن كانت صلاة واجبة لا تبرأ الذمة منها، وإن كان

(١) التلويح: ١٢٣/٢.

(٢) راجع: التوضيح ١٢٣/٢.

بيعاً لا يترتب عليه انتقال الملك.

وإذا أتى المكلف بعمل منها مع استيفاء أركانه وتخلف شرط من الشروط المُعتبرة فيه، فإن كان هذا العمل من العبادات سمي باطلاً أو فاسداً باتفاق الفقهاء، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام.

وإن كان من المعاملات كالبيع والزواج، فالجمهور من الأصوليين يسمونه باطلاً أو فاسداً، ولا يرتبون عليه أي حكم من الأحكام، كما في العبادات، والحنفية يسمونه فاسداً فقط ويرتبون عليه بعض الأحكام دون بعض^(١).

وأصل الخلاف بين الفريقين يرجع إلى أن فساد الوصف المقارن، هل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا؟.

فالشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - الحق فساد الوصف بفساد الأصل وأبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ - فرق بينهما.

والخلاف في المسألة لفظي، فإن مُراد الحنفية من التقسيم: أن التصرفات تنقسم إلى ما نهى عنه الشارع لمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب اختلاف ركن من أركانها، وإلى ما نهى عنه لا لذاته، بل لأمر يرجع إلى شروطه فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قطعية، والثاني مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية^(٢).

(ب) أدرج جمهور الأصوليين غير الحنفية - الصحة والبطلان والفساد ضمن أقسام الحكم الوضعي، فيشمل: السببية، والشرطية، والممانعة، والصحة، والبطلان أو الفساد.

أما الحنفية فلم يعدوا الصحة والبطلان والفساد من أقسام الحكم

(١) راجع: أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص٢٤٦؛ غاية الوصول للدكتور/ جلال عبد الرحمن ص١٧؛ ومعهما التلويح ١٢٣/٢؛ التمهيد للإسنوي ص٥٩؛ نهاية السؤل ٥٨/١.

(٢) راجع: غاية الوصول للدكتور/ جلال ص١٩٣.

الوضعي، ولكنها من أقسام الحكم التكليفي المندرجة تحت ما هو صفة لفعل المُكلف، وتعتبر فيها المقاصد الدنيوية، كما سبق بيانه.

وعلى الحنفية مذهبهم، بأن كون الفعل صحيحاً أو باطلاً لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل العقل يستطيع إدراك صحة الشئ إذا فعله المُكلف مستكماً لشرائطه وأركانه، فهو حكم عقلي^(١).

رابعاً: الانعقاد:

هو ارتباط أجزاء التصرف بعضها ببعض شرعاً، كالإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر، فالبيع الفاسد منعقد لكنه ليس صحيحاً، لأنه لا يوصل إلى المقصود، لاشتماله على خلل في أوصافه الخارجية^(٢).

خامساً: النفاذ: هو ترتب الأثر المقصود على العقد بدون توقف، ففي البيع مثلاً الأثر المترتب هو الملك، وبيع الفضولي منعقد، لارتباط أجزاء التصرف (الإيجاب والقبول) لكنه ليس بنافذ لتوقف الملك على إجازة المالك^(٣).

سادساً: اللزوم:

كون العقد بحيث لا يمكن رفعه، أي لا يقبل الفسخ، كالبيع التام المطلق الخالي من الشروط، فهو عقد لازم، أما البيع بشرط الخيار فهو غير لازم، لاحتماله الفسخ عملاً بالشروط.

النسبة بين الأقسام الخاصة بالمعاملات:

بالنظر فيما سبق في الأقسام الثلاثة الخاصة بالمعاملات (الانعقاد - النفاذ - اللزوم) نجد أن الانعقاد أعم من النفاذ، أي أن الفعل المنعقد أعم من الفعل النافذ، لأن الفعل قد يكون منعقداً لكنه غير نافذ كبيع الفضولي،

(١) راجع: غاية الوصول للدكتور/ جلال الدين عبد الرحمن ص ١٧٦.

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٢٣/٢؛ مُذكرة الدكتور/ دياب عبد الجواد ص ٨.

(٣) راجع المرجعين السابقين.

فإنه منعقد غير نافذ.

وأيضاً النافذ أعم من اللازم، لأن الفعل قد يكون نافذاً لكنه غير لازم كالبيع بشرط الخيار، فإنه نافذ غير لازم.

ومن ثم فأخص هذه الثلاثة هو: اللازم، ثم النافذ، ثم المنعقد فيمكن القول بأن كل لازم نافذ ومنعقد^(١).

(١) راجع: التلويح ١٢٣/٢؛ مُذكرة الدكتور/ دياب عبد الجواد ص٩.

مُتعلقات ما أُعتبرت فيه المقاصد الدنيوية:

هناك فرق بين الحكم ومُتعلق الحكم، فالحكم هو ذات الخطاب، أما مُتعلق الحكم فهو فعل المُكلف الذي يضاف إليه الحكم.

وقد ذكرنا فيما سبق ستة أحكام هي:

الصحة، والبطلان، والفساد، والانعقاد، والنفاد، واللزوم.

ومُتعلقات هذه الأحكام هي:

الصحيح، والباطل، والفساد، والمنعقد، والنافذ، واللازم.

فمثلاً: إذا أدى شخص صلاته مستوفية لأركانها وشرائطها، فهذه الصلاة صحيحة، والحكم الثابت بها الصحة، وكذلك بيع الملاقيح والمضامين بيع باطل، والحكم الثابت بها البطلان، وعلى هذا بقية الأقسام^(١).

(١) راجع: مُذكرة الدكتور/ دياب ص٧-٨.

القسم الثاني

ما أُعتبرت فيه المقاصد الأخروية اعتباراً أولياً

ينقسم ما هو صفة لفعل المكلف وأُعتبرت فيه المقاصد الأخروية إلى قسمين:

الأول: الحكم الأصلي (العزيمة)

الثاني: الحكم غير الأصلي (الرخصة)^(١).

وسنتناول كل قسم تفصيلاً بتوفيق الله تعالى.

أولاً: العزيمة (الحكم الأصلي):

قبل الخوض في ذكر أقسام العزيمة نشير إلى تعريفها لغة واصطلاحاً.

أما لغة فهي: القصد المؤكد أو المحقق، يقال: عزم على الشئ: قصده ومنه قوله تعالى في شأن آدم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾^(٢).

وأما اصطلاحاً فهي: ما شرع أولاً غير مبني على أعذار العباد.

مثالها: فرضية الصلاة والزكاة، فإن فرضيتهما ثبتت بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٣) وهذه الفرضية شرعت أولاً غير مبنية على عذر، ومثل فرضية الصوم ثبتت بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٤)، وهذه الفرضية شرعت أولاً غير مبنية على عذر.

أقسام العزيمة (الحكم الأصلي):

ينقسم الحكم الأصلي المسمى بالعزيمة إلى سبعة أقسام هي:

(١) راجع: التوضيح ١٢٣/٢.

(٢) سورة طه من الآية (١١٥)؛ وراجع: القاموس المحيط ١٤٩/٤ فصل العين باب الميم.

(٣) سورة البقرة من الآية (٤٣).

(٤) سورة البقرة من الآية (١٨٥).

الفرضية، والإيجاب، والسُّنية، والنفلية (الندب)، والإباحة، والتحريم، والكراهة.

هذا تقسيم للحُكم باعتبار ذاته عند الحنفية، أما أقسامه باعتبار مُتعلقه فهي سبعة أيضاً، وهي:

الفرض، والواجب، والسُّنة، والنفل، والمُباح، والجرام، والمكروه.

وجه الحصر في الأقسام السبعة:

أنه إن كان الفعل أولى من الترك مع المنع من الترك، وكان الدليل قطعياً، فهو الفرض، وإن كان الفعل أولى من الترك مع المنع من الترك، وكان الدليل ظنياً، فهو الواجب، وإن كان الفعل أولى من الترك مع عدم المنع من الترك، فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإن لم يكن الفعل طريقة مسلوكة في الدين فنفل، وإن كان الترك أولى من الفعل مع المنع من الفعل فحرام، وبلا منع الفعل فمكروه، وإن استوى الفعل والترك فمُباح^(١).

ويُلاحظ فيما ذكر ما يأتي:

١- هذا التقسيم إنما هو خاص بالحنفية، أما غيرهم فقد قسموا الحُكم إلى خمسة أقسام فقط هي:

الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

٢- معنى أولوية الفعل أو الترك الواردة في وجه الحصر: أولويته عند الشارع بالنص عليه أو على دليله بمعنى: أن يقتضي الخطاب الوجود ويمنع النقيض، كالفرض والواجب والحرام، فإن لم يمنع النقيض فالمندوب والمكروه، وليس المراد بالأولوية معناها الحقيقي، وهو جواز الأمرين مع رجحان أحدهما^(٢).

(١) راجع: التوضيح ١٢٣/٢-١٢٤.

(٢) راجع: التلويح ١٢٣/٢، مُذكرة الدكتور/ دياب عبد الجواد ص-١٠.

٣- يرى صاحب التلويح أن الحكم غير الأصلي المبني على أعذار العباد يتصف بهذه الأحكام أيضاً، كالرخصة الواجبة أو المندوبة أو المباحة، فلا معنى للتخصيص بالحكم الأصلي^(١).

(١) المرجعين السابقين.

الأسئلة

س١: اذكر أقسام الحكم التعليقي، ثم بين وجه الحصر في تلك الأقسام.

س٢: اذكر أقسام الحكم التكليفي مع التفصيل والتمثيل.

س٣: اذكر خلاف الحنفية والجمهور في معنى الفاسد والباطل، ثم بين أصل هذا الخلاف ونوعه.

س٤: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها: (صحة - فساد - بطلان - انعقاد - نفاذ - لزوم - رخصة - عزيمة)

وإليك بيان الأقسام السبعة تفصيلاً:

أولاً: الفرض:

الفرض لغة: القطع، أو التقدير، قال تعالى: ﴿فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ﴾^(١) أي قدرتم، ويأتي أيضاً بمعنى البيان، ومنه قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾^(٢) الآية أي بينهاها^(٣).

واصطلاحاً: ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطعي^(٤).

شرح التعريف: قوله (ما كان فعله أولى) يدخل فيه الفرض والواجب والسنة والنفل، ويخرج به الحرام والمكروه لأن تركهما أولى، والمباح الاستواء الفعل والترك فيه. وقوله (مع منع الترك) يخرج به السنة والنفل، وقوله (بدليل قطعي) خرج به الواجب، لأن المنع فيه ثبت بدليل ظني.

مثال الفرض: قراءة القرآن في الصلاة، فهي ثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيه، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(٥)، وأيضاً فرضية الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها مما ثبت بكتاب الله تعالى، وما علم كونه من الدين بالضرورة^(٦).

حكم الفرض: اللزوم علماً وعملاً، ومعنى اللزوم علماً، أي يلزم اعتقاد حقيقته، لثبوته بدليل قطعي، فلو أنكره قولاً أو اعتقاداً كان كافراً، ومعنى اللزوم عملاً: أي يجب على المكلف أن يعمل بموجبه، فإذا لم يعمل بموجبه يفسق ويعاقب عقاباً شديداً على تركه للآيات والأحاديث الدالة على

(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).

(٢) سورة النور من الآية (١).

(٣) راجع المعجم الوجيز ص٤٦٧؛ غاية الوصول للدكتور/ جلال ص١٤٤.

(٤) راجع: التوضيح ٢/١٢٣.

(٥) سورة المزمل من الآية (٢٠).

(٦) مذكرة الدكتور/ دياب ص١١.

وعيد العصاة، إلا أن يعفو الله تعالى بفضله وكرمه أو بتوبة العاصي وندمه للنصوص الدالة على العفو والمغفرة، ولأنه حق الله تعالى فيجوز له العفو.

وعند المعتزلة: لا عفو ولا غفران بدون التوبة، وهي مسألة وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى^(١) ومحل البحث في هذه المسألة هو علم الكلام.

أقسام الفرض عند الحنفية:

ينقسم الفرض عند الحنفية إلى قسمين:

الأول: فرض علمي. الثاني: فرض عملي.

والفرض العملي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:

١- فرض عين. ٢- فرض كفاية. ٣- فرض مخير فيه.

فرض العين:

هو ما ينظر فيه بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين، أي من كل واحد من المكلفين، كالصلاة فهي مطلوبة من واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما فرض عليه دون أمته.

حكم فرض العين:

اللزوم على من فرض عليه، فلا تبرأ ذمته إلا بأدائه هو، لا بأداء غيره.

فرض الكفاية:

هو ما طلب حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم، أو يُقال: هو ما طلب حصوله من غير نظر إلى فاعله.

مثاله: الجهاد، وتشميت العاطس، ورد السلام وغيرها.

(١) التلويح ٢/١٢٤.

حُكمه:

إذا فعله البعض سقط عن الباقيين، وارتفع الإثم عن الجميع.
وقد يصبح فرض الكفاية فرض عين، وذلك كمن ألقى السلام على شخص واحد معين، فيتعين على هذا الشخص أن يرد السلام، لأنه أصبح عليه فرض عين، ومن ثم يآثم إذا لم يرد السلام.

الفرض المخير فيه:

وهو ما طلبه الشارع لا بعينه، بل في ضمن أمور معينة.

مثاله: خصال الكفارة في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾^(١)، فالإطعام والكسوة وتحرير الرقبة أمور ثلاثة مخير فيها، بحيث يتخير الحائث ما يناسبه ويكفر به، وإذا لم يفعل واحداً منها لزمه صوم ثلاثة أيام، وإلا آثم.

حُكمه:

تبرأ ذمة الحائث إذا أتى بواحدة من الخصال الثلاث، وإن لم يأت بها آثم واستحق العقاب.

أما الفرض العلمي فهو: ما يفوت الجواز بفواته، كالوتر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - فلا يجوز لمن عليه الوتر أن يُصلي الفجر وهو مُتَذَكَّرٌ أن عليه الوتر، فيفوت جواز الفجر بفوات الوتر^(٢).

(١) سورة المائدة من الآية (٨٩) .

(٢) راجع: التلويح ١٢٤/٢؛ ومعه مُذَكَّرَةُ الدكتور/ محمد عبد السميع ص٤٢.

الأسئلة

- س١: عرف الفرض لغة واصطلاحاً، ثم اشرح التعريف، مع بيان حكم الفرض، وذكر مثال له.
- س٢: بين أقسام الفرض عند الحنفية، ثم عرف كل قسم، ومثل له، واذكر حكمه.
- س٣: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها: (فرض عين - فرض كفاية- فرض مخير فيه- فرض علمي)

ثانيًا: الواجب:

وهو لغة: مأخوذ من وجب الشئ وجوبًا: أي لزم وثبت، أو من وجب الحائط: إذا سقط ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾^(١) أي سقطت^(٢).

وأما اصطلاحًا: فهو ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني، وشرح التعريف على غرار ما ذكر في شرح تعريف الفرض، إلا أن قوله (بدليل ظني) جاء به ليخرج الفرض إذ أنه ثبت بدليل قطعي كما مر.

مثال الواجب: الوتر، وصدقه الفطر، وتعديل الأركان، والأضحية وصلاة العيدين، وقراءة الفاتحة في الصلاة، فكل منها واجب الشبوتة بدليل ظني، وهو خبر الآحاد.

حكم الواجب:

اللزوم عملاً لا علمًا، أي المكلف يلزمه العمل بموجبه، لكن لا يلزمه اعتقاد حقيقته لثبوتة بدليل ظني، ومبني الاعتقاد على اليقين، وهو موجود في الفرض لا غير.

وإنما قلنا: إنه يجب العمل بموجبه، للدلائل الدالة على إتباع الظن، ومن ثم فمن أنكر الواجب لا يكفر، وإنما يضل، قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار^(٣) "فمن رد خبر الواحد - كما رده الرافضة وغيرهم - فقد ضل عن سواء السبيل، ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة في إثبات الفرضية - كما فعل أصحاب الظواهر من أهل الحديث - حتى كان الثابت به مثل الثابت بالكتاب في العمل من غير تفاوت بينهما - فقد أخطأ".

(١) سورة الحج من الآية (٣٦) .

(٢) راجع: التلويح ١٢٤/٢؛ غاية الوصول للدكتور/ جلال ص١٤٦.

(٣) كشف الأسرار ٣٠٥/٢؛ ومعه مُذكرة الدكتور/ دياب عبد الجواد ص١٢؛ غاية الوصول

للدكتور/ جلال عبد الرحمن ص١٤٧.

ومن ترك العمل بالواجب إن كان مؤولاً لا يفسق ولا يضل، لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف، وإن لم يكن مؤولاً، فإن كان مستخفاً يضل لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه، ولأن رد خبر الواحد والقياس بدعة، وإن لم يكن مستخفاً يفسق، وتارك الواجب يعاقب عقلياً أقل من تارك الفرض إلا أن يعفو الله تعالى^(١).

هل الفرض والواجب لفظان مترادفان أم لا؟

هناك خلاف مشهور في هذه المسألة وقع بين الحنفية وهو يعلى والشافعية، فالحنفية على أن الفرض والواجب لفظان متباينان - متغايران - يُغَايِر كل منهما الآخر، والشافعية على أنهما لفظان مترادفان، أي لا تغاير بينهما، وهو نفس الخلاف الواقع بينهما في البطلان والفساد، وقد أشرنا إليه آنفاً.

ومبنى مذهب الحنفية: التفاوت بين مدلولي الفرض والواجب بالقطع والظن، وأن اللغة قد فرقت بين الفرض والواجب فهما مُختلفان في الشرع واللغة، فالْحُكْم الذي دل عليه محكم الكتاب ثابت يقيئاً، فهو معلوم تقديره علينا من الله سبحانه وتعالى، والْحُكْم الذي دل عليه محكم خبر الواحد ثابت بغلبة الظن فلا يعلم تقديره، وهو ساقط من قسم المعلوم.

ويُلاحظ أن هذه التفرقة عندهم بناءً على اختلافهما لغة، فالفرض هو التقدير، والواجب هو الساقط - على ما مر - وقد نقل الحنفية هذه التفرقة من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي أي أنهما كما يختلفان لغة كذلك يختلفان اصطلاحاً، ليناسب المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي.

ومما استدل به الحنفية على مذهبهم:

تغاير الفرض والواجب في المفهوم والحُكْم، أما المفهوم، فلأن

(١) راجع التلويح: ١٢٤/٢.

الفرض ثابت قطعاً، والواجب ثابت ظناً، وأما الحكم، فلأن الفرض لازم علماً وعملاً، والواجب لازم عملاً لا علماً، فكانا متغايرين.

وقد وافق الحنفية على مذهبهم الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في إحدى روايته.

أما الشافعية، فقد فرقوا بينهما لغة كالحنفية، ولكنهم نقلوهما من المعنى اللغوي إلى معنى واحد، وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعاً، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني، فكانا عندهم لفظين مترادفين، لكنهم لا ينكرون أن من جحد القطعي كفر، ومن جحد الظني لا يكفر^(١).

ومن أدلة الشافعية على أنهما مترادفان:

أنه قد شاع واستفاض استعمال أحدهما في الآخر، فنقول الصلاة واجبة.

وأيضاً فإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ﴾^(٢) أي أوجب، والأصل أن يكون مشعراً به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواء نفيًا للتجوز والاشتراك عن اللفظ^(٣).

وقد ضعف الشافعية وجهة الحنفية من عدة وجوه:

الأول: أن الحنفية قد نقضوا أصلهم، وخالفوا اصطلاحهم، فاستعملوا الفرض فيما ثبت بظني كقولهم: الوتر فرض، ومسح ربع الرأس فرض، ولم يثبت شئ من ذلك بقاطع.

وأيضاً استعملوا الواجب فيما ثبت بقطعي، كقولهم: الصلاة واجبة، والزكاة واجبة، وهذا شائع مُستفيض.

الثاني: أن الشارع أطلق الفرض على الواجب في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ

(١) راجع: مُذكرة الدكتور/ دياب ص١٣؛ غاية الوصول للدكتور/ جلال ص١٤٨.

(٢) سورة البقرة من الآية (١٩٧).

(٣) راجع: الإحكام للآمدي ١/١٤١.

فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ^(١) أَي أَوْجِبَ.

الثالث: ادعاء التفرقة بين الفرض والواجب في اللغة غير مُسَلَّم، لأن اللغة دلت على أن الفرض معناه التقدير، وهو أعم من أن يكون التقدير بقطعي أو بظني، فليس في اللغة ما يخصص التقدير بالقطعي.

الرابع: أنكم تقولون إن الواجب لغة هو الساقط، ولا نُسَلِّم ذلك لأن الوجوب لغة: مصدر وجب، بمعنى ثبت، وهو غالب استعماله، وثبت الشيء قد يكون مقطوعاً به، وقد يكون مظهرًا.

وأما وجب - بمعنى سقط - فمصدره الوجبة، يُقال: وجب وجبة، أي شققت، وأما وجب - بمعنى خفق واضطرب - فمصدره الوجيب.

والوجوب هنا معناه الثبوت، ولا يناسب المقام أن يكون بمعنى السقوط^(٢).

هل الخلاف بين الحنفية والشافعية لفظي أم لا؟

الحق في هذه المسألة أن الخلاف لفظي، وهو ما صرح به غير واحد من العلماء، فقد قال الآمدي عقب كلامه في المسألة: "وبالجملة فالمسألة لفظية"^(٣) وقال الغزالي في المستصفى: "ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني"^(٤).

وبيان ذلك: أن الفرض والواجب يُراد بهما: الفعل المطلوب طلبًا جازمًا، سواءً ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني، غير أنه إذا كان الطلب دليلاً قطعياً، فإن من جحده يحكم بكفره، ولكنهم (الحنفية) لا يخصصونه باسم الواجب فهم متفقون في الحكم، مُختلفون في التسمية وإطلاق

(١) سورة البقرة من الآية (١٩٧).

(٢) راجع: غاية الوصول للدكتور/ جلال صد-١٥٠.

(٣) الإحكام للآمدي ١٤١/٦.

(٤) المُستصفى ٦٦/١.

اللفظ^(١).

فتبين من ذلك أن الخلاف في التسمية - أي اللفظ - وهو ما يؤيد القول بأن الخلاف لفظي.

تنبيه:

يلتبس على الكثيرين الأمر فيما يتداول من ألفاظ الإيجاب، والوجوب، والواجب، فهذه الألفاظ الثلاثة يفرق بينها بما يأتي: أن الإيجاب هو ذات الخطاب من الشارع، والوجوب هو أثر ذلك الخطاب الذي هو صفة لفعل المُكلف، والواجب هو فعل المُكلف، وبحث الأصولي هو ذات الخطاب (الإيجاب)، وبحث الفقيه هو الأثر (الوجوب)، وكذلك يُقال في التحريم، والحُرمة، والحرام فالتحريم هو ذات الخطاب، والحُرمة هو أثر الخطاب، والحرام هو فعل المُكلف.

توضيح ذلك: قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٢) هذه الآية الكريمة هي ذات الخطاب المسمى بالإيجاب، أما الأثر المترتب على هذا الخطاب فهو وجوب الصلاة على المُكلف، أما فعل المُكلف الصلاة فهو الواجب.

وكذلك يُقال في جانب الحُرمة، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾^(٣) هو ذات الخطاب المسمى بالتحريم، والأثر المترتب على الخطاب هو الحُرمة، وفعل المُكلف الزني حرام^(٤).

وبذلك نكون قد أزلنا الالتباس بين هذه الألفاظ.

(١) راجع: المستصفى ٦٦/١؛ أصول السرخسي ١١٢/١.

(٢) سورة البقرة من الآية (٤٣).

(٣) سورة الإسراء من الآية (٣٢).

(٤) راجع: مُذكرة د/ دياب عبد الجواد ص ١١.

أقسام الواجب باعتبار وقت الأداء:

ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى قسمين:

القسم الأول: الواجب المطلق عن الوقت بحيث لا يفوت الأداء بواته.

القسم الثاني: الواجب المقيد (المؤقت) بحيث يفوت الأداء بفواته.

أما الواجب المطلق فهو: ما ألزم الشارع المُكلف بفعله دون أن يحدد للمُكلف وقتاً يؤديه فيه، فلا يذم المُكلف على تأخير فعله له عن وقت الاستطاعة إلى غيره.

مثاله:

نذر الاعتكاف شهراً: فإنه يعتكف في أي شهر، وكذلك لو نذر صوم شهر، فإنه يفِي بنذره أي شهر شاء، وكذلك من أمثلة الواجب المطلق: الزكاة، وصدقة الفطر، والعشر^(١).

هل الواجب المطلق يجب على الفور أم على التراخي؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فالجُمهور:

على أن الأمر في الواجب المطلق على التراخي، بمعنى جواز تأخيره عن أول وقت الإمكان ما لم يغلب على ظنه فواته.

واستدلوا على ذلك بالآتي: أن قول القاتل لعبده: افعل كذا هذه الساعة، فإنه يوجب الائتمار على الفور، وهذا أمر مقيد وقوله له: افعل مطلق، وبين المطلق والمقيد مغايرة على سبيل المناقاة، فلا يجوز أن يكون حكم المطلق هو حكم المقيد، لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات صفة التقييد من غير دليل، فإنه ليس في الصيغة ما يدل على التقييد في وقت الأداء.

(١) راجع: أصول السرخسي ٢٦/١-٢٧؛ حاشية نسمات الأسحار ص٥٤.

وأيضًا: من قال لعبده: تصدق بهذه الدراهم على أول فقير يدخل، يلزمه أن يتصدق بها على أول فقير يدخل عليه، ولو قال: تصدق بهذه الدراهم (مطلقًا) لم يلزمه أن يتصدق على أول فقير يدخل، وكان له أن يتصدق بها على أي فقير شاء، لأن الأمر مطلق.

وذهب الكرخي - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أن مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور، وهو الظاهر من مذهب الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -^(١).

واستدل على ذلك: بأن أول أوقات الإمكان مُراد بالاتفاق، حتى لو أدى فيه كان ممثلاً للأمر، فلا يثبت ما بعده مُراداً إلا بدليل، ومما يوضحه أن التخيير ينتفي بمطلق الأمر بين الأداء والترك فيثبت هذا الحكم وهو انتفاء التخيير في أول أوقات إمكان الأداء، كما ثبت حكم الوجوب.

وأيضًا: أن التفويت حرام بالاتفاق، وفي هذا التأخير تفويت، لأنه لا يدرى أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا يقدر؟ وبالاختلال الثاني لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضاً للمتيقن به، فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان تفويتاً، ولهذا استحق الذم على ذلك إذا عجز عن الأداء^(٢).

وذهب البعض: إلى أن الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الماهية، وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فوراً أو تراخياً.

واستدلوا عليه: بأنه لو كان حقيقة في واحد منهما (الفور أو التراخي) لزم المجاز وهو خلاف الأصل^(٣).

(١) المرجعين السابقين.

(٢) راجع: أصول السرخسي ٢٦/١-٢٧.

(٣) راجع: نهاية السؤل ٤٧/١؛ إرشاد الفحول ص ١٠٠.

والراجع:

هو المذهب الثالث القائل بأنه لطلب الماهية (القدر المُشترك بين الفور والتراخي)، لأن النزاع في الأمر المجرد المطلق عن الوقت، فإذا ما أتى المُكلف بما أمر به فقد برئت ذمته ولا ينظر في هذه الحالة إلى ما إذا كان أتى به فوراً أو تراخياً، طالما أن الفعل وجد بالطلب.

أما القسم الثاني وهو الواجب المقيد (المؤقت بوقت).

فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يكون الوقت ظرفاً للواجب بالأمر ولا يكون معياراً.

الثاني: ما يكون الوقت معياراً له.

الثالث: ما هو مشكل مشتبّه (الواجب ذو الشبهين)^(١).

ومعنى كون الوقت ظرفاً: أي يكون الوقت زائداً عن وقت أداء الفعل وهو المسمى عند الشافعية بالواجب الموسع كالصلاة مثلاً، فإن أداءها يكون في جزء من كل الوقت.

ومعنى كون الوقت معياراً: أي يكون الوقت مساوياً للفعل، وهو المسمى عند الشافعية بالواجب المضيق، وذلك كصوم رمضان، فإن الصوم في شهر رمضان مساوٍ للوقت.

أما معنى الوقت المشكل المشتبّه: أي أنه يشبه الظرف من وجه ويشبه المعيار من وجه آخر كالحج، أما شبهه بالظرف فلأن أفعاله لا تستغرق أوقاته، وأما شبهه بالمعيار، فلأنه لا يصح في العام الواحد إلا حج واحد.

وإليك بيان الأقسام الثلاثة بشئ من التفصيل:

القسم الأول: ما يكون الوقت فيه ظرفاً للواجب، والبعض يعبر عنه بكونه ظرفاً للواجب، وشرطاً له، وسبباً للوجوب، وذلك كوقت الصلاة،

(١) راجع: أصول السرخسي ٣٠/١.

فإن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^(١) فالوقت يكون ظرفاً للأداء، وشرطاً له وسبباً للوجوب، أما كون الوقت ظرفاً للأداء، لأنه يصح في أي جزء من أجزاء الوقت، وهذا لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها، فإذا لم يطول أركانها يصير مؤدياً في جزء قليل من الوقت، فإذا طول منها ركناً يخرج الوقت قبل أن يصير مؤدياً لها، فعرفنا أن الوقت ليس بمعيار، ولكنه ظرف للأداء.

وأما كون الوقت شرطاً للأداء، فلأن الأداء إنما يتحقق في الوقت، والتأخير عنه يكون تفويتاً، ومعلوم أن الأداء بأركان يتحقق من المؤدى قبل خروج الوقت، فعرفنا أن خروج الوقت مفوت، باعتبار أنه يفوت به شرط الأداء.

وأما بيان كون الوقت سبباً للوجوب، فلأنه لا يجوز تعجيل الصلاة قبل الوقت، وأن الواجب تختلف صفته باختلاف الأوقات، فهذا علامة كون الوقت سبباً لوجوبها^(٢).

ومن أحكام هذا القسم ما يكون الوقت فيه ظرفاً للأداء:

أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً وهو الأصح، وقال أكثر العراقيين من الحنفية: إن الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، ويستدلون على ذلك:

بأنه لو حاضت المرأة في آخر الوقت، فإنها لا يلزمها القضاء - أي قضاء تلك الصلاة التي حاضت في آخر وقتها - إذا طهرت، وعلى الرأي الأول - القائل بوجوب الصلاة بأول جزء من الوقت - يلزمها القضاء لأن ذمتها شغلت بها في أول الوقت، ولا تبرأ ذمتها إلا بقضائها بعد طهارتها.

وأيضا من أدلتهم: أن المقيم إذا سافر في آخر الوقت، صلى صلاة

(١) سورة النساء من الآية (١٠٣).

(٢) راجع: أصول السرخسي ٣٠/١.

المسافرين، وكذلك لو مات في الوقت لقي الله ولا شئ عليه.
وعلى الرأي الأول أن المسافر في آخر الوقت يصلي صلاة المقيم، لأن
الوجوب تعلق بأول جزء من الوقت، وعليه فيأثم إذا مات في الوقت دون
أداء.

ومن أحكام هذا القسم أيضاً اشتراط نية التعيين، لتعدد المشروع،
بمعنى أنه لما كان الوقت ظرفاً (موسعاً) ويسع الفرض وغيره وجب تعيين
الفرض بالنية بأن يقول مثلاً في وقت الظهر: نويت صلاة الظهر، ولا يصح
أن يقول في وقته: نويت الصلاة، لأن الوقت تصبح فيه صلاة الظهر
وصلاة غيره، ومن ثم وجب تعيين المؤدى بالنية^(١).

القسم الثاني: ما يكون الوقت فيه معياراً للواجب، وذلك كصوم
رمضان، لأن ركن الصوم هو الإمساك، ومقداره لا يعرف إلا بوقته، فكان
الوقت معياراً له، بمنزلة الكيل في المكيالات^(٢).

ومن أحكام هذا القسم:

أن الإمساك الذي يوجد منه في الأيام من شهر رمضان لما تعين
لأداء الفرض، لم يبق غيره مشروعاً فيه، لأنه لا يتصور أداء صومين
بإمساك واحد، وما يتصور في هذا الوقت لا يفضل عن المستحق بحال، فلا
يكون غيره مشروعاً فيه مستحقاً ولا متصور الأداء شرعاً.

فالمقيم إذا نوى بصومه في شهر رمضان واجباً آخر - كذا أو كفارة
- فإن صومه يقع عن الفرض لا عن الواجب الآخر، باتفاق بين الإمام
وصاحبيه.

أما المسافر إذا نوى بصومه في رمضان واجباً آخر، فهل يقع هذا
الصوم عن فرض رمضان أم عن الواجب الآخر؟

(١) راجع: أصول السرخسي ٣١/١؛ كشف الأسرار للنسائي ١٢٢/١.

(٢) أصول السرخسي ٣٦/١.

هذه مسألة فقهية اختلف فيها الإمام مع صاحبيه، وإذا كانت صورة المسألة قد تجلت لنا، فلنذكر الآن خلاف الحنفية فيها.

ذهب الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أنه إذا صام المسافر في رمضان عن واجب آخر - أي بنية واجب آخر - فإن صومه يصح عما نوى، أي يقع عن الواجب الآخر، لا عن الفرض.

واستدل على ذلك: بأن الأداء ساقط عن المسافر في رمضان، فصار رمضان في حقه بمنزلة شعبان، وإذا أدى نفلاً أو واجباً آخر في شعبان يصح، فكذا في رمضان.

ولأن المسافر مخير بين الأداء أو التأخير إلى عدة من أيام آخر، فلا ننفي صحة أداء صوم آخر منه بهذا الإمساك.

ولأن الوجوب ثابت في حق المسافر، ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت في حقه أيضاً، وإذا كان هو بالفطر مترخصاً، لأن فيه رفقاً ببذنه، فلأن يكون في صرفه إلى واجب آخر، وهو مصالح دينه، كان أولى. وذهب صاحبان إلى أن صومه في رمضان عن واجب آخر، يقع عن الفرض، لا عن الواجب.

واستدلوا: بأن وجوب صوم الشهر يثبت بشهود الشهر في حق المسافر، ولهذا صح الأداء، إلا أن الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع المشقة عنه، فإذا ترك الترخص كان هو والمقيم سواء، فيكون صومه عن فرض رمضان، فتلغو نيته لتطوع أو لواجب آخر^(١).

وأما المريض إذا صام رمضان بنية واجب آخر، فإنه يقع عن رمضان، لتعلق الرخصة بحقيقة العجز، فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه، فصار كالصحيح.

(١) راجع: أصول السرخسي ٣٦/١-٣٧؛ حاشية نسمات الأسفار ص ٥٨؛ كشف الأسرار للنسفي ١٢٥/١.

واختار الإمام أبو حنيفة مساواة المريض بالمسافر، وعليه فيقع صومه عما نوى، لأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم.

والراجع:

ما ذهب إليه الإمام - رَحِمَهُ اللهُ - في الصورتين - أي المسافر والمريض - من أنهما إن صاما رمضان عن واجب آخر، وقع عما نويًا، لأن بالترخيص لهما بالفطر صارا مخيرين بين الأداء وتركه، ألا وقد اختارا قضاء ما عليهما لتبرأ ذمتهما مما شغلت به، فكان ذلك أولى.

القسم الثالث: ما هو مشكل مشتبّه (الواجب ذو الشبهين) وسمي بذلك، لأنه يشبه المعيار والظرف، وهو يتمثل في فريضة الحج، فإن وقته مشكل مشتبّه.

وبيان ذلك من وجهين:

الأول: بالنسبة إلى سنة الحج، وذلك أن وقته يشبه الظرف من جهة أن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج، كوقت الصلاة، ويشبه المعيار من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد، كالنهار للصوم.

الثاني: بالنسبة إلى سنين العمر، وذلك لأن وقته العمر، وهو فاضل على الواجب، حتى لو أتى به في العام الثاني كان أداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت، فأشبهه الظرف، وهو لا يسع إلا حجًا واحدًا فأشبهه المعيار من جهة أنه لا يسع واجبين من جنس واحد^(١).

هل يجب الحج وجوبًا موسعًا أم مضيقًا؟

هذه مسألة فقهية تتفرع على ما ذكرناه في هذا القسم، وقد اختلف الصاحبان - رحمهما الله - في هذه المسألة، وبيان ذلك:

(١) راجع: التوضيح والتلويح ٢١٢/١؛ حاشية نسمات الأسحار ص ٥٩.

أن من وجب عليه الحج - بتوافر شروطه - هل يجب عليه مضيقاً - فوراً - حتى لا يجوز تأخيره عن العام الأول، أم يجب عليه موسعاً - متراخياً - بحيث يجوز له تأخيره عن العام الأول؟

هذه هي صورة المسألة، وإليك ما قيل فيها:

ذهب الإمام محمد - رَحِمَهُ اللهُ - إلى جواز تأخير الحج عن أنعام الأول، بشرط ألا يفوته، فإن عاش أدى وكانت أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء، كأجزاء الوقت في الصلاة، وذلك لأن الحج لما كان الإتيان به في العمر أداءً إجماعاً، علم أن كل العمر وقته، كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما.

وذهب الإمام أبو يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - إلى وجوب الحج عليه فوراً، أي يجب الحج وجوباً مضيقاً، فلا يجوز له تأخيره عن العام الأول، لأنه لما وجب الحج على المكلف لا يسعه أن يؤخره، لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة، حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الأول، بخلاف قضاء الصلاة والصوم، فإن الحياة إلى اليوم الثاني غالبية فاستوت الأيام كلها^(١).

وقد أرجع الكرخي - رَحِمَهُ اللهُ - هذا الخلاف إلى الخلاف الذي بين الصاحبين في الأمر المطلق، أيوجب الفور أم التراخي؟ وقد نفى صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - ذلك، لأن الأمر المطلق عند عامة علماء الحنفية لا يوجب الفور، فمسألة الحج مسألة مبتدأة^(٢).

والحق أن الخلاف بين الصاحبين لا يعد خلافاً في المعنى، بل يؤول إلى الاعتبار.

بيان ذلك: أن أبا يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - حكم بالتضييق للاحتياط، لا

(١) راجع: التوضيح ٢١٢/١.

(٢) المرجع السابق، كشف الأسرار للنسفي ١١٣/١.

لانتقطاع التوسع بالكلية، ولهذا جاز أدأؤه في العام الثاني، ومحمدًا - رَحِمَهُ اللهُ - حكم بالتوسع، لظاهر الحال في بقاء الإنسان، لا لانتقطاع التضيق بالكلية، فهذا يَأْثُمُ بالتأخير لو مات العام الثاني - فثبت أن وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار. عندهما - رحمهما الله - إلا أن الأظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند أبي يوسف، والظرفية عند محمد^(١).

إذن: فقد تبين أن الاختلاف في اعتبار كل منهما، ومن ثم فهما مُختلفان اعتبارًا متفقان مآلاً.

(١) راجع: التلويح ٢١٣/١.

وبذلك نكون قد وقضنا على أقسام الواجب المُقيد - المؤقت بوقت - وهي ثلاثة كما ذكره الإمام السرخسي في أصوله، لكن بعض العلماء كصدر الشريعة، والنسفي، أضافا قسمًا رابعًا على الثلاثة المذكورة، وهو ما يكون معيارًا لا سببًا، كقضاء رمضان والكفارة.

وبيان ذلك: أن الوقت في صوم القضاء، والكفارة معيار، لأن مقداره يعرف به، ولكنه ليس بسبب لوجوبه، بخلاف صوم رمضان، فالوقت ثمة معياره وسبب لوجوبه، أما صوم القضاء فسبب وجوبه هو شهود الشهر السابق، لا الشهر الحاضر، ولذلك لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحد، وأداء كفارتين بالصوم في شهرين.

ومن أحكامه:

أنه يشترط فيه نية التعيين، بأن يقول: نويت الصوم للقضاء أو للكفارة، ولا يتأدى بمطلق النية، ولا بنية النفل، أو واجب آخر، بخلاف القسم الثاني (ما يكون معيارًا وسببًا كصوم رمضان) فإنه لا يشترط فيه نية التعيين، ويصح بمطلق النية أو بنية واجب آخر، على خلاف المذكور في محله.

ومن أحكامه كذلك: اشتراط تبييت النية من الليل، لأن ما سوى رمضان كله محل للنقل، فيقع جميع الإمساكات على النفل ما لم يعين من الليل الصوم العارضي، وهو القضاء أو الكفارة بخلاف القسم الثاني أيضًا، فلا يشترط في صوم رمضان تبييت النية من الليل، لأنه معين في نفسه، ولا يقع الإمساك المطلق إلا عليه ما لم يصرفه إلى واجب آخر^(١).

(١) راجع: كشف الأسرار للنسفي مع شرح نور الأنور للملاييون ١/١٣١-١٣٢؛ التوضيح والتلويح ١/٢١٢.

الأسئلة

- س١: عرف الواجب لغة واصطلاحاً، ومثّل له، واذكر حكمه بالتفصيل.
- س٢: هل الفرض والواجب مترادفان؟ فصلّ القول في هذه المسألة مع ذكر الأدلة والرد عليها، وبيان نوع الخلاف.
- س٣: فرّق بين الإيجاب والوجوب والواجب مع التمثيل لكل ما تذكر.
- س٤: اذكر أقسام الواجب باعتبار وقت الأداء مع التمثيل لكل ما تذكر.

ثالثاً: السنة:

وهي في اللغة: مأخوذة من السنن - بفتحتين -، وهو الطريق، ومن قول القائل: من الماء: إذا صبه حتى جرى في طريقه^(١).

ويراد بها أيضاً: السيرة والطريقة حميدة كانت أو نميمة، والجمع سنن وخصها الخطابي والأزهري لغة بأنها الطريقة المحموده، فإذا أطلق لفظ السنة انصرف إليها وقد تستعمل في غيرها مقيدة كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من سن في الإسلام سنة سيئة"^(٢).

والأصح: ما عليه جمهور العلماء من أن السنة يُراد بها الطريقة والسيرة مطلقاً سواء كانت حميدة أم نميمة، ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾^(٣).

والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالحكم، وأفاضل أعمالكم وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين، والطرق التي سلكوها في دينهم لتتقدوا بهم.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٤).

والمعنى: وإن يعودوا لقتاله، فقد مضت سنة الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر، أو فقد مضت سنة الأولين الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم فدمروا، فيتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا^(٥) وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن السنة يُراد بها لغة الطريقة والسيرة مطلقاً حميدة أو ذميمة.

(١) راجع: أصول السرخسي ١١٣/١؛ القاموس المحيط ٢٣٧/٤ باب النون فصل السين.

(٢) راجع: إرشاد الفحول ص ٣٣؛ بحوث في السنة لأستاذنا الدكتور/ فرغلي ١٩/١.

(٣) سورة النساء من الآية (٢٦).

(٤) سورة الأنفال من الآية (٣٨).

(٥) راجع: بحوث في السنة للدكتور/ فرغلي ص ٢٠.

أما السُّنة في الاصطلاح:

يختلف تعريف السُّنة في اصطلاح الفقهاء عنه في اصطلاح المحدثين عنه في اصطلاح الأصوليين، والذي يهدنا ههنا هو اصطلاح الأصوليين، لأنه محل دراستنا، فالسُّنة عندهم في باب الأدلة هي: كل ما صدر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

والسُّنة في باب الأحكام هي: ما كان فعله أولى من تركه من عدم المنع من الترك، وكان طريقاً مسلوفاً في الدين^(١).

وإذا كنا نبحث في السُّنة من حيث كونها من أقسام الحكم التكليفي، لذا سنشرح تعريف السُّنة المذكور في باب الأحكام.

فقوله (ما كان فعله أولى من تركه) قيد خرج به الحرام والمكروه، لأن تركهما أولى من فعلهما ويخرج أيضاً المباح، لأنه يستوي فعله وتركه، وشمل الفرض والواجب والنفل، وقوله (مع عدم المنع من الترك) يخرج الفرض والواجب، لأن المكلف فيهما يمنع من تركهما، وقوله (وكان طريقاً مسلوفاً في الدين) يخرج النفل والمندوب^(٢).

أقسام السُّنة: للسُّنة قسمان:

الأول: سُنَّة هُدى.

الثاني: سُنَّة زوائد.

أما سُنَّة الهدى فما يكون إقامتها تكميلاً للدين وشعيرة من شعائره مثالها الأذان، وصلاة العيدين، والجماعة، والإقامة. حُكمها الثواب لفاعلها، والإساءة والكراهية لتاركها، لمخالفة تاركها لما واطب عليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من شعائر الإسلام، فترك السُّنة المؤكدة قريب من الحرام، يتعلق به محظور دون استحقاق العقوبة بالنار، وذلك كحرمانه من شفاعته

(١) راجع: مُذكرة الدستور/ دياب ص١٤.

(٢) المرجع السابق؛ وراجع: أصول السرخسي ١١٣/١.

- عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

وعلى ذلك: فالأخذ بسنة الهدى هداية، وتركها ضلالة، ولذا قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ: "إذا أصر أهل مصر على ترك الأذان والإقامة أمروا بهما، فإن أبوا قوتلوا على ذلك بالسلاح، كما يقتلون عند الإصرار على ترك الفرائض والواجبات، لأن هذه الأشياء من أعلام الدين، والإصرار على تركه استخفاف بالدين، فيقاتلون على ذلك لهذا".

وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: المقاتلة بالسلاح عند ترك الواجبات، أما السُّنن فإنما يؤدبون على تركها، ليظهر الفرق بين الواجب وغيره.

وأما سنة الزوائد: فهي التي لم يواظب عليها النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

مثالها: قيامه وقعوده، ولباسه وركوبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حُكْمُهَا:

الأخذ بها حسن، حتى يثاب على فعلها، وتركها لا بأس به، بمعنى أنه لا يتعلق بتركها كراهة أو إساءة، لكن الأولى الإتيان بها^(١).

ماذا يُراد بالسُّنة إذا أُطلقت؟

اتفق العلماء على أن لفظ السُّنة إذا ورد مقيداً، فإنه يحمل على ما قيد به، فإذا قلنا مثلاً: سنة هذه البلد كذا، حملت عليه، وسنة الصحابة كذا، حملت عليه.

أما الخلاف فيظهر في ورود لفظ السُّنة مطلقاً، كقول الراوي من السُّنة كذا، فهل يحمل على سُنَّته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقط، أم يحمل عليها وعلى سنة غيره من الصحابة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، إليك بيانها بإيجاز.

(١) راجع: المبسوط ١٣٢/١-١٣٣؛ أصول البردوي مع كشف الأسرار ٣١٠/٢؛ أصول السرخسي

١١٤/١؛ التوضيح والتلويع ١٢٤/٢.

المذهب الأول:

وهو للجمهور، ويرون أن قول الراوي: " من السنة كذا محمول على سنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنه حجة ومرفوع.

ودليلهم: أن مطلق لفظ السنة ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، ومن يجب اتباع سنته، وهو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأنه هو الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته، فإذا أطلق اللفظ يجب حمله على سنته.

ولأن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هو المقتدى والمتبع على الإطلاق، فلفظ السنة على الإطلاق لا يحمل إلا على سنته، كما لو قيل: هذا الفعل طاعة، فإنه لا يحمل إلا على طاعة الله وطاعة رسوله، وأما إضافة لفظ السنة إلى غير الرسول فمجاز، لاقتدائه فيها بسنة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوجب أن يحمل عند الإطلاق على حقيقته دون مجازه^(١).

المذهب الثاني:

وهو لمعظم علماء الحنفية، منهم: البزدوي، والسرخسي، والذبوسي، والجصاص، وغيرهم، وهؤلاء يرون أن إطلاق لفظ السنة لا يحمل على سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاصة إذ يجوز أن يُراد سنة البلدان، أو الأئمة، فهو ليس بمرفوع بل موقوف.

ودليلهم: أن السنة قد تطلق ويراد بها سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويراد بها أيضاً سنة غيره، ودليل ذلك: قول على كرم الله وجهه - في الخمر: جلد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربعين، وجلد أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أربعين، وجلد عمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانين، وكل سنة".

وجه الدلالة:

أن علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أطلق لفظ السنة على ما فعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى ما فعله أبو بكر، وعلى ما فعله عمر.

(١) راجع: كشف الأسرار ٣٠٩/٢؛ بحوث في السنة د/ فرغلي ٨٣/١-٨٤.

ويُجاب عن ذلك بأن هذا الدليل في غير محل النزاع، لأن السُّنة هنا مقيدة، ولا مانع عند التقييد من إطلاقها على سنة الصحابة وعلى سنة غيرهم، كما لا مانع من إطلاقها على السُّنة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيكون الدليل في غير محله ^(١).

المذهب الثالث:

وهو لأبي بكر الإسماعيلي، وقال بالتوقف.

ودليله أن لفظ انسنة عند الإطلاق يحتمل أن يكون سنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما يحتمل أن يكون سنة غيره، ولا دليل يبين لنا المرء، كما لا قرينة تعين أحد الاحتمالين على الآخر، فالتوقف يكون أسلم، اقتداء بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ^(٢).

ويُجاب عن ذلك بأننا لا نسلم أنه لا دليل يبين المراد، ولا تسلم أنه لا قرينة بل هنا دليل يدل على أن المراد سنة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأنه المبين للشرع، ولأنه المقتدى به والمتبع على الإطلاق، فحمل لفظ من السُّنة كذا على سنته - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أولى، لظهور ذلك اللفظ فيه ولتبادره، والتبادر أمانة الحقيقة.

الراجع:

هو قول الجمهور (المذهب الأول) وهو أن قول الراوي: من السُّنة كذا يحمل على سنته - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لقوة أدلتهم، ورد أدلة من عداهم لضعفها، ولأن لفظ السُّنة هو المتبادر عند الإطلاق، والتبادر أمانة الحقيقة كما سبق ^(٣).

(١) راجع: كشف الأسرار ٣٠٩/٢؛ وبحوث في السُّنة د/ فرغلي ٨٨/١.

(٢) سورة الإسراء من الآية (٣٦) .

(٣) راجع: بحوث في السُّنة المطهرة د/ فرغلي ٩٧/١، ١٠٢.

الأسئلة

- س١: عرف السنة لغة واصطلاحاً، وما هي سنة الهدى؟ وماهي سنة الزوائد؟ وما الفرق بينهما؟
- س٢: ما المراد بلفظ السنة عند الإطلاق؟ اذكر أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك، ثم اختر من الآراء ما تراه راجحاً.
- س٣: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل وبيان حكم كل منها: (سنة الهدى - سنة الزوائد).

رابعاً: النفل:

وهو لغة: الزيادة، ولهذا سمي ولد الولد نافلة، لكونه زيادة للمرء على ما حصل، وهو الولد الصليبي بدون اختياره وكسبه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾^(١) أي زيادة على إسحاق الابن الصليبي، لأن يعقوب ابن اسحاق.

وسُميت الغنيمة نفلاً، لأنها زيادة على ما هو المقصود، وهو الجهاد^(٢).

والنفل اصطلاحاً: هو ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك، ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين.

فقوله (ما كان فعله أولى من تركه) يدخل فيه الفرض والواجب والسنة، ويخرج الحرام والمكروه لأن الترك فيهما أولى، ويخرج أيضاً المباح لأن الفعل مساو للترك، وقوله (مع عدم المنع من الترك) يخرج الفرض والواجب، وقوله (ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين) قيد لإخراج السنة بقسميها، إذ هي طريقة مسلوكة في الدين.

وقد عرف بعض العلماء النفل بحكمه، أي جعلوا حكم النفل تعريفاً له فقالوا هو: ما يُثاب المرء على فعله، ولا يعاقب على تركه، وبذلك عرفه البزدوي، والنسفي، وصدر الشريعة^(٣).

ومُرَاد هؤلاء من قولهم "ولا يعاقب على تركه": عدم الإساءة على تركه، كما ذكره صدر الشريعة في التنقيح "ولا يسئ تاركه".

وظاهر كلامهم هنا: أن النفل ما لم يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يرغب فيه بخصوصه، لأنهم جعلوه مقابلاً للسنة بنوعيتها - الهدى والزوائد - ولذا فهو دون سنن الزوائد، لأن السنة طريقة مسلوكة في الدين وهو ليس

(١) سورة الأنبياء من الآية (٧٢).

(٢) راجع: تفسير ابن كثير ١٩٠/٣؛ القاموس المحيط ٥٩/٤؛ أصول السرخسي ١١٥/١.

(٣) راجع: أصول البزدوي، ٣١١/٢؛ كشف الأسرار للنسفي ٤٥٧/١؛ التوضيح ١٢٥/٢.

كذلك، ولذا كان النفل دون سُنّة الزوائد^(١).

هذا ويطلق على النفل المندوب، والنافلة، والمرغوب فيه، والمدعو إليه، والمستحب^(٢).

حُكم النفل:

لكي نبين حكم النفل لابد من التفرقة بين حالتين:

الأولى: حُكم النفل قبل الشروع.

الثانية: حُكمه بعد الشروع.

أما حُكمه قبل الشروع فيه:

فيُثاب فاعله ولا يسئ تاركه، ومعنى أن يثاب فاعله أي يستحق الثواب، فإن الله تعالى لا يجب عليه شئ، ومعنى لا يسئ تاركه: أي لا يلحقه إثم، حتى لو تركه مطلقاً، فلم يأت به ولا في الحال ولا الاستقبال، بخلاف ترك الصوم للمسافر، فإن عدم الإساءة في وقت مخصوص، وهو حال السفر، ولا يجوز الترك مطلقاً، بل لابد من الإتيان به، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾^(٣).

والمراد مما سبق بيان حكم النفل الذي لا تتغير حقيقته بعروض حالة محتمة، فلا يدخل في النفل قراءة الزائد عن ثلاث آيات من القرآن في الصلاة، لأن هذه الزيادة فرضت حالة تحتمها^(٤).

أما حُكم النفل بعد الشروع فيه:

فقد اختلف فيه كل من الحنفية والشافعية وقبل ذكر هذا الخلاف نذكر صورة المسألة: شخص نوى صلاة ركعتين أو صوم يوم تطوعاً، ثم

(١) راجع: التنقيح ١٢٥/٢.

(٢) راجع: مُذكرة د/ دياب ص١٧.

(٣) سورة البقرة من الآية (١٨٤).

(٤) راجع: التلويح ٢/١٢٤؛ ومُذكرة د/ دياب ص١٧.

عرض له عارض، فلم يستكمل الصلاة أو الصوم، فهل يلزمه قضاء الصلاة أو الصوم المتطوع بهما أم لا؟ وبعبارة أخرى هل يلزم النفل بالشروع فيه أم لا؟.

مذهب الشافعية:

أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، أي لا يلزم هذا المكلف المتطوع القضاء، وبذلك قال الإمام أحمد، وهو قول عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

أدلتهم: استدل هؤلاء على عدم لزوم القضاء على المتطوع بما يأتي:

١- ما روي عن أم هانئ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كانت صائمة صوم تطوع، فخيرها - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتم صومها، وقيس الصلاة على الصوم في الأمرين، ولأن حكم النفل: التخيير فيه، فإذا شرع فهو مخير فيما لم يأت تحقيقاً لمعنى النافلة^(١).

الجواب عن ذلك: أن هذا الدليل هو عين محل النزاع، لأن الأحناف لا يقولون بالتخيير في النفل بعد الشروع فيه^(٢).

٢- واستدلوا أيضاً بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المتطوع أمير نفسه" فهو نص في المطلوب.

الجواب عن ذلك: أن هذا الحديث محمول على ما قبل الشروع^(٣).

أما مذهب الحنفية:

فهو لزوم القضاء على المتطوع إذا أفسد ما شرع فيه من نفل، وبه قال الإمام مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - سواء أكان النفل صلاة أم صوماً^(٤).

(١) راجع: المجموع للنووي ٣٩٣/٦؛ المغني لابن قدامة ٨٩/٣.

(٢) راجع: التلويح ١٢٥/٢.

(٣) راجع: مُذْكَرَة د/ دياب ص ١٧.

(٤) راجع: المبسوط ٦٨/٣-٦٩؛ أقرب المسالك ٢٧٠/١.

أدلتهم:

١- أن عدم الإتيان بترك الباقي يؤدي إلى إبطال العمل المؤدى وكل إبطال منهي عنه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾^(١) فيكون الترك حراماً، فلزم الإتيان.

رُد على هذا الدليل من قبل الشافعية: بأن عدم الإتيان بترك الباقي ليس إبطالاً وإنما هو بطلان أدى إليه أمر مُباح له، وهو ترك النفل، إذ هو فعل مخير فيه، فلا يدخل في جملة الحرام المنهي عنه في الآية، وهذا قياس على من سقى زرعه فنز الماء إلى زرع غيره فأتلفه، فإن المتلف لا يضمن، لأن التلف ثبت تبعاً للأمر مُباح وهو السقي.

وقد رد الحنفية على ذلك: بأن هذا إبطال لا بطلان، إذ المفهوم من الإبطال فعل الإنسان فعلاً يحصل به البطلان ولو كان فعله مُباحاً.

أما قياسه على من سقى زرعه فأتلف الماء زرع غيره فهو قياس مع الفارق، فإنه سبب يضاف إليه التلف، وهو رخاوة الأرض، والقياس الصحيح أن يقاس على من شق زقاً مملوكاً له وفيه عسل لغيره فتلف بذلك، فإنه يعد إتلافاً فيضمن.

٢- واستدلوا أيضاً: بأن أداء المتنقل صار حقاً لله تعالى، فبضمه الباقي يكون عبادة، وكل ما هو كذلك تجب صيانتة، لأن التعرض لحق الغير بالإفساد حرام، ولا طريق لصيانة المؤدى إلا بلزوم الباقي، لأن الصحة لا تتم إلا بلزوم هذا الباقي، لأن الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق الثواب عليها^(٢).

٣- واستدلوا أيضاً: بأن الناذر إذا نذر نذراً لله تعالى، صار هذا النذر حقاً لله تعالى بالتسمية، ويجب الوفاء بهذا النذر إجماعاً، وما أداه من

(١) سورة محمد من الآية (٣٣) .

(٢) راجع: التلويح ١٢٥/٢.

النفل صار حقاً لله تعالى فعلاً، فإذا لزم ما صار حقاً لله تعالى تسمية - النذر - وهو ضعيف، فالأولى أن يلزم ما صار حقاً لله تعالى فعلاً - النفل - وهو أقوى، لأن ما وقع الله تعالى فعلاً أقوى مما صار له تسمية، فإذا وجب صيانة الأضعف - وهو ما صار له تسمية - فمن باب أولى أن يجب صيانة الأقوى وهو ما وقع له فعلاً وهو النفل^(١).

وثمرة الخلاف تظهر فيمن نوى صوم يوم مثلاً - تطوعاً - فأفطر بعذر الضيافة، هل عليه القضاء أم لا؟.

فالحنفية على أنه يلزمه قضاء هذا اليوم بعد ذلك، وإن لم يقضه يُلحقه الإثم.

والشافعية على أنه لا يلزمه القضاء، ولا إثم عليه إذا لم يقضه.

الراجع:

والذي أراه راجحاً هو رأي الحنفية، بوجوب قضاء ما شرع فيه من نفل ولم يتمه، سواء كان النفل صلاة أم صوماً، وذلك لأن شروع المُكلف في صوم أو صلاة - تطوعاً - شروع في عبادة والعبادات يجب صيانتها من الإبطال، لأن الأخذ بالاحتياط في العبادات أولى من عدمه.

وأيضاً: ما ذكره الحنفية من أدلة، وردهم على أدلة الخصم ومناقشتها يرجح ما ذهبوا إليه.

(١) راجع: التلويح ١٢٥/٢؛ الوافي للسغناقي - رسالتنا "للدكتوراه" ص٥٧٤-٥٧٥؛ مُذكرة د/ دياب ص١٨.

الأسئلة

- س١: عرف النفل لغة واصطلاحاً، مع شرح التعريف بالتفصيل.
- س٢: ما هو حكم النفل قبل الشروع فيه؟ وهل يختلف حكمه بعد الشروع فيه؟ اذكر أقوال العلماء وأدلتهم، ثم بين ثمرة الخلاف في المسألة، مع بيان الرأي الراجح.

خامساً: الحرام:

الحرام في اللغة: من الحُرمة، وهو المنع، ومنه: حرم مكة، يقال: حرمت على الكافر دخول مكة: أي منعته من دخولها، فمعنى حُرمة الفعل: كونه ممنوعاً^(١).

وفي الاصطلاح: ما كان تركه أولى من فعله مع المنع من الفعل بدليل قطعي.

فقوله: (ما كان تركه أولى) يخرج الفرض والواجب والسنة والنفل، والمباح، لأن ما سوى المباح فعله أولى، والمباح يستوي فيه الفعل والترك كما سبق، وقوله (مع المنع من الفعل) يخرج به المكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

حكم الحرام:

من اقترف حراماً، كالقتل أو الزنى، أو السرقة أو غيرها، فإنه يعاقب ويذم شرعاً، ويتفاوت العقاب بتفاوت المحرمات في شدة حرمتها في نظر الشارع، وتاركه لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا تركه تقرباً إلى الله تعالى، فيكون حينئذ عبادة يثاب عليها، كمن ترك الزنى أو السرقة وهو قادر عليهما، فله الأجر والمثوبة من الله تعالى^(٢).

ويُسمى الحرام بأسماء متعددة كالمُحرم، والمحذور، والذنب، والمزجور عنه، والقبيح، والمعصية، والمتوعد عليه، فكل هذه الأسماء تؤدي إلى معنى واحد، وهو استحقاق العقاب على الفعل^(٣).

(١) راجع: المُعجم الوجيز ص١٤٧؛ الإحكام للآمدي ١/١٦٠.

(٢) راجع: تيسير التحرير ٢/١٣٥؛ مُذكرة د/ دياب ص١٩.

(٣) تيسير التحرير ٢/١٢٥.

بم يُعرف الحرام؟ (صيغ الحرام)

للحرام صيغ يعرف بها، وهي:

- (١) صيغة التحريم الصريح، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾^(١).
- (٢) النهي الجازم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا﴾^(٢).
- (٣) الأمر بالاجتناب الجازم كقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾^(٣).
- (٤) ترتب العقوبة على الفعل، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(٤).
- (٥) صيغة "لا يحل"، كقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ.....﴾^(٥).

أقسام الحرام: ينقسم الحرام إلى قسمين:

الأول: حرام لعينه.

الثاني: حرام لغيره.

أما الحرام لعينه:

فما كان منشأ الحرمة فيه عين ذلك الشئ الذي تعلق به الفعل، وذلك كأكل الميتة وشرب الدم والخمر، فهذه الأشياء هي منشأ الحرمة، وقد خرج المحل، وهو الميتة والدم والخمر عن قبول الفعل، لأن كلاً منها مُحَرَّم لذاته، والحرمة مُتعلِّقة بعين الميتة والخمر والدم، فعدم الفعل - الأكل والشرب - - فيهما لعدم المحل، فيكون المحل أصلاً ويكون الفعل تبعاً له، فتنسب الحرمة إلى المحل، لتدل على عدم صلاحيته للفعل، وتعلق الحرمة بالمحل يجعل

(١) سورة المائدة من الآية (٣) .

(٢) سورة الإسراء الآية (٣٢) .

(٣) الحج من الآية (٣٠) .

(٤) سورة المائدة من الآية (٣٨) .

(٥) سورة الأحزاب من الآية (٥٢) .

الدلالة على حُرمة الفعل أبلغ.

فإذا قلنا مثلاً: الميتة حرام، فليس هذا من باب إطلاق المحل - الميتة - وإرادة الحال - الأكل - بل معناه أن المحل نفسه، وهو الميتة منشأ الحُرمة، وإسناد الحُرمة إليها للدلالة على أنها أصل ومنشأ الحُرمة، والمحل، وهو الميتة مستعمل في حقيقته، وإنما التجوز في كلمة حرام، وهي المُسند^(١).

وأما الحرام لغيره:

فهو ما لم يكن منشأ الحُرمة فيه عين ذلك الشئ الذي تعلق به الفعل، وذلك كأكل مال الغير، فإنه حرام، فحُرمة الأكل ليس منشؤها المال، بل لكونه ملك الغير، فالأكل مُحرم ممنوع نكن المحل قابل للأكل في الجملة، بأن يأكل منه صاحبه، فالحُرمة ههنا راجعة إلى الفعل، وهو الأكل، وأما المحل نفسه، وهو المال تقابل للفعل، فيحل هذا المال إذا لم يكن للغير، بخلاف الحرام لعينه، فإن المحل خارج تماماً عن صلاحية الفعل فينعدم الانعدام المحل، فهنا التجوز في المسند إليه - طعام الغير - مثل قولنا: طعام الغير حرام، فيراد أكل طعام الغير، من باب إطلاق المحل - الطعام -، وإرادة الحال الأكل أو على الحذف بتقدير: أكل طعام الغير حرام.

وبالجُملة: فالفرق بين الحرام لعينه ولغيره من وجهين:

الوجه الأول:

من جهة المعنى: وهو أن منشأ الحُرمة في الأول عين ذلك المحل، وفي الثاني الحُرمة في الفعل، ففي الحرام لعينه المحل أصل في الحُرمة والفعل تبع، وفي الحرام لغيره الفعل هو الحرام.

الوجه الثاني:

من جهة اللفظ: وهو أن الحرام لعينه من باب المجاز العقلي في الإسناد، فإسناد الحُرمة إلى المحل لكونه سبباً، وفي الحرام لغيره من باب

(١) راجع: التوضيح ١٢٥/٢؛ مُذكرة د/ دياب صـ ٢٠.

إطلاق المحل وإرادة الحال - الفعل - فيكون مجازاً مُرسلاً، أو مجازاً بالحذف^(١).

(١) المرجعين السابقين.

الأسئلة

- س١: عرف الحرام لغة واصطلاحاً، وما هو حكمه؟ وما هي الصيغ التي يعرف بها؟
- س٢: للحرام أقسام، اذكرها، ثم اذكر الفرق بينها مع التمثيل.
- س٣: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل وبيان حكم كل منها:
(الحرام لنفسه - الحرام لغيره).

سادساً: المكروه:

المكروه في اللغة: مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب، ومنه قولهم: جمل كره - بفتح السكون - أي شديد الأس، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية.

ويُراد به أيضاً: القبيح، يقال: كره الأمر: قبح^(١).

وفي الاصطلاح: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل. فقوله ما كان تركه أولى يخرج الفرض، والواجب والسنة، والنفل لأن فعل هذه الأشياء أولى من الترك، ويخرج أيضاً المباح، لأن الفعل فيه مساو للترك، وقوله (مع عدم المنع من الفعل) يخرج الحرام، لأنه ممنوع فعله بالدليل القطعي^(٢).

أقسام المكروه:

ينقسم المكروه إلى قسمين هك بيانهما:

مكروه كراهة تنزيه، ومكروه كراهة تحريم.

فالمكروه تنزيهاً هو: ما كان إلى الحل أقرب، بمعنى أنه لا عقاب على فاعله أصلاً، ولكن يُثاب تاركه أدنى ثواب.

مثاله: تشبيك الأصابع، وتقليب الحصى في الصلاة.

وأما المكروه تحريماً: فهو ما كان إلى الحرام أقرب، ومعنى القرب من الحرمة، أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، كالحرمان من الشفاعة، فتترك الواجب حرام يسحنى العقوبة بالنار، وترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة، وذلك لقوله -

(١) راجع: المعجم الوجيز ص ٥٣٣: الإحكام للآمدي ١/١٧٤.

(٢) راجع: التوضيح ٢/١٢٤.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "من ترك سُنتي لم ينل شفاعتي" ^(١).

وهذا التعريف المذكور للمكروه تحريماً إنما هو عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -.

أما الإمام محمد بن الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - فقد اختلف مع إمامه وصاحبه، فقال: إن المكروه تحريماً ليس إلى الحرام أقرب بل هو حرام ثبتت حرمة دليل ظني، فهو بذلك يفرق بين نوعين من الحرام، فما لزم تركه إن ثبت ذلك بدليل قطعي فهو الحرام، وإن ثبت تركه بدليل ظني فهو المكروه كراهة التحريم؛ فيقابل بذلك الفرض والواجب، فما لزم فعله إن ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وإن ثبت بدليل ظني فهو الواجب.

وبناء على ذلك: فإن ترك الواجب عنده مكروه تحريماً، وعندهما حرام، وترك السُّنة المؤكدة عنده مكروه تنزيهاً، وعندهما مكروه تحريماً. مثال المكروه تحريماً: صوم يوم النحر، والبيع عند أذان الجمعة.

الأسئلة

س١: عرف المكروه، ثم اذكر أقسامه بالتفصيل مع التمثيل لكل ما تذكر.

س٢: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل: (المكروه - كراهة تحريمية - كراهة تنزيهية).

س٣: اذكر خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف مع محمد بن الحسن في المكروه كراهة تحريمية، ثم اذكر ما يترتب على هذا لاختلاف.

الطبيبات مُباحة.

وقد يعرف المُباح بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة له عن إفادة الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾^(١).

وقد يُعرف المُباح باستصحاب الأصل - البراءة الأصلية - وذلك إذا لم يوجد دليل يدل على حكمه، بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة^(٢).

مما سبق يتبين أن المُباح يعرف بأمور هي:

نفي الإثم، ونفي الحرج، ونفي الجناح، والتصريح بالحل، وصيغة الأمر المقرونة بما يدل على الإباحة، وباستصحاب الأصل.

هل الإباحة حكم شرعي أم لا؟

مذهب الجمهور: أن الإباحة حكم شرعي.

وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: الإباحة ليست حكماً شرعياً، لأن معناها: انتفاء الحرج في الفعل والترك، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده.

وحقيقة الخلاف: إنما هو فيما تحمل عليه الإباحة إذا أطلقت في لسان الشرع، هل تحمل على الإباحة الأصلية، أم أنها تحمل على تخيير الشارع للمُكلف بين الفعل والترك؟

فاتفقوا على أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك إباحة عقلية، وأن تخيير الشارع للمُكلف بين الفعل والترك إباحة شرعية، ولكن الخلاف فيما تحمل عليه الإباحة عند الإطلاق.

فالجمهور حملوها على أن وجودها يتوقف على وجود الشرع، لأنها عبارة عن تخيير الشارع للمُكلف بين الفعل والترك فهي عندهم حكم شرعي.

(١) سورة البقرة من الآية (٦٠) .

(٢) راجع: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص١٥٥؛ غاية الوصول د/ جلال ص١٦٥.

والمعتزلة حملوها على انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو وارد قبل الشرع، فهي عندهم غير شرعية.

ونظراً لاختلافهم فيما تحمل عليه الإباحة، كان خلافهم لفظياً^(١).

هل المباح مأمور به؟

الجمهور على أن المباح غير مأمور به؛ لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه ومطلق، غير مستدعى ولا مطلوب.

ويُسمى المباح مأموراً به على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن الاسم الحقيقي للمباح هو المأذون فيه.

وذهب بعض العلماء كالكعبي من المعتزلة، وأبي الفرج المالكي، وأبي بكر الدقاق، إلى أن المباح مأمور به.

ودليلهم: أن المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون المباح واجباً، ومن ثم فهو مأمور به.

والجواب عن ذلك: لا نسلم أن المباح بذاته هو ترك الحرام، وإنما يلزم منه ترك الحرام، وفرق بينهما.

الراجح: مذهب الجمهور، لأن المباح حقيقة هو المأذون فيه، وليس المأمور به^(٢).

هل الإباحة تكليف؟

الجمهور على أن الإباحة ليست تكليفاً؛ لأنه لم يؤمر بها فعلاً ولا تركاً، وإنما عدها الجمهور من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلاً للقسمة.

وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى أن الإباحة تكليف؛ لأن المكلف يجب عليه اعتقاد إباحة الشيء وأنه من الشرع، وهذا رأى ضعيف^(٣).

(١) راجع: الإحكام للآمدي ١/١٧٦؛ غاية الوصول د/ جلال ص١٦٤-١٦٥.

(٢) راجع: المستصفى ١/٧٤؛ روضة الناظر ١/٢٠٣.

(٣) راجع: المستصفى ٧١/٧١؛ روضة الناظر ١/٢٠٣.

الأسئلة

- س١: عرف المباح لغة واصطلاحاً، وما هو حكمه؟ وبم يعرف المباح؟
- س٢: هل الإباحة حكم شرعي؟ وضح ذلك بالتفصيل.
- س٣: هل المباح مأمور به؟ اذكر آراء العلماء وأدلتهم في ذلك مع ذكر الرأي الراجح.

ثانياً: الرخصة (الحكم غير الأصلي):

بعد الفراغ من القسم الأول لما هو صفة لفعل المكلف واعتبرت فيه المقاصد الأخروية، وهو العزيمة (الحكم الأصلي) وبيان أقسامها، نشرع بعون الله تعالى في بيان القسم الثاني- الرخصة - وما يتعلق بها فنقول: قبل الخوض في ذكر أقسام الرخصة يتحتم علينا تعريفها لغة واصطلاحاً.

تعريف الرخصة:

أما تعريفها لغة فهي: عبارة عن النعومة واللين والسهولة والتيسير، فرخصة الله لعباده تسهيله عليهم، ويقال: رخص السعر: أي تيسر وسهل، وهي ضد الغلاء، والرخصة في الأمر: التخفيف، فهي خلاف التشديد فيه^(١).

وأما اصطلاحاً فهي: ما ثبت ثانياً مبنياً على أعذار العباد.

أو يُقال: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، وفي أصول الشافعية هي: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة في حقه، أي أن دليل الحرمة إذا بقي معمولاً به، وكان التخلف عنه مانع طارئ في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، فخرج بذلك الحكم بجل شئ ابتداءً، أو نسخاً لتحريم، أو تخصيصاً من نص مُحرم^(٢).

ومثال الرخصة: فطر المسافر والمريض في رمضان، وقصر الصلاة في السفر وغيرها، وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على أقسام الرخصة.

تنبيه:

حصر بعض العلماء كصدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - العزيمة في أقسام أربعة فقط هي: الفرض الواجب، السنة، النفل، ومن ثم فعلى رأيه يكون

(١) راجع: الإحكام للآمدي ١/١٨٨؛ غاية الوصول د/ جلال ص٢٣٤.

(٢) راجع: التلويح ٢/١٢٧؛ ومُذكرة د/ دياب ص٢٤.

الحرام، والمكروه، والمُبَاح حُكْمًا أصليًا وليس عزيمة، فالْحُكْمُ الأصلي عنده أعم من العزيمة، لأنه إن وقع في مقابلة الرُّخصة يُسمى عزيمة، وإن لم يقع في مقابلة الرُّخصة يُسمى حُكْمًا أصليًا فقط.

وعند البعض: أن اسم العزيمة لا يشترط وقوعه في مقابلة رُخصة، فعلى هذا يكون كل حكم أصلي عزيمة، قال صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسُّنة والنفل والحرام والمكروه والمُبَاح: إن العزيمة اسم للحكم الأصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا من الفرض والواجب والسُّنة والنفل ونحوها.

ورأى صدر الشريعة محمول على ما قبل ورود الرُّخصة أما بعده فالصحيح أن العزيمة تجري في أنواع الحُكم السبعة، فقد تكون العزيمة حرامًا كصوم المريض إذا خاف الهلاك^(١).

هل المقصود الأخرى متحقق في الرُّخصة؟

الحق أن المقصود الأخرى متحقق في الرُّخصة، بمعنى أنه يعتبر ذلك في مفهومه اعتبارًا أوليًا، وذلك لأن الآخذ بالرُّخصة يعامله الله تعالى معاملة من يفعل المباح في عدم العقاب، وعدم العقاب مقصود أخرى.

ويظهر ذلك واضحًا في عبارات العلماء في تعريف الرُّخصة، فقد عرفها فخر الإسلام بأنها: ما استباح مع قيام المحرم، وتعريفها في أصول الشافعية ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لثبتت الحرمة، فيكون المقصود الأخرى متحققًا في مفهوم الرُّخصة اعتبارًا أوليًا^(٢).

أقسام الرُّخصة:

للرُّخصة أربعة أنواع، نوعان من الحقيقة، ويطلق عليها اسم "الرُّخصة

(١) راجع: التلويح ١٢٧/٢؛ ومُذكرة د/ دياب ص ٢٣.

(٢) راجع: المرجعين السابقين.

الحقيقية"، ونوعان من المجاز، ويطلق عليها اسم "الرخصة المجازية" فالرخصة الحقيقية نوعان: أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر. والمجازية نوعان أيضاً: أحدهما أتم في المجازية - أبعد من حقيقة الرخصة - من الآخر، وليست أتم فصارت الأنواع أربعة: أحق بكونه رخصة، ليس أحق، أتم في المجازية، ليس أتم^(١).

وجه الحصر: أن الإباحة إن كانت ثابتة مع قيام الدليل المحرم والحُرمة فهذه رخصة حقيقية وأحق بكونها رخصة، وهو النوع الأول.

وإن كانت الإباحة مع قيام الدليل المحرم دون الحُرمة، فهي رخصة حقيقية أيضاً لكنها دون الأولى في أحقية كونها رخصة وهو النوع الثاني. وإن لم يكن المحرم قائماً، فإما أن يكون الحكم الأصلي غير مشروع في الجملة فهي الرخصة المجازية الأتم، وهو النوع الثالث. وإن كان الحكم الأصلي مشروعاً في الجملة، لكنه غير مشروع في مقابلة الرخصة، فهي رخصة مجازية ليست أتم في المجازية، وهو النوع الرابع^(٢).

وبعد بيان وجه الحصر نشرع في بيان كل نوع تفصيلاً:

النوع الأول:

الرخصة الحقيقية التي هي أحق بكونها رخصة، وهي: ما استباح مع قيام المحرم والحُرمة.

فقوله (ما استباح) المراد بالاستباحة: تجويز الفعل، وهو أعم من أن يكون مُساوياً أو راجحاً حتماً أو غير حتم، فيشمل الواجب والمندوب والمباح. وقوله (المحرم والحُرمة) المراد بالحُرمة والمحرم في الرخصة ما يعم جانب الفعل أو الترك فيشمل الفرض والواجب أيضاً، ومعنى الحُرمة: المنع سواء كان بطريق اللزوم أو الرجحان، كالسُّنة والمندوب، فإن المنع من

(١) راجع: التوضيح ١٢٧/٢؛ الوافي للسغناقي بتحقيقنا رسالة دكتوراه ص٥٧٨.

(٢) راجع: الوافي للسغناقي رسالة دكتوراه بتحقيقنا ص٥٧٨؛ ومُذكرة د/ دياب ص٢٠٨.

الترك فيهما راجح.

ومعنى قيام المحرم: وجود الدليل المحرم لما رخص به ويخرج بهذا المباح من الحكم الأصلي، لأنه شرع ابتداء من غير مُحرم، وتخرج الرخصة المجازية بنوعيتها، لأنهما لا يكونان مع قيام المحرم، لعدم العزيمة فيهما، ومعنى قيام الحرمة ثبوتها في الحكم المرخص بإباحته لعذر، وهو يخرج النوع الثاني من الرخصة الحقيقية، لأن الحرمة فيها متراخية.

ويُراد أيضاً بالاستباحة: أن يُعامل مُعاملة المباح بترك المؤاخذة عليه، فلا يوجب سقوط الحرمة كارتكاب الكبيرة والعفو عنها، فإن العفو لا يخرجها عن التحريم، بل يسقط المؤاخذة، فلا يلزم الجمع بين الضدين^(١).

ولهذا النوع أمثلة كثيرة، منها ما ترجع الحرمة فيه إلى الفعل، ومنها ما ترجع الحرمة فيه إلى الترك.

مثال ما ترجع الحرمة فيه إلى الفعل: إجراء كلمة الكُفر على اللسان مكرهاً بالقتل و القطع، فيرخص له أن ينطق بكلمة الكُفر ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان، فإن حرمة الكُفر قائمة أبداً، لأن الأدلة على وجوب الإيمان وحرمة الكُفر قائمة أبداً، لقوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٢) وقوله ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾^(٣) وقوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٤)، فالمشروع أولاً وجوب الإيمان وحرمة النطق بالكُفر وهو المسمى بالرخصة، فيباح لمن خاف التلف على نفسه عند النطق بالكُفر وهو المسمى بالرخصة، لأن في الامتناع عن النطق بها حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى، وبإجراء كلمة الكُفر لا يفوت

(١) راجع: التلويح ١٢٨/٢؛ ومُذكرة د/ دياب ص ٢٥.

(٢) سورة النساء من الآية (١٣٦) .

(٣) سورة المائدة من الآية (٥) .

(٤) سورة النساء الآية (١٦٧) .

ما هو الواجب معنى لبقاء الاعتقاد والتصديق بالقلب، ولأنه سبق منه الإقرار مع التصديق القلبي فيصح إيمانه، واستدامة الإقرار في كل وقت ليس بركن، إلا أن في إجراء كلمة الكُفر هتك حُرمة الله تعالى صورة لا معنى، ولكن إذا أخذ بالعزيمة فلم يجر كلمة الكُفر على لسانه، وبذل نفسه حسبة في دينه، كان أولى، لما في ذلك من رعاية حق الله تعالى صورة ومعنى، فيضاعف له الأجر، وإمامه في ذلك خبيب بن عدي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لما امتنع عن النطق بكلمة الكُفر وصير به حتى صُلب وقُتل، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هو أفضل الشهداء وهو رفيقي في الجنة".

وكذا عمار بن ياسر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حينما أخذه المشركون وأجبروه على سب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلما فعل تركوه، فذهب إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مهموماً، فقال له: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر، ما تركوني حتى نلت منك وذكرت ألهمهم بخير، فقال له: كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئناً بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد، إي إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى الترخيص^(١).

فتلك صورتان: الأولى فيها أخذ بالعزيمة، وهو الأولى والأحسن عند الحنفية، لأن خبيب بن عدي لم ينطق بكلمة الكُفر، مراعاة لحق الله تعالى صورة ومعنى، فهو أفضل عند الله تعالى من الذي نطق بها ترخيصاً لذا فقد قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "هو أفضل الشهداء..." الحديث.

والصورة الثانية فيها أخذ بالرخصة، لأن عماراً نطق بكلمة الكُفر، مراعيًا حق الله معنى لا صورة، فكان دون من أخذ بالعزيمة.

ومما يدل على ذلك - أي على أن الأخذ بالعزيمة أوصى - ما ورد أن مسلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله، فقال وأنا؟ قال أنت أيضاً، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله قال: ما تقول في ؟ قال: أنا أصم، فأعادها عليه ثلاثاً، ولم يتغير جواب الصحابي فقتله، فبلغ

(١) راجع: أصول السرخسي ١١٨/١؛ كشف الأسرار ٣١٦/٢؛ التوضيح ١٢٨/٢.

ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أما الأول فقد أصاب السنة، وأما الثاني فله الأجر مرتين^(١).

ومن ثم قال الحنفية: إن الأخذ بالعزيمة أولى وأحسن من الأخذ بالرخصة، خلافاً للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما نسب له أن الأخذ بالرخصة أولى^(٢).

ومن أمثلة ما ترجع فيه الحرمة إلى الفعل أيضاً: تناول مال الغير بغير إذنه للمضطر عند خوف الهلاك، فإنه رخصة مع قيام سبب الحرمة وحكمها وهو حق المالك.

ومن أمثلته أيضاً: الإكراه على الإفطار في رمضان الصحيح المقيم، فيرخص للمكره الفطر كيلا يفوت حقه صورة ومعنى لا إلى بدل، وحق الله تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء، والتقيد بكونه صحيحاً مقيماً، لأنه لو كان مريضاً أو مسافراً لا يكون ترخيصه من هذا النوع، لأنه لو لم يفطر حتى قتل كان أثماً، لأنه لما أبيح للمريض والمسافر الفطر في رمضان، صار رمضان في حقهما كشعبان.

ومن أمثلته أيضاً: الإكراه على الجناية على الصيد للمُحَرَّم، مع قيام المُحَرَّم والحرمة، فله أن يأخذ بالرخصة وله أن يأخذ بالعزيمة، وهو أولى^(٣).

وأما مثال ما كانت الحرمة فيه راجعة إلى الترك: الإكراه على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام المُحَرَّم والحرمة ولكن يرخص له في الترك، مع إنكاره ذلك بقلبه، وإذا أخذ بالعزيمة فلم يترك وبذل نفسه حسبة الله تعالى كان أولى، قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٤).

(١) راجع: التلويح ١٢٨/٢؛ مُذَكَّرَةٌ د/ دياب ص ٢٦.

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٢٨/٢.

(٣) راجع: أصول السرخسي ١١٨/١-١٩٩؛ كشف الأسرار ٣١٧/٢.

(٤) سورة لقمان من الآية (١٧) .

ومن أمثلته أيضاً: الإكراه على ترك الصلاة وغيرها من العبادات وتوجيهه كما تقدم.

مما سبق يتضح أن هذا النوع من العزيمة يجري في العقائد كالإيمان بالله تعالى، وفي العبادات كالإكراه على ترك الصلاة أو الصوم، وفي حقوق العباد أيضاً كالإكراه على أكل مال الغير، والحكم في كل ما ذكر من أمثلة واحد، وهو أن له الأخذ بالرخصة بالإقدام على ما فيه رفع الهلاك عن نفسه، فذلك توسعة له وتيسيراً من الشارع عليه، وإن امتنع - أخذ بالعزيمة - فهو أولى وأفضل له^(١).

هذا: ويطلق على هذا النوع الرخصة الحقيقية الكاملة، لأن الحرمة لما كانت قائمة مع سببها، ومع ذلك شرع للمكلف الإقدام عليه من غير مؤاخذه لعذره كانت في أعلى مراتب الكمال في رتب الرخص، فكان هذا النوع أحق بإطلاق اسم الرخصة عليه من الأنواع الباقية^(٢).

النوع الثاني:

الرخصة الحقيقية التي ليست أحق، وهي ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة، ويطلق عليها اسم الرخصة الناقصة نظراً لتراخي الحكم، بخلاف النوع الأول، فقله (ما استبيح مع قيام المحرم) يخرج الرخصة المجازية بنوعيتها وقوله (دون الحرمة) يخرج النوع الأول، وهو الرخصة الحقيقية الأحق، وسبق بيان معنى المحرم والحرمة في النوع الأول.

مثال هذا النوع: الصوم في شهر رمضان للمسافر والمريض، فقد رخص لهما الفطر لعذر السفر والمرض، مع قيام الدليل المحرم وهو شهود الشهر، ولكن الحرمة غير قائمة، بل متراخية إلى إدراك عدة من أيام آخر، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾^(٣).

(١) راجع: أصول السرخسي ١١٨/١-١١٩؛ التوضيح والتلويح ١/٢٢٨.

(٢) راجع: كاشف معاني البديع - رسالتنا الماجستير ص ٣٤٩.

(٣) سورة البقرة من الآية (١٨٤) .

حكم هذا النوع: يجوز الأخذ بالرخصة فيباح الفطر للمريض والمسافر ويجوز الأخذ بالعزيمة، فإن صام المريض والمسافر شهر رمضان جاز، وهو الأولى والأحسن، وبذلك قال الحنفية أي أن الأخذ بالعزيمة أولى عندهم لما يأتي:

أولاً: أن العمل بالرخصة وترك العزيمة إنما شرع لليسر، واليسر حاصل في العزيمة أيضاً، لما في ذلك من موافقة سائر المسلمين في صوم الشهر الكريم، لأن الصوم منفرداً فيه مشقة على النفس، كما أن الأخذ بالعزيمة موصل إلى ثواب لا يوجد في الرخصة، لأنه كلما كانت العبادة شاقة كان الثواب عليها أعظم، لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أفضل العبادات أحمرها"^(١) أي أشقها على النفس، وقوله للسيدة عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- "أجرك على قدر نصبك"^(٢) أي تعبك، فكلما لاقى المسلم مشقة ونصبا في العبادة كان أجره أعظم عند الله تعالى.

ثانياً: قيام السبب المحرم للفطر، الموجب للصوم، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٣).

لما سبق كان الأخذ بالعزيمة أولى عند الحنفية، على أنه لا يمكن أخذ هذا الكلام على إطلاقه، بمعنى: إن الأخذ بالعزيمة يكون أولى بشرط أن لا يتسبب الصوم في إضعاف الصائم - المسافر أو المريض - أما إذا كان الصوم يتسبب في إضعافه فالأخذ حينئذ بالرخصة أولى، وإلا كان آثماً، قاتلاً نفسه بسبب الصوم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٤) وقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ليس من البر الصيام في السفر"^(٥) وهذا محمول على حالة الخوف من الهلاك.

(١) راجع: كشف الخفاء للعجلوني ١٧٥/١ رقم ٤٥٩.

(٢) فتح الباري ٦١٠/٣ العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب.

(٣) سورة البقرة من الآية (١٨٥).

(٤) سورة البقرة من الآية (١٩٥).

(٥) فيض القدير للمناوي ٣٨١/٥ رقم (٧٦٦٧).

وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -: لما كان حكم الوجوب متأخرًا إلى إدراك عدة من أيام آخر، كان الفطر أفضل، أي أنه يقول: الأخذ بالرخصة أفضل^(١).

وبذلك نكون قد انتهينا من نوعي الرخصة الحقيقية، بقى لنا أن نذكر الفرق بينهما.

الفرق بين الرخصة الحقيقة الأحق، والرخصة الحقيقية التي ليست أحق.

يظهر الفرق واضحًا في الآتي:

١- أن النوع الأول استبيح مع قيام المحرم والحُرمة، والنوع الثاني استبيح مع قيام المحرم دون الحُرمة، فهما متفقان في الدليل المحرم، إذ هو موجود فيهما، مُختلفان في الحُرمة، إذ هي موجودة في الأول دون الثاني، وعلة ذلك: أن الدلائل المُحرمة للكُفر والموجبة للإيمان دلائل قطعية عقلية، والعلل العقلية لا يتصور تراخي المعلول - الحكم - عنها عقلاً وشرعاً، ولهذا كانت حُرمة الكُفر أبدية تقوم بقيامها وتدوم بدوامها.

بخلاف النوع الثاني، فعلة وجوب الصوم وحُرمة الإفطار شرعية، وهي شهود الشهر الذي جعله الله علة لوجوب الصوم وحُرمة الإفطار بقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٢) والعلل الشرعية أمارات وعلامات على الأحكام، فيجوز تراخي الحكم عنها^(٣).

٢- قولنا: إن النوع الأول أحق بكونه رخصة من النوع الثاني ذلك لأن في الثاني وجد السبب للصوم، وهو شهود الشهر، ولكن الحكم تراخي، وتراخي الحكم الذي هو الحُرمة يجعل هناك شبهة في أن تكون إباحة

(١) راجع: أصول السرخسي ١١٩/١؛ التوضيح مع التلويح ١٢٨/٢.

(٢) سورة البقرة من الآية (١٨٥).

(٣) راجع: مُذكرة د/ دياب ص ٢٨.

الإفطار حُكْمًا أصليًا، فصار رمضان في حق المسافر والمريض كأيام شعبان.

بخلاف النوع الأول، فإن قيام المحرم والحُرمة يجعل الحُرمة فيه هي الحُكم الأصلي، وينفي شبهة كون استباحة الكُفر حُكْمًا أصليًا، فيكون النوع الأول أحق بكونه رُخصة من الثاني^(١).

وبذلك يظهر الفرق بين نوعي الرُخصة الحقيقية ونشرع الآن في بيان نوعي الرُخصة المجازية.

النوع الثالث:

الرُخصة المجازية الأتم في المجازية أي أبعد من حقيقة الرُخصة من النوع الرابع، وهو ما وضع عنا من الإصر والأغلال، فالأصر هو الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك وضرب ذلك مثلاً لثقل تكلفهم وصعوبته، وذلك كاشتراط قتل النفس في صحة توبتهم، وكذا الأغلال مثل لما كانت في شرائعهم من الأشياء الشاقة، كجزم الحُكم بالقصاص عمداً كان القتل أو خطأ، وقطع الأعضاء الخاطئة، أو قرص موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم، وتحريم السبت، فروي أن بني إسرائيل كانوا إذا قاموا للصلاة لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم، وربما ثقب الرجل ترقوته، وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية ليحبس نفسه على العبادة^(٢) ومما كان عليهم من إصر وأغلال تحريم الطيبات بسبب الذنوب، وأن الطهارة من الجنابة والحدث لا تكون إلا بالماء، وكتابة الذنب للمذنب ليلاً على باب داره صباحاً، وكون الصلاة في اليوم الواحد خمسين صلاة وغير ذلك.

فهذه أمثلة لما كان على الأمم من قبلنا من الإصر والأغلال، ولم يشرع عندنا أصلاً تكريماً لنبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورحمة بناء فسقطت عنا،

(١) راجع: التوضيح ١٢٨/٢-١٢٩؛ مُذكرة د/ دياب ص٢٨.

(٢) راجع: كشف الأسرار ٣٢١/٢؛ التلويح ١٢٩/٢.

فمن حيث إنها كانت واجبة على غيرنا ولم تجب علينا توسعة وتخفيفاً، شابته الرخصة فسميت بها، لكن لما كان السبب معدوماً في حقنا، والحكم غير مشروع أصلاً، لم تكن حقيقة بل مجازاً، وفي كون الأصل لم يبق مشروعاً أصلاً دليل على صحة تسميته رخصة، وعلى كون مجازاً كاملاً لا حقيقة^(١).

النوع الرابع:

رخصة مجازية ليست أتم في المجازية: أي أقرب إلى حقيقة الرخصة من النوع الثالث، وهو ما سقط عنا مع كونه مشروعاً في الجملة، والمراد بدل ما سقط عنا، لأن الرخصة ليست في الساقط، بل في بدله الذي هو تخفيف عنه، فمن حيث إنه سقط كان مجازاً، لأن الحكم ساقط بسقوط السبب الموجب في محل الرخصة.

ومن حيث إنه بقي مشروعاً في الجملة، كان شبيهاً بحقيقة الرخصة من النوع الثالث، لأن الحكم لم يبق فيه أي النوع الثالث - أصلاً، فبعد عن الحقيقة، وقوله (ما سقط) يخرج به الرخصة الحقيقة بنوعيتها، لأن المحرم قائم فيهما، وقوله (مع كونه مشروعاً في الجملة) يخرج به النوع الثالث، لأنه غير مشروع في الجملة^(٢).

مثال هذا النوع: أكل الميتة وشرب الخمر حالة الاضرار، فقد سقطت حرمتها مع ثبوتها في الجملة، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ﴾^(٣) فقد استثنى حالة الاضرار من الحرمة، والكلام المقيد بحالة الاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى، وعليه فيثبت التحريم حالة الاختيار.

ولأن تحريم الخمر لصيانة العقل، وبعدم شرب الخمر تفوت النفس

(١) راجع: التلويح ١٢٩/٢؛ مذكرة د/ دياب ص ٢٩.

(٢) راجع: مذكرة د/ دياب ص ٣٠.

(٣) سورة الأنعام من الآية (١١٩).

والعقل معاً^(١).

فائدة:

اختلف العلماء في حكم الميتة والخمر والخنزير ونحوها في حالة الاضطرار، هل تصير مُباحة، أو تبقى على الحُرمة ويرتفع الإثم؟.

فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل، ولكن يرخص الفعل في حالة الاضطرار إبقاء للمهجة، كما في الإكراه على الكُفر وأكل مال الغير، وهو مروي عن أبي يوسف، وأحد قولي الشافعي.

وذهب أكثر علمائنا منهم فخر الإسلام، وصدر الشريعة إلى أن الحُرمة ترفع في هذه الحالة.

وفائدة الخلاف تظهر فيما يأتي:

١- إذا صبر حتى مات، فإنه لا يكون آثماً عند الفريق الأول، لأن الحُرمة باقية، ويكون آثماً عند الفريق الثاني، لأن الحُرمة ارتفعت وأصبحت مُباحة، والامتناع عن تناول المُباح حتى الهلاك إثم.

٢- إذا حلف لا يأكل حراماً، فتناول خمرًا أو خنزيرًا أو نحوهما في حالة الاضطرار، فإنه يحنث عند الفريق الأول، لبقاء الحُرمة، ولا يحنث عند الفريق الثاني لارتفاع الحُرمة، فهي مُباحة لا حرام^(٢).

ومثاله أيضاً سقوط وجوب التعيين في السلم، وذلك بما روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أنه رخص في السلم"^(٣) والسلم نوع بيع، واشترط العينية في المبيع المشروع قائم في الجملة، ثم سقط هذا الشرط في السلم أصلاً، فلم يبق التعيين في السلم عزيمة ولا مشروعاً، لأنه إنما يكون للعجز عن التسليم، فكان سقوط شرط العينية في السلم تيسيراً للمحتاجين حتى

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٢٩/٢-١٣٠؛ أصول السرخسي ١/١٢١.

(٢) راجع: كشف الأسرار ٢/٣٢٢-٣٢٣.

(٣) صحيح البخاري بشرح السندي ٣٠/٢، باب السلم في كيل معلوم.

يتوصلوا إلى مقصودهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم ويتوصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح، فلما كان التعيين مشروعاً في الجملة في بقية أنواع البيع، كان أقرب إلى حقيقة الرخصة من الثالث وأبعد في المجازية عنه^(١).

وسقوط التعيين في السلم لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث والناس يتعاملون به فأقهرهم عليه، وقال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"^(٢).

ومن أمثلته أيضاً قصر الصلاة في السفر، فهي رخصة إسقاط عند الحنفية، وذلك لسقوط وجوب الإتمام بسقوط موجبها، وبهذا كانت مجازاً، ومن حيث إنه مشروع في الجملة كان أقرب إلى الحقيقة.

وتوضيح ذلك: أن الرخصة قسمان: رخصة إسقاط ورخصة ترفيه، فرخصة الإسقاط متحقق فيها اليسر من كل النواحي، كما في قصر الصلاة، فيصلّي المسافر ركعتين بدلاً من أربع تيسيراً.

أما رخصة الترفيه ففيها يسر من ناحية ومشقة من ناحية أخرى، كإفطار المسافر في رمضان، فاليسر متحقق من جهة أن لا يجمع بين مشقة الصيام ومشقة السفر، والمشقة متحققة أيضاً من جهة أنه يصوم عدة من أيام آخر منفرداً عن المسلمين، وأيضاً اليسر بالنسبة للمسافر من جهة أنه يصوم مع عامة المسلمين وتتحقق المشقة من جهة أنه يجمع بين مشقة الصوم ومشقة السفر، فكان مخيراً بين الإفطار والصوم، والتخيير يفيد وبذلك يتبين الفرق بين النوع الرابع والنوع الثاني، وهناك فرق آخر، وهو أن المحرم في النوع الثاني قائم، وفي النوع الرابع معدوم.

وقصر الصلاة في السفر عند الحنفية من قبيل رخصة الإسقاط أي إسقاط محض لا يتوقف على قبول العبد، فقصر الرباعية عندهم عزيمة

(١) راجع: أصول السرخسي ١/١٢١؛ مذكّرة د/ دياب ص-٣٠.

(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وإطلاق اسم الرخصة عليه مجاز علاقته المشابهة، لأن الرخصة مخففة وكذلك صلاة الركعتين بدل الأربع، ومعنى أنه رخصة إسقاط أي ليس رخصة حقيقية، بل هو إسقاط للعزيمة وهي الأربع.

أما قصر الصلاة عند الشافعية فهي من قبيل رخصة الترفيه، والعزيمة هي الأربع، حتى لو فات الوقت يقضي أربعاً سواء قضاها في السفر أم الحضر، وفي قول آخر له: يقضي ركعتين في السفر دون الحضر^(١).

الأدلة:

استدل الشافعية على أن قصر صلاة المسافر من قبيل رخصة الترفيه بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾^(٢).

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلت على مشروعية القصر بلفظ الجناح، وهو يدل على أنه مباح لا واجب، إذ لفظ الجناح، للإباحة دون الوجوب، فكان المسافر مخيراً بين القصر والإكمال^(٣).

ثانياً: أن الوقت سبب للأربع، والسفر سبب للقصر، لا على رفع الأول وتغييره، فإنه لو اقتدى بمقيم صح ويلزمه الأربع ولو ارتفع لما لزمه، كمن يصلي الفجر إذا اقتدى بمن يصلي الظهر، فيعمل بأيهما شاء، إلا أن القصر سبب عارض، فما لم يعمل به لا يرتفع حكم الأصل، وهذا كالعبد إذا أذن له مولاه بالجمعة يتخير بين أن يؤدي الجمعة ركعتين وبين أن يؤدي الظهر أربعاً، فكذا المسافر يميل إلى أيهما شاء.

(١) راجع: كشف الأسرار ٢/٣٢٤؛ شرح ابن ملك ص ٦٠٠.

(٢) سورة النساء من الآية (١٠١).

(٣) راجع: مُغْنِي المحتاج للشربيني ١/٢٦٢.

واستدل الحنفية على أن قصر الصلاة المسافر رخصة إسقاط بما يأتي:

أولاً: ما روي عن علي بن ربيعة الوالبي قال: سألت عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ما بالناس نقصر الصلاة ولا نخاف شيئاً، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١)، فقال عمر: أشكل على ما أشكل عليك، فسألت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"^(٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن الإشارة في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذه ترجع إلى الصلاة المقصورة، أو إلى قصر الصلاة، والتأنيث باعتبار كون القصر صدقة، وقوله "فاقبلوا" معناه: اعملوا بها واعتقدوها كما يقال: فلان قبل الشرائع، والتصديق بما لا يحتمل التملك إسقاط لا يحتمل الرد ولو كان صادراً من العبد كالعفو عن القصاص من الولي^(٣)، وإذا كان هذا في حق العباد، فمن باب أولى أن يكون ذلك في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مفترض الطاعة، لا يمكن رد ما أوجبه وأثبتته، سواء كان لنا أم علينا، وذلك كالإرث فإنه تملك من الله تعالى إلى الوارث، فإذا قال العبد: لا أقبل، فإنه لا يعتبر قوله^(٤).

ثانياً: أن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقاً كما في كفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾^(٥)، وكذلك التخيير الثابت في جزاء الصيد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا

(١) سورة النساء من الآية (١٠١).

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣٣٧/٢، باب صلاة المسافرين وقصرها.

(٣) فإذا قال ولي الدم لمن عليه القصاص: تصدقت به عليك، سقط القصاص من غير قبول ممن عليه القصاص (راجع: كشف الأسرار ٣٢٥/٢).

(٤) راجع: التوضيح والتلويع ١٣٠/٢.

(٥) سورة المائدة من الآية (٩٥).

قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴿١﴾.

أما في قصر الصلاة فالرفق متعين، ولا خيار فيه، لأن القصر أيسر
من الإتمام، فصلاة الركعتين أخف من صلاة الأربع ^(٢).

اعترض على ذلك: بأن صلاة الأربع فيها مشقة تزيد الثواب، وصلاة
الركعتين فيها تخفيف في العمل ينقص الثواب، فحقه التخيير بين القصر
والإتمام، فيكون القصر رخصة ترفيه لا إسقاط.

الجواب: أن الثواب بصلاة أربع ركعات للمقيم هو نفس ثواب المصلي
ركعتين في السفر، إذ كل منهما عزيمة وأداء فرض، فهما متساويان، وليس
أحدهما أكمل ثواباً من الآخر، فالقصر متعين للرفق، والتقيد بالثواب
بأداء الفرض، لجواز أن يكون الإتمام أكثر ثواباً باعتبار كثرة القراءة
والأذكار، وطول الركوع والسجود، كالتخيير بين الأربع والشتين قبل العصر
وبعد العشاء، لأن الشتين أخف عملاً، والأربع أكثر ثواباً وأشق عملاً، فيثبت
التخيير ويعتبر ذلك رخصة ترفيه بخلاف القصر والإتمام، فإنهما
متساويان في الثواب الحاصل بأداء الفرض فلا فائدة من التخيير ^(٣).

تنبيه: التعليق بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط.

ذهب صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أن التعليق بالشرط لا يدل على
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وقد استدل على ذلك بما يأتي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ^(٤)، ففي الآية الكريمة
تعليق القصر على الخوف حيث قال: "إن خفتم" وقد استمر القصر بعد

(١) سورة المائدة من الآية (٩٥).

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٠/٢.

(٣) راجع: التلويح ١٣٠/٢-١٣١؛ مذكرة د/ دياب ص٤٤.

(٤) سورة النساء من الآية (١٠١).

زوال الخوف بفعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفعل الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ومن بعدهم، فقد قصرُوا الصلاة في السفر ولو كان التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحُكم عند انتفاء الشرط لما قصرُوا الصلاة حال الأَمْن وزوال الخوف ولكنهم فعلوا، فدل ذلك على أن التعليق بالشرط لا يدل على انتفاء الحُكم عند انتفاء الشرط.

ورد على هذا الدليل: بأن القول بمفهوم الشرط إنما يكون إذا لم تظهر فائدة أخرى، مثل الخروج مخرج الغالب، كما في هذه الآية، فإن الغالب من أحوالهم في ذلك الوقت كان الخوف وكذا قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾^(١) فإن الغالب أن الإنسان إنما يكتب العبد إذا علم فيه خيراً^(٢).

٢- سؤال عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقوله "ما لنا نقصر وقد أَمنا"، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن هذه صدقة.....".

وتوجيه ذلك: أنه لو كان التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحُكم عند انتفاء الشرط، لفهم عمر ذلك ولم يسأل، لأن عمر من أرباب الفصاحة والبلاغة.

ورد على هذا الدليل: بأن سؤال عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عنه كان بناء على اعتقاده استصحاب وجوب الإتمام، لا على أنه مفهوم من التقييد بالشرط. كما أنه يجوز أن يكون سؤال عمر بناء على وقوع العمل على خلاف ما فهمه، كما يشعر به سياق القصة^(٣).

وذهب فخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - إلى أن انتفاء الحُكم بانتفاء الشرط لازم البته وإن لم يكن مدلول اللفظ، وإلا كان التقييد بالشرط لغوًا، وأن في آية الكتابة المعلق بالشرط هو استحباب - الكتابة،

(١) سورة النور من الآية (٣٣) .

(٢) راجع: التلويح ١٣٠/٢.

(٣) راجع: التلويح ١٧٠/٢.

وهو منتف عند عدم الخير في المكاتب، وفي آية القصر المراد قصر الأحوال، كالإيجاز في القراءة والتخفيف في الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء.

وما ذهب إليه فخر الإسلام ضعفه صاحب التلويح، فذكر أن قصر الصلاة ليس المراد منه قصر الأحوال، لأن الأئمة كالمجمعين على أن الآية في قصر أجزاء الصلاة^(١).

هذا وقد ترتب على ذلك اختلاف العلماء في المُعتبر حالة القصر، هل المُعتبر في قصر الصلاة هو الخوف، أم أن المُعتبر هو حال القوم من حضر وسفر؟.

فذهب بعض العلماء إلى أن المُعتبر في ذلك هو الخوف فالمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط ومن ثم فلا قصر طالما لم يتحقق شرط الخوف، وروى هذا المذهب عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فقد كان يقول: صلاة المقيم أربع ركعات وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة واحدة، وبه أخذ بعض العلماء، فانتقصت عدد الركعات بسبب الخوف، واحتج لذلك بأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في غزوة ذات الرقاع بكل طائفة ركعة، فكانت له ركعتان، ولكل طائفة ركعة.

أما علماء الحنفية: فإن الخوف عندهم لا يكون سبباً في انتقاص عدد الركعات فيصلي بهم الإمام ركعتين إن كانوا مسافرين، أو كانت الصلاة من ذوات الركعتين كالفجر، وإن كانت الصلاة من ذوات الأربع أو الثلاث وكانوا مقيمين، صلى بهم الإمام أربعاً أو ثلاثاً، ولا ينتقص عدد الركعات بسبب الخوف، وهو قول عامة الصحابة والمالكية والشافعية.

واحتجوا لذلك: بما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة - رضوان الله عليهم - أن صلاة الرسول كانت كذلك، أي: لا ينتقصها بسبب

(١) المرجع السابق.

الخوف وكذلك فعل الصحابة، فيكون إجماعاً منهم^(١).

وبالجُملة: فإن المُعتبر فيما ورد عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - هو حالة الخوف، فإن تحقق الخوف قصرت الصلاة أخذاً بظاهر الآية، إذ القصر مشروط بالخوف، وهذا يوافق ما ذهب إليه فخر الإسلام.

والمُعتبر فيما ورد عن الحنفية والمالكية والشافعية الجمهور - هو حال القوم من حضر أو سفر، فيصلون صلاة كاملة إذا كانوا مقيمين، ويقصرون الصلاة إذا كانوا مسافرين، فلا عبرة بالخوف عندهم، لتحقيق القصر بدونه وظاهر هذا المذهب يوافق ما ذهب إليه صدر الشريعة من أن التعليق بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط، بمعنى أنه يمكن أن يوجد الحكم - القصر - ولا يوجد الشرط - الخوف - بدليل صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه قصرًا حالة السفر، وتاماً حالة الإقامة، بغض النظر عن وجود الخوف أو عدمه.

وهذا المذهب هو الراجح فتصلي الصلاة قصرًا حالة السفر وإن لم يتحقق الخوف، وهو ما عليه الجمهور.

والقاعدة التي ذكرها صدر الشريعة: من أن انتفاء الشرط لا يلزم منه انتفاء الحكم لا يمكن أخذها على إطلاقها، فهذه القاعدة تتماشى مع آية القصر لأن الشرط وهو الخوف انتفى ومع ذلك وجد الحكم، وهو القصر، ولا تتماشى مع أحكام آخر، كوجوب الإنفاق على المطلقة الحامل مثلاً في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٢) فيجب الإنفاق حالة الحمل، ولا يجب حالة عدمه، فهنا إذا انتفى الشرط وهو الحمل، انتفى الحكم وهو وجوب الإنفاق، وإذا وجد الشرط وجد الحكم.

(١) راجع: الوافي للسغناقي في رسالتنا "الدكتوراه ص ٥٩٣ ومعها؛ بدائع الصنائع ٢٤٣/١؛

أقرب المسالك ١٩٨/١؛ المنهاج بشرح المحلى ٢٩٩/١.

(٢) سورة الطلاق من الآية (٦).

ومن ثم فالقاعدة التي ذكرها صدر الشريعة ليست مطردة ولعله ذكرها بناء على مذهب الحنفية، وهو أن مفهوم الشرط ليس بحجة، لأن القول بأنه حُجة - كما قال الشافعية - يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فجاء صدر الشريعة بهذه القاعدة ليخالف مذهب الشافعية بحُجية مفهوم الشرط، ويوافق مذهب الحنفية بعدم حُجيته.

وبذلك نكون قد انتهينا من مُباحث الحكم التكليفي، ونشرع الآن في بيان مُباحث الحكم التعليقي-الوضعي.

الأسئلة

- س١: عرف الرخصة لغة واصطلاحاً، ثم اذكر أقسامها مع بيان وجه الحصر في تلك الأقسام.
- س٢: للرخصة أقسام، اذكرها بالتفصيل والتمثيل.
- س٣: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل: (رخصة حقيقية أحق بكونها رخصة - رخصة حقيقية ليست أحق - رخصة مجازية أتم في المجازية - رخصة مجازية ليست أتم في المجازية).

الحكم التعليقي (الوضعي)

سبق أن ذكرنا أن الحكم قسمان: تكليفي ووضعي، وقد ذكرنا التكليفي بأقسامه، فبقى لنا أن نذكر الوضعي وأقسامه، فنقول:

تعريف الحكم التعليقي: هو ما يكون حكمًا بتعلق شئ بشئ آخر تعلقًا زائدًا، والمراد بالزائد أي زائدًا عن التعلقات الضرورية: الثلاثة (الحاكم - المحكوم فيه - المحكوم عليه)، وقوله (زائدًا) يخرج جميع أقسام الحكم التكليفي، لأن التعلق فيه غير زائد.

أقسامه:

سبقت الإشارة إلى أن الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام: الركن، والعلة، والسبب، والشرط، والعلامة.

وجه الحصر: أن الشيء المتعلق إن كان داخلًا في حقيقة الآخر فهو الركن، كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، وإن كان غير داخل وكان مؤثرًا فيه فهو العلة، كشهود الشهر في الصوم، وإن كان غير مؤثر لكنه موصل إليه في الجملة فهو السبب، كالدلوك بالنسبة للصلاة، وإن كان غير موصل لكنه توقف عليه وجوده فهو الشرط، كالطهارة للصلاة، فإن لم يكن شيئًا مما تقدم فلا أقل من أن يدل عليه، وهو العلامة كالأذان للصلاة، وكالخلوة بالأجنبية قياسًا على الخلوة الصحيحة في النكاح، بجامع مطلق الخلوة، على ما سيأتي تفصيله^(١).

والمراد: بتأثير الشئ المذكور في وجه الحصر هو: اعتبار الشارع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشئ الآخر، ولا يُراد به الإيجاد كما هو الحال في العلل العقلية.

ويُلاحظ أن العمدة في مثل هذه التقسيمات هو الاستقراء، والمذكور في وجه الانحصار إنما هو مجرد الضبط، وإلا فالمانع وارد على التقسيم

(١) راجع: التوضيح والتلويع ١٣٠/٢-١٣١؛ مذكرة د/ دياب ص ٣٧.

لجواز التعلق بوجوه آخر مثل المانعية، كتعلق النجاسة بصحة الصلاة^(١).

وبعد ذكر وجه الحصر نشرع في بيان الأقسام تفصيلاً.

أولاً: الركن:

تعريفه لغة: هو الجانب الأقوى والسند، ومنه قوله تعالى على لسان سيدنا لوط - عَلَيْهِ السَّلَام - قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ^(٢).

تعريفه اصطلاحاً: هو الشئ المتعلق تعلقاً زائداً وهو داخل فيه، فقوله (المتعلق تعلقاً زائداً) يُخرج الحكم التكليفي، وقوله (وهو داخل فيه) يخرج بقية أقسام الحكم التعليقي.

وذكر صدر الشريعة له تعريفاً آخر، وهو: ما يقوم به الشئ.

واعترض على هذا التعريف بأنه تعريف بالأخفى، وكذا غير مانع لدخول الجوهر فيه، لأن الجوهر يقوم به العرض.

والجواب عن هذا الاعتراض: أن (ما) واقعة على الداخل، فلا يشمل الجوهر، أو يقرأ بتشديد الواو أي ما يقوم به، فيكون المعنى: ما يدخل في قوام الشئ.

وسبب ذكر صدر الشريعة لهذا التعريف الثاني: أنه أراد التمهيد لذكر تشنيع بعض الناس على الحنفية والجواب عنه ونبين ذلك فيما يلي:

قال بعض الحنفية: الإقرار ركن زائد، والتصديق ركن أصلي، فشنع عليهم بعض الناس.

وجه التشنيع: أن تقسيم الحنفية للركن إلى أصلي، كالاعتقاد في الإيمان وإلى غير أصلي (زائد)، كالإقرار باللسان في الإيمان بعد تعريفهم للركن بما يكون داخلاً في الشئ يستلزم أن يكون ركناً وغير ركن، لأن

(١) التلويح ١٣١/٢.

(٢) سورة هود من الآية (٨٠) ؛ وراجع: القاموس المحيط ٢٢٩/٤ فصل الرأء باب النون.

الركن داخل والزائد خارج فيكون داخلاً وغير داخل، فإذا كان الإقرار ركنًا في الإيمان يلزم من انتفائه انتفاء المركب، كما ينتفي العشرة بانتفاء الواحد^(١).

الجواب عن هذا التشنيع: لا نسلم أن مُراد الحنفية بالزائد: الخارج عن الشئ، بحيث لا ينتفي بانتفائه، لأن معنى الزائد: ما لا ينتفي بانتفائه حكم الشئ، فالرُّكن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى لا ينتفي حكم الشئ، بل يكون موجوداً حُكمًا، بحسب اعتبار الشارع، وهذا إذا كان الجزء ضعيفًا، فإنه يكون شبيهًا بالأمر الخارج، فيُسمى زائدًا بهذا الاعتبار، فمثلاً إذا عدم الإقرار في الإيمان لخرس أو إكراه، فهذه ضرورة، فاعتبر عدم الإقرار معفوًا عنه ويكون الإيمان موجوداً حُكمًا.

وكذلك وجود النية في صوم رمضان قبل الضحوة الكبرى، وكذا إذا كان أكثر الثوب طاهرًا وأقله نجسًا، كربعه، فإنه يصلي فيه إذا لم يجد ثوبًا طاهرًا.

ضعف الجزء إما بحسب الكيفية كالإقرار في الإيمان، أو بحسب الكمية كالأقل في المركب منه ومن الأكثر، ولهذا قيل: للأكثر حكم الكل. ومثل ذلك: أعضاء الإنسان، فاليد ركن لا ينتفي الإنسان بانتفائها، والرأس ركن ينتفي بانتفائها، فلا تبقى الحياة وتوابعها، وتبقى بانتفاء الأول.

ويمكن أن يُقال في توجيه الركن الزائد: إن بعض الشرائط والأمور الخارجية قد يكون له زيادة تعلق واعتبار في الشئ، بحيث يصير بمنزلة جزء له، فيُسمى ركنًا مجازًا، فالحاصل أن لفظ الزائد أو لفظ الركن مجاز، والجواب الأول أصوب وأوفق^(٢).

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣١/٢.

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٣١/٢؛ مُذكرة د/ دياب ص ٣٨.

وليس من هذا القبيل جعل الأعمال داخلة في الإيمان على ما نقل عن الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، لأنه إنما يجعلها داخلة في الإيمان على وجه الكمال، لا في حقيقة الإيمان.

وأما عند المعتزلة: فهي داخلة في حقيقته، حتى إن الفاسق لا يكون مؤمناً.

واعلم: أن ما سبق ذكره من كون الإقرار ركناً زائداً في الإيمان هو مذهب الإمام فخر الإسلام البزدوي، والسرخسي.

وقال أكثر الحنفية: الإيمان هو التصديق القلبي، والإقرار شرط لا جزء^(١).

ثانياً: العلة:

تعريفها لغة: هي المغير، ومنه سمي المرض علة، لأنه يغير حال الإنسان من الصحة إلى السقم^(٢).

تعريفها اصطلاحاً: هي الوصف الخارج المؤثر، والمناسبة ظاهرة، لأن الوصف يؤثر في الحكم ويغيره من العدم إلى الوجود والعكس.

فقوله (الوصف) جنس في التعريف يشمل العلة وغيرها، وقوله (الخارج) قيد خرج به الركن، لأنه وصف داخل في الشئ لا خارج كما سبق، وقوله (المؤثر) قيد خرج به السبب والشرط والعلامة، فهي أوصاف غير مؤثرة.

وقال المعتزلة في تعريفها: هي الوصف المؤثر في الحكم بذاته، وهو باطل؛ لأن التأثير إنما يكون بجعل الشارع، لا بذات الوصف وتعريفهم هذا بناء على مذهبهم، من أن العقل يدرك في الأفعال حساً وقبلاً، وأن الأحكام تكون تابعة لما أدركه العقل في ذلك الفعل، فإن أدرك العقل في

(١) راجع: مُذكرة د/ دياب ص ٣٨.

(٢) راجع: أصول السرخسي ٣٠١/٢.

الفعل حسناً كان واجباً أو مندوباً، وإن أدرك فيه قبحاً كان مُحَرَّمًا أو مكروهًا، وإن لم يدرك في الفعل شيئاً - لا حسناً ولا قبحاً - كان مُباحاً.

وقال الإمام الغزالي - رَحِمَهُ اللهُ - في تعريفها: هي الوصف المؤثر في الحُكم لا بذاته بل بجعل الشارع.

ولفظ العلة يشمل العلل الوصفية التي جعلها الشارع عللاً، كالبيع علة للملك شرعاً، والنكاح علة للحل شرعاً، والأوقات للعبادة شرعاً، والقتل العمد علة لوجوب القصاص شرعاً، باعتبار أن الشرع جعلها موجبة لهذه الأحكام، والعلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها، لأنه لا موجب إلا الله تعالى، إلا أن ذلك الإيجاب غيب عنا، فجعل الشرع الأسباب التي يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحُكم في حقنا للتيسير علينا، فأما في حق الشرع فهذه العلل لا تكون موجبة شيئاً، وهو نظير الإمامة، فإن المميت والمحيي هو الله تعالى حقيقة، ثم جعله مضافاً إلى القاتل بعله القتل فيما ينبني عليه من الأحكام، وكذلك أجزية الأعمال فإن المعطي للجزاء هو الله تعالى بفضله، ثم جعل ذلك مضافاً إلى عمل العامل بقوله تعالى ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١).

فتبين من ذلك أن التأثير في العلل الشرعية ليس ذاتياً، بمعنى أن ذات العلة - الوصف - لا تأثير له، وإنما المؤثر في الحقيقة هو الشارع، مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة في تعريفهم للعلة، وأن تعريف الغزالي وجمهور الحنفية هو الراجح والأصوب.

وكما يشمل لفظ العلة العلل الشرعية، يشمل كذلك العلل المستنبطة بالاجتهاد، كالمعاني المؤثرة في القياس.

أقسام العلة:

العلة باعتبار ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أو بالمجاز سبعة أقسام، أما حقيقة العلة فهي واحدة؛ لأن الأصوليين اعتبروا في الوصف

(١) سورة الواقعة الآية (٢٤)؛ وراجع: أصول السرخسي ٣٠٢/٢.

الذي يكون علة حقيقية ثلاثة أمور:

الأول: أن يضاف الحكم إلى الوصف، أي يترتب الحكم على الوصف، كما يقال: عتق بالشرء، أو ملك المبيع بالبيع، أو هلك بالجرح، وهذا يُسمى علة اسماً.

الثاني: أن يكون الوصف مؤثراً في الحكم، أي يوجد الحكم بالوصف، كتأثير صيغ البيع - الإيجاب والقبول - في ثبوت الملك، وهذا يُسمى علة معنى.

الثالث: حصول الحكم بالوصف من غير تراخٍ عنه في الزمان وتسمى هذه علة حكماً.

فإن وجدت هذه الأمور الثلاثة (الإضافة - التأثير - المقارنة) كانت العلة حقيقية تامة، وتسمى علة اسماً ومعنى وحكماً، وإن وجد واحد من الثلاثة السابقة تحصل ثلاثة أقسام: العلة معنى، والعلة اسماً، والعلة حكماً.

وإن اجتمع اثنان يتحصل ثلاثة أيضاً، فإذا اجتمع التأثير والإضافة فقط كانت العلة اسماً ومعنى لا حكماً، وإن اجتمع التأثير والمقارنة كانت العلة معنى وحكماً لا اسماً، وإذا اجتمع الإضافة والمقارنة كانت العلة اسماً وحكماً، فصارت الأقسام سبعة^(١)، وإليك بيانها تفصيلاً:

أولاً: العلة اسماً ومعنى وحكماً: وهي التي يضاف الحكم إليها، وتؤثر فيه، ولا يتراخي عنها.

مثالها: البيع المطلق للملك، أي البيع البات الخالي عن شرط الخيار، فإنه يثبت به الملك، فهو علة اسماً، لأن الملك يضاف إلى البيع، يقال: ملك المبيع بالبيع، وهو علة معنى كذلك، لأن صيغة العقد الإيجاب والقبول - مؤثرة في ثبوت الملك، وعلة حكماً أيضاً، لأنه يترتب الملك على البيع دون تراخٍ.

(١) راجع: التلويح ١٣١/٢؛ أصول السرخسي ٣١٢/٢.

ومثالها أيضاً: النكاح للحل، فهو علة اسمًا، لأن الحل يضاف إلى النكاح، يُقال حلت المرأة بالنكاح، وهو علة معنى كذلك، لأن صيغة العقد- الإيجاب والقبول - تؤثر في ثبوت الحل، وعلة حكمًا أيضًا، لأنه بمجرد صدور صيغة العقد الصحيح يثبت الحل بدون تراخٍ في الزمن.

ومن الأمثلة أيضًا لهذا القسم: القتل العمد للقصاص، والتطليق لوقوع الطلاق، والإعتاق لثبوت الحرية.

فهذه أمثلة للعة اسمًا ومعنى وحكمًا، وتوجيه تلك الأمثلة كما سبق في توجيه المثالين الأولين.

فكل واحد من هذه الأمثلة علة اسمًا من حيث إنه موضوع لأجل هذا الموجب، وأن هذا الموجب مضاف إليه بغير واسطة، وعلة معنى من حيث إنه مشروع لأجل هذا الموجب، وعلة حكمًا من حيث إن هذا الحكم يثبت به ولا يجوز أن يتراخى عنه، فكان علة حقيقية^(١).

هل العلة مقارنة لمعلولها؟

قبل أن نجيب عن هذا السؤال، ينبغي الإشارة إلى أن العلة نوعان علة عقلية، وعلة شرعية.

أما العلة العقلية: فلا خلاف بين العلماء في أنها مقارنة لمعلولها بالزمان، كحركة الإصبع تقارن حركة الخاتم، وفعل التحرك يقارن صيرورة الفاعل متحركًا، والكسر يقارن الانكسار والاستطاعة تقارن الفعل، إذ لو لم يكن المعلول مقارنة للعة العقلية لزم وجود المعلول بلا علة، وهو فاسد.

وكذلك لا خلاف بين العلماء في تقدم العلة على المعلول بمعنى احتياج المعلول إليها، وهو التقدم بالذات.

وأما العلة الشرعية، فقد انقسم العلماء إلى فريقين:

(١) راجع: أصول السرخسي ٣١٢/٢؛ كشف الأسرار ١٨٧/٤.

فريق يرى: أن العلة الشرعية كالعلة العقلية، فتجب المقارنة بين العلة ومعلولها، لأنها لو لم تقارن معلولها لجاز تخلف الحكم عن علته، ولو جاز لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم، وهذا مبطل لغرض الشارع من وضع العلة للأحكام، لأن غرضه إثبات الأحكام بثبوت عللها، وهو مذهب الجمهور.

واستدل هذا الفريق: بأن الأصل اتفاق العقل والشرع، فتكون العلة الشرعية كالعقلية.

وذهب بعض الحنفية: كأبي بكر محمد بن الفضل - رَحِمَهُ اللهُ - إلى التفرقة بين الشرعية والعقلية، فجوز في الشرعية تأخر الحكم عنها، بخلاف العقلية.

واستدلوا على ذلك: بأن العلة لا توجب الحكم إلا بعد وجوده، فيثبت عليتها، فيلزم تقدمها، بزمان، وهو الفاصل بين تحققها وترتب الحكم عليها، وإذا جاز بزمان جاز بزمانين، بخلاف العقلية كالاستطاعة مع الفعل، فالاستطاعة عرض لا يبقى زمانين، فتلزم المقارنة وإلا لوجد الحكم بدون العلة، أو خلو العلة من المعلول.

أما الشرعية فموصوفة بالبقاء، لأنها في حكم الجواهر والأعيان، بدليل قبولها الفسخ بعد أزيمة متطاولة، كفسخ البيع والإجارة والرهن والسلم وغيرها، فهذه العقود يجوز فسخها بعد أزيمة طويلة، لو لم يكن لها بقاء شرعي لما تصور فسخها بعد مدة، وإذا كان كذلك لا يلزم من تأخر الحكم عنها ما لزم في الاستطاعة^(١).

ويرد على ذلك: بأنه ثبت بالدليل مقارنة العلة العقلية معلولها ومقارنة الاستطاعة الفعل، والأصل اتفاق الشرع والعقل، فوجب أن تكون العلة الشرعية مقارنة لحكمها أيضاً.

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٢/٢.

وأيضاً علل الشرع أعراض في الحقيقة، فكانت كالأستطاعة في عدم قبول البقاء، والقول بأنها موصوفة. بالبقاء غير مسلم، لأن كثيراً من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بقاء للعقود الشرعية، لأن العقد كلامه مخلوق لا بقاء له حقيقة^(١).

والراجع:

أنه لا يجوز تأخر الحكم عن العلة، ولكن الحكم يتصل بثبوته بوجود هذه العلة بعد صحتها لا محالة، فيكون بذلك بمنزلة العلة العقلية، إذ أنها تقارن المعلول، كالأستطاعة مع الفعل، حيث لا يجوز القول بأنها تسبق الفعل، فترجح بذلك ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن العلة الشرعية كالعقلية في مقارنتها للمعلول^(٢).

فائدة:

سبق أن المراد في العلة معنى أن تكون مؤثرة في الحكم، ومعنى التأثير: اعتبار الشارع له بحسب نوع الحكم أو جنسه القريب وليس المراد الإيجاد الحقيقي، لأن موجد الحكم هو الله تعالى، ولكن لما كان إيجاب الله تعالى غيباً عنا ونحن عاجزون عن إدراكه، شرع لهم العلة ليتمكنهم الوقوف عليها، وجعلها موجبات للأحكام في حق العمل، فهي - العلة موجبة للأحكام في الظاهر بجعل الله تعالى لها موجبات لا بذاتها، وهي في حق صاحب الشرع علامات لعباده على الإيجاب.

وقد سبق ذلك في تعريف العلة أنها وصف مؤثر في الحكم لا بذاته، بل بجعل الله تعالى، لذا أبطل الجمهور تعريف المعتزلة للعلة بأنها وصف مؤثر بذاته.

تشارك العلة مع السبب في الإيماء والملائمة والمناسبة بينهما وبين

(١) راجع: التلويح ١٣٢/٢؛ كشف الأسرار ١٨٧/٤-١٨٨.

(٢) راجع: أصول السرخسي ٣١٣/٢.

الحكم، ويفترقان في أن السبب قد يتأخر عنه الحكم، وقد يتخلف الحكم عن السبب أما العلة فلا يتصور تأخر الحكم أو تخلفه عنها^(١).

ثانيًا. العلة اسمًا فقط: لا معنى ولا حكمًا، وهي أن يضاف الحكم إلى العلة من غير تأثير ولا مقارنة، فباعتبار الإضافة تكون علة اسمًا، وإذا ثبت الحكم يضاف إليها بلا واسطة، وبانتفاء التأثير ينتفي كونها علة معنى، وبانتفاء المقارنة ينتفي كونها علة حكمًا.

مثالها: كل إيجاب معلق بالشرط، ولتوضيح ذلك نذكر بعض الأمثلة: -

١- قول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذه الصيغة بالنسبة لوقوع الطلاق علة اسمًا، لأن الحكم وهو الوقوع بعد تحقق الشرط يضاف إلى التطليق السابق التلفظ به في الصيغة عند المتكلم بها، وليس علة معنى لأن التعليق يمنع انعقاد العلة في الحال، وإذا لم تكن منعقدة لا تكون مؤثرة في الحكم قبل وجود الشرط، وهي ليست علة حكمًا، لأن وقوع الطلاق يتراخي إلى زمان وجود الشرط.

٢- بيع الحر: فإنه علة اسمًا، لوجود صورة الإيجاب والقبول وليس معنى ولا حكمًا، لعدم التأثير والحكم.

٣- قول السيد لعبده: إن فعلت كذا فأنت حر، توجيهه كما سبق في المثال الأول.

٤- اليمين للكفارة قبل الحنث: فهو علة اسمًا لأن الكفارة تضاف إلى اليمين، وليس علة معنى، لعدم التأثير، ولا علة حكمًا، لأن الكفارة تتراخي إلى وقت الحنث، وذلك بأن العلة معنى وحكمًا، ما يكون ثبوت الحكم عند تقريره لا عند ارتفاعه، وبعد الحنث لا تبقى اليمين بل ترتفع وكذلك بعد وجود الشرط في اليمين بالطلاق والعتاق لا يبقى اليمين^(٢).

(١) راجع: التلويح ١٣١/٢؛ مذكرة د/ دياب ص٤٢.

(٢) راجع: أصول السرخسي ٣١٣/٢؛ كشف الأسرار ١٨٩/٤؛ التلويح ١٣٢/٢.

ثالثاً: العلة اسماً ومعنى: لا حُكماً، وهي ما أضيف الحُكم إليها، وتكون مؤثرة فيه، ولكنه يتراخى عنها، وهي قسمان:

قسم لا يشبه السبب، وقسم يشبه السبب:

والفرق بينهما:

أنهما وإن اتفقا في أن الحُكم فيهما مُتراخٍ عن العلة، لكنهما يفترقان في أنه إذا كان ثبوت الحُكم مستنداً إلى وقت حصول العقد، فهو القسم الأول (لا يشبه السبب)، وإذا كان ثبوت الحُكم مقتصرًا على وقت زوال المانع، فهو القسم الثاني (يشبه السبب) وإليك أمثلة لكل قسم:

أمثلة القسم الأول:

١- البيع الموقوف، كأن يكون صادرًا من فضولي فهذا البيع منعقد، ولكنه موقوف على إجازة المالك فكان علة اسمًا ومعنى لا حُكماً، ولا يشبه السبب.

أما كونه علة اسمًا، فلأن الملك يضاف إليه، وأما كونه علة معنى، فلتأثيره في الملك، لثبوت الملك به، وليس علة حُكماً، لأن الحُكم - الملك - مُتراخٍ عن العقد إلى حصول الإجازة من المالك، وهو لا يشبه السبب، لأن السبب الحقيقي ما توسط بينه وبين الحُكم علة، فالحكم في السبب مُتراخٍ إلى زمان وجود العلة.

فهنا وإن تراخى الملك عن العقد، إلا أنه عند الإجازة يثبت مُستنداً إلى وقت الإيجاب، وهو العقد، لا مقتصرًا على وقت الإجازة، كأنه لا يتخلل بين العقد والملك فلا يشبه السبب في التخلل.

ويدل على ثبوت الملك مستنداً إلى العقد: أن زوائد المبيع سواء كانت متصلة كالسمن أم منفصلة كالثمرة والولد تكون للمشتري لا للبائع.

٢ - البيع بشرط الخيار: فهو بالنسبة إلى الملك علة اسمًا ومعنى لا حُكماً

ولا يشبه السبب، وتوجيهه كما في المثال السابق^(١).

أمثلة القسم الثاني (ما يشبه السبب):

١- الإجارة: فإن عقد الإجارة على ملك المنفعة علة اسمًا، لأنه يضاف إليه، وهو علة معنى كذلك، لأن صيغة العقد مؤثرة في ملك المنفعة، ولهذا التأثير صح تعجيل الأجرة، ولو لم يوجد التأثير ما صح التعجيل، لأن الحكم لا يتقدم على العلة، ولذلك فإنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث عند الحنفية، لأن علة الكفارة في اليمين الحنث، فلا يجوز تقديم الكفارة - الحكم - على الحنث - العلة - لأن المعلول يثبت بعد ثبوت علته وليست الإجارة علة حكمًا، لوجود الفاصل، فإنه إذا أضاف إلى المستقبل صريحًا، بأن يقال: أجرتك هذه الدار من وقت كذا، فقد وجد الفاصل حقيقة، ولو لم يضاف باعتبار تجدد المنافع شيئًا فشيئًا يوجد الفاصل.

والإجارة تشبه الأسباب، لما فيها من الإضافة إلى وقت مستقبل سواء ذكر أو لم يُذكر، فإذا قيل في "بعضها": أجرتك الدار في رمضان يثبت الحكم - الإجارة - في رمضان لا في رجب، فقد تخلل بين عقد الإجارة وبين ملك المنفعة زمن، فيشبه الأسباب لوجود التخلل، بخلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار، فإنه لا تخلل لثبوت الملك مستندًا إلى العقد، وكذلك إذا لم يصرح بالإضافة إلى المستقبل كقوله أجرتك الدار الآن، لأن الإجارة نفسها متضمنة للإضافة إلى المستقبل تقديرًا، بدليل أن التصريح بالإضافة لا يبطلها، أما البيع فإن الإضافة تبطله، لكونه غير متضمن لها، فلا يصح بعثك الدار في رمضان.

٢- كل إيجاب مضاف إلى المستقبل: كقول الرجل لامرأته: أنت طالق الشهر القادم، أو قول السيد لعبده: أنت حر بعد شهرين، فهو علة اسمًا، لإضافة الحكم (الطلاق أو العتاق) إليه، وهو علة معنى أيضًا

(١) راجع: أصول السرخسي ٢/٣١٣-٣١٤.

لتأثيره في وقوع الطلاق وحصول العتق، وليس علة حُكماً، لأن وقوع الطلاق أو حصول العتق مُتراخٍ عن التكلم.

وهو يشبه السبب، لتخلل الزمان بين الكلام ووجود الحكم.

٣- ملك النِصاب: فإنه علة لوجوب الزكاة اسماً ومعنى لا حُكماً، وهو يشبه السبب، أما كونها علة اسماً، فلاضافة الحُكم إليه، فيقال: وجبت الزكاة بملك النِصاب، أما كونها علة معنى فلان ملك النِصاب مؤثر في الوجوب، لأن الغنى يوجب مواساة الفقراء، ولهذا صح الأداء قبل حولان الحول، ولو لم يكن مؤثراً لما صح التعجيز لأنه يكون تقديماً للحُكم على العلة، فإذا تم الحول والنِصاب كامل، فقد صار المؤدى زكاة، لاستيفاء الوصف إلى أول الحول، ولو لم يكن كاملاً كان المؤدى تطوعاً.

وقال الشافعية: النِصاب قبل الحول علة تامة لوجوب الزكاة، والحول وقت آخر المطالبة من صاحب المال تيسيراً، فيصح التعجيل قبل الحول عندهم.

وليس النِصاب علة حُكماً لوجود التراخي بين العلة - النِصاب - وبين الحُكم - وجوب الزكاة^(١).

وكون النِصاب علة تشبه السبب، فلأن النماء متخلل بين ملك النِصاب والوجوب، فإذا حدد وصف النماء يتعين صفة النِصاب من العلية أو السببية أو علة العلة، للتوسط بين النِصاب والوجوب، فلو كان النماء علة حقيقية كان النِصاب سبباً حقيقياً، لأن السبب الحقيقي ما توسط بينه وبين الحُكم علة حقيقية، لكن النماء ليس علة حقيقية مستقلة، لأنه وصف تابع للمال، قائم به.

ولأنه - أي النماء - لو كان علة أو جزء علة لما صح أداء الزكاة قبله،

(١) راجع: التوضيح والتلويع ١٢/٢-١٣٤

لأنه لا يجوز تقديم الحكم على العلة، والأداء قبله صحيح، فإذا لم يكن النماء علة لم يكن النصاب سبباً حقيقياً.

٤- مرض الموت: فإنه علة للحجر على التصرفات التي يتعلق بها حق الورثة من الهبة والصدقة وغيرها، ومرض الموت علة اسماً لإضافة الحكم - الحجر - إليه، وهو علة معنى، لتأثير المرض في الحجر، وليس علة حكماً، للتراخي إلى الاتصال بالموت.

وهو يشبه السبب للتخلل بين مرض الموت وبين الحجر.

٥- الجرح أو الرمي بالسهم: علة اسماً ومعنى لا حكماً، أما اسماً فلاضافة الموت إليه، وأما معنى فلتأثير الرمي في الموت، وأما كون الجرح ليس علة حكماً، فلأن الحكم يتراخى إلى نفوذ السهم في المرمى أو سراية الجرح، وعلة الجرح أو الرمي تشبه السبب كذلك، للتخلل بين العلة والحكم.

٦- علة العلة: ك شراء القريب، وقد وقع الخلاف في هذا الفرع، فالإمام فخر الإسلام البزدوي رأى أنه علة اسماً ومعنى لا حكماً، لأن الشراء علة الملك، والملك علة العتق، وكان الشراء علة اسماً، لأن المضاف إلى المضاف إلى شئ مضاف إلى ذلك الشئ، ومعنى ذلك أن العتق مضاف إلى الملك، والملك مضاف إلى الشراء، فيكون العتق مضافاً إلى الشراء لكن بواسطة الملك، والشراء علة معنى كذلك، لأنه المؤثر في الملك والملك مؤثر في العتق، وليس علة حكماً. لتخلل الواسطة، وهو الملك ولذا كان شبيهاً بالأسباب^(١).

وذهب صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أن شراء القريب علة اسماً ومعنى وحكماً، وهو يشبه السبب لوجود الإضافة والتأثير وعدم التراخي، فالعتق مضاف إلى الشراء، والشراء مؤثر في الملك، والملك مؤثر في العتق والعتق يترتب على الشراء بدون تراخ، وهو يشبه السبب لتخلل الملك بين

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٥/٢؛ أصول السرخسي ٣١٦/٢.

الشراء والعتق، فكان شراء القريب علة اسماً ومعنى وحُكماً وشبيها بالسبب عند صدر الشريعة.

وجُملة القول في العلة اسماً ومعنى لا حُكماً: أن العلة اسماً ومعنى لا حُكماً قد تشبه السبب كالإجارة، وكل إيجاب مضاف إلى المستقبل، والنِصاب، ومرض الموت، والجرح، وقد لا تشبه السبب كالبيع الموقوف، والبيع بشرط الخيار، وقد تكون علة اسماً ومعنى وحُكماً كشراء القريب على رأي صدر الشريعة^(١).

رابعاً: العلة معنى فقط: لا اسماً ولا حُكماً: وهي ما كانت مؤثرة فقط من غير إضافة ولا اتصال، وعبر عنها صدر الشريعة بما له شبه العلية، وفخر الإسلام بالوصف الذي له شبه العلة.

أما كون العلة معنى فقط، فلأن الحُكم إذا تعلق بوصفين مؤثرين، فلا تتم العلة إلا بهما، لأن كل واحد منهما جزء العلة وليس العلة كل وصف منهما على حدة، وهي ليست علة اسماً، لعدم الإضافة، وكذا ليست علة حُكماً، لتأخر الحُكم إلى وجود الوصف الثاني^(٢).

والمراد بأحد الوصفين: أنه إن كان الوصفان مرتبين فالمراد الجزء الأول منهما، ومثال ذلك: القرابة في عتق القريب، إذا ملكه قريبه، أي: إذا وجدت القرابة ثم وجد الملك عتق القريب، فالقرابة علة معنى، لأن لها تأثيراً في العتق، وليست علة اسماً، لأن الحُكم يضاف إلى القرابة والملك معاً، وليست علة حُكماً، لتراخي الحُكم إلى وجود الجزء الثاني وهو الملك، أما الملك، وهو الجزء الثاني من هذين الوصفين، فله نوع تأثير أيضاً، لكن له حكم آخر سيبين في العلة معنى وحُكماً.

وإذا كان الوصفان غير مرتبين فالمراد مطلق أحدهما، ومثاله: القدر والجنس في الربا، لأن علته القدر مع الجنس، فكل واحد منهما تأثير في

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٥/٢؛ مُدكرة د/ دياب ص٤٧.

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٥/٢.

الحُكم فيثبت أحد هذين الوصفين ما يثبت بالشبهة كرها النسبية، فإنه يثبت بالقدر أو الجنس، لما فيه من شبهة الفضل، لما في النقد من مزية على النسبية، فلا يجوز أن يسلم حنطة في شعير، لوجود أحد الوصفين وهو القدر، بخلاف ربا الفضل حقيقة فإنه لا يثبت بشبهة العلة، بل يتوقف ثبوته على حقيقة العلة، أي القدر والجنس معاً، لأن ربا الفضل أقوى الحرمتين^(١).

إذن: فالذي يطلق عليه العلة معنى هو الجزء الأول في الوصفين المرتبين، والذي يطلق عليه العلة معنى هو مطلق أحدهما في الوصفين غير المرتبين.

خامساً: العلة معنى وحُكمًا: لا أسماء وهي التي تكون مؤثرة في الحكم، ومتصلة به من غير تراخ، ولكن لا يضاف الحُكم إليها، وذلك بأن تكون العلة ذات وصفين مؤثرين مرتبين في الوجود فالمتأخر منهما وجوداً يكون علة معنى وحُكمًا لوجود التأثير واتصال الحُكم بالوصف، ولا يكون علة اسمًا، لعدم الإضافة إليه بدون واسطة، لأن الإضافة للمجموع.

مثالها: عتق القريب فهو يتكون من وصفين: القرابة والملك، والجزء الأخير من هذين الوصفين، علة معنى وحُكمًا لا اسمًا، ولكل من القرابة والملك نوع تأثير في العتق، فتجب الصلات للقرابة عند الاحتجاج، وتجب نفقة العبد للملك.

وعلى هذا: فالذي يوجد أولاً هو العلة معنى، أما الذي يوجد ثانيًا فهو العلة معنى وحُكمًا، فإذا كانت القرابة ثابتة ثم وجد الملك فهو العلة معنى وحُكمًا، لأنه الجزء الأخير من الوصفين المرتبين، فالحكم يضاف إلى الملك، كالمتن الأخير من السفينة إذا غرقت بسببه، فيكون هو المؤثر، وتكون القرابة هي العلة معنى.

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣١/٢؛ مُذكرة د/ دياب ص٤٩.

وإذا وجد الملك ثم ثبتت القرابة، تكون القرابة علة معنى وحُكمًا، لأنه الجزء الأخير من الوصفين المرتبين، ويكون الملك علة معنى^(١).

ولتوضيح ذلك نسوق مثالين:

المثال الأول: وفيه تأخر الملك عن القرابة: أن يكون له قريب عبد، فيشتريه وهو عالم بقرابته، فبمجرد الشراء يثبت الملك وبالملك يثبت العتق لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "من ملك ذا رحم مُحرم منه عتق عليه"^(٢)، فيكون الملك علة معنى وحُكمًا، ولهذا تصح نية الكفارة عند الشراء، فإن نية الكفارة تعتبر عند الإعتاق، فتعتبر عند الشراء.

المثال الثاني: وفيه تأخر القرابة عن الملك: فتكون القرابة علة معنى وحُكمًا، ويكون الملك علة معنى فقط، أن يرث رجلان عبداً مجهول النسب ثم ادعى أحدهما أنه قريبه، فيعتق العبد، ويضمن المدعي قيمة نصيب شريكه، لأنه بادعائه القرابة أفسد على شريكه نصيبه بصنعه واختياره، أما لو كانت القرابة معلومة لم يضمن مدعي القرابة، لأنها لم تحصل بصنعة وقد رضي الأجنبي بفساد نصيبه.

وهذه الصورة تخالف الشهادة، وذلك فيما إذا شهد واحد بشئ ثم شهد آخر بذلك الشئ فإذا رجع أحدهما ضمن النصف فقط، لأن الحكم يثبت بالمجموع، وهو يقع بشهادة الشاهدين، ولا يضاف الحكم إلى الشهادة الأخيرة، بل إلى المجموع، وإذا رجعا معاً يضمنان^(٣).

سادساً: العلة اسماً وحُكمًا: لا معنى فهي التي يضاف إليها الحكم، ولا يتراخى عنها، من غير تأثير لها فيه.

وهذا القسم يتحقق في أمرين:

الأول: إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه.

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٥/٢؛ مذكرة د/ دياب ص٤٩.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ٢٦/٤ كتاب العتق باب: فيمن ملك ذا رحم منه.

(٣) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٦/٢؛ أصول السرخسي ٣١٨/٢.

الثاني: إقامة الدليل مقام المدلول.

والفرق بين الأمرين: أن السبب الداعي هو الذي يفضي إلى الشئ في الوجود، فلا بد من أن يتقدمه.

أما الدليل: فهو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشئ، فربما يكون متأخرًا في الوجود، كالإخبار عن المحبة، فإنه يقتصر على المجلس^(١).

أمثلة القسم الأول: إقامة السبب الداعي مقام السبب المدعو إليه:

١- السفر والمرض بالنسبة إلى إباحة الإفطار، أو السفر بالنسبة لقصر الصلاة، فإنه علة اسمًا، لأن الإفطار أو القصر يضاف إليه فنقول: أفطر للسفر أو للمرض، أو قصر الصلاة للسفر.

وهو علة حُكمًا كذلك، لعدم التراخي، فيثبت القصر بمجرد تجاوز بيوت الحضر، وليس علة معنى، لأن السفر أو المرض غير مؤثر، إنما المؤثر في الحقيقة هو المشقة، وهي غير منضبطة لاختلافها باختلاف الناس، ولما كانت المشقة غير منضبطة أقام الشارع مقامها السبب الداعي، وهو السفر أو المرض، أما المشقة فهي السبب المدعو إليه.

٢- النوم بالنسبة للحدث: فالمؤثر هو استرخاء المفاصل، لأنه مظنة خروج النجاسة، فأقيم السبب الداعي ههنا، وهو النوم، مقام السبب المدعو إليه وهو استرخاء المفاصل، فكان النوم علة اسمًا للإضافة، وعلة حُكمًا لعدم التراخي، وليس علة معنى لعدم التأثير.

٣- إقامة الدواعي من المس والتفخيز والتبطين مقام الوطء في حُرمة المصاهرة وفساد الإحرام والاعتكاف إذا أنزل فيه، فالمؤثر هو الوطء، وهذه الأشياء داعٍ إليه، فأقيمت مقامه فتكون علة اسمًا للإضافة، وعلة حُكمًا كذلك لعدم التراخي، وليست علة معنى لعدم التأثير، بل المؤثر

هو الوطاء^(١).

أمثلة القسم الثاني: إقامة الدليل مقام المدلول:

١- إقامة الإخبار مقام المحبة، فإذا قال الرجل لامرأته: إن أحببتني فأنت طالق، فالمعلق عليه هنا هو المحبة، وهو أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، لأن محله القلب، فأقيم الإخبار الذي هو دليل المحبة - وهو أمر ظاهر - مقام المحبة التي هو المدلول، فيقع الطلاق بمجرد الإخبار فيكون الإخبار علة اسمًا، لإضافة الطلاق إليه، وعلة حكمًا كذلك، لأن الطلاق يقع بمجرد الإخبار، ويتوقف الإخبار على المجلس، وليس علة معنى، لأن الإخبار غير مؤثر، بل المؤثر هو ذات المحبة.

٢- الطهر الخالي عن الجماع بالنسبة إلى إباحة الطلاق: فنظرًا لأن الطلاق أمر محظور، لما فيه من قطع النكاح المسنون، إلا أنه شرع ضرورة أنه قد يحتاج إليه عند العجز عن إقامة حقوق النكاح، ولما كانت الحاجة أمرًا باطنًا لا يوقف عليه، أقيم دليلها وهو زمان تتجدد فيه الرغبة (الطهر الخالي عن الجماع) مقامها - الحاجة - لأنه - أي وقت الطهر - الوقت الذي تظهر فيه الحاجة إلى الطلاق، لإقدامه على الطلاق، مع أنه وقت للرغبة في الجماع، فيكون الطهر علة اسمًا للإضافة، وحكمًا لعدم التراخي، وليس علة معنى، لأنه غير مؤثر في إباحة الطلاق، بل المؤثر الحقيقي هو الحاجة التي هي أمر باطن لا يوقف عليه، فأقيم دليلها وهو الطهر الخالي عن الجماع مقامها تيسير^(٢).

الداعي إلى الإقامة:

السبب المقتضي لإقامة الداعي مقام المدعو إليه، والدليل مقام المدلول أحد هذه الأمور الثلاثة: -

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٦/٢؛ أصول السرخسي ٣١٨/٢-٣١٩.

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٦/٢؛ أصول السرخسي ٣١٩/٢.

الأول: دفع الضرورة، وذلك كما في إقامة الإخبار عن المحبة مقام ذات المحبة، في قوله مثلاً: إن أحببتي فأنت طالق.

الثاني: الاحتياط، كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات، أي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة، حيث أقيمت مقام الزنى في الحرمة على الإطلاق إذا كانت مع الأجنبية.

وهذه الدواعي أقيمت مقام الوطاء في الحرمة حالتي الاعتكاف والإحرام إذا كانت مع الزوجة أو الأمة.

ومن أمثلة الاحتياط: الصلاة في جماعة، فإنها أقيمت مقام الإسلام، حتى وجب الحكم بالإسلام بها، وإن لم يعرف من تصديق ولا إقرار وكذا الإقرار المجرد، أقيم مقام الإسلام في أحكام الدنيا، حتى وجبت العبادات به احتياطاً.

الثالث: دفع الحرج، وذلك كما في السفر والمرض، حيث أقيما مقام المشقة، وكذا التقاء الختانيين أقيم مقام الإنزال في الجناية^(١).

الفرق بين دفع الضرورة ودفع الحرج:

يفرق بينهما بأن في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف على ذلك الشئ كالمحبة، فإن وقوف الغير عليها محال، فالضرورة داعية إلى إقامة الإخبار عن المحبة مقام المحبة.

أما في دفع الحرج فإنه يمكن الوقوف على الشئ لكن بمشقة، كالمشقة في السفر، والإنزال في التقاء الختانيين، إذ الوقوف عليهما ممكن، لكن في إضافة الحكم إليهما مشقة لخفائهما^(٢).

ما سبق كان وجه الاختلاف بينهما، أما وجه الاتفاق، فإنهما في الحكم سواء، حيث إن الحرج مدفوع شرعاً بالضرورة.

(١) راجع: التلويح ١٣٦/٢-١٣٧.

(٢) راجع: التوضيح ١٣٧/٢.

سابعاً: العلة حُكماً فقط، لا اسماً ولا معنى: وهي التي يكون الحكم فيها مقارناً لها، لكن لا يضاف إليها، ولا تكون مؤثرة فيه، وهي تتمثل في أمرين:

الأول: السبب الداعي إذا كان مركباً من جزئين، فيكون الجزء الأخير من السبب هو العلة حُكماً فقط، للمقارنة، وليس علة اسماً لعدم الإضافة، لأن الحكم يضاف إلى الجزئين معاً لا إلى أحدهما وليس علة معنى، لعدم التأثير.

الثاني: الشرط الذي علق عليه الحكم، كما في قوله لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الحكم يتصل به ويحصل الطلاق عليه بدون تراخ، فيكون علة حُكماً، وليس علة معنى، لعدم التأثير، لأن نفس الدخول غير مؤثر في الطلاق، وليس علة اسماً، لعدم الإضافة، فإن الطلاق لا يضاف إلى الشرط، وإنما يضاف إلى الصيغة^(١).

ثالثاً: السبب:

وهو القسم الثالث من أقسام الحكم التعليقي، ونتناول فيما يلي تعريفه وأقسامه.

تعريف السبب لغة: ما يتوصل به إلى الشئ، ويأتي بمعنى الطريق ومنه قوله تعالى ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾^(٢) أي طريقاً، وبمعنى الحبل ومنه قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾^(٣) أي بحبل من سقف البيت، وبمعنى الباب ومنه قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾^(٤) أسباب السماوات أي أبواب السماوات، فهذه المعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وهو طريق الوصول إلى الشئ فالطريق يوصل إلى المقصود، والحبل يوصل إلى الماء أو السقف،

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٧/٢.

(٢) سورة الكهف من الآية (٨٩) .

(٣) سورة الحج من الآية (١٥) .

(٤) سورة غافر الآية (٣٦) .

والباب يوصل إلى الدار^(١).

تعريف السبب اصطلاحاً: هو الوصف الخارج المفضي إلى الحكم من غير تأثير، فقوله: (الوصف) جنس في التعريف يشمل السبب وغيره، وقوله: (الخارج) قيد خرج به الركن، لأنه داخل في الماهية كما سبق، وقوله: (المفضي إلى الحكم) خرج به الشرط والعلامة، لأنهما لا يوصلان إلى الحكم، وقوله: (من غير تأثير) خرج به العلة، وبعضهم قيد الإفضاء بكونه في الجملة، لأنه لا يلزم الإفضاء إلى الحكم إلا إذا وجد الحكم، كسوق الدابة بالنسبة للهلاك، فقد يوجد السوق ولا يوجد الهلاك.

وهذا تعريف للسبب الحقيقي المحض الذي يوصل للحكم مجرد توصيل من غير زيادة في الإيصال بشبهة التأثير، أو نقص فيه كالمُتعلقات التي توصل مآلاً لا حالاً.

ولهذا: فإن السبب عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الحقيقي، وأما غيره مما له تأثير، أو فيه الإيصال مآلاً، فلا يطلق عليه لفظ السبب فقط، بل يُقال فيما له تأثير إنه سبب في معنى العلة، وفيما يوصل مآلاً بأنه سبب مجازاً، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام في تقسيم السبب.

وبعض العلماء عرف السبب بأنه: كل ما دل السمع على كونه معرفاً للحكم الشرعي، وهو بذلك يشمل السبب والعلة والشرط والعلامة، لأنها معارفات للحكم الشرعي، سواء كان هناك تأثير أم لا، انتفى بانتفائه أم لا، ولهذا صح إطلاق لفظ السبب على العلة ولفظ العلة على السبب، وجاء الاستعمال شائعاً في كتبنا، فتكون النسبة بينه وبين بقية أقسام الحكم الوضعي عدم التباين.

والمشهور هو التعريف الأول، وهو المتبادر عند الإطلاق، لأنه أكثر استعمالاً.

(١) راجع: أصول السرخسي ٣٠١/٢؛ التلويح ١٣٧/٢.

ثم إن الفرق بين السبب والعلة: أن العلة لها تأثير في الحكم، بخلاف السبب فلا تأثير له، وأيضا أن العلة لا يمكن تخلفها عن المعلول ولا تأخره عنها، بخلاف السبب فقد يتأخر الحكم عن السبب أو يتخلف عنه^(١).

أقسام السبب:

قسم بعض العلماء - كفخر الإسلام البزدوي - السبب إلى أربعة أقسام: سبب حقيقي، وسبب في معنى العلة، وسبب مجازي، وسبب له شبهة العلة، ولم يرتض صدر الشريعة هذا التقسيم، لأن السبب الذي له شبهة العلة هو بعينه السبب المجازي، وعد السبب المجازي ضمن الأقسام ليس بمستحسن^(٢)، فقسم السبب إلى سبب حقيقي، وسبب في معنى العلة فإن كانت هناك علة حقيقية مستقلة، بأن كانت فعل فاعل مُختار، ولم يمنع من إضافة الحكم إليها مانع، كان السبب حقيقياً، وإن لم تكن العلة حقيقية مستقلة، بأن لم تكن فعل فاعل مُختار أو منع من إضافة الحكم إليها مانع، كان السبب في معنى العلة، ثم أضاف صدر الشريعة قسماً ثالثاً للسبب، وهو السبب المجازي، فصارت الأقسام عنده ثلاثة، إليك بيانها تفصيلاً:

القسم الأول: السبب الحقيقي (المحض):

هو ما يوصل إلى الحكم وتكون العلة المتوسطة بينه وبين الحكم حقيقية مستقلة، بأن كانت فعل فاعل مُختار، ولم يمنع من إضافة الحكم إليها مانع.

حكمه: إضافة الحكم بجميع آثاره وكل ما يترتب عليه إلى العلة، مع قطع نسبة الحكم إلى السبب.

مثاله: لهذا القسم أمثلة كثيرة نذكر منها مثالين:

(١) راجع: أصول السرخسي ٣٠١/٢؛ مذكرة د/ دياب ص ٥٦.

(٢) راجع: التلويح ١٣٧/٢.

١- دلالة رجل لآخر على سرقة مال شخص، فسرقه المدلول، فالسبب هو دلالة الرجل الأول للثاني على مال ذلك الشخص، والسرقه التي هي فعل السارق هي العلة، والحكم الذي هو هلاك المال يضاف إلى السرقة (العلة)، لأنها فعل فاعل مُختار هو السارق، ولم يمنع من إضافة الحكم إليها مانع، فيترتب أثر الحكم وهو الضمان على السارق بعله السرقة، ولا ضمان على الدال، لأن هذه الدلالة طريق موصل إلى الهلاك، فلا ضمان بسببها، لوجود المؤثر وهو العلة، فكانت الدلالة سبباً محضاً للإيصال فقط من غير تأثير ولا شبهة تأثير في الحكم.

٢- دلالة رجل للمجاهدين على حصن للعدو، فاقتحم المجاهدون الحصن وغنموا، فالسبب، هنا هو دلالة الرجل للمجاهدين على الحصن، والحكم هو سقوط الحصن في أيدي المجاهدين، والعلة هي فعل المجاهدين، وهي فعل فاعل مُختار، فيُضاف الحكم إليها منقطعاً عن السبب وهو الدلالة، لأنها مُجرد موصل، فيكون أثر الحكم وهو الغنيمة للمجاهدين ولا شئ للرجل الدال للغنيمة، لأنه موصل محض^(١).

القسم الثاني: السبب في معنى العلة:

هو ما يُفضي إلى الحكم في الجملة من غير تأثير بأن كانت العلة المتوسطة بينه وبين الحكم غير صالحة لإضافة الحكم إليها، بأن كانت فعل فاعل مُختار، ومنع من إضافة الحكم إليها مانع.

حكمه: إضافة نفس العلة إلى السبب، فيضاف الحكم إليه وتترتب عليه آثاره.

أمثلته:

١- ساق رجل دابة أو قادها، فوطئت الدابة بقوائمها شخصاً فقتلته، فالسوق أو القود سبب موصل إلى القتل في الجملة، لأنه قد يحصل

(١) راجع: التوضيح لمتن التنقيح ١٣٧/٢؛ مذكرة د/ دياب ص ٥٧.

بدون قتل، والعلة في الهلاك وطء الدابة، وهو فعل فاعل غير مختار، لأن فعل البهيمة هدر، والحكم هو وجوب الدية على القائد أو السائق، فهنا قد أضيفت العلة التي هي وطء الدابة إلى السبب (السوق أو القود) فيما يرجع إلى بدل المحل (الدية) لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة كالحرمان من الميراث، وهذا سبب في معنى العلة، لأن السوق أو القود لم يوضع للتلف ولم يؤثر فيه، وإنما هو طريق للوصول إليه، فأضيفت العلة إليه.

٢- هذا المثال يصلح لأن يكون سبباً محضاً، ولأن يكون سبباً في معنى العلة، وهو ما إذا دفع شخص سكيناً لصبي ممیز ليمسكها له، فإذا قطع الصبي يده أو وجأ بها عنق نفسه فمات، فإنه يكون من أمثلة السبب الحقيقي، لأنه توسط بينه وبين الحكم علة مستقلة هي فعل الصبي، فلا تضاف إلى السبب لأنها فعل فاعل مختار، فلا ضمان على معطي السكين.

أما إذا سقطت السكين من يد الصبي فجرح أو قتل، فيكون من أمثلة السبب في معنى العلة، فيضمن معطي السكين، لأنه لم تتوسط بين السبب والحكم علة مستقلة، فأضيف الحكم إلى السبب وهو الدفع، وقيدنا الصبي بكونه ممیزاً، لأنه إذا لم يكن ممیزاً يكون الدفع سبباً في معنى العلة، فيضمن الدافع مطلقاً^(١).

القسم الثالث: السبب المجازي:

هو ما يُفْضِي إلى الحكم مآلاً، كالصيغ الدالة على تعليق شئ بشئ مثل الطلاق المعلق في قول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ومثل العتق المعلق في قول السيد لعبده: إن سافرت إلى الخارج فأنت حر، وكذلك النذر المعلق في مثل قوله: إن شفى الله مريضى لأذبحن شاة، فهذه الصيغ أسباب لما يترتب عليها من الجزاء، وقد لا توصل إلى مجازية

(١) راجع: التوضيح والتلويع ١٣٧/٢-١٣٨؛ أصول السرخسي ٣٠٩/٢.

الجزاء، لأن الشرط معدوم على خطر الوجود، وهي أسباب مجازية قبل حصول المعلق عليه.

وإنما سمي بالسبب المجازي باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العنب خمرًا في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾^(١) وكتسمية الأحياء أمواتًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾^(٢)، فإذا وقع المعلق عليه كانت هذه الصيغ علة حقيقية، لوجود الإضافة والتأثير بعد زوال المانع من الانعقاد وترتب الحكم واتصاله بوجود المعلق عليه.

ومن أمثلة السبب المجازي أيضًا: صيغة اليمين بالله تعالى، كمن قال: والله لا أدخل هذه الدار، فقبل الدخول تكون هذه الصيغة سببًا مجازًا، أما بعد الدخول فتكون سببًا حقيقيًا وليست علة، لأن العلة هي الحنث، لأنه المؤثر في وجوب الكفارة، وقد توسط الحنث بين اليمين والكفارة، فيكون اليمين سببًا حقيقيًا، ولم يكن اليمين هو العلة، لأن اليمين موضوعة للبر، والبر لا يفضي الى الكفارة، وإنما المفضى إليها هو الحنث^(٣).

ثم اعلم: أن كون هذه الصيغ المعلقة واليمين أسبابًا مجازية إنما هو مذهب الحنفية أما الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - فهي قبل حصول المعلق عليه والحنث في اليمين أسباب في معنى العلة، لأن اليمين هي التي توجب الكفارة عند الحنث، والمعلق هو الذي يوجب الجزاء عند وجود الشرط، فكان كل واحد منهما سببًا في الحال، لا علة باعتبار تأخر الحكم، ولكن في معنى العلة، باعتبار أنه المؤثر في الحكم لا غير.

وثمره الخلاف في ذلك: أنه على رأي الحنفية يصح التعليق بالملك في الطلاق والعتاق، فإذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر، ثم تزوج هذه المرأة الأجنبية تكون طالقًا، وإذا

(١) سورة يوسف من الآية (٣٦) .

(٢) سورة الزمر الآية (٣٠) .

(٣) راجع: التوضيح والتلويح ١٣٨/٢.

ملك هذا العبد صار حرًا، وذلك لأنها أسباب وليس عللا، فلا يشترط المحل. وفي مسألة اليمين لا يصح التكفير قبل الحنث، لأن هذا تقديم للحكم على العلة.

أما على رأي الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -: فإنه لا يصح التعليق بالملك في الطلاق والعتاق، ففي المثاليين المذكورين لو تزوج هذه المرأة لا تطلق، ولو ملك العبد لا يعتق، لعدم وجود الملك عند وجود العلة، ومن شرط عمل العلة أن تكون في محل صالح للحكم، والمرأة الأجنبية والعبد الذي ليس في ملكه ليسا بمحلين للطلاق والعتاق من جهة هذا المتكلم، وفي مسألة اليمين - يجوز عنده - أي الشافعي - التكفير قبل الحنث، لأن علة الكفارة عنده اليمين، والحنث شرط، فيجوز تعجيل الحكم بعد العلة قبل وجود الشرط، كالزكاة قبل الحول عند وجود النصاب^(١).

وجُملة القول في ذلك: أن الحنفية يعتبرون المعلقات من الطلاق والعتق والنذر أسبابًا مجازية قبل وقوع الشرط، لما يترتب عليها من الجزاء، وهو الطلاق والعتاق أو لزوم المنذور به، لإفضائها إليه في الجملة، لا أسبابًا حقيقية أما بعد وقوع الشرط فتصير عللاً حقيقية لتأثيرها في وقوع الأجنبية مع الإضافة إليها والاتصال بها بمنزلة البيع للملك، لأن الشرط كان مانعًا من الانعقاد، فإذا زال المانع انعقدت علة حقيقية بمنزلة الإيقاعات المنجزة، ولم يجوزوا تعجيل الكفارة قبل الحنث في مسألة اليمين بناء على أصلهم، وهو أن المشروط مع الشرط كلام واحد، فالتكفير قبل الحنث تعجيل للشئ قبل وجود علته، وهو لا يصح إجماعًا.

وأما الشافعية فيعتبرون هذه الأشياء أسبابًا في معنى العلل، أي علل للجزاء في المعلقات والكفارة، بناء على أصلهم من أن عدم الشرط لا يمنع من انعقاد السبب، واليمين عندهم سبب كفارة، والحنث شرط، وإنما كان اليمين سببًا لإضافة الكفارة إليه في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا

(١) راجع: التوضيح لمتن التنقيح ١٣٨/٢؛ مذكرة د/ دياب ص ٦٢.

حَلَفْتُمْ^(١)، وأما كون الحنث شرطاً، فلتوقف الكفارة عليه فيثبت نفس الوجوب بناء على السبب، ويثبت وجوب الأداء عند الشرط وهو الحنث، فالتكفير قبل الحنث يكون فعلاً للواجب بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه. وقد رد الحنفية على الشافعية بأن اليمين سبب للكفارة، بأن الكفارة سببها الحنث، لأنه المفضي إليها، أما اليمين فلا تصلح أن تكون سبباً لها، لأنها موضوعة للبر تعظيماً لاسم الله تعالى، فكيف تكون سبباً لما ترتب على ضد مقصودها، وهو الحنث^(٢).

بيان أسباب الشرائع

المُرَاد بأسباب الشرائع: الأسباب الظاهرة للأحكام، فما من حكم إلا وله سبب ظاهر يترتب الحكم عليه.

ثم اعلم: أنه لا خلاف بين العلماء في أن مشرع الشرائع هو الله تعالى وحده، وأنه المتفرد بإيجاب الأحكام، وأن السبب الحقيقي للأحكام والمؤثر فيها هو إيجاب الله تعالى، والأسباب الظاهرة ما هي إلا أمارات وعلامات على الأحكام لا مؤثرات.

وإذا كان ما سبق محل اتفاق، فالخلاف قد وقع بين العلماء فيما إذا كانت لهذه الأحكام أسباب ظاهرة تضاف إليها أم لا؟.

وقد اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: أن للأحكام أسباباً ظاهرة تضاف إليها في الظاهر، كالوقت للصلاة، والشهر للصوم، والموجب لها في الحقيقة هو الله تعالى، وهو مذهب عامة الحنفية وبعض الشافعية، وعامة المتكلمين، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي - رَحِمَهُ اللهُ - وهو المذهب الراجح.

الثاني: أن العقوبات وحقوق العباد لها أسباب يضاف وجوبها إليها، فأما

(١) سورة المائدة من الآية (٨٩).

(٢) راجع: التلويح ١٣٩/٢؛ أصول السرخسي ٣٠٤/٢-٣٠٥.

العبادات فلا يضاف وجوبها إلا إلى إيجاب الله تعالى وخطابه، وهو مذهب جمهور الأشاعرة.

الثالث: إنكار الأسباب بالكلية، فقالوا: إن الحكم في المنصوص عليه ثابت بظاهر النص، وفي غيره بالوصف الذي جعل علة، وهو أمانة لثبوت الحكم في الفرع^(١).

وأخذًا بالمذهب الأول - الراجح - القائل بأن للأحكام أسبابًا ظاهرة تضاف إليها، نذكر فيما يلي الأسباب الظاهرة لبعض الأحكام:

١- سبب وجوب الإيمان:

الإيمان بالله تعالى هو التصديق والإقرار بوجوده ووحدانيته وسائر صفاته، وسببه على ما ورد به النقل وشهد به العقل هو حدوث العالم، أي كون جميع ما سواه تعالى من الجواهر والأعراض مسبقًا بالعدم، ولا يخفى أن وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى، إلا أنه نسب إلى سبب ظاهر تيسيرًا على العباد وقطعًا لحجج المعاندين، وإلزامًا لهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعدم ظهور السبب، فالحادث يدل على أن له محدثًا صانعًا قديمًا غنيًا عما سواه واجبًا لذاته، ثم وجوب الوجود ينبئ عن جميع الكمالات وينفي جميع النقائص.

وليس المراد بالسبب بالنظر إلى كل واحد هو حدوث العالم فقط، بل مراتب الناس في ذلك متفاوتة على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾^(٢) إلا أن الاستدلال بالآفاق والأنفس هو أشد المراتب وضوحًا وأكثرها وقوعًا وأثبتها دوامًا؛ إذ كل واحد يشاهد نفسه والسموات والأرض، فكان ملازمًا لكل واحد من أهل الإيمان.

ولذلك صح إيمان الصبي المميز، لتحقيق سببه، وهو الآفاق والأنفس

(١) راجع: كشف الأسرار ٣٣٩/٢-٢٤٠؛ فتح الغفار ٧١/٢؛ التوضيح والتلويع ١٤١/٢.

(٢) سورة فصلت من الآية (٥٣).

ووجود ركنه وهو التصديق والإقرار الصادر عن النظر والتأمل، إذ الكلام في الصبي العاقل، وهو أهل لذلك، بدليل أن الإيمان قد يتحقق في حقه تبعاً للأبوين، فلو امتنع صحته لم يكن إلا بحجج شرعية، وذلك في الإيمان محال، لأنه لا يحتمل عدم المشروعية أصلاً.

نعم إنه غير مخاطب بالإيمان لعدم التكليف المعتبر في الخطاب، فسقط عنه الأداء الذي يحتمل السقوط في بعض الأحوال، كما إذا أراد الكافر أن يؤمن فأكرهه على السكوت عن كلمة الإسلام^(١).

بماذا يتحقق وجوب الأداء؟

اختلف العلماء في ذلك:

قال بعضهم: وجوب الأداء مبني على العقل الكامل.

وقال عامة المشايخ: وجوب الأداء مبني على الخطاب.

وثمره ذلك تظهر فيما إذا بلغ الصبي في شاهره جبل، ولم تبلغه الدعوة حتى مات فعلى قول العامة يكون معذوراً، لأن وجوب الأداء بالخطاب، ولم يبلغه.

وعند اصحاب المذهب الأول: لا يكون معذوراً، لأن وجوب الأداء إنما يشترط فيه الخطاب إذا كان في حكم يحتمل النسخ. والرفع، والإيمان ليس كذلك^(٢).

٢- سبب وجوب الصلاة:

السبب الظاهر لوجوب الصلاة هو الوقت، لأن الوقت تضاف إليه الصلاة، فيقال: فرض الوقت، وصلاة الفجر والظهر مثلاً، ولذلك فإنها تتغير من الأداء إلى القضاء بتغيره، ويتجدد الوجوب بتجدد الوقت، وهو سبب لنفس الوجوب لا لوجوب الأداء، لأن وجوب الأداء مبني على العقل

(١) راجع: التلويح ١٤٢/٢.

(٢) التلويح ١٤٢/٢.

الكامل، أو على الخطاب كما سبق، والسبب الحقيقي هو الإيجاب القديم^(١).

٣- سبب وجوب الزكاة:

السبب الظاهر لوجوب الزكاة هو ملك النصاب، لأن الزكاة تضاف إليه، فيقال: زكاة المال، ولأن الوجوب يتضاعف بتضاعف النصاب في وقت واحد، ومع اختلاف الناس في الغنى قدّره الشارع بالنصاب، لأنه لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

اعتراض وجوابه:

أشكل على كون النصاب سبباً للزكاة، أن تكرر الوجوب يدل على سببية ذلك الوصف، وهنا الوجوب يتكرر بتكرر الحول، فيجب أن يكون الحول سبباً لا النصاب.

الجواب:

أن الغنى لا يكمل إلا بمال نام، والنماء بالزمان، فأقيم الحول مقامه، لأن النماء أمر باطن، والحول مشتمل على الفصول الأربعة التي لها تأثير في النماء بالدر والنسل، وبزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في كل فصل إلى ما يناسبه، فصار الحول شرطاً، وتجده تجدد للنماء، وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب، لأن السبب هو المال بوصف النماء، والمال بهذا النماء غيره بذلك النماء، فيكون تكرر الوجوب بتكرر الحول وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط، أي إن المال يتجدد بتجدد الحول، فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديراً^(٢).

٤- سبب وجوب الصوم:

السبب الظاهر لوجوب الصوم هو الشهر، لأنه يضاف إليه ويتكرر

(١) راجع: كشف الأسرار ٢٤٦/١؛ كشف الأسرار للنسفي ٤٧٦/١.

(٢) راجع: التوضيح والتلويع ١٤٢/٢؛ مُذكرة د/ دياب ص ٢٩.

بتكرره، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(١)، وأيضاً لم يجز الأداء قبله، وجاز القضاء بعده، وهذا عند المتأخرين من الحنفية.

وذهب الإمام السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ - إلى أن السبب هو مطلق شهود الشهر يعنى الأيام لباليها، لأن الشهر اسم للمجموع، وسببته باعتبار إشهار شرف الوقت، وذلك في الأيام والليالي جميعاً، ولهذا يلزم القضاء على من كان أهلاً في الليل ثم جن وأفاق بعد مضي الشهر.

وذهب الأكثرون - وهو ما اختاره صدر الشريعة - إلى أن كل يوم سبب لصومه، بمعنى أن الجزء الأول الذي لا يتجزأ من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة، مختص بشرط وجوده، وينعدم بحدوث المنافي^(٢).

هـ- سبب وجوب صدقة الفطر:

هو رأس يموئه ويلى عليه، وإنما الفطر شرط، ودليل ذلك:

أ- قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أدوا عن تمونون"^(٣).

وجه الدلالة من الحديث:

أن كلمة "عن" تدل على انتزاع الشئ عن الشئ وانفصاله عنه لأنها للبعد والمجاورة، وانتزاع الشئ عن الشئ قد يكون بانتزاع الحكم عن السبب، كما يقال: أدى الزكاة عن ماله والخراج عن أرضه، وقد يكون بالدلالة على أن ما وجب عليه قد أداه عنه غيره، كأنه نائب عنه، كما يقال: الدية واجبة على القاتل ثم تتحمل عنه العاقلة، والوجه الثانى باطل، لاستحالة الوجوب على العبد والكافر، فتعين الوجه الأول، وهو أن تكون

(١) سورة البقرة من الآية (١٨٥) .

(٢) راجع: كشف الأسرار ٣٤٢/٢؛ أصول السرخسي ١٠٤/١؛ التوضيح والتلويع ١٤٢/٢.

(٣) أخرجه الدارقطني والبيهقي سنن الدارقطني ١٤١/٢؛ كتاب زكاة الفطر؛ والسُنن الكبرى ١٦/٤ باب إخراج زكاة الفطر.

"عن" لانتزاع الحُكم عن السبب.

ب- تضاعف الواجب بتضاعف الرأس:

قيل: إن السبب هو الفطر، لإضافة الصدقة إليه، يُقال: صدقة الفطر، والإضافة دليل السببية بالاتفاق، فيكون الفطر سبباً للصدقة.

أجيب عنه: أنه كما صحت الإضافة إلى الفطر، صحت كذلك إلى الرأس، فوجد التعارض، وإذا تعارضا تساقطا، فنتمسك بسببية الرأس بالتضاعف، وهذا الدليل أقوى من الإضافة، لأن الحُكم قد يضاف إلى غير السبب مجازاً، وهذا المجاز لا يجري في التضاعف.

وأيضاً مما يرجح سببية الرأس هو وصف المؤنة الوارد في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "عمن تمونون"، فقد علق الحُكم - الوجوب - على وصف المؤنة، وهو يشعر بأن هذه الصدقة تجب وجوب المؤن رأس يلي عليه، كما فى العبيد والبهائم، ثم إن المؤنة خاصة بالرأس ويتكرر وجوبها بتكرر الحاجة فتكون الرأس متجددة المؤنة، وهذا يرجح كون الرأس سبباً^(١).

٦- سبب وجوب الحج:

السبب الظاهر لوجوب الحج هو البيت لإضافته إلى الحج في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾^(٢) وليس السبب الوقت أو الاستطاعة لعدم الإضافة إليهما ولا يتكرر بتكررهما، مع صحة الأداء بدون الاستطاعة كما فى الفقير، ولكن الوقت شرط لجواز الأداء والاستطاعة شرط لوجوبه، لأنه لا جواز بدون الوقت، ولا وجوب بدون الاستطاعة^(٣).

٧- سبب وجوب العُشر والخراج:

هو الأرض النامية، لكن العشر يكون نماء الأرض حقيقياً، وفي

(١) راجع: كشف الأسرار ٢/٣٥٠؛ التوضيح والتلويع ٢/١٤٢-١٤٣.

(٢) سورة آل عمران من الآية (٩٧).

(٣) راجع: كشف الأسرار ٢/٣٥٣؛ التوضيح والتلويع ٢/١٤٣.

الخراج يكون نماءً تقديرياً، وهو التمكن من الزراعة والانتفاع، وذلك لأن العشر مقدر بجنس الخارج، فلا بد من حقيقته، والخراج مقدر بالدراهم، فيكفي النماء التقديري.

وجوه الاتفاق والاختلاف بين العشر والخراج:

يتفقان في أن كلا منهما مؤنة للأرض حتى لا يُعتبر فيه الأهلية الكاملة، لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الحين الموعود، وذلك بالأرض وما يخرج منها، فتجب عمارتها والنفقة عليها كالعبيد والدواب.

ووجه الاختلاف بينهما: أن الخراج للمقاتلة الذابين عن الدار، الحامين لها من الأعداء، أما العشر فهو للمحتاجين والضعفاء الذين بهم يستنزل النصر على الأعداء ويستمطر في السنة الشهباء.

وأيضاً: فإن العشر عبادة باعتبار النماء الحقيقي، لأن الواجب جزء من النماء، أي الخارج من الأرض قليل من كثير، بمنزلة الزكاة من المال النامي.

وأما الخراج فإنه عقوبة باعتبار النماء التقديري، لما في الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن الجهاد الأصغر والأكبر، والإقبال على المبعوض المذموم بلسان الشرع، والدنو من رأس الخطيئات، وهذا يصلح سبباً للذلة والصغار وضرب ما هو بمنزلة الجزية.

ولما كانت الأرض أصلاً، والنماء وصفاً، يكون كل منهما باعتبار الأصل مؤنة، أما باعتبار الوصف فالعشر عبادة والخراج عقوبة، فيتناهيان باعتبار الوصف، فلا يجتمعان في سبب واحد هو الأرض النامية هذا مذهب الحنفية.

وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -: يجب العشر في الأرض الخراجية، وإن لم يجب الخراج في الأرض العشرية، وذلك لأن سبب الخراج عنده الأرض،

وسبب العشر الخارج من الأرض^(١).

وعليه: فتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والشافعية في جواز اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة.

فعند الشافعية: يجوز اجتماعهما، لأنهما حقان مُختلفان، وجبا في محلين بسببين مُختلفين، فلا يتنافيان.

وعند الحنفية: لا يجوز اجتماعهما، لأن سبب الحقين واحد، وهو الأرض النامية^(٢).

٨- سبب الطهارة:

هو إرادة الصلاة، لترتيبها عليها في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾^(٣) أي إذا أردتم القيام للصلاة، ومثل هذا مشعر بالسببية.

أما الحدث: فهو شرط لوجوب الطهارة، لأن الغرض من الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي الله تعالى بصفة الطهارة، فلا يجب تحصيلها إلا على تقدير عدمها، وذلك بالحدث، فيتوقف وجوب الطهارة على الحدث، فيكون شرطاً، ولهذا لو توضأ من غير وجوب، كما لو توضأ قبل الصلاة واستدام إلى الوقت، جازت الصلاة بها، لأن المُعتبر في الشرط هو الوجود، قصد أو لم يقصد.

وليس الحدث بسبب، لأن سبب الشئ ما يفضى إليه ويلائمه، والحدث يزيل الطهارة وينافيه^(٤).

(١) راجع: التلويح ١٤٣/٢-١٤٤؛ كشف الأسرار ٣٥٤/٢.

(٢) راجع: الهداية ١٥٩/٢؛ المجموع ٥٤٣/٥.

(٣) سورة المائدة من الآية (٦).

(٤) التلويح ١٤٤/٢.

٩- سبب الحدود والعقوبات والكفارات:

أسباب الحدود والعقوبات: ما نسب إليه، لأن السبب يكون على وفق الحكم، فأسباب الحدود والعقوبات المحضة تكون محظورات محضة، كالزنى والسرقه والقتل وغيرها.

أما أسباب الكفارات، فما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة، فالفطر في رمضان مثلاً من حيث إنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له مُباح، ومن حيث إنه جناية على العبادة، محظور، وكذا الظهار والقتل الخطأ وصيد الحرم ونحو ذلك، فإن فيها كلها جهة من الحظر والإباحة، بخلاف الشرب والزنا، فإنه يلاقي حراماً محضاً^(١).

١٠- سبب شرعية المعاملات:

هو البقاء المقدر، يعني: إرادة الله سبحانه وتعالى بقاء العالم إلى حين علمه، فالزمان الذي قدره تعالى سبب لشرعية المعاملات كالبيع والنكاح والإجارة وغيرها.

توضيح ذلك: أن الله تعالى قدر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاء إلى قيام الساعة، وهو مبني على حفظ الأشخاص، إذ بها بقاء النوع، والإنسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك، وهذا يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد النوع.

ثم يحتاج للتوالد والتناسل إلى ازدواج بين الذكور والإناث، وقيام بالمصالح، وكل ذلك يفتقر إلى أصول كلية مقدرة من عند الشارع بها يتحقق العدل والنظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع، والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص، إذ كل واحد يشتهي ما يلائمه ويفضبه على من

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٤٤/٢.

يزاحمه، فيقع الجور ويختل أمر النظام، فلهذا السبب شرعت المعاملات^(١).

١١- سبب الاختصاصات الشرعية:

المُرَاد بالاختصاصات الشرعية: أثر أفعال العباد، كالمالك في البيع، والحل في النكاح، والمنفعة في الإجارة، والحُرمة في الطلاق، وسبب هذه الاختصاصات هي الأفعال التي هي آثارها، وهي التصرفات المشروعة، كالإيجاب والقبول مثلاً^(٢).

الفرق بين العبادات والمعاملات:

الأحكام الشرعية إن تعلقت بأمر من أمور الآخرة، فهي العبادات، وإن تعلقت بأمر من أمور الدنيا، فهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص، وهي المعاملات، أو ببقاء النوع باعتبار المنزل، فهي المناكحات، أو باعتبار المدنية والمجتمع، فهي العقوبات.

(١) التلويح ١٤٤/٢.

(٢) المرجع السابق.

رابعاً: الشرط:

الشرط لغة: العلامة اللازمة، وقيد باللازمة للتمييز بينه وبين العلامة الحقيقية، ويقرأ الشرط - بفتح الشين والراء - وجمعه أشراط ومنه قوله تعالى في شأن الساعة: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾^(١) أي علاماتها.

ويقرأ الشرط - بفتح الشين وسكون الراء - وجمعه: شروط^(٢).

واصطلاحاً: اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب، أي يتوقف عليه وجود الشيء، بأن يوجد عند وجوده لا بوجوده، كقول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق يتوقف على وجود الدخول، ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إلى الدخول موجوداً عنده، لا واجباً به، بل الوقوع بقوله: أنت طالق عند الدخول.

فمن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به، ولا من حيث الوصول إليه، لم يكن الدخول سبباً ولا علة، بل كان علامة، ومن حيث إنه مضاف إليه كان الدخول شبيهاً بالعلل، وكان بين العلامة والعلة، فسميناه شرطاً^(٣).

أقسام الشرط:

قسم صدر الشريعة الشرط إلى أربعة أقسام:

الأول: شرط محض.

الثاني: شرط فيه معنى العلة.

الثالث: شرط في معنى السببية.

الرابع: شرط مجازاً.

(١) سورة محمد من الآية (١٨) .

(٢) راجع: القاموس المحيط ٣٦٨/٢ فصل الشين باب الطاء؛ المعجم الوجيز ص ٣٤٠.

(٣) راجع: أصول السرخسي ٣٠٣/٢.

أولاً: الشرط المحض:

هو ما كان وجود الحكم مضافاً إليه، ولم يتخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مُختار غير منسوب إليه، وكان غير متصل بالحكم وعارضته علة تصلح لإضافة الحكم إليها، كدخول الدار في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن وقوع الطلاق يضاف إلى الشرط ولم يوجد تخلل، وعارضته علة صالحة لإضافة الحكم إليها.

وللشرط المحض قسمان: حقيقي، وجعلي.

أما الحقيقي: فهو ما يتوقف عليه الشئ في الواقع أو بحكم الشارع، حتى لا يصح الحكم بدونه أصلاً، كالشهود للنكاح، أو يصح بدونه عند تعذره كالطهارة للصلاة.

وأما الجعلي: فهو ما يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته، وذلك إما بكلمة الشرط كقوله: إن تزوجت فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدل الكلام على التعليق، كدلالة كلمة الشرط عليه، كقوله: المرأة التي أتزوجها فهي طالق، فإنه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أن ترتب الحكم على الوصف تعليق له بالشرط.

ويختلف الشرط الحقيقي عن الجعلي في الأثر، فأثر الشرط الحقيقي لا يصح الحكم بدونه إلا عند تعذره، وأثر الجعلي ليس كذلك، فهو يمنع انعقاد العلة عند الحنفية، ويمنع الحكم عند الشافعية.

ثانياً: الشرط في حكم العلة:

هو ما كان وجود الحكم مضافاً إليه، ولم يتخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مُختار غير منسوب إليه، وكان غير متصل بالحكم، ولم تعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها، فيضاف الحكم إلى الشرط خلفاً عن العلة، لأنه يشبهها في توقف الحكم عليه أما إذا وجدت العلة الحقيقية، فلا عبرة بما يشبهها، لأنه لا عبرة بالخلف عند وجود الأصل.

مثاله: شهد شاهدان أن رجلاً قال لامرأته غير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وشهد آخران بأنها دخلت الدار، وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر، فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أداه إلى المرأة من نصف المهر، لأنهما شهود الشرط السالم عن معارضة العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها، وإن رجع شهود اليمين ودخول الدار معا فالضمان على شهود التعليق، لأنهما شهود العلة، إما باعتبار ما يؤول إليه، أو باعتبار أن العلة أعم من الحقيقة ومما فيه معنى السببية أو باعتبار أنه بعد شهادة الفريقين وقضاء القاضي اتصل الحكم بالعلة، فكملت العلية، ومع وجود العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها، لا جهة للإضافة إلى الشرط.

ولم يضاف الحكم إلى الآخرين، لأنهما خلف وشبهه، ولا عبرة بالخلف والشبه مع وجود الأصل، كما أنه لا عبرة بالسبب عند وجود العلة، وذلك كما إذا شهد شاهدان على أن الرجل خير امرأته في نفسها، وشهد آخران على أن المرأة اختارت نفسها، فإذا قضى القاضي بوقوع الطلاق، ورجع الفريقان، كان الضمان على الآخرين، لأنهما علة، لأن الاختيار يستحق به لزوم المهر، وأما الأولان فسبب، لأن التخيير قد يفضي إلى الحكم إذا اختارت، وقد لا يفضي إذا لم تختار، ولا عبرة بالسبب، فيضاف الحكم إلى العلة دون السبب، فكذا يضاف الحكم إلى العلة دون الشرط.

فالشاهدان الأولان هما شاهدا التخيير، وهذا هو السبب، والشاهدان الآخران هما شاهدا الاختيار، وهذا هو العلة وعند اجتماعهما يضاف الحكم إلى العلة لا إلى السبب^(١).

ثالثاً: الشرط في معنى السببية:

هو الذي اعترض عليه فعل فاعل مُختار، أو هو الشرط الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مُختار، غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٤٥/٢.

الشرط المحض مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق، إذ التعليق وهو فعل المُختار لم يعترض على الشرط، وخرج ما إذا اعترض فعل فاعل غير مُختار، بل طبيعي كما إذا شق زق الغير فسال المائع فتلف.

وخرج ما إذا كان فعل المُختار منسوباً إلى الشرط، كما إذا فتح الباب على وجه يفر به الطائر فخرج، فإنه ليس في معنى السبب، بل في معنى العلة، ولهذا يضمن.

مثاله: حل رجل قيد عبد الغير، فأبق العبد، لا يضمن عندنا، لأن حل القيد لما كان متقدماً على الإباق الذي هو علة التلف، كان شرطاً في معنى السبب، لا في معنى العلة، لأن العلة ههنا مستقلة غير مضافة إلى السبب ولا حادثة به^(١).

رابعاً: الشرط المجازي:

ويُسمى الشرط اسماً لا حُكماً، كما إذا علق الطلاق بشرطين، فأولهما وجوداً هو الشرط اسماً، لتوقف الحُكم عليه في الجملة، لا حُكماً لعدم تحقق الحُكم عنده.

مثاله: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، والحكم في ذلك: أنه إذا وجد الشرطان بأن دخلت الدارين وهي في ملكه تطلق اتفاقاً، وإذا وجد الشرطان بأن دخلت الدارين وهي في غير ملكه، فإنها لا تطلق اتفاقاً.

وإذا وجد الأول وهي في ملكه، ثم أبانها فوجد الثاني، لا تطلق اتفاقاً، وإذا أبانها قبل الدخول لأحد الدارين، فدخلت إحداها وهي بائن، ثم تزوجها ودخلت الثانية، تطلق خلافاً لزفر.

وجهة من قال بالطلاق: إن اشتراط الملك لصحة الجزاء، وليس شرطاً لصحة الشرط، وما دام الملك موجوداً عند دخول الدار الثانية فإنها لا

(١) راجع: التوضيح والتلويح ١٤٧/٢.

تطلق، ولا يشترط الملك لبقاء اليمين، لأن محلها الذمة، فتبقى ببقائها ما لم تنحل، فلا يشترط الملك عند الأول.

وجهة زفر في عدم وقوع الطلاق: أن الشرطين كشئ واحد في وجود الجزاء، فإذا شرط الملك في أحدهما وجب أن يشترط في الآخر.

ورد على دليله بأن شرط الملك عند الثاني، لأنه حال نزول الجزاء، وهو مُفتقر إلى الملك^(١).

(١) المرجع السابق.

خامساً: العلامة:

العلامة في اللغة: المعرف والأمانة، كالميل في الطريق، والمنارة في المسجد، فالمنارة علامة الجامع لأنها معرفة له، والميل علامة الطريق لأنه معرف له.

وفي الاصطلاح: ما يكون معرفاً للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافاً إلى العلامة، وجوباً لها لا وجوداً عندها^(١).

أو يُقال في تعريفها: ما تعلق بالشئ من غير تأثير فيه ولا توقف عليه، بل من جهة أنه يدل على وجود الشئ.

مثالها: الإحصان بالنسبة لوجوب الرجم للزاني، فإنه علامة يعرف بظهوره كون الزنى موجباً للرجم، وهو - أي الإحصان - ليس بعلة ولا سبب ولا شرط محض في إيجاب الرجم، فيكون وجوب الرجم حكماً، علته الزنى، والإحصان علامة على وجوب هذا الحد.

واستبعد البعض كون الإحصان علامة، لأن وجوب الرجم موقوف عليه، ولهذا أطلق عليه بعضهم شرطاً على الإطلاق، والبعض الآخر أسماه شرطاً في معنى العلامة.

وقد أنكر صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - كون الإحصان شرطاً، معللاً ذلك: بأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو، فيكون متأخراً في الوجود على وجود صورة العلة، كدخول الدار المعلق عليه الطلاق، وهنا الإحصان سابق على العلة وهي الزنى؛ لأن علية الزنى لوجوب الرجم لا تتوقف على إحصان يحدث متأخراً.

ولكون الإحصان علامة لا شرطاً، صح ثبوته بشهادة الرجال مع النساء، مع أن الزنى لا يثبت إلا بشهادة الرجال وحدهم، لقوله تعالى ﴿ثُمَّ

(١) راجع: أصول السرخسي ٣٠٤/٢.

لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ^(١) لَأَنَّ الْعُقُوبَاتِ مِمَّا يَحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهَا، وَتَدْرَأُ بِالشَّبَهَاتِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ قَاصِرَةٌ؛ لِنَقْصَانِ عَقْلِهِنَّ وَقِلَّةِ تَدِينِهِنَّ^(٢).

ونظراً لأن العلامة ليست في معنى العلة، يجوز أن تثبت العلامة بما لا تثبت به العلة، ولهذا قال صاحبان: تقبل شهادة القابلة على الولادة من غير فراش أو حبل ظاهر.

وتوضيح ذلك: إذا علق رجل طلاق زوجته أو عتق عبده على ولادة امرأة، ولم يقر بأنها حبل، ثم شهدت القابلة على ولادتها، يثبت بها وقوع الطلاق والعتاق، لأن هذا شرط بمنزلة العلامة من حيث إن الطلاق إنما يصير مضافاً إلى نفس الولادة وجوداً عندها، وأما ظهور الولادة فمعرّف، لا يضاف إليه الطلاق وجوباً به ولا وجوداً عنده، والولادة تظهر بشهادة النساء في غير هذه الحالة، حتى يثبت النسب بشهادة القابلة وحدها.

ولكن أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - يقول: إن الولادة شرط محض، من حيث إنه يمنع ثبوت علة الطلاق والعتاق حقيقة إلى وجوده، ثم لا يكون الطلاق والعتاق من أحكام الولادة، وشهادة القابلة حجة ضرورية في الولادة، لأنه لا يطلع عليها الرجال، فإنما تكون حجة فيما هو من أحكام الولادة، أو مما لا تنفك الولادة عنه خاصة، فأما في الطلاق والعتاق هذا الشرط كغيره من الشرائط، لأن الطلاق والعتاق لا ضرورة فيهما، لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلا تقبل فيه شهادة الواحدة^(٣).

ونظير ذلك: شهادة المرأة الواحدة على أن الأمة ثيب، وقد بيعت على أنها بكر، فشهدت امرأة واحدة بأنها ثيب، فتقبل في شهادة الأمة بنفسها، ولا تقبل في استحقاق ردها على البائع، بل يحلف البائع.

أقسام العلامة: تنقسم العلامة إلى أربعة أقسام نذكرها إجمالاً فيما

(١) سورة النور من الآية (٤).

(٢) راجع: التوضيح والتلويح ١٤٩/٢.

(٣) التوضيح والتلويح ١٤٩/٢؛ أصول السرخسي ٣٢٩/٢.

يلي:

الأول: علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجوداً قبله، وذلك مثل علم الثوب وعلم العسكر، وهذا حد العلامة المحضة.

الثاني: علامة بمعنى الشرط، وذلك مثل الإحصان في حكم الرجم.

الثالث: علامة هي علة، لما عرف أن العلل الشرعية بمنزلة العلامات للأحكام.

الرابع: علامة تسمية ومجازاً، وهي علل الحقائق المُعتبرة بنواتها^(١) والله أعلم.

(١) راجع: أصول السرخسي ٣٣١/٢.

الأسئلة

- س١: عرف الحكم التعليقي، ثم اذكر أقسامه مع التمثيل وبيان وجه الحصر في تلك الأقسام.
- س٢: عرف العلة لغة واصطلاحاً، ثم اذكر أقسامها مع التفصيل والتمثيل.
- س٣: عرف السبب لغة واصطلاحاً، ثم اذكر أقسامه مع التمثيل.
- س٤: عرف الشرط لغة واصطلاحاً، ثم اذكر أقسامها مع تعريف كل قسم والتمثيل لكل ما تذكر.
- س٥: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها: (الركن- العلة- السبب- الشرط- العلامة)

الأهلية وعوارضها

سبق تعريف الأهلية عند الكلام عن شروط المحكوم عليه، وسنتناول هنا أقسامها بالتفصيل (أهلية وجوب وأداء):

قسم فقهاء الحنفية الأهلية إلى: أهلية وجوب وأهلية أداء.

أولاً- أهلية الوجوب

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. أو هي وصف يعتبر الإنسان أهلاً لما له وعليه^(١)، وسميت كذلك لأنها تتعرض لما يجب للشخص وما يجب عليه، أو بعبارة أخرى صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، وهي ملازمة لوجود الروح في الجسد من غير نظر إلى عقل وتمييز.

مناط أهلية الوجوب:

ومناط هذه الأهلية الذمة، والذمة صفة شرعية يقدرها الشارع في الشخص، يصير بها أهلاً لثبوت الحقوق له أو عليه، وتثبت للشخص بمجرد وجود الحياة فيه، فمتى تحققت الحياة وجدت الذمة، وبوجودها توجد أهلية الوجوب، لذا فهي ثابتة للجنين قبل أن يولد^(٢).

وتنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين:

الأول: أهلية وجوب ناقصة:

وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له دون أن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت هذه للجنين قبل ولادته، وبها يكون صالحاً لثبوت بعض الحقوق له، وهي التي يكون فيها منفعة، ولا تحتاج إلى قبول، كالإرث

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٦١/٢.

(٢) قال ابن قدامة: "وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي يفهم به التكليف في ثاني الحال". روضة الناظر ١٦٢/١.

وثبوت النسب من أبويه والوصية والوقف^(١)، وبناءً على هذا لو مات رجل وامرأته حامل فالجنين يعد من ورثته.

ويوقف له أكبر النصيبين من نصيب الذكر والأنثى، وإذا أوصى شخص لحمل امرأة بشئ صحت الوصية وكذا لو وقف إنسان شيئاً وجعل منفعته لجنين امرأة حامل، استحق الجنين هذه المنفعة وتتوقف ملكية ذلك كله عند ولادته حياً، فإذا ولد حياً ثبتت له الملكية مستندة إلى وقت وجود سببها بأثر رجعى، وإن ولد ميتاً رد ذلك إلى أصحابه الأصليين.

أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول فإنها لا تثبت للجنين لأنه ليست له عبارة مطلقاً وليس له ولى ولا وصى حتى يقبل عنه.

الثاني: أهلية وجوب كاملة:

وهى صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه، وتثبت هذه الأهلية للشخص بمجرد ولادته حياً، ويكون صالحاً لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، غير أن أهلية الوجوب رغم كمالها بعد الولادة، فهى لا تجعل الإنسان صالحاً للتعامل، فلا يكون لصاحبها حق التعاقد والالتزام بنفسه إلا إذا كانت له أهلية أداء، فأهلية الوجوب لا تتعلق بالتعامل مطلقاً، إذ الذى يجعل الشخص أهلاً للتعامل هو أهلية الأداء^(٢).

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٦٣/٢؛ شرح المنار وحواشيه لابن ملك ٩٣٨.

(٢) شرح المنار لابن ملك ٩٣٨؛ شرح التلويح على التوضيح ١٦٤/٢.

ثانياً- أهلية الأداء

وهى صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يُعتد به شرعاً^(١).

مناط أهلية الأداء:

مناط أهلية الأداء هو التمييز والعقل، فإذا وُجدت الأهلية، وإذا انتفيا انتفت؛ لأن التمييز والعقل يجعل الإنسان مدركاً لعبارته، فيفهم ما يترتب على قوله من نفع أو ضرر. وتنقسم هذه الأهلية أيضاً إلى قسمين تبعاً لكمال تمييز العقل ونقصانه.

الأول: أهلية أداء ناقصة:

وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر أو صدور التصرفات التى يتوقف نفاذها على رأى غيره، وتثبت هذه للصبي إذا بلغ السابعة وكان عاقلاً، أى صبيّاً مميزاً ولم يصل إلى سن البلوغ، ومن ثم يصح بعض التصرفات منه دون البعض الآخر، وفى حكم الصبي المميز المعتوه البالغ فإنه قاصر العقل كالصبي المميز وسبب تحديد بدء هذه الفترة من بلوغ الصبي السابعة، أن هذه السن هى التى يكون فيها مميزاً، والفرق بين التمييز وعدمه - كما قال الفقهاء- أن المميز يدرك الحسن من القبيح، والطيب من الخبيث، والحلو من المر، والصدق من الكذب^(٢).

وفى هذه الحالة نفرق بين حقوق الله وحقوق العباد أما حقوق الله تعالى فتصح من الصبي المميز كالإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج، ولكن لا يكون ملزماً بأداء العبادات إلا على جهة التأديب والتعويد، حتى إذا بلغ شب وتعود عليها.

أما حقوق العباد فقد قسم الحنفية عقودهم المالية إلى ثلاثة أقسام:

(١) راجع: مرآة الأصول ٣٢١؛ والتلويح ٣٣٧/٢.

(٢) راجع: حاشية ابن عابدين ٢٥٧/٤.

١- عقود نافعة نفعاً محضاً، وهى التي يترتب عليها دخول شئ فى ملكه من غير مقابل، مثل قبول الهبة والوصية والوقف، فهذه العقود تصح منه، ولا تحتاج إلى إذن وليه، لأنها خير على كل حال.

٢- عقود ضارة ضرراً محضاً، وهى التي يترتب عليها خروج شئ من ملكه من غير مقابل، مثل الهبة والوقف وسائر التبرعات فهذه العقود لا تصح منه وتقع باطلة، ولا تنفذ حتى لو أجازها الولي، لأن الولي لا يملك إنشاء هذه العقود ابتداءً، لأن تصرفاته مقيدة بما لا يكون فيه ضرر للصغير.

٣- عقود دائرة بين النفع والضرر، وهى التي تحتل الربح والخسارة، كالبيع والشراء والإيجار والزواج.

فهذه العقود تنعقد على الراجح صحيحة إذا أذنه وليه قبل التصرف، وإلا فهي موقوفة على إجازته^(١).

الثانى: أهلية أداء كاملة:

صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً، وعدم توقفها على رأى غيره.

وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد، وصاحب هذه الأهلية يكون صالحاً لإنشاء جميع التصرفات، وتنفذ دون التوقف على إذن أحد^(٢).

ويعرف البلوغ بظهور علامته الطبيعية عند الصبى والفتاة، وعند عدم وجود هذه العلامات فى تقدير سن البلوغ، فالذى عليه الجمهور ومنهم محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحباً أبى حنيفة أن البلوغ يقدر بخمسة عشر عاماً، لأن هذه السن هى السن الغالبة التي فيها تكتمل مظاهر الرجولة عند الرجل ومظاهر الأنوثة عند الأنثى، أما أبو حنيفة

(١) راجع: شرح التلويح على التوضيح ٣٤٤/٢-٣٤٦.

(٢) راجع: شرح التلويح على التوضيح ٣٤٢/٢؛ شرح المنار لابن ملك ٩٣٩.

فقدرها ثمانية عشر عاماً للفتى وفى رواية تسعة عشر، وقدرها سبعة عشر عاماً للفتاة وفى رواية ثمانية عشر^(١).

ومعنى الرشد عند الفقهاء: حسن التصرف فى المال والقدرة على استثماره استثماراً حسناً^(٢).

أدوار أهلية الإنسان:

وبناء على ما سبق قسم العلماء حياة الإنسان بالنظر إلى الأهلية إلى أربعة أدوار هي:

الأول: الجنين في بطن أمه، **الثانى:** من ولادة الجنين حياً إلى سن التمييز، **الثالث:** من سن التمييز إلى البلوغ، **الرابع:** ما بعد البلوغ، على التفصيل الآتي:

الدور الأول:

وهو دور الإنسان أثناء حملها في بطن أمه، ويثبت للجنين في بطن أمه أهلية وجوب ناقصة، فيكون أهلاً لأن تثبت له حقوق فقط دون أن تلزمه حقوق لغيره بشرط انفصاله عن بطن أمه حياً.

والحقوق التي تثبت هي الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول كالإرث والوصية والوقف، أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالشراء والبيع والهبة لا تثبت له، لأن الجنين ليست له عبارة، كذلك لا يجب في ماله شئ من نفقة أقاربه المحتاجين.

(١) الميزان للشعرانى ٨٤/٢؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٥/٥؛ فتح الله المعين لأبى السعود ٢٩٨ / ٣.

(٢) هذا هو معنى كلام الفقهاء أن الرشد هو الصلاح في المال وعليه الجمهور، ويرى الشافعية أن الرشد هو الصلاح في الدين المال معاً، ويرى الشافعية هو الصلاح في الدين والمال معاً، فالفاسق عندهم لا يعتبر رشيداً، لأن عدم حفظه لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله. راجع: المجموع شرح المذهب ١٢ / ٣٧٤؛ حاشية ابن عابدين ١٥٠/٦؛ كشف القناع للبهوتى ٤٥٢/٣.

والسبب في اعتبار نقص أهلية الوجوب للجنين لماله أمران: الأمر الأول أنه جزء من أمه، والأمر الثاني أنه نفس مستقلة محتملة الوجود، فبحسب الاعتبار الأول لم يجعل له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وبحسب الاعتبار الثاني جعل له ذمة ناقصة تؤهله لاكتساب بعض الحقوق.

واشترط الفقهاء لاستحقاق الجنين هذه الحقوق الموقوفة له أن ينفصل عن بطن أمه حيًا، فلو انفصل ميتًا لم يستحق شيئًا وردت الحقوق إلى أصحابها، فيوزع ما أوقف له من الميراث على باقي الورثة، وترد الوصية إلى الموصي.

الدور الثاني:

وهو دور الصبا، ويبدأ هذا الدور من حين الولادة حيًا حتى سن التمييز وهي السابعة، وفي هذا الدور يثبت للصبي أهلية وجوب كاملة، ويصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يجوز للولي أداؤها نيابة عنه كالزكاة وصدقة الفطر والنفقات.

أما أهلية الأداء فلا تثبت له لضعف بنيته، وقصور عقله عن فهم الخطاب، فلا يطالب بأداء شيء بنفسه، بل يطالب وليه بتحصيل ما يثبت له من الحقوق، فلا تصح تصرفاته القولية، ولا يؤخذ مؤاخذه بدنية بشيء من أفعاله، ولكن يضمن ما أتلف من مال.

الدور الثالث:

وهو دور التمييز، ويبدأ هذا الدور من سن السابعة إلى البلوغ، والإنسان في هذا الدور له عقل لكنه قاصر، فتثبت له أهلية الوجوب الكاملة، لأنها للصبي غير المميز، فتثبت له من باب أولى، لأنه أحسن حالًا من الصبي غير المميز.

ونظرًا لقصور عقله تثبت له أهلية أداء ناقصة، فلا يطالب بشيء من

العبادات إلا على سبيل التأديب، ويؤاخذ بأقواله وأفعاله مؤاخذه بدنية.
أما بالنسبة لعقوده المالية فقد قسمها الحنفية ثلاثة أقسام كما بينها
سابقاً.

الدور الرابع:

وهو الدور الذى يبلغ فيه الإنسان عاقلاً، فمتى بلغ الإنسان سواء كان
بلوغه بعلامة من العلامات الطبيعية أو بالسن، نشب له أهلية وجوب كاملة،
وأهلية أداء كاملة، ويصير أهلاً لتوجه الخطاب إليه بجميع التكاليف
الشرعية، وتصح منه جميع الالتزامات، سواء له أو عليه، ويعتد بأعماله
كلها، فتترتب عليها الآثار إلا إذا اعترضه عارض من عوارض الأهلية فهنا
تتأثر أهليته بهذا العارض، وبالتالي تتأثر تصرفاته حسب ما سنبينه عند
كلامنا عن عوارض الأهلية، ومدى تأثير تصرفات الإنسان بها.

الأسئلة

س١: عرف الأهلية، وما هو مناطها؟ ثم اذكر أقسام الأهلية مع التمثيل لكل قسم.

س٢: عرف أهلية الوجوب، وما هو مناطها؟ وما هي أقسامها؟ مع التمثيل لكل قسم.

س٣: قارن بين أهلية الوجوب الكاملة وأهلية الوجوب الناقصة مع التمثيل.

س٤: عرف أهلية الأداء، وما هو مناطها؟ وما هي أقسامها؟ مع التمثيل لكل قسم.

س٥: قارن بين أهلية الأداء الكاملة وأهلية الأداء الناقصة مع التمثيل.

س٦: تكلم عن أدوار أهلية الإنسان بالتفصيل والتمثيل.

س٧: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها: (أهلية وجوب كاملة- أهلية وجوب ناقصة- أهلية أداء كاملة- أهلية أداء ناقصة- أدوار الأهلية)

عوارض الأهلية

هي الأمور التي تطرأ على الإنسان بعد كمال أهليته فتؤثر فيها، إما بإلغاء الأهلية كالجنون، أو بنقصها كالعته، أو بتغيير بعض الأحكام لمصالح اقتضت هذا التغيير كالسفه والغفلة.

وهذه العوارض قسمان:

عوارض سماوية لا دخل للإنسان فيها كالجنون، وعوارض مكتسبة، وهي التي للإنسان دخل فيها كالسفه والسفر.

وفيما يلي نتناول كل قسم بالتفصيل المناسب مع بيان مدى تأثير هذه العوارض على أهلية الإنسان:

الأسئلة

- س١: عرف عوارض الأهلية، ثم اذكر أقسامها، ثم تكلم بالتفصيل عن اثنين من تلك العوارض.
- س٢: عرف بالمصطلحات الآتية مع التمثيل لكل منها: (عوارض الأهلية- عوارض سماوية- عوارض مكتسبة)

أولاً: العوارض السماوية

١- الصغر

الصغر في اللغة: من صغر الشئ فهو صغير، وجمعه صغار والصغيرة: صفة جمعها صغار، ولا تجمع على صفائر، ويقال: صغرى وصغر، وكبرى وكبر، ومنه الصغار: وهو الذل والهوان، قال - تعالى -: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(١) أي: عن قهر يصيبهم وذُل. ويُقال: صغر في عيون الناس، أي: ذهبته مهابته^(٢).

وأما تعريف الصغر في الاصطلاح: لم أجد تعريفاً محدداً للصغر في الاصطلاح الشرعي، ولكن فهمت معناه من عبارات ساقها في شرح التنقيح، وهى: أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ القطرة، وهو غير لازم لماهية الإنسان^(٣).

فإن قيل: لماذا ذكر الصغر من العوارض مع أنه أصل الخلقة؟

يُجاب عنه: أن آدم وحواء - عليهما السلام - خُلقا بدون صغر، ثم اعترض الصغر أولادهما. ولأن ماهية الإنسان تعرف بدون وصف الصغر فالكبير إنسان، وقد عُرِضَ له وصف الصغر.

والصغر في أول أمره كالجنون في عدم وجود العقل، وقالوا: إذا أسلمت امرأة الصبي فإنه يؤخر عرض الإسلام عليه إلى أن يعقل؛ لأن الصغر له حد ينتهي عنده، فيكون التأخير مفيداً هنا.

أما إذا لم ينتظر وعرض على أبوبة الإسلام فأبياً تقع الفرقة بينه وبين زوجته؛ لأن الصبي قبل البلوغ يكون تابعاً لأبويه، فتقع الفرقة، ويطالب بالمهر في الحال؛ لأن وقوع الفرقة والمطالبة بالمهر من عهدة

(١) سورة التوبة الآية (٢٩) .

(٢) راجع: لسان العرب ٢/٢٤٥٢؛ والمصباح المنير ١/٣٦٥.

(٣) راجع: التوضيح على التنقيح ٢/٣٥١.

الصبي، وهو ليس من أهل الوفاء بحق الزوجة، فينتظر^(١).

ويصح من الصبي أن يُباشر لنفسه ولغيره ما لا ضرر فيه، كقبول الهبة، والوصية، وغير ذلك من الأمور التي فيها نفع محض.

والصبي لا يُحرم من الميراث بالقتل عند الحنفية، فتسقط عنه العقوبة بعذر الصبا؛ لأن فعل الصبي لا يصلح سبباً للعقوبة.

أما الكفر والرق فيحرمان من الميراث؛ لأن الكفر يُنافي أهلية الولاية على المسلم^(٢)، قال - تعالى -: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾^(٣).

وأما أن الرق يمنع من الميراث؛ فلأن الوراثة خلافة الملك والرق يُنافي الملك، فكان الرق مُنافياً للأهلية، فثبت الملك لمولى الرقيق.

وختلاصة الكلام في الصبا: أن الصبي يسقط عنه عهدة ما يحتمل العفو، وإذا عقل فإنه يكون له ضرب من الأهلية، وهي أهلية الأداء الناقصة حتى يبلغ سن التكليف^(٤). وبناء على ما اردت سبق إذا ارتد الصبي، أو استرق فلا يرث.

وأما ما لا يحتمل العفو، لا يسقط عن الصبي كالكفر، فيكون وجوب الإيمان ثابتاً في حقه، وإذا ثبت أن الصبا عجز عن كمال الأهلية والعقل صحت الولاية عليه^(٥).

(١) راجع: زبدة الأسرار في شرح مُختصر المنار: ٢٣٦؛ كشف الأسرار على المنار للنسفي ٤٧٧/٢-٤٧٨.

(٢) راجع: شرح المنار للكاكي ١٢٥٤/٤.

(٣) سورة النساء من الآية (١٤١).

(٤) راجع: شرح المنار للكاكي ١٢٥٤/٤؛ التوضيح على التنقيح ٣٥١/٢؛ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٨١/٤؛ أصول الفقه لو هبة الزحيلي ١٧٠/١.

(٥) راجع: المراجع السابق.

فروع على الصبا

إسلام الصبي

إذا أسلم الصبي المميز صح منه الإسلام، لذا لا يلزمه أن يُعيد إسلامه عند بلوغه، لأن حُكم هذا الإيمان أنه فرض وليس بنفل، لذا تترتب عليه الأحكام المترتبة على إيمان البالغ العاقل من وجوب الميراث، ووقوع الفُرقة بينه وبين زوجته المُشركة، وعدم التوارث بينه وبينها عند الفُرقة بسبب شركها، والدليل على صحة إسلام الصبي:

أ- قوله - تعالى -: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾^(١).

وجه الاستدلال: أن المراد بالحُكم هو النبوة، فإذا صح إسلام الصبي أن يكون داعياً هادياً لغيره، فمن الأولى اعتبار صحة الهداية في حق نفسه، لذا قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، قال: ما للعب خُلقت، قال: فلهذا أنزل الله هذه الآية^(٢).

ب - إسلام الإمام على - كرم الله وجهه -.

لقد حصل أن أسلم الإمام على - كرم الله وجهه - وهو ابن سبع أو ثمانٍ أو عشر سنوات على اختلاف الروايات، وكلها تُعد أحوال صبا، وقد اعتبر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إسلام الإمام علي وهو في هذه السن، فهذا دليل واضح على صحة إسلام الصبي في هذه السن.

والصبي المؤمن يُثاب على إيمانه كما يُثاب البالغ المؤمن على إيمانه، أما عدم أداء الصبي التكليف المترتبة على الإسلام وعدم هذا مطالبة بأدائها فهذا يعود إلى فهم خطاب الشارع المتضمن التكليف، وهو ليس من

(١) سورة مريم الآية (١٢) .

(٢) تفسير ابن كثير ٢١٠/٥.

أهل الفهم في هذه السن، لذا لا يكلف بأداء هذه التكاليف بعد إسلامه^(١).

ويمكن هنا وبعد الإقرار بصحة إسلام الصبي أن يثار التساؤل وهو ما الحكم فيما لو ارتد الصبي بعد إسلامه؟ نقول بأن ردة الصبي مُعتبرة إلا أنه لا يُقتل بسببها، والمبرر لاعتبار ردة الصبي هو أنه كما يتصور الإيمان من الصبي والحكم باعتباره، فكذا يمكن أن نتصور الردة منه بعد هذا الإيمان والحكم باعتبارها.

وقد نُقل عن الإمام أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قوله: إن ردة الصبي غير مُعتبرة، ويبقى مُستمرّاً على إسلامه إلى حين بلوغه، فإذا بلغ واستمر على إسلامه فهو مُسلم، وإن أعلن ردته فهو مرتد، ويُقام عليه حد الردة عندئذٍ^(٢).

حكم عبادة الصبي

الصبي المُسلم إذا قام بأداء العبادات فإن أداءه يكون صحيحاً ويُثاب على هذا الأداء، وثوابه لم يكن لتعلق الخطاب بفعله على وجه الاقتضاء منه، إذ المخاطب هو الولي بأن يأمره بها ترغيباً في فعلها ليعتاد أدائها، حيث إن اعتيادها مظنة عدم تركها عند بلوغه، فالثواب إذن مُرتب على أدائها للترغيب في فعلها، وهذا دليل على صحة العبادة من الصبي إذ إنها لو لم تصح منه لما رتب الشارع الثواب على أدائها^(٣).

زواج الصبي

الصبي وهو في سن الصبا لم يصح له أن يتولى تزويج نفسه بنفسه إنما الذي يتولى تزويجه هو الولي، فإذا زوج الولي الصبي صح هذا الزواج وترتب عليه جميع الأحكام الشرعية المترتبة على الزواج الصحيح، وحُكم عقد الزواج يختلف باختلاف الولي الذي يتولاه، فإذا تولى التزويج

(١) كشف الأسرار للنسفي ٢٦١/٢.

(٢) كشف الأسرار ١٣٧١/٤.

(٣) فواتح الرحموت ١٧٠/١.

الأب أو الجد فالزواج صحيح لازم في حق الصغير والصغيرة، أما إذا تولاه غير الأب والجد من الأولياء فالزواج صحيح، إلا أنه ليس بلازم حيث إنه يجوز لكل من الصغير والصغيرة أن يفسخ هذا الزواج عند بلوغه^(١).

وكالة الصبي عن غيره

لقد قال أكثر الفقهاء بصحة وكالة الصبي عن غيره، لذا صح توكيله في تطلق زوجة غيره أو عتق عبده، أو وكيله بالبيع أو الشراء، لأن هذا التصرف لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصبي، بل يؤدي إلى الفائدة والمنفعة المتمثلة بصحة عباراته واعتبارها، وترتيب آثار الأحكام عليها، فهو في هذه الناحية مُمَاطِل للبالغ العاقل في تصرفه، وهذا النفع يُعتبر من أعظم وجوه النفع عند العُقلاء إذ خص الله - تعالى - بنى آدم وكرمهم به، فقال - تعالى -: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾^(٢)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المرء بأصغريه قلبه ولسانه"^(٣). فهذه الأدلة تفيد أن صحة العبارة في الإنسان هي أعظم وجوه الانتفاع.

وفي توكيل الصبي عن غيره خاصة في البيع والشراء فائدة أخرى يمكن للصبي أن يحصل عليها ألا وهي تدريبه وتوجيهه حتى يكون ملماً بمواطن الغبن والخسران فيتجنبها عند مباشرته البيع والشراء في حق نفسه^(٤).

شهادة الصبي

لقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط الشهادة بين المسلمين ولقبولها من بعضهم على بعض، ومن أجل أن تكون الشهادة صحيحة لابد من تطبيق ضوابط قبول الشهادة عليها ابتداءً.

(١) التقرير والتحرير ١٧٤/٢.

(٢) سورة الرحمن الآيتين (٣، ٤).

(٣) مُجمع الأمثال ٢/٢٢٣.

(٤) أصول السرخسي ٣٤٧/١.

وعند عرض شهادة الصبي على ضوابط الشهادة وقواعد قبولها، نجد أن هذه الشهادة لا تصح لعدم توافر ضوابط الشهادة وقبولها فيها.

ومن ضوابط الشهادة ما جاء بقوله - تعالى - : ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾^(١)، فقد أفادت الآية الكريمة أن من تُقبل شهادتهم هم الرجال والنساء، والصبي ليس منهم، لأنه لم يبلغ مرحلة الرجولة.

كما أن حالة الصبي لا تؤهله لأن يرضى الناس عن شهادته وقد ذكر الإمام القرطبي - رَحِمَهُ اللهُ - في تفسيره لقوله - تعالى - : ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ بأنه نص في رفض شهادة الكفار والصبيان، وقوله - تعالى - : ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾، ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وهذه الصفات ليست في الصبي^(٢).

ومن الأدلة المفيدة لعدم قبول شهادة الصبي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق".

ومن الأدلة العقلية أن ولاية الصبي على أمواله غير مُعتبرة فمن الأولى ألا تُعتبر ولايته على غيره.

ومع ذلك نجد الإمام مالك قد استثنى من هذا العموم قبول شهادة الصبيان على بعضهم في الجروح بشروط أهمها:

- ١- ألا يحضر وقوع الحادث رجل بالغ.
 - ٢- أن يكون الصبي الشاهد مُميزاً.
 - ٣- أن تُعرف شهادة الصبيان قبل تفرقهم وذهاب كل منهم إلى بيته.
- والعلة في قبول شهادتهم حينئذٍ أن الصبيان لا يحضر لعبهم الكبار،

(١) سورة البقرة الآية (٢٨٢).

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨٩.

وقد تقع بينهم الجراح، وهذه تستوجب الشهادة، ولا شهود غيرهم، لذا تُقبل منهم الشهادة في هذه الصورة للضرورة.

وهذا القول مروي كذلك عن عبد الله بن الزبير، والإمام أحمد ابن حنبل بالضوابط المتقدمة^(١).

الأسئلة

س١: من عوارض الأهلية (الصغر)، تحدث عن هذا العارض بالتفصيل مع بيان حكم إسلام الصبي، وزواجه، وشهادته.

(١) يُنظر: عوارض الأهلية للجبوري ١٤٩-١٥٧.

٢- الجنون

الجنون لغة: الستر، تقول: جن الشيء يجنه جناً، بمعنى ستره، وكل شيء ستر عنك، فقد جن عنك، ومنه قوله - تعالى -: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾^(١).

وفي الحديث جن عليه الليل، أي: ستره، ولذلك سميت الجن جناً؛ لاستتارهم، ومنه سمي الجنين؛ لأنه مُستتر في بطن أمه وجن الليل وجنونه: أي: اشتدت ظلمته^(٢).

وأما الجنون في الاصطلاح: فله أكثر من معنى، فقليل معناه: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأقوال والأفعال إلا نادراً^(٣).

وقيل معناه: هو آفة تحل بالدماغ بحيث تمنع جريان الأقوال والأفعال على نهج العقل^(٤).

وعرفه الإمام البزدوي، فقال: المعنى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على أفعال مُضادة لتلك الأفعال من غير ضعف في عامة أطرافه أو فتور في سائر أعضائه يُسمى جنوناً^(٥).

أسباب الجنون:

أولاً: نُقصان جبل عليه دماغ المجنون، وكان من أصل خلقته، فهو مطبوع عليه.

ثانياً: قد يكون سبب الجنون معنى عارضاً زال به اعتدال الدماغ خِلقة بسبب رطوبة مُفرطة، أو يبوسة مُتناهية.

(١) سورة الأنعام الآية (٧٦) .

(٢) راجع: لسان العرب لابن منظور ٧٠١/١.

(٣) راجع: التوضيح على التنقيح ٣٤٨/٢.

(٤) راجع: زبدة الأسرار في شرح مُختصر المنار ٣٣٧.

(٥) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٧١/٤ ط عباس الباز (مكة المكرمة) .

ثالثاً: استيلاء الشيطان على الإنسان فيخيل إليه تخیلات فاسدة، ويفزعه في جميع أوقاته، فيطير قلبه، ولا ينضبط ذهنه، مع سلامة في محل العقل خَلقة، وبقائه على الاعتدال.

وهذا النوع من الجنون يُسمى بالمس، وذلك لوجود وسوسة الشيطان^(١).

أنواع الجنون:

الجنون له نوعان: إما أن يكون جنوناً مُمتداً، أو يكون جنوناً غير مُمتد.

الأول: وهو الجنون المُمتد مُسقط للعبادات التي تحتل السقوط، كالصلاة والصيام، وهناك من الأمور ما لا يحتل السقوط، مثل: ضمان المُتلفات، ووجوب الديات، والأروش.

أما سقوط العبادات عن المجنون جنوناً مُمتداً فهو عدم قدرته على قصد النية في العبادة؛ لعدم وجود العقل.

أما عدم سقوطها في المُتلفات، والديات، فهو أن المُخاطب بذلك، المجنون ولكن يقوم الولي مقامه في مصالح الغير.

الثاني: وهو الجنون غير المُمتد، إما أن يكون طارئاً أو أصلياً، فأما إذا كان الجنون أصلياً فعند الإمام أبي يوسف يكون مُسقطاً للعبادات بناءً على ما هو موجود في الأصل والامتداد.

وقال محمد: إذا كان الجنون أصلياً لا يكون مُسقطاً للعبادات بناءً على إسقاط الامتداد فقط^(٢).

(١) يُنظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٧٢/٤.

(٢) راجع: التلويح على التوضيح ٣٤٩/٢؛ عوارض الأهلية لحسين خلف الجبوري ٦٥.

حكم الجنون غير الممتد

الجنون غير الممتد لا تسقط به الأحكام استحساناً، وذلك لعدة أمور:

أولاً: يلحق بالنوم والإغماء بجامع أن كلا منهما عرض فيكون عُذراً.

ثانياً: إنه لا يُنافي أهلية الوجوب لبقاء دليل الإرث والملك، فكل منهما له فيه حق لا يسقط.

ثالثاً: أنه أهل للثواب وذلك لبقائه على إيمانه حتى بعد الجنون، والمسلم يُثاب على إيمانه، والثواب من أحكام الوجوب مُجملة، والشارع أباح له القضاء في العبادات.

وأما غير الممتد في القياس فمُسقط للعبادات؛ لمُنافاتهِ القُدرة على أداء العبادات، ولهذا عصم الله الأنبياء من الجنون، وإذا لم يقدر على الأداء يسقط الوجوب^(١).

حكم الجنون الممتد

الجنون يختلف حكمه باختلاف العبادات:

فامتداد الجنون المُعتبر في الصلاة، اختلف فيه علماء الحنفية فقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله -: يُعتبر الجنون الممتد بزيادته على يوم وليلة، ولذلك إذا جن قبيل الزوال ثم أفاق في اليوم التالي بعد دخول وقت الظهر فلا قضاء عليه عندهما.

وقال الإمام محمد - رَحِمَهُ اللهُ -: إن الجنون الممتد في الصلاة هو زيادته على يوم وليلة باعتبار الصلوات، أي إن ذلك لا تُعد الصلوات فيه ستاً، فلا يسقط عنه القضاء.

فيترتب على ذلك أنه عند الإمام أبي حنيفة، وأبي يوسف لا قضاء عليه، لأن ذلك يُعتبر أكثر من يوم وليلة من حيث الوقت، وعند الإمام

(١) راجع: التلويح على التوضيح ٣٤٩/٢.

محمد يحسب ذلك باعتبار عدد الصلوات، فإذا مضى عليه وقت ست صلوات يُعتبر ذلك يوماً وليلة، وإذا كان أقل من ست صلوات فإنه يجب عليه القضاء، لأنه يكون قد دخل في حد التكرار^(١).

امتداد الجنون في الصوم:

يُشترط في الجنون الممتد أن يستغرق الشهر كله، ولا يشترط فيه التكرار كما يشترط في الصلاة؛ لأن صوم رمضان وظيفته السنة وليس الشهر.

وعلى ذلك إذا امتد الجنون حتى استغرق الشهر كله لا يجب عليه القضاء، وإذا أفاق في ليلة من رمضان لا يلزمه القضاء، وإذا أفاق في يوم في وقت النية لزمه القضاء، وإذا أفاق بعد وقت النية فيه قولان، الصحيح فيهما أنه لا يلزمه القضاء^(٢).

امتداد الجنون في الزكاة والحج:

اختلف علماء الحنفية في امتداد الجنون في الزكاة والحج، قال الإمام محمد: يقتضى أن يستغرق الجنون الحول كله، لأن الزكاة تدخل في حد التكرار في السنة الثانية، وعلى ذلك إذا جن حولاً كاملاً، وكان مالكا، سقط عنه الأداء.

وقال الإمام أبو يوسف: يقتضى أن يستغرق الجنون أكثر السنة، أما نصف العام فليس بمُعْتَبَر؛ لأن كل وقت الزكاة في الحول كاملاً، وعليه إذا جُنَّ، وكان مالكا للنصاب، فلا تسقط عنه الزكاة إلا إذا مضى عليه الحول كاملاً، فإذا أفاق قبل اكتمال الحول وجبت عليه.

والفرق بين كلا الأمرين: أن الصبي إذا بلغ مجنوناً، وكان مالكا للنصاب، ثم أفاق بعد ستة أشهر، إلى تمام الحول من وقت البلوغ، لم

(١) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٧٩/٤.

(٢) راجع: عوارض الأهلية للجبوري ١٦٧-١٦٩.

تسقط عنه الزكاة عند محمد.

وعند الإمام أبي يوسف لا تجب الزكاة، ويحتسب الحول من وقت الإفاقة ويصير كالصبي الذي بلغ في هذا الوقت.

أما إذا كان الجنون طارئاً فزال بعد ستة أشهر فتجب الزكاة عند الجميع^(١).

أثر الجنون على الأهلية

الجنون يؤدي إلى فقدان التمييز عند المكلف، والتمييز من الأمور التي تستند عليها أهلية المكلف، ففقدانه عند المكلف يعني انعدام الأهلية عنده.

لذا جعل العلماء حكم الجنون يسقط به التكليف فلا يُعتد بتصرفاته من بيع وشراء، وغير ذلك، ولا يلتفت إلى عباراته، ولا يترتب على أقواله أي آثار شرعية.

فيكون الجنون مُفقداً لأهلية الأداء، بخلاف أهلية الوجوب فلا يفقدها المجنون ولا تتأثر بالجنون، فإنه يبقى على إسلامه، ولا يُمنع من الميراث.

فعلى هذا يؤدي الجنون إلى زوال أهلية الأداء، أما أهلية الوجوب فتبقى كما هي لا ترتفع؛ لأنها تثبت بالذمة، والجنون لا يُنافي الذمة^(٢).

ما يثبت للمجنون من حقوق مالية وما يثبت عليه

الجنون لا يترتب عليه تكليفات بدنية، لأن مبنى هذه التكليفات على العقل، وبما أن المجنون فاقد العقل فهو غير مكلف، والدليل على عدم

(١) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٧٧/٤، ٣٨٧؛ عوارض الأهلية للدكتور/ صبري معارك ١٧٤؛ عوارض الأهلية للجبوري ١٦٨، ١٦٩.

(٢) راجع: عوارض الأهلية للجبوري ١٦٩؛ عوارض الأهلية للدكتور/ صبري محمد معارك ١٧٦.

تكليفه ما روي عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"^(١).

فالمجنون إذاً يؤدي إلى إهدار أهلية الأداء في حق المجنون لذا لا يُعتد بكلامه ولا يؤخذ على إقراره.

ويثبت للمجنون أهلية التملك فيما إذا أوصى له أحد، أو وهب له الواهب على أن يقترن التملك لهذه الأمور بقبول الولي، كما أن المجنون يُمكن أن يُثبت له الملكُ بشراء الولي له، أو باستيلائه بنفسه على شئ من الأموال المُباحة، حيث إن الاستيلاء سبب فعلي لثبوت الملكية به من غير حاجة إلى القصد والنية.

كما يثبت للمجنون الملكُ عن طريق الإرث^(٢) حيث إن الإرث نفسه خلافة، إذ الوارث خليفة المورث مُلكاً وتصرفاً فيأخذ حكم الولاية في هذه الحجة، والولاية لا تثبت بدون الذمة.

ويترتب على ثبوت أهلية الوجوب في حقه أن تثبت في ذمته الالتزامات الناشئة عن التصرفات عند وليه ولا يسقط عنه ضمان المُتلفات، والدية، ونفقات الأقارب، كما يلزم المجنون ضمان المال المُتلف من غير إذن صاحب المال المُتلف.

كما أن المجنون يؤخذ عن ضمان الأفعال في الأموال، فإذا أُلِف مال إنسان وجب عليه الضمان كما يجب على العاقل؛ إذ إن المال هو المقصود في حقوق الناس وليس الفعل، والمقصود يحصل بأداء النائب فكان المجنون من أهل وجوبه كالصبي.

أما لو جنى المجنون جناية تتعلق بالنفس كأن قتل عمداً فلا يلزم في

(١) سبق تخريجه.

(٢) تيسير التحرير ٢٦٣/٢.

حقه القصاص إنما تلزمه الدية، وتكون على العاقلة كما في القتل الخطأ، والأمر المسوغ لأن يلزم المجنون ضمان أموال الناس المتلفة من قبله شخصياً أو من قبل وليه: هو تحقيق العدالة بين الطرفين وحفظاً لأموال الناس لأنها معصومة شرعاً، لو لم يجب الضمان لأدى ذلك إلى فوضى تُهدر بسببها أموال الناس الآخرين.

ما يقع على المجنون من عقوبات

العقوبات في الشريعة الإسلامية تتنوع بتنوع الجرائم إلى ثلاثة أنواع

هي: -

١- عقوبة الحدود.

٢- عقوبة القصاص والدية.

٣- عقوبة التعزير، وهو التأديب.

فبالنسبة لعقوبات الحدود والقصاص والتعزير فإنها لا تُقام على المجنون، لأن شرط تنفيذها أن يكون من تُقام عليه عاقلاً، ولانتفاء العقل في المجنون فلا تقام عليه الحدود.

ولأن صحة التكليف مبنية على العقل الذي هو آلة القدرة، وما كان منها مُتعلقاً بحقوق الله - تعالى - فإنه يسقط بالعدر، والمجنون عذر في حق المجنون، أما ما يتعلق منها بحقوق العباد كالقصاص فإنها لا تقبل السقوط إلا أن القصاص لا يُقام على الجاني المجنون إنما يُستعاض عنه بالدية، وتلزم الدية على عاقلته^(١).

إلا أن الإمام الشافعي - رضى الله عنه - قال: "تجب الدية في ماله، إذ إن الواجبات المالية تثبت في ماله".

أما التعزيرات: فإنها لا تُقام على الجاني المجنون لأن الغرض منها

(١) راجع: كشف الأسرار ٢٧٠/٤.

هو التأديب وهو لا يعي ذلك، لهذا لا فائدة من إقامتها عليه.

إلا أن القول بعدم إقامة عقوبات الحدود والقصاص والتعزير على المجنون لا يعني أنه لا ضمان عليه مالياً، بل المجنون إن أتلف مال غيره أو سرق مال غيره فعليه الضمان في ماله في كل ما أتلفه.

أما السرقة فإن كانت عين المال المسروق باقية فيُعاد لصاحبه وإلا فالضمان في مال المجنون، لذا قيل: ويؤاخذ المجنون بضمان الأفعال في الأموال كما إذا أتلف مال إنسان لتحقيق الفعل حساً ولعصمة المحل شرعاً والعذر لا ينافيها^(١).

إسلام المجنون

إذا أسلم المجنون والمجنونة وهما في حالة الجنون لا يصح منهما هذا الإسلام لعدم توفر رُكنه وهو العقل؛ لأن عقد القلب على التصديق إنما يكون بالعقل وهو مفقود بسبب الجنون وعدم اعتبار إسلامهما في الحال لا يُعد ذلك حجراً، لأن الحجر عن الإيمان غير صحيح لأنه نفع محض^(٢).

وهذا بخلاف الإسلام التبعية ونعني به لو كان الأبوان أو أحدهما مُسلماً فهو تبع لهما أو له في إسلامه، لأن هذا من الأمور الحسنة والقاعدة الشرعية أن الابن يتبع أفضل الأبوين ديناً، وهذا ينطوي على رحمة الشارع بعباده، وتحقيق هذه الرحمة يكون بتيسير الإسلام لهم بكل الوسائل وشتى الطرق لأن الإسلام ذاته رحمة ولُطف بالعباد.

وتقع الردة منه بردة الأبوين معاً ولحقه بهما، بينما إذا ارتدا أو لحقا بدار الحرب وبقي هو بدار الإسلام لا يصير مرتدّاً برדתهما، وهذا أيضاً دليل على أن الشارع الحكيم يتحرى للمُسلم النفع، والفائدة في ما يؤدي إليها من وسائل ومساالك، فما على الإنسان إلا أن يسلك طريق الإسلام لأن

(١) مرآة الأصول ٣٢٨؛ عوارض الأهلية للجبوري ١٧٠-١٧٥.

(٢) التقرير والتحبير ١٧٣/٣.

فيه نجاته في الدنيا من متاعبها وضيقها، وفي الآخرة من نارها وأهوالها^(١).

طلاق المجنون

إذا طلق المجنون زوجته فلا يقع طلاقه لأنه لا يعتد بعبارته، ولما روي عن الرسول الكريم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون"^(٢).

ولو حصل أن علق المجنون طلاق زوجته على وقوع أمر من الأمور وهو لا يزال عاقلاً إلا أن هذا المعلق على وقوعه الطلاق قد وقع والمُطلق مجنون وقع طلاقه، وكذا لو حصل أن فوض الزوج زوجته في أن تُطلق نفسها إلا أنها لم تُطلق نفسها إلا بعد أن جن زوجها وقع الطلاق منها.

وإذا كان الحكم ثابتاً في أن المجنون لا يقع طلاقه، فمن يوقع طلاق زوجته، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز تطليق زوجة المجنون من قبل الولي ولو كان الأب، لأن من يملك البضع يملك إيقاع الطلاق، ولقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما رواه ابن ماجه: "إنما الطلاق لمن أخذ الساق"^(٣).

كما أن في إيقاع الطلاق إسقاطاً لحق المجنون وهذا الحق غير مملوك لأحد كالإبراء من الدين^(٤).

القول الثاني: ذكر ابن قدامة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٥) - أن عطاء وقتادة قال

(١) عوارض الأهلية للجبوري ١٧٨-١٨٠.

(٢) السُّنن الكُبرى ٣٥٩/٧؛ نصب الراية ٢٢١/٣.

(٣) ابن ماجه ٦٧٢/١.

(٤) الكافي ٥٧١/٢؛ المجموع شرح المذهب ٥٦/١٧.

(٥) المغني ٣٧١/٧.

بجواز تطليق زوجة المجنون من قبل الأب، واستدلوا على رأيهم هذا بأن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - طلق عن ابن له معتوه، كما رواه الإمام أحمد.

وروي عن ابن عمر: "أن المعتوه إذا عبث بأهله طلق عليه وليه"، ولأنه يصح أن يزوجه فصح أن يُطلق زوجته إذا لم يأنس منهما، مثله في هذا كمثل الحاكم إذ يصح له أن يفسخ الزواج للإعسار، وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه توقف في هذا الحكم واستنتج بعض أصحابه أنه كان يميل إلى جواز ذلك.

والراجع هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم صحة تطليق زوجة المجنون لثبوت النص فيه^(١).

الفرق بين المجنون والصغير في الأحكام

يفترق المجنون عن الصغير في الأحكام بعدة أمور هي: -

- ١- أن عرض الإسلام بالنسبة للمجنون يكون على وليه وبالنسبة للصبي لا يعرض إلا عليه.
- ٢- عرض الإسلام بالنسبة للمجنون لا يؤخر بينما بالنسبة للصبي يؤخر إلى أن يعقل.
- ٣- أن في الجنون العارض غير الممتد يجب قضاء العبادات، بينما لا يجب ذلك في حق الصبي غير العاقل.

(١) عوارض الأهلية للجبوري ١٨٤، ١٨٥.

الأسئلة

- س١: عرف الجنون، وما هي أسبابه؟ وما هي أنواعه؟ وإلى أي عارض من عوارض الأهلية ينسب هذا العارض؟
- س٢: ما هو الفرق بين المجنون والصغير في الأحكام؟ وما هو حكم طلاق المجنون؟

٣- العتة

العتة لغة: من عته عنها من باب تعب، وعتاهًا بالفتح: أي نقص عقله من غير جنون أو دهش، ومنه البناء للمفعول: عتاهة، وعتاهية، فهو معتوه من العتة^(١).

والعتة في الاصطلاح: من اختلط كلامه فكان بعضه ككلام العقلاء، وبعضه ككلام المجانين.

فهو كالصبي مع العقل في كل الأحكام، ولا يمنع صحة قول ولا فعل^(٢).

الفرق بين المعتوه والمجنون

فرق العلماء بين المعتوه والمجنون في عدد من الأمور هي:

الأمر الأول:

المعتوه قد يكون مُميزًا أو غير مُميز، فهو بهذا كالصبي المُميز وغير المُميز، أما المجنون فإنه لا يكون مُميزًا، وهو بهذا كالصبي غير المُميز.

الأمر الثاني:

المعتوه مُصاب بضعف عقلي، أما المجنون فإنه لا عقل له.

الأمر الثالث:

المعتوه لا يُصاحبه في حالة العتة تهيج واضطراب، بينما المجنون قد يُصاحب جنونه في الغالب تهيج واضطراب.

حكم المعتوه

المعتوه كالصبي مع العقل في الأحكام فلا يمنع من صحة القول ولا

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٦٨/٢.

(٢) المصباح المنير ٤٠/٢.

الفعل، وعلى ذلك فإنه تصح منه العبادة حتى لو لم تكن واجبة عليه، وكذلك يصح إسلامه إذا أسلم، ويصح توكيله من الغير في بيع مال غيره، وإعتاق غيره.

ولكن العته يمنع العهدة، أى: يمنع إلزامه بشئ فيه مضرة، فلا يطالب في الوكالة بالبيع والشراء بنقد الثمن وتسليم المبيع، وكذلك لا يرد المبيع عليه بالبيع، ولا يؤمر بالخصومة مع أحد الطرفين^(١).

والخلاصة: أن المعتوه كالصبي في التصرفات، فإذا كانت التصرفات نافعة نفعاً محضاً كقبول الوصية، والهدية، والصدقة فإن ذلك يصح منه بدون إذن الولي.

وإذا كانت التصرفات ضارة ضرراً محضاً، فإنها لا تصح منه حتى لو كان ذلك بإذن الولي كالطلاق، والعتق، والهبة.

وإذا كانت التصرفات دائرة بين النفع والضرر، كالبيع، والشراء، والإجارة، والنكاح، والسلم، وغير ذلك من التصرفات فهذا كله موقوف على إذن الولي بحسب ما يحقق مصلحة المعتوه^(٢).

وأما إذا أتلف المعتوه أموال غيره فلا يدخل في العهدة؛ لأنها مما يحتمل العفو في الشرع، فإذا أتلف مال الغير فإن ذلك ليس من الأمور المنفية عن المعتوه، والضمان شرعاً جبراً لما استهلك من المحل المعصوم، ولهذا قُدر بالمثل، وكون المُستهلك معتوهاً لا يتعارض مع عصمة أموال الناس، وهو المحل المقصود.

وكذلك لا يصح أن يكون المعتوه ولياً عن غيره؛ لأنه يحتاج إلى ولي نفسه، فكيف يكون ولياً على غيره؟^(٣)

(١) زبدة الأسرار في شرح مُختصر المنار ٢٣٩.

(٢) راجع: عوارض الأهلية للدكتور/ صبري معارك ٢٠٣.

(٣) راجع: زبدة الأسرار في شرح مُختصر المنار ٢٤٠؛ عوارض الأهلية للدكتور/ صبري معارك ٢٠٤.

إسلام زوجة المعتوه

إذا كان المعتوه كافرًا متزوجًا ثم أسلمت زوجته وهو في حالة العته، فالحُكم الشرعي الذي قال به جمهور العلماء هو: أن يعرض الإسلام في الحال على المعتوه، فإن أسلم استمر زواجه من امرأته وإن لم يُسلم فرق بينه وبين زوجته، وهو في هذا الحُكم كالصبي المُميز إذا أسلمت زوجته، والمُبَرر لعرض الإسلام على المعتوه والصبي المُميز في الحال هو توفر أصل العقل عند كل منهما، فهذا يكفي لأن يدركا المصلحة عند عرض الإسلام عليهما.

وهذا بخلاف إمراة المجنون إذ إن عرض الإسلام يكون على وليه وليس عليه.

وقد جاء في مرآة الأصول^(١) أن الفقيه حميد الدين الضرير ذهب إلى مخالفة رأي الجمهور في مسألة عرض الإسلام على المعتوه شخصيًا عند إسلام زوجته، بقوله: يلزم عرض الإسلام على وليه دون أن يعرض عليه شخصيًا لأنه لم يكن أهلاً لذلك فهو بهذا كالمجنون، إلا أن هذا القول ليس براجح.

إذن فالراجح هو رأي الجمهور من العلماء، وذلك ضمانًا لحقوق المرأة ودفعًا للضرر عن كل منهما.

ردة المعتوه

المعتوه يشابه الصبي المُميز في كثير من أحكامه، ومن هذه الأحكام الردة، وحُكمها كما يلي:

أولاً: قال الإمام أبو حنيفة ومحمد وأحمد بن حنبل في أحد قوليه بأن المعتوه إن ارتد عن الإسلام صحت ردته، وذلك أخذًا بحُكم القياس

(١) مرآة الأصول ٣٢٩.

على الصبي في رَدِّته عندهم^(١)، ووجه القياس بينهما هو العقل المُميز.

ثانيًا: قال الإمام الشافعي، وأبو يوسف، وزفر، والظاهرية، والإمام أحمد في قوله الثاني، بأن المعتوه إذا ارتد لا تصح منه الردة قياسًا على عدم صحة ردة الصبي المُميز عندهم^(٢)، وذلك لعدم تكليفهم شرعًا، ولقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ"^(٣).

هذه خلاصة الآراء التي وردت في بيان حكم ردة المعتوه، والراجع منها هو عدم اعتبار ردة المعتوه لأنه ليس من أهل التكليف لعدم توجيه الخطاب إليه من الشارع الحكيم^(٤).

(١) شرح فتح القدير ٩٤/٦؛ الإنصاف ٣٢٩/١.

(٢) الأم ١٤٨/٦؛ شرح فتح القدير ٩٤/٦؛ المحلى ١٨٨/١١؛ الإنصاف ٢٣٠/١.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) عوارض الأهلية للجبوري ١٩٩-٢٠٠.

٤- النسيان

النسيان في اللغة: من نسيت الشئ أنساه نسياناً، فهو مُشترك بين أمرين:

الأول: ترك الشئ على ذهول وغفلة.

الثاني: ترك الشئ على تعمّد، ومنه قوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي: تقصدوا عمداً ترك الفضل وذلك بالإهمال.

وتقول: نسيت ركعة، أي: أهملتها ذهولاً، ومنه: رجل نسيان، أي: كثير الغفلة^(١).

أما تعريف النسيان في الاصطلاح: قيل فيه: هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بأفة.

وقيل فيه: معنى يعتري الإنسان بدون اختياره، فيوجب الغفلة عن الحفظ^(٢).

ورود لفظ النسيان في الكتاب والسنة

أولاً: ورود لفظ النسيان في الكتاب:

أ- فمن ذلك وردوده بمعنى التذكر، وهو المعنى الأصلي للنسيان قال - تعالى -: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾^(٣).

قال ابن كثير في تفسير الآية: هذا إرشاد من الله - تعالى - لرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الآداب فيما إذا عزم على شئ ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله - عَزَّجَلَّ - علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون،

(١) راجع: المصباح المنير ٢/٢٧٣.

(٢) راجع: شرح المنار للكاكي ٤/١٢٧٠؛ زبدة الأسرار ٢٣٧.

(٣) سورة الكهف الآية (٢٤).

وما لم يكن لو كان كيف يكون^(١).

وأورد ابن كثير وجهًا آخر في تفسير الآية فقال: هذا إرشاد من الله - تعالى - لمن نسي الشيء بذكر الله - تعالى - ، لأن النسيان منشؤه الشيطان، كما قال فتى موسى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾^(٢)، وذكر الله - تعالى - طارد للنسيان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله سبب للتذكر^(٣).

ب- ومما ورد في القرآن الكريم واستعمل بمعنى الشيء الساقط الذي لا يهتم به ولا يلتفت إليه، قوله - تعالى - : ﴿قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا﴾^(٤)، أي: شيئًا متروكًا لا يُعرف.

ج- ومما ورد في القرآن الكريم واستعمل بمعنى التأخير قوله - تعالى - : ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^(٥)، على من قرأ (نسأها) مهموزًا، أي: نؤخرها، وهو قليل.

د- ومما ورد في القرآن الكريم واستعمل بمعنى الترك، وله أمثلة كثيرة نذكر منها قوله - تعالى - : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾^(٦)، فالنسيان هنا بمعنى الترك.

ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٧)، والمعنى: لما تركوا أمر الله - تعالى -

(١) تفسير القرآن العظيم ٧٨/٣، ٧٩.

(٢) سورة الكهف الآية (٦٣).

(٣) تفسير القرآن العظيم ٧٩/٣.

(٤) سورة مريم الآية (٢٣).

(٥) سورة البقرة الآية (١٠٦).

(٦) سورة الكهف الآية (٥٧).

(٧) سورة التوبة (٥٧).

وارتكبوا نواهيه، تركهم الله من رحمته عقوبة لهم، لأن النسيان لا يصح إطلاقه بمعناه الحقيقي في حق المولى - تبارك وتعالى - ^(١).

ثانياً: ورود لفظ النسيان في السنة المطهرة:

كما ورد ذكر النسيان في القرآن الكريم، ورد ذكره أيضاً في السنة المطهرة، وعلى النحو الذي ذكرنا من معانيه السابقة.

من ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فمعنى النسيان هنا: عدم التذكر، والمُرَاد: وضع الإثم.

ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" ^(٢).

ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" ^(٣).

أنواع النسيان

النسيان ينقسم إلى نوعين:

الأول: النسيان الأصلي: وهو الذي يصلح أن يكون عُذراً يسقط به الإثم عن صاحبه، فلا يؤاخذ عليه.

وإذا كان النسيان يتكرر كثيراً من المكلف ولا يستطيع التحكُّم فيه غالباً، وليس هناك من أسباب التذكير، كنسيان التسمية في الذبيحة، ونسيان بعض أركان الصلاة، ونسيان الصوم بالأكل والشرب ناسياً، والحُكْم

(١) فتح القدير للشوكاني ٣٧٩/٢.

(٢) رواه مُسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله ١٩٣/٥.

(٣) رواه مُسلم كتاب الصيام باب من نسي فأفطر في رمضان ٧٨٢/١؛ أبو داود كتاب الصوم باب (٣٧) ٧٨٥/٢؛ ويُنظر: النسيان وأثره في استنباط الأحكام للدكتور/ عبد الفتاح الدخيمسي ١١٠-١١٠.

هذا النوع أن صاحبه معذور، ولا يؤاخذ عليه.

الثاني: وهو النسيان الطارئ: وهو الذي لا يصلح أن يكون عذراً لصاحبه؛ لأنه يوجد عنده أسباب التذكُّر، ومثل ذلك: نسيان حفظ القرآن، أو نسيان الماء في الرحل والتميم، فهو في حفظ القرآن يُنسى بالإهمال في المراجعة، والتميم مع وجود الماء في الرحل وهذا تقصير في التأكد من وجود الماء^(١).

الفرق بين النسيان والسهو

مسألة الفرق بين النسيان والسهو محل اختلاف بين العلماء:

أ- فقد ذهب البعض إلى أنه ليست ثمة فرق يُذكر بينهما، لأن اللغة لا تفرق بين النسيان والسهو، إذ يعنى أن النسيان المبحوث عنه في هذا المقام الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو المذكور في السنة، وقد استعمل هناك في المعنى اللغوي، واللغة لا تُفرق بينهما^(٢).

وقد عبر عن ذلك ابن نجيم الحنفي بقوله: والمُعتمد أن النسيان والسهو مُترادفان^(٣).

وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني بعد أن عرف النسيان: وهو يُسمى ذهولاً وسهواً^(٤).

ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى الفرق بين النسيان والسهو: بأن قال المُراد من السهو هو: زوال الصورة عن المُدرَكة مع بقائها في الحافظة، فيتنبه له بأدنى تنبيه.

بينما المُراد من النسيان هو: زوال الصورة عن المُدرَكة والحافظة معاً،

(١) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٨٩/٤.

(٢) تيسير التحرير ٢٦٢/٢، ٢٦٣.

(٣) الأشباه والنظائر ٣٠٢.

(٤) التلويح على التوضيح ٣٥٣/٢.

فيحتاج حينئذٍ إلى سبب جديد^(١).

الفرق بين النسيان والذهول

ذكر ابن القيم - رَحِمَهُ اللهُ - الفرق بين النسيان والذهول بقوله:

الذهول: أن يحلف الشخص أن لا يفعل شيئاً وهو مُعتاد لفعله فيغلب عليه الذهول فيفعله.

والفرق بين هذا وبين فعل الناسي هو أن الناسي قد غاب عنه اليمين بالكلية فيفعل المحلوف عليه ذاكراً له عامداً لفعله، ثم يتذكر أنه كان قد حلف على تركه.

ثم قال: وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناسٍ ليمينه، ولكنه لهُ عنها، أو ذهل كما يذهل الرجل عن الشئ وهو في يده أو حجره بحديث، أو نظر إلى شئ ونحوه، ما قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى﴾^(٢)، وفي الحديث: "فلهُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشئ كان في يديه"^(٣) أي: انشغل به.

وأما الناسي فهو ضربان: ناسي لليمين، وناسي للمحلوف عليه.

فالأول: ظاهر.

والثاني: كما إذا حلف على شئ وفعله وهو ذاكراً ليمينه، لكن نسي أن هذا هو المحلوف عليه بعينه.

وهذا كما لو حلف لا يأكل طعام كذا وكذا فنسيه ثم أكله، وهو ذاكراً ليمينه، ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه، فهذا إذا كان يعتقد أنه غير المحلوف عليه، ثم بان أنه هو فهو خطأ، فإن لم يخطر بباله كونه المحلوف عليه، ثم بان أنه هو فهو خطأ، فإن لم يخطر بباله كونه المحلوف عليه، ولا

(١) تيسير التحرير ٢/٢٦٢؛ عوارض الأهلية للجبوري ٢١٠.

(٢) سورة عبس الآيات (٨-١٠).

(٣) المُسند ٧/١٢١، ١٢٧؛ تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي.

غيره فهو نسيان^(١).

حكم النسيان

النسيان لا يُنافي وجوب الأحكام؛ لأنه لا يعدم العقل، ولا ترتفع به الذمة، ولكن النسيان إذا كان مما يؤخذ عليه فلا عذر له في ذلك، كالكلام في الصلاة، وترك مُراجعة القرآن، وعدم التأكد من وجود الماء في الرحل، والجماع في الحج.

وأما إذا كان النسيان مما لا يؤخذ عليه فيكون عذراً له؛ لأن النسيان في هذه الحالة من الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الشرع، كالأكل ناسياً في نهار رمضان، أو الجماع، أو نسي التسمية على الذبيحة، فهذا يصح أن يكون عذراً؛ لأن هذه الأمور تتعلق بحقوق الله تعالى.

وأما إذا كان النسيان يتعلق بحقوق العباد فلا يصلح أن يكون عذراً، كمن أتلف مال الغير ناسياً^(٢).

تأثير النسيان على حقوق الله - تعالى -

بعد استعراض عبارات الأصوليين في تأثير النسيان على حقوق الله - تعالى - وجدنا أن هذه الحقوق التي كان للنسيان تأثير عليها منها ما يتعلق بحقوق الله تعالى في الآخرة، ومنها ما يتعلق بحقوق الله - تعالى - في الدنيا، ولكل منها حكم.

وسنتكلم عن كل واحد منها في مسألة مُستقلة كما يلي:

المسألة الأولى: تأثير النسيان على حقوق الله - تعالى - في الآخرة

ظهر لنا مما سبق أن النسيان لا يُنافي أهلية المكلف، وبما أنه كذلك

(١) النسيان وآثره في استنباط الأحكام دراسة أصولية للدكتور/ عبد الفتاح الدخيسي ١٢٥-١٢٨.

(٢) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٧٨، ٣٧٩؛ التوضيح على التنقيح ٢/٣٥٣؛ كشف الأسرار للنسفي ٢/٤٨٦، ٤٨٧.

فلا يترتب عليه المؤاخذه في الدار الآخرة، وذلك عند الإهمال في بعض التكليفات الشرعية، لأن العقوبة في الآخرة تبني على الإرادة والقصد، لعموم قوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(١)، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

فالإثم هنا هو المقصود بالرفع، لأن الخطأ والنسيان لا يرفعان بعد وقوعهما.

هذا هو حكم ما يتعلق بحقوق الله - تعالى - في الآخرة^(٢).

المسألة الثانية: تأثير النسيان على حقوق الله - تعالى - في الدنيا

أما بالنسبة لحقوق الله - تعالى - التي لها تعلق بأحكام الدنيا فبيانها على الوجه التالي:

أولاً: إما أن يقع النسيان من المكلف مع وجود المذكر لما هو فيه وانتفى الداعي إلى الفعل، يعني وانتفى الداعي إلى أن ما يفعله نسياناً.

مثاله: كأن يأكل المصلي في صلاته نسياناً، فالحكم أن صلاته فاسدة، وتلزمه الإعادة، وذلك لأن هيئة الصلاة مُذكّرة له مانعة من النسيان، وذلك لقصر زمن أداء الصلاة، فإذا وقع الفعل هكذا فلا يكون عذراً مُسقطاً لحكم الأكل في الصلاة وهو الفساد.

ثانياً: وإما أن يقع النسيان من المكلف مع عدم وجود المذكر له، ووجود الداعي إلى الفعل.

مثاله: كأن يأكل الصائم في النهار ناسياً، فالحكم أن صومه صحيح،

(١) سورة البقرة الآية (٢٨٦) .

(٢) شرح التلويح على التوضيح ٣٥٣/٢؛ جامع الأسرار في شرح المنار ٢٧٥/٥.

استدلالاً بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"^(١)، فهذا يقتضي أن صومه لم يفسد، وعليه أن يستمر في صومه.

ويُضاف إلى الدليل المتقدم أن انعدام الهيئة المذكورة للصائم مُنعمة، بل إن أكله هو المطلوب، لأنه جارٍ على ضوء ما تعودده الإنسان، وعلى وفق ما يدعو إليه الطبع الذي تطبع عليه^(٢).

ثالثاً: أما إذا وقع النسيان من المُكلف مع عدم وجود المُذكر له، وانتفاء الداعي إلى الفعل.

مثاله: ترك التسمية على الذبيحة، وهذا محل خلاف بين العلماء.

القول الأول: إن ترك المُذكي التسمية سهواً حلت المذكاة، لأنه لا يُسمى فاسقاً إذا كان ناسياً.

قال بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه إن المسوغ لهذا النسيان أن ذبح الحيوان يبعث في النفس الخوف والرغبة؛ لأن الطبع ينفر منه، ويتغير منه حال البشر، ولذا يهابه كثير من الناس فهذه الحالة تمنع ظهور الأثر لهيئة التذكُّر، فتكون في حكم العدم^(٣).

القول الثاني: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو نسياناً، وهو محكى عن الإمام مالك.

وعللوا ذلك: بأن التسمية سُنة، فإذا تركها الذابح أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه.

القول الثالث: أنه يُحرم أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عليها عمداً أو نسياناً، وهو قول بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد.

(١) سبق تخريجه.

(٢) شرح المنار ٣٤٢؛ الإحكام لابن حزم ٧٧٦/٥.

(٣) شرح العيني على المنار ٢٤٢، ٢٤٣.

واستدلوا بقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ﴾^(١).

كما استدلوا أيضًا: بأن هيئة التذكية وهي اضطجاع الحيوان وإحضار السكين قاصدًا قطع جميع الحلقوم والودجين من المقدم هيئة مُذكّرة^(٢).

القول الرابع: إن ترك المذكي التسمية عامدًا: كره أكل المذكاة، وهو قول بعض علماء الحنابلة^(٣).

القول الخامس: مُقتضاه أن تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدًا إلا إذا كان مُستخفًا فإنها لا تؤكل، وهو لبعض المالكية.

ويظهر من العرض السابق أن الراجح هو القول الأول، والمتضمن اعتبار النسيان عذرًا في حق من نسي التسمية عند الذبح، وذلك إذا لم يكن الذبح مهنته وصنعتة، لأن حالة الذبح قد تُرهب الذابح فينسى التسمية، بخلاف من كان الذبح مهنته، فهو لا يخاف الذبح، ولا يرهب شيئًا اعتاده.

تأثير النسيان على حقوق العباد

أ- النسيان لا تأثير له على حقوق العباد، ومن هنا لا يُعد عذرًا بالنسبة لها، ولذا لم يُعتبره الشارع عذرًا، فمن أتلف مال غيره ناسيًا وجب عليه ضمانه؛ لأن حقوق العباد مُحترمة، وهي ليست للابتلاء^(٤).

ب- كما لا يُعذر من ارتكب جريمة وادعى النسيان عند ارتكابها، فيلزمه العقاب المُرتب على تلك الجريمة، إلا إذا كان شأنه النسيان، فإن ذلك نوع من العته، وبالتالي يكون موضع نظر، فإن قلنا بسقوط المؤاخذه

(١) سورة الأنعام الآية (١٢١) .

(٢) التقرير والتحبير ١٧٧/٢.

(٣) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٣/١١.

(٤) المرأة شرح المرقاة ٣٣.

فلأنه معتوه، لا لأنه ناسي^(١).

ج- وأما من جهة عبارات الناسي والتزاماته كلها فإنها مُعتبرة قضاءً، وتترتب عليها آثارها المُتبعة في أمثالها.

كما لو طلق زوجته، وقال إنى نطقت بلفظ الطلاق ناسياً معناه فلا يصدق قضاءً، لأنه يتعذر التمييز بين القول المُتعمد والقول مع النسيان، ومع ذلك ففى وقوع طلاق الناسي خلاف بين العلماء^(٢).

د- كما أن النسيان لا يكون سبباً في إسقاط الواجبات المترتبة على المُكلف، فإذا فات الأداء بسبب النسيان وجب عليه القضاء عند تذكرها، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"^(٣).

تأثير النسيان في بعض أحكام الطهارة

ونذكر فيها مسألتين:

المسألة الأولى: من صلى وهو حامل لنجاسة، ولم يعلم بها حتى فرغ منها

ففى صحة صلاته وبطلانها خلاف بين الفقهاء على مذهبين:

الأول: أن صلاته صحيحة، ويُندب له إعادتها في الوقت، وهو للمالكية، والشافعي في القديم، ورواية عند أحمد واستدلوا على مذهبهم بحديث خلع النعلين من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه دليل على أن إزالة النجاسة شرط مع الذكر والقُدرة، فلو كانت واجبة مع عدم العلم لما بنى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المُضي من صلاته، لكنه لم يستأنفها،

(١) أصول الفقه للشيخ/ حسن فايد ٣٢٨.

(٢) الأهلية عوارضها ٣٧٥؛ عوارض الأهلية للجبوري ٢١٧.

(٣) سبق تخريجه؛ وراجع: النسيان وآثره في استنباط الأحكام دراسة أصولية ١٣٩-١٤٨.

فدل ذلك على صحتها^(١).

الثاني: يرى بطلان صلاته، وهو للحنفية، وللشافعي في الجديد، وإحدى الروایتين عن أحمد^(٢).

واستدلوا على مذهبهم بأدلة منها:

١- بعموم قوله - تعالى -: ﴿وَتَيَّابَكَ فَطَهَّرْ﴾^(٣)، فقد أمر - تعالى - بالتطهير ومنه غسل الثوب النجس، والأمر للوجوب إذا تجرد عن القرينة، فوجب عليه إزالتها حتى وإن كان ناسياً لها، فتبطل صلاته لفقدان شرطها وهو الطهارة.

٢- بما روى أنس بن مالك أن أعرابياً بال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما قضى بوله أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذنوب من ماء فأريق عليه^(٤).

دل ذلك على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بصب الماء على المكان الذي بال فيه الأعرابي، وهو للوجوب، فتكون طهارة المكان شرطاً في صحة الصلاة كطهارة الثوب^(٥).

٣- وبالقياص فقالوا: إن إزالة النجاسة واجبة، والطهارة منها شرط لصحة الصلاة، فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث، بجامع أن كليهما شرط في صحة الصلاة وتجب إزالته^(٦).

(١) الشرح الصغير ٢٦/١؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٨/١.

(٢) بدائع الصنائع ٤٩/١؛ الفتاوى الهندية ٦١/١؛ المجموع ١٥٦/٣؛ المغني لابن قدامة ٧٥١/١.

(٣) سورة المدثر الآية (٤).

(٤) مُسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب وجوب غُسل البول وغيره من النجاسات إذا دخل المسجد ٤١/١.

(٥) الموجز في الفقه ١٨٤.

(٦) المجموع ١٥٥/٣؛ المغني لابن قدامة ٧٥١/١.

الترجيح:

الراجح المذهب الأول لأن النسيان عُذر يرفع الحكم عن الناسي، ويجلب التخفيف والتيسير ويدفع المشقة.

المسألة الثانية: نسيان الوضوء للمُحْدِث

إذا صلى وهو ناسٍ للحدث الأصغر ظاناً أنه متوضئ بطلت صلاته فرضاً كانت أو نفلاً عند جميع الأئمة، لأن نسيان الحدث لا يُعد عذراً، ويجب عليه الوضوء والصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهو ليس بمتوضئ، ويأثم إن صلى عامداً بدون وضوء، وإن اعتقد خلاف ذلك كفر^(١).

أثر النسيان في بعض أحكام الصلاة

المسألة الأولى: نسيان تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام واجبة على كل من دخل الصلاة، لأنها ركن من أركانها، لحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليها التسليم"^(٢).

وورد عن الإمام مالك إذا نسي الإمام تكبيرة الافتتاح، وكبر للركوع، وكبر من خلفه تكبيرة الافتتاح، ثم صلوا معه حتى فرغوا أو قبل أن يفرغوا، يُعيد الإمام والمأموم^(٣).

وبمثل ذلك ورد عن الإمام الشافعي، وأحمد، وذكره السرخسي في المبسوط^(٤).

(١) سراج السالك ١/١٠٧؛ روضة الطالبين ١/٢٧١؛ النسيان وأثره في استنباط الأحكام ١٧٥-١٨٥.

(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء ٨٨/١؛ والترمذي ٣٨/١.

(٣) المدونة برواية سحنون ٦٤/١.

(٤) الأم ١/١٠١؛ المغني مع الشرح الكبير ١/٣٦٣؛ المبسوط ١/١١.

وهذا القول خلافاً لمن قال إنه يصير شارعاً في الصلاة بمجرد النية، والنية عند من قال بذلك ليست من الواجبات، لأن مبنى الصلاة عندهم على الأفعال لا الأذكار، ألا ترى أن العاجز عن الأذكار، القادر على الأفعال يلزمه الصلاة بخلاف العاجز عن الأفعال القادر على الأذكار.

والمذهب الأول هو الراجح، لقوله - تعالى -: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾^(١) أي: ذكر اسم الله - تعالى - عند افتتاح الصلاة، وفي ذلك رد على من زعم عدم ركنيتها واكتفى بمجرد النية للشروع في الصلاة.

المسألة الثانية: حكم من ترك الفاتحة في الصلاة ناسياً

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها عند الجمهور^(٢)، أما عند الحنفية فهي واجبة.

ومما استدل به الجمهور على ركنية الفاتحة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"^(٣).

فهو دليل صريح على وجوب قراءتها في الصلاة، لأن قوله:

(لا صلاة) نفي للصحة، يعني: (لا صلاة صحيحة) وليس المراد بالصلاة كاملة، فهو إذن نفي للصلاة الشرعية المجزية^(٤).

أما الحنفية الذين ذهبوا إلى أن الفاتحة ليست ركنًا بل هي واجبة، فقد استدلوا على مدعاهم بأدلة منها:

قوله - تعالى -: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(٥) فتعيين الفاتحة في

(١) سورة الأعلى الآية (١٥) .

(٢) المدونة ٦٥/١؛ الأم ١٠٧/١؛ المغني مع الشرح الكبير ٥٢٤/١.

(٣) رواه البخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم (فتح الباري ٢٣٧/٢) ومُسلم ١٠١/٣.

(٤) مُسلم بشرح النووي ١٠١/٤؛ فتح الباري ٢٤٣/٣.

(٥) سورة المزمل الآية (٢٠) .

القراءة زيادة على النص المذكور، وهو يُعدل النسخ، فلا يُثبت بخبر الواحد.
والراجع ما ذهب إليه الجمهور من أن قراءة الفاتحة رُكن لما ذكره
من أدلة، وإن نسيها لم يَكُن سجود السهو جابراً لها، بل لابد من الإتيان به
على الصفة الشرعية لها، بخلاف غير هذه الأركان من أفعال الصلاة، فإن
سجود السهو جابر لها^(١).

(١) النسيان وآثره في استنباط الأحكام ١٩٥-١٩٩.

٥- الغفلة

تعريف الغفلة في اللغة: غفل عن الشئ غفولاً وغفلة: سها من قلة التحفظ والتيقظ، وقيل معناها: تركه إهمالاً من غير نسيان فهو غافل^(١)، فالغافل إذن هو: من لا يدري الخطاب ولا يفهمه، كالساهي والنائم والمجنون والسكران.

تعريف الغفلة في الاصطلاح: عدم الاهتمام إلى التصرفات الرباحة بسبب البساطة وسلامة القلب، وبالتالي تؤدي هذه الصفة إلى الغبن في المعاملات^(٢).

وقيل معناها: هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرباحة، فيغبن في المعاوضات لسهولة خدعه^(٣).

فالمراد إذن من الغفلة: أنها تصرف شخص كامل العقل، إلا أنه بسبب طيبة قلبه وثقته بالمقابل الذي يتعامل معه يمكن أن يلحقه الغبن الكثير في تصرفاته المالية وبالتالي فالمغفل لم يكن مفسداً، وإنما هو لطيفة قلبه وحسن نيته وسلامة طويته لا يسعه أن يتوصل إلى ما فيه نفعه تجارياً بل يغبن في معاملاته المالية من غير قصد ولا إرادة.

حكم تصرفات الغافل

تصرفات ذي الغفلة محل اختلاف بين العلماء، إذ وردت عدة أقوال عنهم تُبين حكم هذه التصرفات والأقوال، هي:

القول الأول: قول الجمهور من العلماء ويتضمن الحجر على تصرفاته، مُستدلين بما جاء بالكتاب والسنة المُطهرة.

(١) المعجم الوسيط ٦٦٣/٢.

(٢) عوارض الأهلية ٩٨.

(٣) الأحوال الشخصية للشيخ/ محمد أبو زهرة ٤٧٨.

أما ما جاء في الكتاب، فقد استدلوا بقوله - تعالى - : ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفاً﴾^(١)، وجه الاستدلال: هو أنهم فسروا قوله تعالى (أو ضعيفاً): بأن المراد به ذو الغفلة.

أما ما استدلوا به من السنة فهو حديث حبان بن مُنقذ الأنصاري، إذ جاء فيه: كان حبان بن مُنقذ من الأنصار رجلاً ضعيفاً ضريراً البصر، وكان في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالوا له: يا رسول الله أحجر على حبان فإنه يبتاع، وفي عقله ضعف، فدعاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهاه عن البيع والشراء، فقال حبان: يا رسول الله: إني لا أصبر على البيع، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن كنت غير تارك البيع فقل: ها وها ولا خلافة^(٢)، ولي الخيار ثلاثة أيام^(٣).

وجه الاستدلال بالحديث: هو أن حبان كان يغبن في البيعات فكان يشتري بالثمن الكثير ما يشتريه غيره بالثمن القليل، ولا شك أن رجلاً كهذا يكون مُبذراً لماله مُسرفاً فيه، وإن لم يقترب ذلك بقصده، فكان ينبغي على أهله أن يطالبوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأن يحجر عليه، ولو كان الحجر بهذا السبب غير مشروع لما ذهبوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليطالبوا منه ذلك، ولو طلبوه وهو غير مشروع لأنكره عليهم الرسول الكريم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلا أنه لم ينكره، ولو أنكره لنُقل إلينا، فلما لم يُنقل إلينا إنكاره دل هذا على ثبوت مشروعية الحجر على ذي الغفلة لغفلته^(٤).

القول الثاني: قول الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ويتضمن عدم الحجر على ذي الغفلة، واستدل بحديث حبان المتقدم ذكره بقوله: بأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يجب أهل حبان على مطلبهم وهو منع حبان من البيع،

(١) سورة البقرة الآية (٢٨٢) .

(٢) الخلافة: المُخادعة، وها وها: أي: خذ وأعط.

(٣) في البخاري بلفظ: (إذا بايعت فقل ولا خلافة) ٣١/٩.

(٤) نظرية الأهلية في الفقه الإسلامي ٢٦١، ٢٦٢.

إنما أرشده إلى طريقة فيها تلافي غبنه في البيع، وهو أن يقول عند البيع: (لا خلافة).

كما أنه لو كان الحجر لازماً لما كان قول حبان: (إني لا أصبر على البيع) مانعاً من الحجر^(١).

وقد رد الجمهور على قول أبي حنيفة، من أن عدم الحجر على حبان كان لخصوصية له، لا لأنه ليس مشروعاً لأن الذي يخدع ويغبن في البيوع لا بد وأن يُحجر عليه.

ومما يُشير إلى عدم الحجر على حبان وأنه كان لخصوصية له هو أنه عندما يبيع شيئاً ويعود إلى أهله ويلمونه على تصرفه للحقوق الغبن له بهذا التصرف، فكان جوابه لهم أنا بالخيار لثلاثة أيام إن شئت أمسكت وإن شئت فسخت البيع، وإذا رغب في الفسخ خلال المدة المحدودة يذهب إلى صاحب السلعة فيردها إليه، فإذا رفض صاحب السلعة ردها يجيبه بأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد جعلني بالخيار ثلاثة أيام، وبما أنها لم تنته بعد فحق الرد ثابت لي.

والراجع من القولين هو قول الجمهور، وذلك صيانة لمال ذي الغفلة ورعاية لمصلحته وحفاظاً على سُمعته ومكانته.

تكليف الغافل شرعاً

قد يتساءل البعض عن الغافل هل أنه مُكلف شرعاً أم لا؟.

الجواب: هو أن العلماء في تكليف الغافل على مذهبين، هما:

المذهب الأول: أنه غير مُكلف شرعاً، لذا لم يجوزوا تكليفه، بل إنهم اعتبروا تكليفه مُحالاً.

وحُجَّتُهم: أن من لا يفهم الخطاب كيف يُقال له افهم؟^(٢).

(١) عوارض الأهلية ١٩٧؛ نتائج الأفكار تكملة فتح القدير ٢٥٩/٩.

(٢) المستصفي للغزالي مطبوع بحاشية فواتح الرحوت ٤/١.

كما أنه لو لم يعلم ما كلف به لم يحصل له الامتثال؛ لأن الامتثال هو الاتيان بالعمل بقصد المطاوعة، والقصد للشئ يقتضى العلم به فإذا لم يحصل القصد لم تحصل المطاوعة، لأن الفعل المجرد عن هذا القصد لا يكفى في الامتثال لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..."

فقد أفاد الحديث أن حصول الأعمال متوقف على وجود النية من الفاعل، فكل عمل لا نية معه تنتفى عنه صفة العمل، وإذا كان الأمر هكذا، فلو وقع التكليف به حال عدم العلم به يلزم التكليف بالمحال، وإنه لعمل باطل.

المذهب الثاني: أنه يجوز تكليفه، إذ إن أصحاب هذا الرأي لا يشترطون في التكليف فهم الخطاب.

وإلى هذا القول ذهب من جوز التكليف بالمُحال، وهو إما أن يزعم أن مُقتضى التكليف مُمكن من الغافل، أو يقول باستحالته ولا يُبالي بعدم الفائدة، وكلا الأمرين باطل.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب: بأن تكليف الغافل بالإتيان بالفعل امتثالاً تكليف بما لا يُطاق، والتكليف بما لا يُطاق جائز، فتكليف الغافل جائز.

والرد على هذا الدليل: هو أن التكليف بما لا يطاق إنما أجازته من أجازته إذا أمكن أن يكون له فائدة اختبار الله - تعالى - للعبد، هل يأخذ في مُقدمات ما كُلف به، والغافل عن التكليف لا يُمكنه الامتثال بما كُلف به ولا بمُقدماته فكان في تكليفه في هذه الحالة عبث مُحال عليه تعالى.

وقد يعترض البعض بالقول: من أنه إذا لم يكن الغافل مُكلفاً، فلمَ وجب عليه ضمان ما أتلّفه، وقضاء ما فاتته من الصلاة في زمان غفلته؟

الجواب: أنه لم يجب عليه ذلك حين غفلته، وإنما وجب عليه وكلف

به بعد زوال هذه الغفلة لوجود سبب الوجوب حين الغفلة، لا لكونه كان مُكلفاً بذلك حينئذٍ^(١).

(١) راجع: عوارض الأهلية عند الأصوليين للدكتور/ حسين خلف الجبوري ٢٢٢-٢٢٩.

٦- النوم

النوم في اللغة: من نام ينام نومًا ومنامًا، فهو نائم والجمع نوم، ويقال: نيام، والنوم قيل فيه: غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء^(١).

وفي الاصطلاح: عجز عن استعمال القدرة لفترة عارضة مع عقله، بمعنى: أن المكلف لا يستطيع أن يستعمل الإدراكات الحسية ليُدرك المحسوسات، ولا يقدر على استعمال نور العقل ليُدرك المعقولات، وكذلك لا يقدر على أفعاله الاختيارية كالقيام، والقعود، والركوع، والسجود، فترتب على ذلك تأخير الخطاب في الأداء لعجزه عن فهم الخطاب من الشارع.

وقيل فيه: فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل، مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه^(٢).

حكم النوم

النوم لا ينفي أهلية الوجوب لأنها ثابتة بالذمة والإسلام، وكلاهما موجود مع النوم.

وأما بالنسبة لأهلية الأداء فإن النوم ينفيها، ويترتب على نفي أهلية الأداء بالنوم أن يتأخر الخطاب إلى وقت زوال النوم؛ لأن فهم الخطاب من النائم مُمتنع، والقدرة من المكلف على إيجاد الفعل وهو نائم مُنتفية، ولكن الوجوب يبقى في حقه إلى زوال النوم، فإذا زال النوم وجب الإتيان بأمر الشارع، والدليل على ذلك^(٣) قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نام عن

(١) راجع: المصباح المنير ٣٠٣/٢.

(٢) كشف الأسرار للنسفي ٤٨٧/٢، ٤٨٨.

(٣) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٩٠/٤؛ كشف الأسرار للنسفي ٤٨٧/٢، ٤٨٨.

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها"^(١).

حكم أقوال النائم

إذا تكلم النائم في الصلاة لم تفسد صلاته، ولا تُعتبر قهقهته حدثاً: لأن القهقهة جعلت حدثاً لقُبْحها في موضع المناجاة فسقط ذلك بالنوم.

وقيل: بأن القهقهة في النوم تفسد الصلاة، وتكون حدثاً: لأن الشارع لما جعلها حدثاً في الصلاة كانت كذلك في جميع الأحوال، وقد قالوا: لا فرق في الصلاة عند الحدث بين النوم واليقظة، وبهذا أخذ عامة المتأخرين^(٢).

حكم أفعال النائم

إذا انقلب النائم على مال الغير فأتلفه وجب عليه الضمان، وإذا انقلب النائم على إنسان فقتله وجبت الدية في هذا القتل باعتباره خطأ.

وعلى ذلك لا تجب عليه عقوبة بدنية؛ لانعدام القصد والاختيار؛ لأن القتل وقع منه من غير قصد فلا يلزم القصاص، وتجب الدية على العاقلة، وتلزمه الكفارة^(٣).

(١) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة ٧٠/٢ ورواه في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ٤٧٧/١؛ ويُنظر: عوارض الأهلية للدكتور صبري معارك ٢١٥ ط دار التوفيق.

(٢) كشف الأسرار للنسفي ٤٨٨/٢؛ راجع: شرح المنار للكاكي ١٢٧٦/٥، ١٢٧٧.

(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢٧١/٧، حيث اعتبر أن انقلاب النائم على غيره إذا قتله يعتبر في معنى الخطأ؛ لأنه مات بثقله، وليس بقصده، وقد ترتب عليه وجوب الكفارة والدية، والجِرمَان من الوصية.

٧- الإغماء

الإغماء في اللغة: هو من غمى على المريض، فهو مُغمى عليه، وأغمى على المريض إغماءً، ويستعمل بمعنى الغشية، يُقال: غشي عليه بالبناء للمفعول، ومغشي عليه، والإغماء والغشى تعطيل القوى المحركة، والأوردة الحساسة؛ لضعف في القلب بسبب وجع شديد، وقال بعضهم: الغشى والإغماء بمعنى واحد، ومنه الغشاء بمعنى الغطاء، ومنه غشى الليل، وأغشى بمعنى حل بظلمته^(١).

فيكون الإغماء والغشاء بمعنى الغطاء والستر، فكأن الإنسان أخفى تحت الغشاء أو الإغماء.

وأما الإغماء في الاصطلاح: هو فتور يُزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة.

وقيل: هو آفة توجب إغلال القوى الحيوانية بغتة، وهو لا يخل بالأهلية كالنوم^(٢).

وقيل: هو تعطل القوى المدركة والمحركة حركة إرادية، بسبب مرض يعرض بالدماغ أو القلب^(٣).

أثر الإغماء على الأهلية

الإغماء لا يؤثر على أهلية المُغمى عليه، ولكنه يمنع فهم الخطاب مع وجود عقله، ولكنه عجز عن استعمال العقل، وهذا لا يعنى أنه فقد العقل، فتكون الأهلية باقية ببقاء العقل، كمن عجز عن استعمال السيف فهذا لا يعنى أن السيف غير صالح.

(١) راجع: المصباح المنير ١٠٠/٢، ١٠١، ١٠٨، ١٠٩ مادة غشى، غمى.

(٢) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٩٢/٤.

(٣) راجع: التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ٣٥٤/٢، ٣٥٥.

والإغماء نوع من المرض وليس زوالاً للعقول كالجنون، ولذلك لم يعصم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإغماء، ولكنه عصم من الجنون^(١)، لقوله - تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ﴾^(٢).

هل الإغماء يُعتبر حدثاً؟

كان الإغماء يُعتبر حدثاً في كل حال، سواءً كان المغمى عليه مضطجعاً، أو قاعداً، أو قائماً، أو راکعاً، أو ساجداً، أما النوم فليس بحدث، وعلى ذلك تبطل العبادات بالإغماء.

والفرق بين تأثير الإغماء في العبادات وتأثير النوم، أن الإغماء أقوى من النوم في كونه أمراً عارضاً، وفي فوت الاختيار أما النوم فهو فترة طبيعية لا يخلو الإنسان عنه في حال صحته.

وكذلك فإن النوم مُلَازِمٌ للإنسان بأصل الخِلقَة، فيكون كثير الوقوع، أما الإغماء فهو من العوارض النادرة، فلم يكن في معنى ما ورد به النص، وهو الحدث الذي يغلب وجوده في جواز البناء^(٣).

الإغماء والعبادات

قال العلماء: إن الإغماء إما أن يكون مُمتداً، أو غير مُمتد، والمُمتد ما زاد على يوم وليلة، وغير المُمتد ما كان أقل من يوم وليلة.

وقد سبق أن أشرنا في عارض الجنون أنه إذا زاد على يوم وليلة فإنه يُعتبر مُمتداً، وعلى ذلك لا يجب عليه قضاء، وهذا باعتبار الأوقات، وقال الإمام محمد: إذا لم يزد على خمس صلوات لا يُعتبر مُمتداً.

وقال الإمام الشافعي ومالك (رحمهما الله): إن الامتداد يُعتبر بوقت صلاة واحدة، وعلى ذلك إذا أغمي عليه لوقت واحد من الصلوات فلا يجب

(١) راجع: عوارض الأهلية للدكتور/ صبري معارك ٢٢٦.

(٢) سورة القلم الآية (٢) .

(٣) راجع: التوضيح على التنقيح ٣٥٥/٢.

عليه القضاء، وهذا في الاستحسان، وفي القياس أنه يجب عليه القضاء.
وإن طالَّت مُدة الإغماء، فيكون تأثير الإغماء في تأخير الأداء، ولا
يوجب سقوطاً، لأن الإغماء مرض لا يؤثر في العقل، ولكنه خلل في القدرة
الأصلية.

ووجه الاستحسان: أن كثيراً من الصحابة أغمي عليهم ففوضوا
الصلوات، فقد روي أن عماراً أغمي عليه ففوض، وقد روى أن عبد الله بن
عمر أغمي عليه ففوض.

حُكم أقوال المَغْمَى عليه وتصرفاته

أولاً: أقوال المَغْمَى عليه:

إن المَغْمَى عليه إذا صدرت منه أقوال في العقود كالبيع، الشراء،
والسلم، والإجارة، وغير ذلك فهذه الأقوال غير مُعتبرة شرعاً، ولا يصح منه
بيع، ولا شراء، ولا سلم ولا إجارة؛ لأن كل هذه الأقوال تأخذ حُكم النائم
في أقواله.

ثانياً: تصرفات المَغْمَى عليه:

تصرفات المَغْمَى عليه كذلك لها حُكم تصرفات النائم، فإذا انقلب
المَغْمَى عليه على إنسان فقتله فالدية واجبة على عاقلته، وإن لم تكن له
عاقلة ففي ماله الخاص وتجب الكفارة.

وتصرفات المَغْمَى عليه التي تتعلق بحقوق الله - تعالى - فحُكم هذه
التصرفات أن الشارع لا يؤاخذها عليها؛ لأنه في حالة انعدام لاستعمال
العقل^(١).

وأما ما يتعلق بحقوق العباد فهو أمام الشارع مؤاخذ عليها مالياً،

(١) راجع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٩٤/٤؛ التوضيح على التنقيح ٣٥٥/٢، ٣٥٦؛
عوارض الأهلية للدكتور/ صبري معارك ٢٢٨؛ عوارض الأهلية للجبوري ٢٤٨؛ شرح المنار
للكاكي ١٢٨١/٥.

وليس بدنيًا، فلا يقتص منه إذا انقلب على شخص فقتله أو انقلب على شئ فأتلفه^(١).

(١) راجع: عوارض الأهلية للجبوري ٢٤٨، ٢٤٩.

٨- المرض

المرض لغة: السقم، ومنه قوله: مرض الحيوان مرضاً، من باب تعب، والمرض حالة خارجة عن الطبع، ضارة بالفعل والآلام، والأورام أعراض عن المرض، ويُقال: مرض مرضاً، ومنه قوله - تعالى -: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ بسكون الضاد في الوقف، ومنه قولهم: مريض، وجمعه مرضى، ويُقال: أمرضه الله، ومرضته تمريراً: أي تكلفت بمداواته^(١).

وأما تعريف المرض في الاصطلاح: هو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة، وقيل في تعريفه: هيئة للحيوان يزول بها اعتدال الطبيعة^(٢).

مرض الموت

مرض الموت هو الذى يغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت، سواء كان الموت بسبب ذلك المرض أو مرض آخر، أم بسبب شئ آخر غير المرض كالقتل.

وألحق الفقهاء بالمريض مرض الموت الأشخاص الأصحاء إذا كانوا في حالة تجعلهم يترقبون الموت، كمن يقدم للإعدام، أو كمن يبارز آخر، أو كمن كان في سفينة وغلبت عليها الأمواج وتوقع الغرق، وبعض الفقهاء ألحق الشخص الصحيح في فشو الطاعون، فإنه يعتبر مريض مرض الموت لأنه يغلب عليه الهلاك^(٣).

والمريض مرض الموت له أهلية وجوب وأداء كاملتان، متى كان بالغاً رشيداً خالياً من العته ونحوهما، ومقتضى ذلك أن تصح جميع عقود تصرفاته، ولا يحجر عليه، إلا أن المرض الذى هو فيه يفضى إلى الموت

(١) المصباح المنير ٢/٢٣٤.

(٢) زبدة الأسرار للسيواسي ٢٤٢.

(٣) حاشية ابن عابدين ٣/٣٨٤؛ حاشية أبى السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ٢/١٥٨؛ كشف القناع ٣/٤١٦.

عادة، ويتعلق بماله وتركته حقوق دائنيه وورثته.

جعل الشارع المراض سبباً في تعليق حقوق الدائنين والورثة بماله في أثناء المراض، وحجر عليه في بعض التصرفات محافظة على حقوق غيره من الورثة والدائنين.

وحقوق الدائنين تتعلق بمالية التركة كلها، لأنها مقدمة على الورثة، وحقوق الورثة تتعلق بثليها فقط أما الثلث الباقي فيجوز للمريض مراض الموت أن يتصرف فيه كيفما شاء بالوصية أو الوقف، كى يتدارك ما فاته من خير في حياته. كما ورد في الحديث الشريف الصحيح.

أما عن تصرفات المريض مراض الموت، فهناك تصرفات يملكها ولا تتوقف على إجازة أحد، وهناك تصرفات موقوفة على إجازة صاحب الحق من الدائنين أو الورثة، أما عن التصرفات التي يملكها فكل ما يحتاجه ولا غنى له عن طعام وكسوة وسكن ونفقة من تلزمه نفقته، فتصرفه في كل ذلك نافذ، ولا يتوقف على إجازة أحد لأن كل ذلك من الضروريات التي لا غنى للإنسان عنها، وكذلك يجوز له أن يتزوج، لأنه محتاج إلى من يخدمه ويؤنسه، إلا أنه يشترط في المهر الذى يسميه ألا يزيد على مهر المثل، فإن زاد على مهر المثل كانت هذه الزيادة تبرعاً وتأخذ حكم الوصية، فإن مات المريض والمرأة في عصمته توقف نفاذها على إجازة الورثة عند الجمهور، ولا يتوقف على إجازة أحد من الورثة إذا خرجت من ثلث التركة بناء على قانون الوصية الجديد.

وكذلك التصرفات الواردة على المنافع كالإجارة والإعارة والمزارعة كلها صحيحة عند الأحناف، وليس لأحد حق الاعتراض عليها سواء من الدائنين أو الورثة حتى ولو فيها غبن يسير أو كثير، لأن المنافع ليست بأموال عند الأحناف، ولا تورث وتنتهي من تلقاء نفسها بموت المتصرف، فإذا مات المريض بطلت إجارته وإعارته ونحوهما.

أما عن التصرفات الموقوفة والتي يمكن إبطالها بعد موت المريض،

فهي العقود والتصرفات التي يكون فيها مساس بحقوق الدائنين أو الورثة، وهى التى يكون لها تأثير فى مال المريض بالنقصان كالتبرع والهبة والصدقة والوقف والوصية والبيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأكثر من ثمن المثل، فهذه التصرفات حكمها حكم الوصية، فتعتبر من ثلث التركة كزيادة المهر عن مهر المثل^(١).

فإذا أوجد المريض تصرفاً من هذه التصرفات كان تصرفه نافذاً حال حياته متى استوفى شروطه وأركانه؛ لصدور التصرف ممن هو أهل له، فإذا مات حينئذ يكون لمن لحقه ضرر من هذه التصرفات من الدائنين أو الورثة حق إبطالها بقدر ما يسلم له حقه، وحق الدائنين مقدم على حق الورثة، ويتعلق بالتركة كلها، وحق الورثة يتعلق بثلث التركة فقط كما أشرنا سابقاً.

(١) حاشية ابن عابدين ٦/٦٧٩.

٩- الحيض

الحيض لغة: السيلان، تقول: حاضت المرأة حيضا، ومحیضا، وحيضتها أى: نسبتها إلى الحيض، والمرأة حيضة، والجمع حيض^(١).

وفي الاصطلاح: هو دم ينفذه الرحم في المرأة السليمة عن الداء والصغر^(٢).

وقوله: (رحم المرأة) يخرج الرعاف، والاستحاضة، و(الصغر) يخرج ما خرج من الصغيرة وليس بحيض لأنه لا يتكرر.

والحيض يؤثر في أهلية الأداء للمرأة، لأنها تقضى الصوم، ولا تقضى الصلاة، ولذلك قالت السيدة عائشة للمرأة التي سألتها: "ما بالنا نقضى الصوم، ولا نقضى الصلاة؟". فقالت لها: كنا نقضى على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصوم ولا نقضى الصلاة^(٣).

قال العلماء: لأن الصلاة متكررة كل يوم بخلاف الصوم فإنه كل سنة، ولكن الطهارة من الحيض والنفاس شرط للصلاة بعد انقطاع الدم من كل منهما، وفي عدم تحقق الشرط فوات الأداء^(٤).

(١) المصباح المنير ١٧٢/١.

(٢) شرح المنار للكاكي ١٣١٤/٥.

(٣) الحديث رواه الترمذی في كتاب الطهارة باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضى الصلاة رقم: ١٣٠ ص ٤١، ورواه النسائي في كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض، حديث رقم: ٢٣١٨.

(٤) يُنظر: شرح المنار للكاكي ١٣١٤/٥، ١٣١٥.

١٠- النفاس

النفاس في اللغة: من نفست المرأة فهي نفساء، والجمع نفاس، يُقال: نفست تنفس من باب تعب، فهي نافس، مثل حائض، والولد الذي يخرج من رحم أمه يُسمى منفوس، ويُطلق التعبير بقولهم: نفست تنفس بمعنى حاضت، ولكنه ليس بمشهور^(١).

والنفاس في الاصطلاح: الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة^(٢).

والنفاس يأخذ حكم الحيض في شرط الطهر منه عقيب الانقطاع وقبل الصلاة، وكذلك كل منهما - أي: الحيض والنفاس - لا يؤثر على أهلية الوجوب، ولا أهلية الأداء، وإذا قيل: إن النفاس يجب أن يسقط الصوم إذا استغرق الشهر كاملاً.

والجواب على ذلك: أنه يأخذ حكم الحيض، فكما أن الحيض لا يسقط الصوم حتى ولو استغرق جميع الشهر.

والعبادات على الحائض والنفساء تجب عليهما بقدر المكنة، أي: بقدر ما يمكن عليهما، ولكن الله يسر عليهما ذلك على قدر الاستطاعة^(٣).

(١) المصباح المنير ٢/٢٨٨.

(٢) شرح المنار للكاكي ١٣١٤/٥، ١٣١٥.

(٣) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٤٣٣، ٤٣٤؛ التوضيح على التنقيح ٢/٣٦٩؛ أصول الفقه لوهبة الزحيلي ١/١٧٤، ١٧٥.

الأسئلة

- س١: العته من عوارض الأهلية، فما هو العته؟ وما الفرق بين المعتوه والمجنون؟
- س٢: عرف النسيان بعبارته عارض من عوارض الأهلية، وما هي أنواع النسيان؟ وما الفرق بين النسيان والسهو؟
- س٣: من عوارض الأهلية (الغفلة)، عرف هذا العارض، وما حكم تصرفات الغافل؟
- س٤: هل يصح تكليف الغافل بأحكام الشريعة؟
- س٥: عرف الإغماء، وبين أثر الإغماء على الأهلية، وهل يعتبر الإغماء حدثاً؟

ثانياً: العوارض المكتسبة

١- الجهل

الجهل في اللغة: من جهلت الشئ جهلاً وجهالة خلاف علمته، ويقال: كفى بالشك جهلاً، وجهل على غيره أي: سفه وأخطأ، وجهل الحق أي: أضاعه، فهو جاهل وجهول، ومنه قولهم: جهلته أي: نسبته إلى الجهل^(١).

وأما الجهل في الاصطلاح: فهو صفة تضاد العلم عند احتمال تصويره.

واحترز بتعبير الجهل عن الأشياء التي ليس لها علم لأنها لا يتصور العلم فيها.

والجهل يُذكر، ويُراد به: الشعور بالشئ على خلاف حقيقته، ويُذكر ويُراد به: السفه^(٢)، ولذلك قال المولى - عَزَّجَلَّ -: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(٣).

وقيل في تعريف الجهل: اعتقاد الشئ على خلاف ما هو به^(٤).

أثر الجهل على الأهلية

الجهل لا يؤثر في أهلية المكلف لأن متعلق الأهلية هو الذمة والعقل والتمييز، ولا تأثير للجهل على هذه المقومات التي تقوم عليها أهلية المكلف. ولكن الشارع تيسيراً منه على المكلفين، استثنى بعض الحالات التي تصلح عذراً للمكلف، وبذلك تسقط عنه المؤاخذه على بعض الأمور التي

(١) المصباح المنير ١/٢٣٢.

(٢) شرح المنار للكاكي ٣٣٧/٥؛ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٥٧٧.

(٣) سورة الأعراف الآية (١٩٩).

(٤) كشف الأسرار للبزدوي.

يفعلها عن جهل^(١).

الجهل عند علماء الكلام

وينقسم إلى قسمين:

الأول: الجهل البسيط.

الثاني: الجهل المركب.

أما الجهل البسيط: وهو عدم العلم عما من شأنه لأن يكون عالماً، وهذا النوع يقرب منه السهو، وكأنه جهل سببه عدم استنباط التصور حتى إذا نبه تنبه، وهذا النوع يقرب منه الغافل والذاهل.

وأما الجهل المركب فهو: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، وهذا النوع ضد العلم يصدق لأحد الضدين عليهما^(٢).

أنواع الجهل من حيث كونه يصلح عذراً للمكلف أو لا يصلح عذراً:

النوع الأول: الجهل الباطل، الذي لا يصلح عذراً للمكلف في حكم الآخرة الذي يتعلق بمعرفة الله وتوحيده، مثل: جهل الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يوحد، ولا يعترف بصفاته، فإن المكلف هنا كافر مكابر امتنع عن الانقياد إلى الحق، قال الله - تعالى -: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(٣)، وقال الله - تعالى -: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾^(٤)، وكذلك الدلائل التي دلت على وحدانية الله، وصحة رسالة الرسل ومعجزاتهم، ومعنى الجهل هنا - هو عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول.

(١) راجع: أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ١١٣؛ عوارض الأهلية للجبوري ٣٣٨.

(٢) راجع: المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين والملة ١٤٢.

(٣) سورة النمل الآية (١٤).

(٤) سورة البقرة الآية (١٤٦).

وقد حصل اختلاف بين العلماء فى اعتقاد الكافر فى حكم من أحكام الدنيا، هل يكون عذراً أو لا؟.

فقال الإمام أبو حنيفة (رضى الله عنه): إن ما اعتقده الكافر تحكم من أحكام الدنيا يصلح دافعاً للتعرض ودافعاً لدليل الشرع فى الأحكام التى تحتل التغيير، مثل: حرمة الخمر، والخنزير، ونكاح المحارم.

ويترتب على ذلك: أن نكاح الكافرين ماداماً معتقدين أنه صحيح، فإذا أراد أن يفسخ هذا النكاح يتقدماً بطلب إلى القاضي، لقوله - تعالى - : ﴿فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ولا يفرق بينهما إذا رفع الأمر إلى القاضي من طرف واحد، بل لابد من طلب الزوجين معاً.

واستدل الإمام أبو حنيفة فقال: إننا أمرنا أن نتركهم وما يدينون، وهم يدينون باعتقاد صحة نكاح المحارم.

بحكم الإسلام فى ذلك، قياساً وقال صاحبان: يصح أن يفصل القاضي بطلب أحد الزوجين على إسلامه، والكفار يتوارثون بهذه الأنكحة عند جميع العلماء، لأنها منسوخة بعد آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) منذ نوح (عَلَيْهِ السَّلَام)، وقد ترك لهم ذلك لتدينهم به وفاءً بالذمة.

وإذا فعلوا شيئاً لم يتدينوا به لا نتركهم عليه لأنه محرم عندهم، وذلك كالزنا، والربا فلا نتركهم عليه إذا أتوا بمثل هذه الأشياء؛ لأنها محرمة فى جميع الملل^(١).

وأما فى الأحكام الى لا تحتل التبديل فلا تصلح عذراً للكافر فى أحكام الدنيا، وهذه الأحكام كتحرير السرقة، والزنا، والقتل، وعلى هذا لا يلزم اعتبار ديانتهم فى استحلال الربا؛ لأن استحلال الربا ليس بديانة لأنه محرم فى كل الأديان، قال الله - تعالى - : ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا

(١) يُنظر: التوضيح على التنقيح ٣٨٧/٢؛ ينظر: شرح المنار للكاكي ١٣٣٨/٥، ١٣٣٩؛ يُنظر: عوارض الأهلية للجبوري ٣٣٩، ٣٤٠.

حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبَصَدِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ^(١)، وجعل استحلال الربا منهم فسقا، ومثل استحلال الربا ما لو استحلوا الزنا، والسرقة، فإن ذلك لا يعتبر ديانة، لأن أحكام هذه الأشياء لا تحتل التبديل، وحكمها واحد في جميع الأديان^(٢).

النوع الثاني من الجهل: وهو لا يصلح عذرا في الآخرة، وهذا النوع أقل من الأول، ومثاله: جهل صاحب الهوى بإنكار صفات الله عند المعتزلة، حيث قالوا: إنه عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، وكذلك مثل هذا النوع كلام المشبهة بأن صفات الله - تعالى - تحدث وتزول، وهذا تشبيه بالحوادث، والله - تعالى - يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾^(٣)، ويقول - تعالى -: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾^(٤)، ويقول - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^(٥).

ومثال هذا النوع: جهل بسؤال ملائكة القبر، وعذاب القبر والميزان والشفاعة لأهل الكبائر، وإنكار الجهمية بقاء ودوام الجنة والنار وأهليهما. ومن هذا النوع جهل الباغي: وهو الذي خرج عن الإمام متمسكا بتأويل فاسد، ولكنه لا يخرج عن الإسلام ولا يحكم بكفره، ولا يحرم ورثته من ميراث ماله^(٦).

ومن النوع السابق أيضا: جهل من خالف الكتاب والسنة، كمن كانوا يقولون: بجواز بيع أم الولد، بدليل حديث روى عن جابر. وهو قوله: "كنا

(١) سورة النساء الآيتان (١٦٠، ١٦١).

(٢) يُنظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٤٦٦.

(٣) سورة البقرة الآية (٢٥٥).

(٤) سورة النساء الآية (١٦٦).

(٥) سورة لقمان الآية (٢٦).

(٦) يُنظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٣٦٧؛ ويُنظر: التوضيح على التنقيح ٢/٣٨١؛

وشرح المنار للكاكي ٥/١٣٣٩-١٣٤٣.

نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ^(١) " وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، منهم: بشر المريسي، وداود الأصفهاني، وبعض أهل الظاهر.

ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن؛ لورود عدة أدلة في ذلك، منها: قوله: " اعتقها ولدها ^(٢)، وقوله: "أيما أمة ولدت عن مولاهما فهي معتقة عن دبر منه ^(٣).

وكان عمر - رضى الله عنه - يقول: "إن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاهما"، وقد تلقت الأمة بالقبول هذه الآثار، فكان مخالفا للكتاب، لأن مخالفة الإجماع تعتبر مخالفة للكتاب، ومن هذا أيضا الفتوى بحل متروك التسمية عمدا لقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ^(٤).

النوع الثالث من الجهل: وهو الجهل في موضع الشبهة فإنه يصلح عذراً، وهو ما يُسمى بالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح.

ومثال هذا النوع: من صلى الظهر على غير وضوء، ثم صلى العصر، فإن العصر فاسد عند الحنفية، لأن ترتيب الفوائت واجب عندنا، وعند الشافعي تصح صلاة العصر؛ لأن ترتيب الفوائت ليس بواجب عنده.

ومن هذا النوع أيضاً: إذا أفطر المحتجم على ظن أن الحجامة تفطر، وظن أنه ليس عليه كفارة بعد الأكل، فهو معذور تسقط عنه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد، وهناك من يقول: إذا احتجم وظن أنه يفطره، فأفطر ولم يستفت أحداً فعليه كفارة، وإذا لم يستفت أحداً وعلم بالحديث،

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/٣ بلفظه؛ وابن ماجه حديث رقم ٢٥١٧ في كتاب العتق ط بيت الأفكار الدولية.

(٢) ابن ماجه حديث رقم ٢٥١٦ في كتاب العتق ط الأفكار الدولية.

(٣) ابن ماجه حديث رقم ٢٥١٥ في كتاب العتق ط الأفكار الدولية.

(٤) سورة الأنعام من الآية: ١٢١؛ ويُظَر: شرح المنار للكاكي ١٣٤٧/٥، ١٣٤٨.

وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم"^(١)، ولم يعلم بالن مخ أو التأويل فيه فعند أبي حنيفة لا كفارة عليه، وعند صاحبين عليه الكفارة^(٢).

النوع الرابع من أنواع الجهل: الجهل في دار الحرب، وهذا يكون من مُسلم في بلاد الكفر لم يصل إلينا، فهذا إذا قصر في بعض الأحكام يكون له عذره فيها، فإذا مكث مدة لا يصلي فيها، لا يصوم فله عذر، وذلك إذا لم يعلم أن هناك صلاة، ولا صيام مفروضين عليه، وعلى ذلك لا يجب عليه قضاء ما فاتته في هذه المدة، وعلة عدم القضاء أن الخطاب النازل خفى في حقه، لأنه لم يبلغه حقيقة ولا تقديرًا، وهذا عند جمهور العلماء.

وقال الإمام زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إن عدم علمه لا يسقط عنه القضاء، فهو كالتائم الذي انتبه وقد مضى عليه وقت الصلاة فيج عليه أن يؤديها قضاءً، فكذا هذا الذي أسلم في دار الحرب، ولم يعلم أنه بإسلامه أصبح ملتزمًا، إلا أنه قصر عنه خطاب الأداء لجهله به، وهذا لا يسقط القضاء.

ومثال ذلك - وهو الجهل بالخطاب: ما روي في قصة أهل قباء، فإنهم صلوا صلاة الظهر إلى بيت المقدس، وكذلك افتتحوا العصر متوجهين إلى بيت المقدس، فتحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾^(٣) لأنهم لما تحولوا إلى الكعبة سأل الناس، فقالوا: وما حكم من مات من أصحابنا قبل التحويل فنزلت الآية.

ومثال ذلك أيضًا: جهل الوكيل بالوكالة، والمأذون بالإذن، وجهل الشفيع بالشفعة، وجهل الأمة بالإعتاق، فإن ذلك كله يكون عذرا: لعدم العلم وعدم الخبر، فإذا تصرف الوكيل، والمأذون قبل وصول خبر الوكالة

(١) رواه البخاري رقم ١٩٣٧ كتاب الصوم؛ وأبو داود في الصيام؛ والترمذي في الصيام؛ وابن ماجة رقم ١٦٧٩ في كتاب الصيام.

(٢) يُنظر: شرح المنار للكاكي ١٣٥١/٤؛ وينظر: عوارض الأهلية للجبوري: ٣٤٥، ٣٤٦.

(٣) سورة البقرة من الآية (١٤٣).

لم ينفذ تصرف أيًا منهما.

وإذا وكله بشراء شئ فاشتراه لنفسه قبل أن يعلم بالوكالة يصح في حق نفسه، ولا يصح في حق الموكل، وكذلك لو باع شيئًا للوكيل قبل العلم بالوكالة لا ينفذ ويكون كالفضولي^(١).

(١) يُنظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي؛ ٤/٤٨٠ وما بعدها، وينظر: عوارض الأهلية للجبوري: ٣٤٨، ويُنظر: التوضيح على التنقيح ٣٨٨/١.

٢- السكر

السكر هو غيبة عقل نتيجة تناول الإنسان مواد مسكرة كالخمر ونحوها إلى حد اختلاط كلامه وغلبة هذيانه ولا يدري الحسن من القبيح.

والسكر نوعان: سكر بطريق مباح، وسكر بطريق محظور.

أما النوع الأول: فهو السكر بطريق مباح، كسكر المضطر إلى شرب الخمر عند الظم الشديد وعدم وجود ماء أو شرب المضطر للعلاج.

وحكم هذا النوع أن الإنسان غير مؤاخذ على شربه هذا، ويمنع صحة جميع التصرفات كالبيع والشراء والطلاق والعتاق لمكان عذره وعدم قصده وإرادته.

النوع الثاني: وهو السكر بطريق محظور، وهو السكر من كل شراب حرام، كالسكر من شرب الخمر المحرمة بقصده واختياره.

وحكم هذا النوع: أنه لا يمنع التكليف، ويلزم السكران في هذه الحالة بكل الأحكام الشرعية، وتصح تصرفاته وعباراته كالبيع والشراء والطلاق والعتاق.

لأن السكر لا يعدم العقل وإنما يفوت قدرة فهم الخطاب بسبب المعصية التي ارتكبها، فيجعل في حكم الموجود زجرًا له، وعقوبة على سكره. وإذا فعل فعلاً يترتب عليه عقوبة بدنية كالقتل والقذف والزنى فلا أثر للسكر بالنسبة إلى ذلك، إلا أنه لا يقتص منه ولا يقام عليه الحد إلا بعد صحوه من السكر، لكي يحصل الزجر والردع.

وهذا الرأي المتقدم هو الذي نختاره ونرجحه، لأننا لو لم نلزم السكران بطريق محظور بأقواله وأفعاله لكانت المعصية سببًا في إعفائه من المسؤولية، وهو مالا ينبغي أن يكون.

ويرى بعض العلماء أن تصرفات السكران وعقوده غير صحيحة

مطلقاً، سواء كان السكر بطريق مباح أم محظور، لأن صحة التصرفات والعقود تتوقف على صحة القصد وسلامته، والسكر يزيل القصد والإرادة^(١).

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في مصر برأى هؤلاء في إيقاع الطلاق ففضى في المادة الأولى على "لا يقع طلاق السكران".

(١) قليوبى وعميرة ٣/٣٣٣؛ المغني عن شرح الكبير ٨/٢٥٤ وما بعدها.

٣- السفه

السفه خفة تعتري الشخص فتحمله على العمل باختياره على خلاف موجب العقل رغم وجوده، ولا ينافي الأهلية، وقد عرفه الفقهاء بأنه عدم الإحسان في التصرفات المالية وتبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل، سواء أنفقه في وجوه الخير أم في وجوه الشر^(١).

وحكم السفه: أنه لا يوجب خللاً في الأهلية، ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع، فالسفيه أهل لمباشرة التصرفات والعقود، ومطالب بأداء العبادات المختلفة.

وإن بلغ الصبي سفيهاً يمنع عنه ماله لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(٢)، ثم علق سبحانه وتعالى دفع المال إليهم على إيناس الرشد منهم فقال تعالى: ﴿وَابْتَالُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾^(٣).

وإذا بلغ الشخص رشيداً واكتملت أهليته، ثم طرأ عليه سفه، فإنه يحجر عليه عند جمهور الفقهاء.

ويرى أبو حنيفة عدم الحجر عليه^(٤)، وحجة الجمهور أن السفه موجب للحجر على السفيه، لأن في الحجر عليه مصلحة وهي حفظ ماله، لأنه إذا أسرف في ماله وأنفقه على غير ما يوافق العقل قد يؤدي به إلى ضياع ماله، ويصبح عالة على غيره، فكان من الحكمة منعه من التصرف.

(١) هذا عند الحنفية، أما الشافعية فيرون أن إسراف المال في وجوه الخير لا يعد سفهًا،

انظر حاشية ابن عابدين ١٤٧/٦؛ المجموع شرح المذهب ٣٧٦/١٢.

(٢) سورة النساء الآية (٥).

(٣) سورة النساء من الآية (٦).

(٤) حاشية ابن عابدين ١٤٨/٦؛ المجموع شرح المذهب ٣٧٩/١٢؛ حاشية الدسوقي ٢٦٣/٢؛

كشاف القناع ٤١٧/٣.

وحجة أبى حنيفة في منع الحجر على السفية أنه حر مخاطب فتصرفه صادر عن أهله مضاف إلى محله فلا يمنع، لأن الخطاب بالأهلية وهى التمييز، والسفه لا يوجب نقصاناً فيه، ولهذا يخاطب بحقوق الشرع ويحبس في ديون العباد وتصح عباداته في الطلاق والعتاق، ويجب عليه العقوبات إذا ارتكب موجبها كالحدود والقصاص مع أن ضرر النفس أشد من ضرر المال، فتصرفه يكون صادراً عن أهله في محله فلا يمنع فيه^(١).

ولا شك أن رأى الجمهور أرجح، لأن ليس في منع تصرفات السفية محافظة على ماله فقط، بل أيضاً محافظة على بيت مال المسلمين، وفيه دفع الضرر عن الناس مخافة أن يتصرف في ملكه ثم يستدين ولا يفي بما استدان، فيصير على المسلمين وبالأعلى وعلى بيت المال عيالاً.

وإذا حجر على السفية يكون حكمه حكم الصبى المميز في التصرفات، وقد تقدم ما يصح فيها وما لا يصح.

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٤٨/٦؛ حاشية أبى السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ٢٩٧/٣.

٤- السفر

السفر لغة: من سفر الرجل سفرًا فهو سافر، والجمع سفر، والاسم السَفَر، وهو: قطع المسافة، ويقال ذلك إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العدو^(١)، حتى إن بعضهم قال: أقل السفر يوم، والسفر جمعه أسفار.

ويشتق منه قولهم: سفرت الشمس، أي: طلعت، ومنه قولهم: سفرت بين القوم سفر سفارة، أي: أصلحت، ومنه قولهم: سفرت المرأة سفورًا، أي: كشفت وجهها فهي سافر، ومنه: إسفار الصبح، فيقال: أسفر الصبح إسفارًا، أي: أضاء، وأسفر الرجل بالصلاة، أي: صلاها في الأسفار^(٢).

وأما تعريف السفر في الاصطلاح: فهو خروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك مسيرة ثلاثة أيام^(٣).

وقيل: هو الخروج المديد عن موضع الإقامة على قصد السير، وأدناه ثلاثة أيام^(٤).

هل السفر يؤثر على الأهلية؟

السفر لا يؤثر على أهلية المكلف، سواء أكان ذلك في أهلية الوجوب، أم في أهلية الأداء؛ وذلك لأن القدرة الظاهرة والباطنة باقية بكمالها ولا تمنع من وجوب شئ من الأحكام^(٥).

(١) وهي المسافة التي يذهب إليها الرجل ويرجع فيها في عدو واحد، ينظر: المصباح المنير ٤٦/٢ ط دار الفكر.

(٢) ينظر: المصباح المنير ٢٩٨/١ ط دار الفكر؛ وينظر: القاموس المحيط ٧١/٢ باب الرء فصل السين.

(٣) ينظر: جامع الأسرار شرح المنار للكاكي ١٣٩٨/٥.

(٤) ينظر: زبدة الأسرار للسيواسي: ٢٤٨.

(٥) يُنظر: جامع الأسرار شرح المنار للكاكي ١٣٩٨/٥.

وإذا كان السفر لا يؤثر على الأهلية إلا أنه يعتبر سبباً من أسباب التخفيف بشرط وجود المدة التي حددها الشارع، وهو ثلاثة أيام بلياليها، وهي أقل مدة يمكن أن يوصف الإنسان فيها بأنه مسافر وتنطبق عليه أحكام السفر، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام"^(١)، لأن السفر لما كان لا يخلو من مشقة منيطة بالسفر فيكون سبباً من أسباب التخفيف، وجعله الشارع رخصة للمكلف في قصر الصلاة، والمسح، والفطر في رمضان، لقوله -: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحلكم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله"^(٢)

أحكام السفر

ومعنى أحكام السفر: أى ما يتمتع به المسافر من رخص أثناء سفره، حيث إن الشارع خفف عن المسافر في الصلاة، وفي الصيام، وإذا سافر المكلف من أجل فعل معصية فله حكم أيضاً سنذكره - إن شاء الله تعالى -.

أولاً: ما يتعلق بالمسافر من أحكام في الصلاة:

السفر بالنسبة للمسافر يؤثر على الصلاة الرباعية، فيقصر صلاته، والقصر واجب عند الحنفية، وقال الشافعية: إن شاء أتم وإن شاء أقصر، والقصر في الصلاة بجعلها ركعتين بدلاً من أربع^(٣).

ووجهة نظر الحنفية في جعل القصر واجباً، ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر،

(١) الحديث رواه النسائي في كتاب الطهارة رقم: ١٢٩؛ ورواه أبو داود في كتاب الطهارة رقم: ١٥ بالمعنى.

(٢) الحديث رواه البخارى فى كتاب العمرة رقم ١٨٠٤؛ وفي كتاب الجهاد رقم ٣٠٠١؛ وكتاب الأطعمة ٥٤٢٩؛ وينظر: جامع الأسرار للكاكي ١٣٩٨/٥، وعوارض الأهلية للجبوري: ٤٥٧.

(٣) يُنظر: جامع الأسرار شرح المنار للكاكي ١٣٩٩/٥.

وزيدت في الحضر"^(١)، وكذلك ما روى عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر: ما بالناس نقصر وقد أمننا؟، فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"^(٢).

وأما وجهة نظر الشافعية في رخصة الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين، هو أن الغرض من الرخص هو التبسيط والتخفيف على العباد، وهذا التخفيف للمكلف أن يأخذ به، أو لا يأخذ.

وأما الحنفية فقد بنوا كلامهم على أن رخصة السفر في الصلاة هي رخصة إسقاط، ولذلك قال الشافعية: إنها مندوبة، وقال الحنفية: إنها واجبة^(٣).

ثانياً: أحكام السفر في الصيام:

السفر علة للفطر هذا إذا لم يستطع الصوم، وأما إذا كان قادراً على الصوم فالأفضل الصيام، لقوله - تعالى -: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾^(٤)، وقال - تعالى -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(٥)، والمكلف إذا شرع في الصوم ليس له أن يفطر، وذلك بعد الفجر، أما إذا وجد السفر قبل البدء في الصوم فله أن يفطر، وأما إذا عرض السفر فجأة فليس له أن يفطر إذا كان قد شرع في الصوم.

وكذلك إذا مرض المقيم جاز له أن يفطر لعذر المرض، وإذا أفطر أثناء السفر عليه التضاء فقط، وليس الكفارة لأن السعر مبيح، وعند

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم: ١١٩٨ صلاة المسافر؛ والنسائي في كتاب الصلاة رقم: ٤٥٥.

(٢) رواه في كتاب صلاة السفر رقم ١١٩٩؛ والنسائي في كتاب تقصير الصلاة رقم: ١٤٣٣.

(٣) يُنظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ٤٨/١ ط الفاروق؛ وينظر: جامع الأسرار للكاكي ١٣٩٩/٥ ط نزار مصطفى؛ وعوارض الأهلية للجبوري: ٤٦٢.

(٤) سورة البقرة من الآية (١٨٣).

(٥) سورة البقرة من الآية (١٨٥).

الشافعي تلزمه الكفارة، وإذا أفطر المقيم ثم سافر تلزمه الكفارة بخلاف المرض^(١).

حكم سفر المعصية:

إذا سافر المكلف بقصد أن يجامع في نهار رمضان، أو أن يقطع طريقا لسرقة ونهب أموال الناس، قال الحنفية: إن سفر المعصية يعتبر رخصة؛ لأن المعصية منفصلة عن السفر.

وقال الشافعية: لا يعتبر سفر المعصية رخصة؛ لأن الرخصة نعمة من الله فلا تنال بالمعصية، ولقوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ^(٢)﴾، ولأن جواز الرخص في سفر المعصية (إعانة) على المعصية وهذا لا يجوز.

وقال القرطبي: لا يجوز قصر الصلاة في سفر المعصية وهذا قول الجمهور. وأما الأكل في رمضان في سفر المعصية فالمشهور من مذهب مالك جواز الأكل^(٣).

وأميل إلى كلام الشافعية في منع الرخصة لمن سافر وفي نيته يعصى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد وأن يعامل بنقيض قصده حتى لا يكون ذلك مفتاحاً لحيل تؤدي إلى محرم.

(١) يُنظر: جامع الأسرار شرح المنار للكاكي ١٤٠١/٥، ١٤٠٢؛ وينظر: المجموع شرح المذهب

٢٦٠/٦، ٢٦٢ ط دار الفكر؛ وعوارض الأهلية للجبوري: ٤٦٥، ٤٦٦.

(٢) سورة البقرة من الآية (١٧٣) ؛ وينظر: التوضيح على التنقيح والتلويع على التوضيح

١٤٠/٢؛ وينظر: جامع الأسرار للكاكي ١٤٠٢/٥؛ وعوارض الأهلية للجبوري: ٤٦٧، ٤٦٨.

(٣) يُنظر: تفسير القرطبي ٣٥٦/٥، ٢٣٣/٢ ط دار الشعب؛ والمذهب ١٠٢/١ ط دار الفكر.

٥- الهزل

الهزل في اللغة: من قولهم هزل هزلاً، أي: مزح، وتصغير هزل هزيل، وبه سمى، ويقال: هزيل بن شرحبيل، ومنه قولهم: هازل اسم فاعل، وهزال صيغة مبالغة، ويقال: هزلت الدابة أهزلها هزلاً، أي: ضعفت بإساءة القيام عليها، وهزلت بالبناء للمجهول فهي مهزولة^(١).

وأما الهزل في الاصطلاح: هو عبارة عن أن يراد باللفظ معنى، لا يكون اللفظ موضوعاً له، ولا يكون صالحاً لأن يراد به ذلك المعنى على سبيل المجاز^(٢).

وقيل في الهزل: أن يراد بالشئ ما لم يوضع له، والهزل مخالف للمجاز والحقيقة؛ لأن الحقيقة تقابل المجاز، والهزل يقابل الجد، والمجاز داخل في الجد كالحقيقة، فكان الهزل مخالفاً لكل منهما^(٣).

هل الهزل يؤثر على الأهلية؟

الهزل لا يُنافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، ولا ينافي وجوب شئ من الأحكام، ولكن الهزل ينافي الاختيار والرضا؛ لأنه يعدم الرضا والاختيار في حق الحكم دون مباشرة السبب، فقله:

بعت واشتريت يوجدان برضا المتكلم واختياره، ولكن البيع لا يثبت لعدم الرضا به، والرضا به يكون بمنزلة خيار الشرط.

فيؤثر الهزل فيما يحتمل النقص كالبيع والإجارة، وأما ما لا يحتمل النقص كالطلاق والعتاق فلا يؤثر فيه وينفذ عليه^(٤).

(١) يُنظر: المصباح المنير ٣١١/٢؛ وينظر: القاموس المحيط ٩٢/٤؛ ط دار إحياء التراث العربي.

(٢) يُنظر: زبدة الأسرار للسيواسي ٣٤٨ ط نزار مصطفى.

(٣) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣٩٦/٤ وذكر له تعريفات أخرى.

(٤) يُنظر: شرح المنار للكاكي ١٣٦٥/٥؛ وينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٩٦/٤،

شرط الهزل

للهزل شرط واحد، وهو: أن يتكلم العاقدان بصريح اللسان بأنهما هازلين في العقد، ولا يشترط إثبات الهزل في العقد يل يكفي أن يكون ذلك سابقاً على العقد^(١).

هل هناك فرق بين الهزل والتلجئة؟

التلجئة هي: أن يلجئك إلى أمر باطنه خلاف ظاهره، وعلى ذلك تكون التلجئة نوعاً من الهزل، وبين التلجئة والهزل عموم وخصوص، فكل هزل تلجئة، وليس كل تلجئة هزل: لأن التلجئة لا تكون إلا في الاضطرار، أما الهزل فقد يكون باضطرار، وقد يكون بغير اضطرار، وقيل: إنهما بمعنى واحد^(٢)، وقد ذكر ذلك في كشف أسرار البزدوى، فقال: والتلجئة هي الهزل؛ لأن التلجئة أن تلجئك إلى أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره، فتكون التلجئة نوعاً من الهزل، وهو أعم.

ما يكون فيه الهزل عن التصرفات

الهزل يكون في ثلاثة أمور:

الأول: الإنشاءات.

الثاني: الإخبارات.

الثالث: الاعتقادات.

أما القسم الأول وهو الإنشاءات: فهو إحداث السبب الذي يستعقب

٤٩٧؛ ويُنظر: التوضيح على التنقيح ٣٩٤/٢ ط دار الكتب العلمية.

(١) يُنظر: التوضيح ٢، الصفحة السابقة؛ وينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤٩٧/٤؛ ويُنظر: عوارض الأهلية للجبوري ٣٧٣.

(٢) يُنظر: جامع الأسرار شرح المنار للكاكي ١٣٦٦/٥؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٤٦٦/٤؛ وعوارض الأهلية للجبوري ٣٧٤.

حكماً شرعياً.

والأسباب المؤدية إلى أحكام شرعية^(١)، إما أن تكون قابلة للانتقاض، أو لا تكون قابلة للانتقاض، أما التي تقبل الانتقاض فمثل البيع والإجارة والرهن والمزارعة وغير ذلك، فهذه الأشياء يمكن التواضع عليها بين العاقدين، وهذه لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تدخل المواضعة على أصل العقد.

الصورة الثانية: أن تدخل المواضعة على مقدار الثمن.

الصورة الثالثة: أن تدخل المواضعة على جنس الثمن.

الصورة الأولى: دخول المواضعة على أصل العقد:

إما أن يتفق العاقدان على الإعراض عن الهزل، وإما أن يتفقا على البناء على الهزل، وإما أن يتفقا على أنه لم يحضرهما شئ^(٢)، وإما أن يختلفا في الإعراض والبناء، فهذه أربع حالات:

أما الحالة الأولى وهي: إذا اتفقا على الإعراض عن الهزل: يقع البيع صحيحاً؛ لأن الهزل يرتفع بما قصدا من الجد...

أما الحالة الثانية وهي: إذا اتفقا على البناء على الهزل: ينعقد البيع فاسداً غير موجب للملك حتى ولو اتصل به القبض. ويترتب على ذلك ألا ينفذ إعتاق المشتري فيه بعد القبض.

وأما الحالة الثالثة، والرابعة وهي: إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شئ حين العقد، أو أنهما اختلفا فقال أحدهما: كنا معرضين عن المواضعة أثناء العقد، وقال الآخر: كنا مصرين

قال الإمام أبو حنيفة العقد صحيح؛ لأن الأصل في العقود الصحة

(١) يُنظر: عوارض الأهلية/للجبوري: ٢٧٦.

(٢) يُنظر: جامع الأسرار شرح المنار للكاكي ١٣٦٨/٥؛ وعوارض الأهلية للجبوري ٣٧٧.

واللزوم حتى يقوم عارض، والمواضعة عارض، ولم يتفقا على المواضعة، وهنا لم يتيقن العارض.

وقال الإمام أبو يوسف ومحمد: العقد فاسد؛ لأنهما لم يتفقا على رفع المواضعة، وإذا اتفقا على أنهما أعرضا حين العقد على المواضعة، وبني العقد على الجد فإن العقد صحيح عند الجميع^(١).

الصورة الثانية: دخول المواضعة على مقدار الثمن:

وفيه أربع صور:

الأولى: أن يتم الاتفاق بينهما على الإعراض.

الثانية: أن يتم الاتفاق على أنه لم يحضرهما شئ.

الثالثة: أن يختلف المتعاقدان فيما بينهما.

الرابعة: أن يتفق المتعاقدان على البناء على المواضعة.

ففى الأولى الاعتبار بما اتفقا عليه، وفي الثانية الهزل باطل وتصح التسمية عند الإمام، فإذا كانت بمأتي دينار صحت، وقال صاحبان: تجب المواضعة، ويعمل بها، وينعقد البيع بالمائة.

وفي الصورة الثالثة كالثانية، وفي الصورة الرابعة إذا اتفق المتعاقدان على البناء على المواضعة فالحكم عند الإمام الثمن مائتا دينار على الأصح، وعند صاحبين الثمن مائة؛ لأن غرضهم بالمائة الزائدة وهو الظهور أمام الناس.

الصورة الثالثة: دخول المواضعة على جنس الثمن:

وهو: أن يتواضع المتعاقدان على أن يكون البيع بمائة دينار، والثمن في الواقع ألف درهم.

(١) يُنظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٤٩٦؛ وعوارض الأهلية للجبوري: ٣٧٨، ٣٧٩؛ وعوارض الأهلية للدكتور/ صبرى معارك ٣٣٧، ٣٣٨.

وحكم هذا البيع: جائز في جميع الصور استحساناً؛ لأن البيع لا يصح إلا بالتسمية في البذل، وهما قصداً الجد في أصل العقد، فلا بد من تصحيحه.

وأما في القياس فالبيع باطل؛ لأنهما قصداً الهزل بما سميا ولم يذكر في العقد ما قصداً^(١).

أما القسم الثاني: وهو الذي لا يقبل الانتقاض، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: أسباب ليس فيها مال.

الثاني: أسباب المال فيها تبع.

الثالث: أسباب فيها المال مقصود.

أما النوع الأول مما لا يقبل الانتقاض: فهو كالطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص، والحكم في هذه الأشياء الصحة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، واليمين"^(٢).

وأما العفو عن القصاص، فإنه ملحق بالطلاق بجامع أن كلا منهما إسقاط.

الثاني: مثل تواضع المتعاقدان في النكاح على أصل النكاح، أو على قدر من المهر، أو على جنس المهر.

ففي التواضع على أصل النكاح يكون العقد صحيحاً، ويجب مهر المثل؛ لأن النكاح ليس فيه هزل بنص الحديث^(٣).

(١) يُنظر: عوارض الأهلية للجبوري ٣٨١، ٣٨٢.

(٢) الحديث رواه ابن ماجه رقم ٢٠٣٩ كتاب الطلاق، وأبو داود في كتاب الطلاق رقم ٢١٩٤ ط بيت الأفكار الدولية.

(٣) فإذا اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان، وأما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شئ من الإعراض والبناء، أو اختلفا فالنكاح جائز عند الإمام.

وأما إذا تواضعاً على جنس المهر، فإذا اتفقا على الإعراض يكون المهر بما سميا، وإذا اتفقا على البناء، أو على أنه لم يحضرهما شئ، أو اختلفا يجب مهر المثل

وأما النوع الثالث: وهو الأسباب التي يكون فيها المال مقصوداً: كالخلع، والعق على مال، والصلح عن دم العمد أما الخلع فالهزل يؤثر فيه عند أبي حنيفة، لأنه بمنزلة خيار الشرط، فلا يقع الطلاق، ولا يجب المال إذا شاءت المرأة ذلك وعند أبي يوسف ومحمد: لا يؤثر الهزل في الخلع، ولا يختلف بالبناء أو الإعراض أو الاختلاف، ففي جميع الصور يبطل الهزل، ويقع الطلاق، ويلزم المال^(١).

الهزل في الإقرارات

والهزل في الإقرارات سواء كان منه ما يحتمل الفسخ أو لا يحتمل فإنه يبطل الجميع؛ لأن الإقرارات مبنية على وجود المخبر به، والهزل في كلامه ما يدل على عدم المخبر به، لأن الهزل يظهر للناس ما هو خلاف الحقيقة، والإقرار يلزم صاحبه لأنه يترجح فيه جانب الوجود على جانب عدم.

الهزل في الاعتقادات

فإذا هزل في أمر يتعلق بالعتيدة على سبيل الهزل فقال مثلاً: إن الصنم إله، فهذا التعبير يكفر به، لأنه استخفاف بالدين، لأن الله - تعالى - يقول: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾^(٢) (وَقَالَ - تعالى - ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ

يُنظر: عوارض الأهلية للدكتور/ صبرى معارك: ٣٤١، ٣٤٢.

(١) كشف الأسرار للنسفي ٥٥٢/٢ وما بعدها؛ وينظر: عوارض الأهلية للدكتور/ معارك: ٣٤٤،

٣٤٥.

(٢) سورة التوبة الآية (٦٤).

لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ^(١).

والفرق بين الهازل بالكفر، والمكره على إجراء كلمة الكفر، أن الأول رضى بأن ينطق بهذه الكلمة الشنيعة على نفسه، وأما الثاني فأجبر عليها، وفدبه مطمئن بالإيمان، فيكفر الأول، ويبقى الثاني على إيمانه^(٢).

(١) سورة التوبة الآيتين (٦٥، ٦٦).

(٢) يُنظر: كشف الأسرار للنسفي ٥٥٧/٢؛ وشرح نور الأنوار على المنار للشيخ/ ملاجيون سعيد الميهوي هامش كشف الأسرار ٥٥٧/٢؛ وينظر: عوارض الأهلية للدكتور/ معارك: ٣٤٩.

٦- الخطأ

الخطأ في اللغة: ضد الصواب، يقال: أخطأ إخطاء، وخاطئة وتخطأ وخطئ، ومنه: أخطيت لغة رديئة، والخطيئة: الذنب، أو ما تعمد منه، الخطاء، والخطأ غير التعمد، ويقال: خطأه تخطئة، وتخطيئاً، أي: قال له: أخطأت^(١).

وأما تعريف الخطأ في الاصطلاح: فهو وقوع الشئ على خلاف ما أريد^(٢).

وقيل فيه: أن يفعل فعلاً من غير أن يقصد قصدًا تاماً^(٣).

وقال في التنويع: إن تمام الفعل بقصد المحل، ولكن المخطئ يقصد الفعل دون المحل، والخطأ من أسباب التخفيف كالسفر والمرض^(٤).

وقيل في تعريفه: الخطأ أمر يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت منه عند مباشرة أمر مقصود سواد^(٥).

هل الخطأ يؤثر في الأهلية؟

الخطأ لا يؤثر في أهلية الوجوب، ولا في أهلية الأداء بالنسبة للمكلف؛ لأن عقله وحياته هما الأساس في الأهلية، ولأنه يستطيع أن يميز بين القبيح والحسن، ولذلك لا يسقط عنه بسبب الخطأ أي تكليف من التكليف الشرعية، ولكن الخطأ اعتبر من عوارض الأهلية المكتسبة لأن الخطأ كما

(١) يُنظر: القاموس المحيط ١٨٨/١ ط دار إحياء التراث العربي؛ وينظر: المصباح المنير: ١٨٧ ط دار الفكر.

(٢) يُنظر: زبدة الأسرار للسيواسي: ٢٤٨.

(٣) يُنظر: التوضيح على التنقيح ٤١١/٢ ط دار الكتب العلمية.

(٤) يُنظر: التلويع على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ٤١١/٢.

(٥) يُنظر: جامع الأسرار للكاكي ١٤٠٤/٥ ط نزار مصطفى؛ وينظر: كشف الأسرار للبخاري ٥٣٤/٤.

سبق فى بعض التعريفات المشار إليها لا يقع إلا نتيجة لعدم التثبت والانتباه.

وقد اختلف العلماء فى مؤاخذة المخطئ على فعله، فقال المعتزلة: المخطئ غير مؤاخذ على فعله؛ لأنه غير قاصد للخطأ ولا للجناية التي وقعت منه، والجناية لا بد فيها من القصد.

وقد أجاب جمهور العلماء على كلام المعبرنة فقالوا: الجناية فى الخطأ وإن كانت غير مقصودة، لكنها جاءت نتيجة عدم التثبت والاحتياط. وقد استدل الجمهور بقول الله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾^(١) وقد استجاب الله للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك^(٢).

تأثير الخطأ فى حقوق الله، وفى حقوق العباد

إذا صدر من المكلف خطأ فى حق الله - تعالى - فإن الله أسقط العقوبة التى على المكلف، واعتبر الخطأ عذراً تعالى مخففاً، لقوله -تعالى-: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾^(٣).

وقوله: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"^(٤).

وبناءً على ذلك إذا أخطأ فى الفتوى بعد الاجتهاد لا يأثم، وإذا أخطأ فى الاتجاه إلى القبلة لا يأثم بعد الاجتهاد، وإذا أخطأ فرمى صيداً فإذا هو إنسان فمات فلا يأثم، وإذا زفت إليه غير امرأته فوطئها فلا يأثم.

وأما خطأ العبد فى حقوق العباد فلم يعتبره الشارع عذراً تسقط به

(١) سورة البقرة من الآية (٢٨٦) .

(٢) يُنظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٥٣٤/٤؛ وينظر: عوارض الأهلية للدكتور: حسن خلف الجبوري: ٣٩٦.

(٣) سورة البقرة من الآية (٢٨٦) .

(٤) رواه ابن ماجة فى السنن فى كتاب الطلاق رقم ٢٠٤٣؛ وأخرجه الطحاوي فى شرح معاني الآثار ٥٦/٢.

هذه الحقوق، ومن ذلك: لو أتلّف مال الغير خطأ بأن رمى صيدا فقتل شاة أو بقرة مملوكة لغيره فعليه الضمان، وكذلك إذا رمى صيدا فقتل إنساناً فعليه الدية؛ لأن الدية وجبت بالخطأ، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾^(١).

هل يصح طلاق المخطئ؟

إذا طلق امرأته خطأ بدون قصد الطلاق، فقد قال جمهور الحنفية: إن الطلاق نافذ وصحيح؛ لأن القصد أمر باطنى يصعب الاطلاع عليه، فلا يتعلق الحكم بوجود القصد حقيقة، ولكنه يتعلق بالسبب الظاهر الذى دل عليه، وهو أهلية المكلف، والأهلية مناطها العقل والبلوغ، فيكون نفياً للحرَج. وقال الإمام الشافعى: لا يقع طلاق المخطئ؛ لأن الطلاق يقع بالكلام، والكلام يصح إذا صدر عن قصد صحيح، ولكن الكلام هنا فسد لعدم القصد الصحيح، والمخطئ غير قاصد فلا يصح طلاقه، فيكون كالنائم والمغمى عليه.

وقد أجاب الجمهور عن الشافعى فقالوا: إن الشئ يقوم مقام غيره بشرطين:

الأول: أن يصلح دليلاً عليه.

الثاني: أن يكون في الوقوف على الأصل حرج لخفائه فينتقل الحكم عند وجود هذين الشرطين إلى الدليل مقام المدلول تيسيراً، ودفعاً للحرج.

والنائم في هذا المقام فقد فى حقه شرط وهو: أن الوقوف على الأصل ممكن، وهو إعمال العقل؛ لأن النوم مانع من استعمال العقل، على ذلك لا يصح إقامة البلوغ عن عقل مقام القصد لانتفاء الشرط فى حقه.

وإذا جرى على لسان المكلف لفظ البيع خطأ، فقال: بعث هذه العين

(١) سورة النساء من الآية (٩٢) ؛ ويُنظر: كشف الأسرار على أصول البزدوى ٥٣٥/٤.

بكذا بدلاً من قوله: سبحان الله، فقال الآخر: قبلت، وجب انعقاد البيع ولكنه ينعقد فاسداً، ويكون كبيع المكره.

الفرق بين الخطأ والهزل

والفرق بين كل من الخطأ والهزل يتضح بأمرين:

الأول: أن المخطئ من يريد أن يقول قولاً، فيسبق لسانه إلى ما لا يريد معناه.

والثاني: المخطئ ضد المصيب بينما الهازل ضد الجاد.

الفرق بين المخطئ والناسي

أن المخطئ يكون خطره نتيجة عدم التثبت والانتباه، أما الناسي في ذلك يكون فعله مما لا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه معنى يعتري الإنسان بدون اختيار منه فيوجب الغفلة عن الحفظ^(١).

(١) يُنظر: كشف أصول البزدوي ٥٣٧/٤، ٣٨٧؛ وينظر: التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ٤١٢/٢؛ وينظر: جامع الأسرار على المنار للكاكي ١٤٠٨/٥؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٥٣٧/٤؛ وعوارض الأهلية للجبوري: ٤٠٨.

٧- الإكراه

الإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه، بحيث لو خلى ونفسه لم يفعله ولم يباشره.

والإكراه يكون معدماً للرضا لا الاختيار، والرضا هو الارتياح إلى فعل شئ والرغبة فيه، والاختيار هو ترجيح فعل الشئ على تركه أو العكس.

وجميع أفعال الإنسان لابد لها من اختيار، إلا أنه يكون فاسداً إذا كان ترجيحاً لأهون الضررين، وقد يكون صحيحاً إذا كان صادراً عن رغبة في الفعل.

ولا يلزم من وجود الفعل من الإنسان أن يكون راضياً به مرتاحاً إليه، لأن الذي يجبر على فعل أحد الأمرين كلاهما مر، ويقدم على فعل أخفهما ضرراً يعد مختاراً ولكنه غير راض، وعلى هذا فإذا رضي الإنسان على فعل أو قول اختاره، ولكن قد يختاره ولا يرضاه، وذلك في حالة إذا كان يقصد من الاختيار دفع الأذى عن نفسه أو ماله.

أنواع الإكراه:

الإكراه عند الحنفية نوعان:

الأول: إكراه ملجئ أو تام، وهو الذي يوجب الإلجاء والاضطرار معاً، كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف معه تلف النفس أو العضو.

الثاني: إكراه غير ملجئ أو ناقص، وهو ما دون ذلك، كالضرب اليسير الذي لا يؤدي إلى تلف النفس أو العضو.

وحكم الأول: أنه يفسد الاختيار ويعدم الرضا، وحكم الثاني: أنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وسبب هذه التفرقة أن النوع الأول لا قدرة للعبد معه، لذا جعلوه مفسداً للاختيار والرضا معاً، أما الثاني فإنه يمكن الصبر

عليه، فجعلوه مفسداً للرضا دون الاختيار^(١).

ويرى الشافعية وغيرهم أن الاختيار والرضا متلازمان فلا اختيار من غير رضا، ولا رضا من غير اختيار، فمن أكره على فعل شئ فهو غير مختار له ولا راضٍ عنه.

شروط الإكراه:

شروط الإكراه التي يتحقق بها هي:

- ١- قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، فإن لم يكن في وسع المكره إيقاع ما هدد به فلا ثمة إكراه.
- ٢- قدرة المكره على إيقاع ما هدد به حالاً، ويكون ذلك بغلبة ظن الواقع عليه الإكراه.
- ٣- أن يكون التهديد ضرره كبيراً، ويكون الضرر كبيراً إذا أتلّف نفساً أو عضواً، أو كان ضرباً شديداً أو حبساً طويلاً، وهذا يختلف باختلاف الناس، فقد يكون الحبس القصير لا يتحمّله إنسان، وقد يرضى الآخر بالحبس الطويل.
- ٤- أن يكون ليس في وسع الواقع عليه الإكراه دفعه وتقاضيه.
- ٥- أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يعتبر إكراهاً، ولا تأثير له على صحة التصرفات، كإجبار المدين على بيع ماله وفاء لدينه، أو نزع الملكية للمصلحة العامة كتوسيع الطرق أو المساجد^(٢).

أثر الإكراه:

الإكراه عند الحنفية يختلف أثره بحسب ما إذا كان في الأقوال والأفعال على التفصيل الآتي^(٣):

(١) حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ٢٨٨/٣.

(٢) المذهب للشيرازي ٧٨/٢؛ كشاف القناع ٢٣٦/٥؛ بدائع الصنائع للكاساني ٤٤٧٩/٩.

(٣) شرح التلويح على التوضيح ١٩٧/٢؛ فواتح الرحموت ١٦٧/١.

الإكراه فى الأقوال:

الأقوال إما أن تقبل الفسخ أو لا تقبل، أما ما يقبل الفسخ من الأقوال إذا كانت عقوداً كالبيع والإجارة ونحو ذلك من العقود والتصرفات، فأثر الإكراه فيها هو الفساد لا البطلان، سواء كان الإكراه ملجئاً أو غير ملجئ.

وحجتهم: أن الإكراه لا يعدم الاختيار وإنما يعدم الرضا، والرضا من شروط الصحة والنفاذ، وليس ركناً ولا شرطاً من شروط الانعقاد، فيلزم من ذلك فساد العقد لا بطلانه، لذا فإذا أجاز من وقع عليه الإكراه العقد حال السعة والاختيار بعد زوال الإكراه، صح العقد لزوال المعنى المفسد.

وأما الأقوال التي لا تقبل الفسخ، فهذه لا تتأثر بالإكراه كالطلاق والعتاق واليمين والنذر، فإن هذه التصرفات لا تقبل الفسخ ويكفي فيها الاختيار فقط دون الرضا، وتقع كلها صحيحة من الواقع عليه الإكراه، وقد حكم الشارع بصحة هذه العقود مع الهزل، فوجب أن تكون كذلك مع الإكراه، فحكم الحنفية بصحة زواج المكره وطلاقه ورجعته وعتقه ويمينه، إذ إن الشارع اكتفى في صحة هذه العقود بالاختيار دون الرضا، والمكره مختار للعبارة وإن لم يرض عنها.

أما الأقوال إذا كانت إقرارات فلا تصح كلها، لأن الإقرار خبر يتردد بين الصدق والكذب، وإنما يوجب الحقوق باعتبار رجحان جانب الصدق على جانب الكذب، فإذا تحقق الإكراه وانعدم الرضا دل على الكذب فلا تثبت الحقوق به سواء كان الإكراه ملجئاً أم غير ملجئ.

ويرى جمهور الفقهاء أن الإكراه يبطل أقوال المكره مثل بيعه وشرائه وطلاقه^(١) لعدم وجود الرضا والرغبة فيها، وليس فيها اختيار صحيح، والإكراه ليس كالهزل، فإن الهازل ينطق بالعبارة وهو راغب في التكلم بها، وعنده اختيار صحيح لها، وإنما يريد الاستهزاء والهزل، فيجب أن يعاقب

(١) حاشية الخرض ٩/٥؛ المغنى مع الشرح الكبير ٢٥٩/٨؛ قليوبى وعميرة ٣/٣٣٢؛ حاشية ابن القاسم على الروض المربع ٤/٣٣٢.

على ذلك تغليظاً وتشديداً عليه، وذلك بجعل عبارته صحيحة، وليس كذلك المكره

فلا رغبة عنده ولا اختيار صحيح في النطق بالعبرة، وإنما يقصد دفع الأذى عن نفسه، فهذا عذر يناسبه التخفيف وذلك بإلغاء عبارته، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"^(١).

الإكراه في الأفعال:

الأفعال منها ما لا يمكن أن يكون الفاعل آلة للحامل، ومنها ما يمكن أن يكون الفاعل آلة للحامل.

فالنوع الأول هو ما لا يمكن أن يكون الفاعل آلة للحامل، كالأكل والشرب والزنى، فهذا لا أثر للإكراه فيه، ويقتصر أثر الفعل على الفاعل؛ لأن الأكل بفم غيره لا يتصور، وكذا الزنى لا يتصور أن يكون بآلة غيره، وكما إذا أكره صائماً على الإفطار في رمضان، فإنه يبطل صوم الفاعل لا المكره، ولكن إذا أوجب الفعل حداً كالزنى، فإن الإكراه يسقط الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة.

أما النوع الثاني وهو ما يمكن أن يكون فيه الفاعل آلة للحامل، كإتلاف النفس أو الأعضاء أو المال، وهذا قسمان:

القسم الأول: أن يكون الفاعل آلة للمكره يغير محل الإكراه، فهذا لا أثر للإكراه فيه، بل يلزم الفاعل بحكم فعله، ويكون حكمه مقصوراً عليه، وذلك كإكراه محرم محرماً آخر على قتل الصيد، فإن الفاعل أراد من الحامل الجناية على إحرامه، فلو جعلنا الفاعل آلة للحامل، كان الفعل منه جناية على إحرام الحامل، وهو غير ما أكره عليه، فلا يتحقق الإكراه، ولهذا فإن الفاعل يضمن جزاء ما قتل من الصيد.

(١) وفي رواية: "إن الله تجاوز....." والحديث فيه كلام كثير، راجع: تلخيص الحبير ٢٨١/١.

القسم الثاني: أن يكون الفاعل آلة للمكره لا يغير محل الإكراه، كإتلاف النفس والمال، فإن كان الإكراه غير ملجئ اقتصر الحكم على الفاعل؛ لأن اختياره صحيح فيضمن قيمة ما أتلفه من الأموال، ويقام القصاص عليه في القتل العمد.

وإن كان الإكراه ملجئاً نُسب القتل إلى الحامل ابتداءً، فيلزم ضمان المال ويقتضى منه وحده عند أبي حنيفة ومحمد وتلزمه الكفارة؛ لأن الإنسان مجبول على حب الحياة، فلما أكره الفاعل على قتل غيره التمس لنفسه مخلصاً من الهلاك، فيفسد اختياره بالإكراه؛ لأنه كالآلة في يد غيره يحركها كيف يشاء.

ويرى أبو يوسف أنه لا قصاص على أحد، بل الواجب الدية على الحامل؛ لأن القصاص إنما هو مباشرة جناية تامة، وقد عدمت في كل من الحامل والفاعل، ولكن عليهما الإثم في الآخرة.

ويرى الإمام زفر أن القصاص يجب على الفاعل، لأنه المباشر للقتل العمد العدوان، وقد باشر ذلك لإحياء نفسه عمداً، فيلزمه القود، لأن إثم القتل لم يسقط عنه بالإكراه، فلا يسقط عنه حكم القتل من باب أولى^(١).

(١) راجع: بدائع الصنائع ٧/ ١٧٩؛ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ٧٥٨.

الأسئلة

- س١: عرف الجهل، واذكر أثره على الأهلية، ثم اذكر أنواعه من حيث قبول العذر به من عدمه.
- س٢: عرف السفه، ثم بين أثره على الأهلية، وإلى أي قسم من عوارض الأهلية ينتمي؟ ثم اذكر خلاف العلماء في حكم الحجر على السفه.
- س٣: عرف الخطأ لغة واصطلاحاً، وهل يؤثر الخطأ في الأهلية؟ وما الفرق بين المخطئ والناسي؟
- س٤: عرف الإكراه، واذكر أنواعه، وما هي الشروط التي يتحقق بها الإكراه؟

ثانياً: الدراسة النصية

(فصل^(١) في: دفع^(٢) العلل المؤثرة)

أي: الاعتراضات^(٣) الواردة على العلل^(٤) المؤثرة^(٥).

(١) الفصل في اللغة، معناه: القطع، ومنه: الفصل في الخصومات، وهو الحكم بالقطع، تقول: فصلت المرأة رضيعها، أي: قطعتة عن الرضاع. المصباح المنير للفيومي ١١٩/٢. والفصل في الاصطلاح: هو القدر المكتوب في علم معين من العلوم. والفصل: جزء من الكتاب يندرج تحت الباب. والفصل يساوي البحث، فكلاهما بمعنى واحد. ينظر: البحث الفقهي طبيعته وخصائصه، لإسماعيل عبد العال ص١٢، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، د/عبد الوهاب أبو سليمان ص٢٥.

(٢) الدفع معناه: الرد، وهو: الإتيان بدعوى قبل الحكم أو بعده من قبل المدعى عليه تزيل دعوى المدعي، أو هو: جواب المدعى عليه على دعوى المدعي.

(٣) الاعتراضات جمع، ومفردتها: الاعتراض، أو الاعتراض، وهو: إقامة الدليل على ما يخالف دليل الخصم.

اختلفت آراء العلماء في بيان عدد ما يقدر في العلة، فمنهم من ذكر خمسة وعشرين قادحاً كالآمدي (الإحكام للآمدي ٦٩ / ٤) وما بعدها، وابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ٢ / ٢٥٧)، ومنهم من اقتصر على ذكر ثمانية عوارض كإمام الحرمين (البرهان ٩٧ / ٢) وما بعدها، ومنهم من جعلها خمسة كفخر الدين الرازي (المحصول للرازي ٣٦٠ / ٢) وما بعدها، ومنهم من اتجه إلى غير ذلك.

(٤) العلل جمع ومفردة العلة، وهي لغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله، ومنه سمي المرض علة؛ لأنه يغير حال الإنسان من الصحة إلى السقم، ومن القوة إلى الضعف. أو مأخوذة من العلل، وهو: الشرب بعد الشرب؛ لأن الفقيه يعاود النظر فيها مرة بعد مرة. النهاية لابن الأثير ٢٤٢ / ٣. والعلة اصطلاحاً: الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته، أو الوصف المعرف للحكم، أو الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور مع الحكم وجوداً وعدمًا. ينظر: المذهب في أصول المذهب ٢٦٠ / ٢، كشف الأسرار للبخاري ١٧١ / ٤.

(٥) التأثير معناه: الإيجاد، أي: التي ثبت تأثيرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع، ويوجد الحكم بوجودها.

والعلل نوعان:

أ- علل مؤثرة، وهي التي قال بها الحنفية ويعترض عليها الشافعية، ثم يجيب عنها

(منه^(١)): النقض، وهو: وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم^(٢)، ودفعه بأربع طرق)، أي: الجواب عنه يكون بأربع طرق^(٣):

الحنفية، كإثبات الولاية على الصغيرة، فالصغر وصف مؤثر في إثبات الولاية، وكالضرورة في طواف الهرة، فالضرورة مؤثرة في إسقاط النجاسة. وترد عليها ستة اعتراضات هي: النقض، وفساد الوضع، وعدم الانعكاس، والفرق، والممانعة، والمعارضة.

ب - علل طردية، وهي التي قال بها الشافعية، ويعترض عليها الحنفية على وجه يلجئ الشافعية للقول بالتأثير، كالإسكار فإنه علة لتحريم كل مسكر، فيحرم الخمر إذا كان مسكرا، وتزول حرمة إذا زال إسكاره بأن صار خلا. وترد عليها أربع اعتراضات هي: القول بالموجب، والممانعة، وفساد الوضع، والمناقضة. والطرده لغة معناه: الإخراج، يقال: طرده يطرده، وطرده السلطان، أي: أخرجه. لسان العرب لابن منظور ٢٦٥١/٤ مادة طرد. والطرده في الاصطلاح: هو الوصف الذي لا مناسب له في الحكم ولا يشعر به. وعرفه البابرتي فقال: هو الوجود عند الوجود في جميع الصور، وزاد البعض فقال: وهو العدم مع العدم. ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ٦١٩/٢، التقرير للبابتري ١٢٨/٦، جامع الأسرار للكاكي ١١٣١/٤.

(١) أي: من دفع الاعتراضات التي ترد على العلة المؤثرة، فالضمير يعود على الدفع.
(٢) هذا تعريف النقض في الاصطلاح، وأما تعريفه لغة، فهو: الحل والإبطال، أو إفساد الشيء بعد إحكامه، يقال: نقض البناء، أي: هدمه. والنقض هو أول اعتراض يورده الخصم على العلة المؤثرة، فهل النقض من الاعتراضات الصحيحة أو الفاسدة؟ قولان للعلماء: الأول: أنه لا يرد على العلة المؤثرة؛ لأن التأثير لا يثبت إلا بنص أو إجماع. الثاني: أنه اعتراض صحيح يمكن دفعه والجواب عنه؛ لأن المؤثر ليس موجبا للعلم قطعا، ولكنه مؤثر بغالب الظن. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٦٢/٤.

(٣) وجه حصرها في أربعة: أن المعلن إما أن يدفع قول السائل بوصف العلة، أو يدفعه بآثرها؛ لأن الوصف إنما صار علة بالآثر، أو يدفعه بحكمه؛ لأن العلة لما لم توجد حكما تكون لغوا، أو يدفعه بالغرض؛ لأن الحكم ما شرع إلا لغرض فيصح الدفع به.

ويذكر فيه أربع طرق: الأول: الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض. والثاني: الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلة علة لأجله. والثالث: الدفع بالحكم وهو منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. والرابع: الدفع بالغرض وهو أن يقول الغرض التسوية بين الأصل والفرع فكما أن العلة موجودة

(الأول^(١)): منع وجود العلة في صورة النقض، نحو: خروج النجاسة علة الانتقاض^(٢)، فنوقض بالقليل^(٣)، فيمنع الخروج فيه^(٤)، وكذا^(٥) وجود ملك بدل المغصوب (يوجب ملكه) أو ملك المغصوب؛ لثلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد، (فنوقض بالمدير)^(٦)، أي: إذا كان ملك بدل المغصوب علة للملك المغصوب، ففي غضب المدير يكون كذلك، لكن الحكم متخلف؛ لأن المدير غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندهم، (فيمنع ملك بدله)، أي: ملك بدل المغصوب،

في الصورتين فكذا الحكم وكما أن ظهور الحكم قد يتأخر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكل حال. ينظر: التلويح ١٧١/٢.

- (١) أي: الطريق الأول من طرق دفع النقض، وهو: المسمى الدفع بالوصف.
- (٢) أي: انتقاض الوضوء حكم معطل بخروج النجاسة، وهذا كلام الحنفي (المستدل).
- (٣) أي: ينقض الشافعي (المعتز) ما قاله الحنفي، وبيان النقض: لو كان النجس الخارج من بدن الإنسان حدثاً، لكان القليل الذي لم يسلم من رأس الجرح حدثاً، وليس كذلك عند الحنفية؛ لأنهم يقولون: بأن الدم إذا لم يسلم عن موضعه لم ينقض الوضوء.
- (٤) هذا جواب المستدل على النقض المذكور، وبيانه: لا نسلم أن القليل الذي لم يسلم خارج؛ لأن الخروج يعني الانتقال من مكان باطن إلى مكان ظاهر، ولم يوجد ذلك عند عدم السيلائن، فلا يعتبر خارجاً، بل ظهرت النجاسة لزوال الجلدة الساترة لها، بخلاف السبيلين فإنه لا يتصور ظهور القليل إلا بالخروج. ينظر: حاشية منلا خسرو على التوضيح ص٣٤٤.

- (٥) هذا مثال آخر للدفع بالوصف، وتوضيحه: أن يقول المستدل: ملك بدل المغصوب علة للملك المغصوب، فينقض المعتز هذا الكلام بالمدير، وهو من أعتق عن دبر بعد موت سيده، كأن يقول له سيده: أنت حر بعد موتي، وكيفية النقض بالمدير: أن ملك بدل المدير المغصوب موجود كعلة، ولم يوجد الحكم (ملك المدير المغصوب)؛ لأن المدير عند الحنفية غير قابل للانتقال.

- (٦) فيه إشارة إلى جواب المستدل على النقض المذكور؛ لأن المدير لا يجوز أن يملك بدلاً عن المغصوب؛ لأنه غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك، فيمنع ملك بدل المدير المغصوب؛ لأن ضمان بدل المدير ليس في مقابل المدير، ولكن هو في مقابل اليد الفاتنة حتى يرده الغاصب إلى صاحبه، فلا نقض إذن. ينظر: التوضيح ١٧٩/٢.

بأن يمنع في المدير كون بدله بدل المغصوب، فإنه ليس بدل العين، بل بدل اليد الفائئة، (فإن ضمان المدير ليس بدلا عن العين، بل بدل عن اليد الفائئة)^(١).

(والثاني^(٢): منع معنى العلة في صورة النقض)، أي: المعنى الذي صارت العلة علة لأجله، وهو^(٣) بالنسبة إلى العلة كالثابت بدلالة النص^(٤) بالنسبة إلى المنصوص، (نحو: مسح الرأس مسح، فلا يسن فيه التثليث^(٥)، كمسح الخف^(٦) فنوقض بالاستنجا^(٧)، فيمنع في الاستنجا المعنى الذي في المسح، وهو: أنه تطهير حكمي^(٨)

(١) وخلاصة الجواب من المستدل: أنا لا نسلم أن بدل المدير المغصوب بدل عن عين المدير بل هو بدل عن اليد الفائئة.

(٢) أي: الطريق الثاني من طرق الجواب عن النقض، وهو: المسمى الدفع بمعنى الوصف، وهو أن يقول المستدل: ليس المعنى الذي صار الوصف به علة - وهو التأثير - موجودا في صورة النقض، فلا يكون الوصف بدونه علة، وبناء عليه فلا يكون نقضا.

(٣) أي: المعنى الذي صارت العلة علة لأجله.

(٤) وهي: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة تدرك بمجرد اللغة. كما في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) من الآية ٢٣ سورة الإسراء، فالتأفيف منصوص عليه، وهو محرم بمنطوق الآية، وأشد حرمة منه الضرب والشتم وكل ما فيه أذى للأبوين، وهذا ثابت بدلالة النص، ويسمى الشافعية مفهوم الموافقة.

(٥) مبنى هذا الكلام على أن يكون المراد بعدم سنية التثليث كراهته؛ لئلا يكون حكما شرعيا فيعمل. التقرير والتحبير ٣٣٨/٢.

(٦) هذا مثال للدفع بمعنى الوصف، وتوضيحه: أن يقول المستدل: مسح الرأس مسح فيكره فيه التثليث (التكرار) قياسا على مسح الخف، بجامع المسح في كل، فالعلة هي المسح وكراهة التكرار أو التثليث هو الحكم.

(٧) هذا نقض أورده المعارض على المثال الذي أورده المستدل، وبيانه: أن العلة - وهي المسح - منقوضة بالاستنجا بالأحجار، فإنه مسح، ومع ذلك يسن فيه التكرار، فقد وجدت العلة وهي المسح، وتخلف الحكم وهو كراهة التكرار؛ حيث لا يكره التكرار في الاستنجا.

(٨) هذا جواب عن النقض الذي أورده المعارض، ومعناه: أنا لا نسلم أن الاستنجا مسح، بل المشروع فيه إزالة عين النجاسة؛ لأنه تطهير حقيقي معقول المعنى، فيفيد فيه التكرار؛ لتأكيد التطهير كالغسل بالماء، بخلاف مسح الرأس فإنه تطهير حكمي غير معقول المعنى؛

غير معقول، ولأجله)، أي: لأجل أنه تطهير حكمي غير معقول^(١) (لا يسن في المسح التثليث؛ لأنه لتوكيد التطهير المعقود^(٢) فلا يفيد)، أي: التثليث (في المسح، كما في التيمم، ويفيد في الاستنجاء)^(٣).

(والثالث^(٤): قالوا: هو الدفع بالحكم)، وهو: أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض.

(وذكروا له أمثلة^(٥): خروج النجاسة علة للانتقاض^(٦)، وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب^(٧)،

وحل الإتلاف لإحياء المهجة^(٨) لا ينافي عصمة المال^(٩)، كما في الخمصة، فيضمن الجمل الصائل، فنوقض بالمستحاضة، والمدبر، ومال الباغي.

-
- لأن المسح لغة: الإصابة، وهي تعني التخفيف، فلا يفيد التكرار في المسح؛ لأنه تطهير حكمي كالتيمم، ويفيد في الاستنجاء؛ لأنه تطهير حقيقي. شرح المنار وحواشيه ص٤٤٤.
- (١) أي: أنه توقيفي تعبدى، فلا يسأل أحد عن علته؛ لأن الرأس طاهر بطبعه، فلا يحتاج إلى طهارة إلا باتباع الأمر في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) من الآية ٦ سورة المائدة
- (٢) هكذا في جميع النسخ المطبوعة، ولعله سهو من الناسخ، والصواب هو: التطهير المعقول؛ لأنه في الاستنجاء لقلع وإزالة النجاسة، كما ستعلم حالاً.
- (٣) لأن التطهير في الاستنجاء معقول المعنى؛ لأنه إزالة عين النجاسة، ولهذا كان الغسل فيه أفضل، وفي التثليث توكيد للتطهير، فيندفع النقض وتسلم العلة ويثبت بها الحكم.
- (٤) أي: الطريق الثالث من طرق الجواب عن النقض، وهو: المسمى الدفع بالحكم.
- (٥) ممن ذكرها: الإمام فخر الإسلام البزدوي متابعاً القاضي أبي زيد الدبوسي.
- (٦) العلة هي خروج النجاسة، والحكم هو انتقاض الوضوء.
- (٧) العلة هي ملك بدل المغصوب، والحكم هو جواز ملك المغصوب.
- (٨) المهجة هي: خالص دم الإنسان الذي إذا خرج خرجت روحه وهو دم القلب في قول الخليل، والعرب تقول: سالت مهجهم على رماحنا.
- (٩) العلة هي إحياء النفس من الهلاك، والحكم هو وجوب الضمان؛ لأن إحياء المهجة لا ينافي عصمة المال لصاحبه.

فأجابوا في الأولين^(١) بالمانع^(٢)، لكن هذا تخصيص العلة^(٣)، ونحن لا نقول به، وفي الثالث بأننا لا نسلم حل الإلتلاف ينافي العصمة في مال الباغي، بل إنما انتفت بالبغي).

أورد الإمام نحر الإسلام^(٤) - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - للدفع بالحكم ثلاثة أمثلة:

أحدها: خروج النجاسة علة للانتقاض، فنوقض بالمستحاضة؛ أن خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض^(٥).

وثانيها: أن ملك بدل المغصوب علة لملك المَغْصُوب، فنوقض بالمدير.

فأجاب نحر الإسلام - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - في الصورتين بأنه إنما تخلف الحكم في

(١) أي: ما ورد من نقض على ما ذكره المستدل في المثاليين الأولين، وهما: خروج النجاسة علة الانتقاض، وملك بدل المَغْصُوب علة لملك المَغْصُوب.

(٢) المانع لغة: الحاجز. وفي اصطلاح الأصوليين: هو الذي يلزم من وجوده العدم، أي: يلزم من تحققه انعدام صحّة العمل أو أجره.

(٣) التخصيص لغة: الأفراد بالشيء، يقال: خصه بكذا إذا أفرد به دون غيره، وفي الاصطلاح فعند الحنفية: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن. وعند الجمهور: قصر العام على بعض ما تناوله. وأما تخصيص العلة فهو: تخلف حكم الأصل عنها في محل، وذلك بعد وجودها بركنها مسنوفة لشروطها على الوجه الذي يقتضي ثبوت الحكم بها. أو هو: تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع. وصدر الشريعة اقتصر على ذكر مذهبيين في خلاف العلماء في تخصيص العلة، وستأتي أدلة الفريقين بعد ذكر الطريق الرابع من طرق دفع النقض.

(٤) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، المعروف بفخر الإسلام، البزدوي نسبة إلى بزدة، وهي قلعة حصينة تبعد عن نصف ستة فراسخ، فقيه ما وراء النهر، على مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي سنة ٤٨٢هـ، ودفن بسمرقند. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٥٩٤/٢.

(٥) أي: أن المستحاضة يخرج منها الدم، وليس حدثاً؛ لأنها صارت باستمراره من أصحاب الأعداء، فكان خروجه عفواً.

الصورتين بالمانع^(١).

فأقول: هذا الجواب ليس دفعا بالحكم، بل هو تخصيص العلة ونحن لا نقول به
وثالثها: أن حل الإلتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة، كما في الخمصة^(٢)، فإنه إن
أكل مال الغير في الخمصة لإحياء المهجة يجب الضمان، فيضمن الجمل
الصائل^(٣)، فنوقض بمال الباغي؛ أن العادل^(٤) إذا أتلف مال الباغي حال
القتال؛ لإحياء المهجة لا يجب الضمان، فعلم أن حل الإلتلاف لإحياء
المهجة ينافي العصمة، فأجاب: بأننا لا نسلم أن حل الإلتلاف ينافي العصمة في
مال الباغي فإن عصمة مال الباغي لم تنتف بحل الإلتلاف بل بالبغي.

فأقول: الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائل وجوب الضمان وبقاء العصمة،
فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم^(٥)، بل حاصل هذا المثال أن
المعلل^(٦) ادعى حكما أصليا وهو العصمة - مثلا - فإن الأصل في أموال
المسلمين العصمة وهي لا ترتفع إلا بعارض^(٧)، وليس في المتنازع فيه وهو

(١) وهو العذر في المستحاضة، وعدم قابلية المدبر للملك. المذهب ٢/٢٦٥.

(٢) الخمصة: المجاعة، أو خلاء البطن من الطعام.

(٣) والمعنى في ذلك: أن حل الإلتلاف لمال الغير لا ينافي عصمة المال في حالة الخمصة
لإحياء النفس، فيجب الضمان، ويقاس عليه حل إلتلاف الجمل الصائل لإنقاذ النفس
المصول عليها، فيجب الضمان عند الحنفية، وعند الشافعي لا يضمن، وكلام الشافعي
أقرب إلى التعقل. أصول البزدوي ٤/ ١٠٤، ١٠٥، المذهب ٢/٢٦٥، ميزان الأصول ص ٦٣٢.

(٤) المقصود منه هنا: السلطان الحاكم بشرع الله إذا أتلف مال الباغي بغير ضمان، لماذا
ضمن في الصور الأولى ولم يضمن في مال الباغي، مع أن الكل معصوم؟

(٥) لم يرتض صدر الشريعة أن وجوب الضمان في الجمل الصائل يعتبر دفعا بالحكم.

(٦) المعلل هو: من نصّب نفسه لإثبات الحكم، والسائل هو: من نصّب نفسه لنفي الحكم.

(٧) المقصود بالحكم الأصلي هنا هو: عصمة أموال المسلمين ولا تنتفي هذه العصمة إلا
بعارض، والحكم الأصلي هو العصمة، والعارض هو الصيال.

الجلل الصائل إلا عارض واحد وهو حل الإلتلاف^(١)، وقد ثبت بالقياس على الخمصة أن حل الإلتلاف لا يصلح رافعا للعصمة، فتبقى العصمة في الجمل الصائل، فيجب الضمان^(٢)، فنوقض بمال الباغي؛ أن حل الإلتلاف رافع للعصمة في مال الباغي^(٣).

فأجاب^(٤): بأن رافع العصمة في مال الباغي ليس حل الإلتلاف، بل الرافع هو البغي، فهذا لا يكون دفعا بالحكم، بل بيان أن علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقض شيء آخر، هذا معنى قوله: (والضابط^(٥) المنتزع من هذه الصورة أن المعلن إذا ادعى حكما أصليا لا يرتفع إلا بعارض كالعصمة - هنا - وليس في المتنازع فيه إلا عارض واحد وهو حل الإلتلاف، وأثبت بالقياس أن هذا العارض لا يرفعه، كما في الخمصة، فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا، فأجاب بأن الرافع شيء آخر، فهذا بيان أن علة الحكم في صورة النقض شيء آخر) ويمكن أن يتكلف في أن تصير هذه المسألة نظيرا للدفع بالحكم^(٦)، ووجهه: أن يراد بالحكم عند منافاة حل الإلتلاف

(١) فإذا كان العارض هو صيال الجمل على الإنسان، فيكون الحكم هو الإلتلاف لإحياء النفس، فيضمن الجمل الصائل إذا قتله لإحياء نفسه. التوضيح ١٨١/٢.

(٢) أي: قياس الجمل الصائل على الخمصة، فكانت الخمصة هي الأصل، والجمل الصائل هو الفرع، أما الاعتراض الذي أورد على الخمصة فهو مال الباغي؛ حيث إنه معصوم، وعلة الإلتلاف هي البغي.

(٣) أي: أن مال الباغي معصوم، وسبب الإلتلاف هو البغي.

(٤) أجاب الإمام فخر الإسلام البزدوي، أن حل الإلتلاف لمال الباغي لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه.

(٥) الضابط هو: أمر كلي يجمع تحته جزئيات في باب واحد، وأما القاعدة فهي: أمر كلي يجمع تحته جزئيات غير محصورة، وتكون في أبواب كثيرة.

(٦) هذا كلام صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللهُ - حيث تكلف فجعل هذا المثال دفعا بالحكم، وهو عدم منافاة حل الإلتلاف، فلا تسقط عصمة المال بقتل الجمل الصائل إحياء للمهجة، فاعلة حل الإلتلاف، والحكم وجوب الضمان؛ لعدم سقوط العصمة.

العصمة، وهذا الحكم ثابت في الجمل الصائل قياسا على الخمصة، فنقض بمال الباغي؛ أن حل الإتلاف ثابت فيه وعدم منافاته العصمة غير ثابت؛ لأن الثابت فيه منافاة حل الإتلاف العصمة

فأجاب: بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه؛ لأن العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الإتلاف، بل إنما انتفت بالبغي، هذا غاية التكلف ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة^(١)؛ لأن النقض وجود العلة مع تخلف الحكم، وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة؛ لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة فلا يكون نقضا، فلأجل هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة أورد مثلا آخر في المتن فقال:

(وأنا أورد للدفع بالحكم مثالا^(٢)) وهو: القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين^(٣) فنقض بالتييم)، أي: في صورة عدم القدرة على الماء يوجد القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة، ومع ذلك لا يوجب الوضوء، (فيمنع عدم وجوب الوضوء فيه، بل الوضوء واجب لكن التيمم خلف عنه)، معناه: أنا لا نسلم عدم وجوب الوضوء في صور عدم الماء، بل الوضوء واجب

(١) هذا اعتراض من المصنف رَحِمَهُ اللهُ، حاصله بأن حل الإتلاف ليس علة لعدم المنافاة حتى يكون تحققه في مال الباغي مع المنافاة نقضا؛ وذلك لأنه لا يلائم عدم المنافاة، وعدم سقوط العصمة، فضلا عن تأثيره فيه، وأجاب التفتازاني على اعتراض المصنف بقوله: إن التمثيل إنما هو على تقدير أن يجعل حل الإتلاف علة مؤثرة، ويكفي في التمثيل الفرض والتقدير. ينظر: التلويح ١٨٢/٢.

(٢) لم يرتض صدر الشريعة الأمثلة الثلاثة المذكورة واعتبرها غير صالحة للدفع بالحكم، فذكر المثال الذي أورده في كلامه وهو صالح للدفع بالحكم عنده. التوضيح ١٨٢/ ٢، التلويح ١٨٣/٢.

(٣) معناه: أن الخارج من السبيلين أو غيرهما يوجب الوضوء، وهذا كلام المستدل.

لكن التيمم خلف عنه^(١).

الرابع^(٢): الدفع بالغرض نحو: خارج نجس فيكون ناقضاً^(٣)، فنقض بالاستحاضة^(٤)، فنقول^(٥): الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما؛ فإنه حدث ثمة^(٦)، لكن إذا استمر يصير عفواً، فكذلك هنا^(٧).

(ثم اعلم^(٨) أنه إن تيسر الدفع)، أي: دفع النقض (بهذه الطرق فيها^(٩))، وإلا

(١) هذا جواب المصنف عن النقض السابق، وهو واضح في أن الحكم لم يتخلف عن العلة، بل الواجب هو الوضوء، لكن التيمم خلف عنه عند تعذره، أي: عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله، وجد القيام إلى الصلاة، فيجب الوضوء، والتيمم خلف عنه.

(٢) أي: الطريق الرابع من طرق الجواب عن النقض، وهو المسمى: الدفع بالغرض، أي: أن الغرض التسوية في الحكم بين المقيس وهو الفرع، والمقيس عليه وهو الأصل.

(٣) هذا كلام المستدل، يبين فيه أن خروج النجاسة علة لنقض الوضوء، سواء كان خروجها من السبيلين أو من غيرهما.

(٤) هذا كلام المعترض، وبيانه: أن ما قاله المستدل منقوض بالمستحاضة؛ فإنها تتوضأ لكل صلاة، فإن توضأت ثم خرج منها دم قبل الصلاة لا ينتقض وضؤها؛ لكون الدم مستمراً، فقد وجدت العلة وهي خروج النجاسة، وتخلف الحكم وهو نقض الوضوء.

(٥) أي: في الجواب على هذا النقض.

(٦) أي: في السبيلين.

(٧) أي: في غير السبيلين، وتوضيح هذا الجواب: أن الغرض من الدفع هو التسوية بين السبيلين وغيرهما، والخارج من السبيلين مثل الاستحاضة وسلس البول، وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف من الأنف أو دم الجرح من اليد، فإن الخارج من غير السبيلين إذا استمر يكون عفواً، ويتوضأ المكلف لوقت كل صلاة، فيرفع الحرج لوقت الصلاة، وينتقض بخروج الوقت. شرح المنار وحواشيه ص٨٥٢، التوضيح ١٨٣/٢، حاشية منلا خسرو على التوضيح ص٣٤٥.

(٨) هذا تنبيه من العلامة صدر الشريعة رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَنْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِنْ النِّقْضُ لَا يَرُدُّ عَلَى الْعِلَلِ الْمُؤَثِّرَةِ؛ لِأَنَّ التَّأْثِيرَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَلَا تَوْجِدُ مَنَاقِضَةً، وَأَجَابَ التَّفْتَازَانِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ ثَبُوتُ التَّأْثِيرِ قَدْ يَكُونُ ظَنًّا، فَيَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِالنِّقْضِ.

(٩) أي: إذا ورد نقض صوري على العلة المؤثرة، فلا بد من رده بأحد طرق الدفع الأربعة

فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلة، وإن وجد المانع فلا^(١) لكن بعض أصحابنا^(٢) يقولون: العلة توجب هذا لكن تخلف الحكم لمانع، فهذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به، بل نقول: إنما عدم الحكم لعدم ما هو العلة حقيقة، فنجعل عدم المانع جزءاً للعلة أو شرطاً لها^(٣).

لهم^(٤) في جواز التخصيص: القياس على الأدلة اللفظية^(٥)، والثابت بالاستحسان^(٦) عطف على قوله: القياس على الأدلة اللفظية) فإنه مخصوص عن

التي سبق ذكرها، فإذا دفع النقض بأحدها فيها ونعمت، أي: قد تم التعليل وثبت الحكم. (١) معنى ذلك: أن النقض إذا لم يندفع بأحد الطرق الأربعة المذكورة، فلا يخلو الحال من أمرين: أن يوجد في صورة النقض مانع يمنع من ثبوت الحكم أو لا، فإذا لم يوجد مانع فقد بطل التعليل، أي: بطلت العلة؛ لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع، وإن وجد مانع لم تبطل العلة لوجود المانع، فيكون ذلك إما قولاً بتخصيص العلة كما ذهب إليه البعض، وإما قولاً بأن عدم المانع جزء العلة أو شرط لها، فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض لانتفاء العلة بانتفاء جزئها أو شرطها على ما سيبدأ في توضيحه.

(٢) كالإمام البزدوي؛ حيث يقول: إن عدم المانع من قبيل تخصيص العلة. (٣) هذا ما يقول به صدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ، وهو: أن عدم المانع جزء العلة أو شرطها، فيترتب على ذلك انتفاء الحكم في صورة النقض؛ بناءً على انتفاء جزء العلة أو شرطها. التلويح / ١٨٣.

(٤) أي: أدلة من أجاز تخصيص العلة. (٥) هذا دليلهم الأول، ومعناه: أنه يجوز قياس تخصيص العلة على تخصيص الأدلة اللفظية، فكما أن العلة توصف بالعموم؛ لوجودها في محال متعددة، فيقاس على الأدلة اللفظية. أجاب المانعون تخصيص العلة فقالوا: إن التخصيص من الأحكام التي لا تتعدى من الأصل، وهو الأدلة اللفظية إلى الفرع، وهو تخصيص العلة؛ لأن تخصيص العلل ملزوم للمجاز، وذكر العام وإرادة الخاص من قبيل المجاز، فلا يتعدى من الأصل إلى الفرع.

(٦) هذا دليلهم الثاني، ومعناه: أن عدم المانع يقاس على الاستحسان، فكما أن في عدم المانع توجد العلة ويتخلف الحكم، فكذلك في الاستحسان.

أجاب المانعون تخصيص العلة فقالوا: إن الحكم الثابت بطريق الاستحسان هو ترك القياس لدليل أقوى منه، وهذا الدليل يسمى الاستحسان، وهو ليس من تخصيص العلة

القياس، ولأن التخلف قد يكون لفساد العلة، وقد يكون لمانع كما في العلل العقلية^(١) وذكروا أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة، المسطور في كتبنا: أنه ذكر القائلون بتخصيص العلة: أن الموانع خمسة، لكنني عدلت عن هذه العبارة لما سيأتي^(٢)

(مانع من انعقاد العلة^(٣))، كأنقطاع الوتر في الرمي وكبيع الحر، أو من تمامها^(٤) كما إذا حال شيء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه، أو من ابتداء الحكم^(٥) كما إذا أصاب السهم فدفعه الدرع وتكيار الشرط، أو من تمامه^(٦) كما إذا اندمل بعد إخراج

في شيء. التوضيح ١٨٦/٢.

(١) هذا دليلهم الثالث، ومعناه: أن تخلف الحكم عن العلة لا يخلو من احتمالين: الأول: أن يكون تخلفه لفساد في العلة، والثاني: أن يكون تخافه لمانع من ثبوت الحكم، والمعلل قد بين أن تخلف الحكم لمانع، فيجب قبوله؛ لأنه بيان أحد المحتملين، وهذا بمنزلة العلل العقلية، كالإحراق بالنار للخشب الملطخ بالطلق المحلول، فالنار علة عقلية للإحراق، فلو وضع خشب - وهو قابل للإحراق - ولكن وضعت عليه مادة عازلة، وهو الطلق المحلول، ثم وضع في النار لا يحترق مع أن العلة وهي النار موجودة، لكن تخلف الحكم وهو الإحراق لمانع، وهو المادة العازلة، فكذا في العلل الشرعية.

أجاب المانعون بتخصيص العلة فقالوا: إن العلة هي مجموع الوصف مع عدم المانع، وهو خلاف الغرض؛ لأن الغرض أن العلة هي الوصف فقط. حاشية منلا خسرو ص ٣٤٨. وهناك أدلة أخرى تنظر في كتب أصول الفقه لمن أراد المزيد.

(٢) أي: أن القائلين بتخصيص العلة ذكروا في كتب المذهب الحنقي الأصولية أن الموانع خمسة أقسام: مانع من انعقاد العلة، ومانع من تمام العلة، ومانع من ابتداء الحكم، ومانع من تمام الحكم، ومانع من لزوم الحكم. لكن صدر الشريعة لم يرتض هذه العبارة، وعدل عنها ليشمل المانع عن الحكم وعن العلة انعقادا وتاماً، والعمدة في ذلك كله الاستقراء.

(٣) هذا أول الموانع التي ذكرها القائلون بتخصيص العلة، وهو مانع من انعقاد العلة، وذكروا لكل مانع جانبين: جانب حسي، وجانب شرعي.

(٤) هذا ثاني الموانع التي ذكرها القائلون بتخصيص العلة، وهو مانع من تمام العلة.

(٥) هذا ثالث الموانع التي ذكرها القائلون بتخصيص العلة، وهو مانع من ابتداء الحكم.

(٦) هذا رابع الموانع التي ذكرها القائلون بتخصيص العلة، وهو مانع من تمام الحكم.

السهم والمداواة ونكحار الرؤية، أو من لزومه^(١) كما إذا خرج وامتد حتى صار طبعاً له وأمن ونكحار العيب، فالتخصيص ليس في الأولين^(٢) بل في الثلاث الأخرى؛ لأن التخصيص أن توجد العلة ويتخلف الحكم لمانع، فالمانع ما يمنع الحكم بعد وجود العلة، ففي الأولين من الصور الخمس ليس كذلك؛ لأن العلة لم توجد فيهما وفي الثلاث الأخرى العلة موجودة والحكم يتخلف لمانع، فتخصيص العلة مقصور على الثلاث الأخرى^(٣)؛ فلهذا لم يقل في المتن^(٤) إن الموانع خمسة، بل قال: ما يوجب عدم الحكم خمسة.

والفرق بين الخيارات:

أن في خيار الشرط قد وجد السبب وهو البيع والخيار داخل على الحكم وهو الملك على ما عرف في فصل مفهوم المخالفة^(٥) أن الخيار يثبت بالضرورة فدخوله على الحكم أسهل من دخوله على السبب؛ لأن دخوله على السبب يوجب الدخول على المسبب والحكم، فإذا كان داخلاً على الحكم لم يكن الملك ثابتاً.

وأما خيار الرؤية فإن البيع صدر مطلقاً من غير شرط فأوجب الحكم وهو الملك لكن الملك لم يتم؛ لعدم الرضا بالحكم عند عدم الرؤية.

وأما خيار العيب فإنه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا بالحكم؛ لأنه قد

(١) هذا خامس الموانع التي ذكرها القائلون بتخصيص العلة، وهو مانع من لزوم الحكم.

(٢) وهما المانع من انعقاد العلة والمانع من تمامها.

(٣) وهي المانع من ابتداء الحكم، والمانع من تمامه، والمانع من لزومه. قال التفتازاني: إن

الموانع ثلاثة ولكنهم أضافوا إليها الانعقاد والتمام، وهما ليسا منها. التلويح ١٨٧/٢.

(٤) المقصود به: متن كتاب التنقيح.

(٥) مفهوم المخالفة هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل

النطق، ويسمى دليل الخطاب أيضاً. الإحكام للأمدى ٦٩/٣.

وجد الرؤية لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العيب، ففي خيار العيب يتمكن المشتري من رد البعض؛ لأنه تفريق الصفة وهو بعد التمام جائز، وفي خيار الرؤية لا يتمكن؛ لأنه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز.

ولنا^(١): أن التخصيص في الألفاظ مجاز فيخص بها^(٢)، وترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصاً؛ لأنه ليس بعلة حينئذ^(٣) ولأن العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم؛ لإجماع العلماء على وجوب التعدية إذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع، مع أن هذا التقييد واجب، فعلم أن عدم المانع حاصل عند وجود العلة، فهو إما ركنها أو شرطها، أي: عدم المانع إما ركن العلة أو شرطها، (فإذا وجد المانع فقد عدم العلة ثم عدمها قد يكون لزيادة وصف^(٤) كما أن البيع

(١) أي: أدلتنا على عدم جواز تخصيص العلة، وهي ردود على أدلة القائلين بجواز تخصيصها.

(٢) هذا رد على الدليل الأول للمجوزين تخصيص العلة؛ لأن التخصيص ملزوم للمجاز، والمجاز من خواص اللفظ، واختصاص اللازم يوجب اختصاص الملزوم به، وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم، وهو محال، فلا يتعدى إلى غير اللفظ، وهو العلل، فيكون قياس العلل على الأدلة اللفظية قياساً مع الفارق.

(٣) هذا رد على الدليل الثاني للمجوزين تخصيص العلة؛ لأن إثبات الحكم بطريق الاستحسان فيه ترك للقياس بدليل أقوى منه، وهو ليس من تخصيص العلة؛ لأن انتفاء الحكم لمانع مع تحقق العلة لوجهين: الوجه الأول: أن الوصف في القياس ليس بعلة عند وجود المعارض الأقوى - كما علمت أن من شرط القياس أن لا يعارضه دليل أقوى منه - فانتفاء الحكم في صورة النقض مبني على عدم العلة لا على تحقق المانع عن الحكم من وجود العلة.

الوجه الثاني: أن العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الإجماع على وجوب تعدية الحكم إلى كل صورة توجد فيها العلة من غير تقييد بعدم المانع، فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم، بل يتخلف عنه ولو لمانع لا يكون علة.

(٤) كأن تكون عليته مشروطة بعدم ذلك الوصف، فينتفي بوجوده، كما في البيع المطلق، أي: غير المقيد بشرط علة الملك، فإذا زيد عليه الخيار لم يبق مطلقاً، فلم يكن علة.

المطلق علة للملك، فإذا زيد الخيار فقد عدت، أو لنقصانه كالخارج النجس - مع عدم الحرج - علة للانتقاض، وهذا معدوم في المعذور^(١).

(ومنه^(٢): فساد الوضع^(٣)، وهو: أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه^(٤)، ولا شك أن ما ثبت تأثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع^(٥) وما ثبت فساد وضعه علم عدم تأثيره شرعا^(٦) وسيأتي مثاله^(٧)).

(١) عدم العلة قد يكون لنقصان وصف هو من جملة أركان العلة أو شرطها، فينتفي الكل بانتفاء جزئه أو شرطه، كالخارج النجس، فإنه مع عدم الحرج علة للانتقاض الوضوء، فعند وجود الحرج لا يكون علة، كما في المستحاضة؛ لأن استمرار نزول الدم صيرها من ذوي الأعذار فكان عفوًا.

خلاصة القول في الفرق بين النقض والتخصيص:

أن من قال بعدم تخصيص العلة جعل تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور قادحا في العلة وسماء نقضا، ومن قال بتخصيص العلة لم يعتبر تخلف الحكم نقضا، ولكن سماء تخصيصا قياسا على دلالات الألفاظ. التوضيح ١٨٧/٢، حاشية منلا خسرو ص ٣٥١.

(٢) أي: ومن دفع العلل المؤثرة، فالضمير يعود على الدفع.

(٣) هذا الاعتراض الثاني؛ لأن الأول هو النقض، وفساد الوضع لغة: وضع الكلام في غير موضعه.

(٤) هذا تعريفه في الاصطلاح عند صدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ. والمراد به: فساد وضع العلة، وهو: كون الوصف في نفسه بحيث يكون آيبا عن الحكم ومقتضيا لصدده.

(٥) مثال ما ثبت تأثيره شرعا: الصغر فإنه وصف مؤثر في إثبات الولاية على الصغيرة، والإسكار فإنه وصف مؤثر في تحريم الخمر.

(٦) مثل: تكرار المسح في التيمم، فإذا ثبت فساد الوضع في العلة بأن ترتب عليها نقيض ما تقتضيه علم عدم تأثيرها شرعا.

(٧) أي: مثال فساد الوضع هو: أن يقول الشافعي: التيمم مسح فيسن فيه التثليث كالاستنجاء، فيجيب الحنفي عن ذلك بقوله: ما قاله الشافعي فاسد في وضعه؛ لأنه ترتب على الوصف (المسح) نقيض ما يقتضيه؛ إذ المسح أصلا يقتضي عدم التكرار (التثليث) كما سبق في الدفع الثاني - بمعنى العلة - في النقض، فإن المسح يعني الإصابة، وهي تنبئ عن التخفيف، والتكرار فيه لا يفيد، بخلاف إزالة النجاسة في الاستنجاء، فإن التكرار فيه مفيد، وعليه فالتكرار في مسح الرأس لا يفيد، ومن ثم فهو

(ومنه^(١): عدم العلة مع وجود الحكم^(٢)، وهذا^(٣) لا يقدر؛ لاحتمال وجوده بعلّة أخرى^(٤)).

مكروه، وما قاله الشافعي هنا أن المسح لا يكره فيه التكرار، ومن ثم فقد اعتبر الوصف (المسح) في الكراهة والاستحباب معا، وهما نقيضان، فالعلة فاسد وضعها؛ لأنه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح على الخف. حاشية الوجيزة النافعة على التوضيح ص٤٧٧.

- (١) أي: ومن دفع العلل المؤثرة، فالضمير يعود على الدفع.
 (٢) وهو المسمى بعدم الانعكاس، وهو الاعتراض الثالث الوارد على العلل المؤثرة، وما ذكره صدر الشريعة يمكن اعتباره تعريفا لعدم الانعكاس، وهو عكس تعريف النقض.
 (٣) اسم الإشارة يقصد به عدم الانعكاس، ومثاله:

أ - أن يعلل المستدل تحريم مجامعة الرجل زوجته المحرمة بالإحرام، فيقول المعارض: إن تحريم مجامعتها يحصل فيما لو كانت حائضا أو كانت صائمة في رمضان ولم تكن محرمة، فتعليل التحريم بالإحرام لا ينعكس، والعلة يجب أن تكون مطردة منعكسة.
 ب - أن يقول المستدل على منع تقديم أذان الصبح: صلاة الصبح صلاة لا تقصر، فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب، فيقول المعارض: تعليلك بأنه " صلاة لا تقصر " لا يصح؛ لأنه لا ينعكس، فالحكم وهو منع تقديم الأذان على الوقت موجود فيما يقصر من الصلوات أيضا، فالوصف الذي ذكرته غير معرف للحكم؛ لأن الحكم وجد بدونه، وأيضا ليس مؤثرا في الحكم؛ لأنه لو كان مؤثرا لما وجد الحكم بدونه، وإن خلفه وصف مؤثر آخر فعليك أن تذكره لنا، وإلا فالتعليل بهذا الوصف غير صحيح، وهذا رجع إلى عدم التأثير. ينظر: الإبهاج لابن السبكي ١١٢/٣.

(٤) معنى كلام العلامة صدر الشريعة رَحِمَهُ اللهُ: أن عدم الانعكاس لا يقدر، أي: لا يؤثر في العلية؛ لجواز ثبوت الحكم بعلل شتى، كالملكية - مثلا - فإنها حكم يمكن أن يعلل بأكثر من علة، كالبيع والهبة والإرث، فهذا مثال في العلل الشرعية، ويمكن التمثيل لعدم الانعكاس في العلل العقلية بالحرارة، فإنها تعتبر حكما يمكن تعليله بالحركة والشمس والنار. وهناك قول ثان وهو: أن عدم الانعكاس يقدر في العلية؛ لأنه لا يجوز تعليل الحكم بأكثر من علة؛ لأن المعلول - وهو الحكم - لا يوجد بدون علته. لباب الأصول للسمرقندي ص٦٤، المحصول للرازي ٣٧٥/٢.

(ومنه^(١): الفرق^(٢) قالوا: هو فاسد^(٣)؛ لأنه غصب منصب المعلل^(٤) وهذا نزاع جدلي^(٥)، ولأنه إذا ثبت عليه المشترك لا يضره الفارق، لكن إذا أثبت في الفرع مانعا يضره^(٦).

وكل كلام صحيح في الأصل إذا أورد على سبيل الفرق لا يقبل، فينبغي أن يورد على سبيل الممانعة^(٧) حتى يقبل^(٨)، كقول الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - إعتاق

(١) أي: ومن دفع العلل المؤثرة، فالضمير يعود على الدفع.
(٢) الفرق هو الاعتراض الرابع من الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة، ويجب دفعه، وتعريفه لغة: ضد الجمع، ومعناه: الفصل والتمييز بين الشيئين، يقال: فرقت بين الحق والباطل، أي: فصلت بينهما. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤/٤٩٣.
وفي الاصطلاح: أن يتبين في الأصل وصف له مدخل في التعليل ولا وجود له في الفرع.
(٣) شرع المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - في ذكر أقوال الأصوليين في الفرق هل يعد قادحا في العلة أو لا؟ واقتصر في الذكر - هنا - على قول المانعين له وعدم اعتباره قادحا في العلة. وللأصوليين قولان آخران في عده أو عدم عده قادحا، فتصير أقوالهم ثلاثة:
القول الأول: أن الفرق لا يقبل ولا يعد قادحا في العلة؛ ولذلك يلزم رده وعدم قبوله مطلقا. القول الثاني: أن الفرق صحيح ويقبل ويقدر في العلة، وهو إن اشتمل على معارضة معنى الأصل، ومعارضة علة الفرع بعلة، فليس المقصود منه المعارضة، وإنما الغرض منه مناقضة الجمع.

القول الثالث: أن الفرق ليس سؤالا على حياله، بل هو سؤالان، فهو معارضة في الأصل بمعنى، ومعارضة في العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة.

(٤) هذا الدليل الأول للأكثرين الذين لم يعتبروا الفرق قادحا.
(٥) بعد بيان الدليل الأول للأكثرين الذين لم يعتبروا الفرق قادحا، فإنه لا يخفى عليك أن هذا النزاع جدلي، يقصد به عدم وقوع الخطأ في البحث، وإلا فهو غير نافع في إظهار الصواب، والجدل معناه: العلم الذي يقتدر به على حفظ أي وضع يراد، ولو باطلا، وهدم أي وضع يراد ولو حقا.

(٦) هذا الدليل الثاني للأكثرين الذين لم يعتبروا الفرق قادحا، ومعناه: لو أثبت الفارق على وجه يمنع ثبوت الحكم في الفرع يكون مضرا.

(٧) سيأتي بيانها بعد الانتهاء من هذا الاعتراض.

(٨) أي: يكون مقبولا إذا أورد على سبيل الممانعة.

الراهن تصرف يبطل حق المرتهن) هذا تعليم ينفع في المناظرات وهو أن كل كلام يكون في نفسه صحيحاً، أي: يكون في الحقيقة منعا للعلة المؤثرة، فإنه إذا أورد على سبيل الفرق يمنع الجدلي توجيهه، فيجب أن يورد على سبيل المنع لا على سبيل الفرق فلا يتمكن الجدلي من رده، كقول الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - إعتاق الراهن^(١) تصرف يبطل حق المرتهن، (فيرد كالبيع، فإن قلنا: بينهما فرق فإن البيع يحتمل الفسخ لا العتق، يمنع توجيه هذا الكلام، فينبغي أن نورده على هذا الوجه، وهو: أن حكم الأصل إن كان هو البطلان فلا نسلم) الأصل هنا بيع الراهن، فإن أراد أن الحكم فيه البطلان فهذا ممنوع؛ لأن الحكم عندنا في بيع الراهن التوقف^(٢).

(وإن كان التوقف)، أي: إن كان حكم الأصل التوقف، (ففي الفرع إن ادعيت البطلان لا يكون الحكمان متماثلين، وإن ادعيت التوقف لا يمكن؛ لأن العتق لا يحتمل الفسخ).

(وكقوله في العمد^(٣): قتل آدمي مضمون، فيوجب المال كالخطأ، فنقول: ليس كالخطأ؛ إذ لا قدرة فيه على المثل)، أي: في الخطأ على المثل؛ لأن المثل جزاء كامل فلا يجب مع قصور الجناية وهو الخطأ، فإن أورد على هذا الوجه ربما لا يقبله الجدلي فنورده على سبيل الممانعة.

(فتوجيه هذا)، أي: توجيه هذا الكلام على سبيل الممانعة (أن حكم الأصل) وهو الخطأ (شرع المال خلفاً عن القود، وفي الفرع مزاحمته إياه) يعني أن المال شرع

(١) لعبده الذي قام برهنه.

(٢) أي: على إجازة المرتهن، فإن أجازته نفذ، وإلا فلا؛ لأن موجب الرهن ثبوت الاستيفاء للمرتهن. تبين الحقائق للزيلعي ٨٥/٦.

(٣) أي: كقول الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - في القتل العمد، وهذا مثال ثان للفرق.

خلفا عن القود؛ لأن حكم الأصل وجوب القود، لكن لم يجب لما قلنا^(١)، فوجب خلفه، وفي الفرع - وهو العمد - الحكم عند الشافعي - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى - مزاحمة المال القود، فلا يكون الحكمان متماثلين^(٢).

(ومنه^(٣): الممانعة^(٤) فهي إما في نفس الحجة^(٥)؛ لاحتمال أن يكون متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد^(٦) والتعليل بالعدم^(١)، ولاحتمال أن لا تكون العلة هذا بل

(١) وهو: أن القتل الخطأ فيه قصور الجناية، فلا يوجب المثل الكامل، فوجب المال خلفا عنه.
(٢) حيث إنه قياس مع الفارق؛ لأن قصور الجناية في الأصل (وهو القتل الخطأ) لا يوجب المثل الكامل، فوجب المال خلفا عنه، بخلاف العمد، فإن ولي الدم مخير بين القصاص والدية بطريقة المزاحمة، أي: مزاحمة المال القصاص.

(٣) أي: ومن دفع العلة المؤثرة، فالضمير يعود على الدفع.
(٤) الممانعة في اللغة: مأخوذة من الفعل منع، تقول: منعه الأمر، ومن الأمر منعا، فهو ممنوع، أي: محروم، والفاعل مانع، وللمباغة ممنوع ومَنَّاع، فهي: أن تحول بين الرجل وبين الذي يريده، والمنع خلاف الإعطاء، ومنه قوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا) الآيات ١٩ - ٢١ سورة المعارج. المصباح المنير للفيومي ٢٤٧/٢.

والممانعة في الاصطلاح هي: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المجيب من غير دليل، أو هي: عدم قبول السائل ما ذكره المعلن من مقدمات الدليل كلها أو بعضها من إقامة الدليل عليه، أو هي: منع مقدمة الدليل، إما مع السند أو بدونه. التلخيص شرح التنقيح لنجم الدين الدركاني ص ٣٨٦.

(٥) شرع صدر الشريعة - رَحْمَةُ اللَّهِ - في تفصيل أوجه الممانعة، فقوله: (إما) هنا للتفصيل، وأقسام الممانعة أربعة سيذكرها المصنف تباعا:

القسم الأول: أن يمنع المعارض كون ما تمسك به المجيب علة، بأن يقول: لا أسلم أن ما ذكرت من الوصف صالح لكونه علة. واختلف الأصوليون في قبول هذا الوجه إلى قولين: أولهما: أنه لا يقبل؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل لجامع، فلا يكفي إثبات ما يدعيه. وثانيهما: أنه يقبل، وهو اختيار المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ.

والممانعة في نفس الحجة هي أساس المناظرة؛ لعموم ورودها على القياس؛ إذ قلما تكون العلة قطعية، وعند إيرادها يرجع المعلل في التقصي عنها إلى مسالك العلة وهي كثيرة.

(٦) هذا رد على من قال بعدم قبول القسم الأول من الممانعة؛ حيث قال المصنف: يقبل؛

غيره كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد^(٢)، وإما في وجودها في الأصل أو في الفرع كما مر^(٣)، وإما في شروط التعليل^(٤) وأوصاف العلة، ككونها مؤثرة^(٥).

- لاحتتمال أن يكون المجيب أو المستدل متمسكا بما لا يصلح دليلا كالطرد.
- (١) فقد اختلف فيه الأصوليون، فمنعه الحنفية، وجوزه بعض الشافعية
- (٢) كما في قولهم: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فلا يسلم أن العلة في الأصل أعني المكاتب كونه عبدا، بل العلة هي جهالة المستحق أهو السيد أم الوارث؟. المذهب ٢/٢٤٨، التلخيص ص٣٨٦، حاشية منلا خسرو على التوضيح ص٣٦٤.
- (٣) هذا هو القسم الثاني من أقسام الممانعة، وهو: أن يمنع المعارض وجود الوصف في الأصل أو في الفرع بعد تسليم كون الوصف صالحا للعلة.
- (٤) هذا هو القسم الثالث من أقسام الممانعة، وهو ممانعة من قبل المعارض في شروط القياس؛ إذ الشيء لا يثبت بدون شروطه، والمعارض هنا يمنع شرطا مجمعا عليه وليس مختلفا فيه.
- (٥) هذا هو القسم الرابع من أقسام الممانعة، وهو: منع المعنى الذي صار الوصف به علة ودليلا، وهو التأثير أو الأثر، وهو ما يعبر عنه بصلاح الوصف للإلزام على الخصم.
- وأما غير المصنف فقسم الممانعة إلى أربعة أقسام أيضا، وهي: ١ - منع حكم الأصل ٢ - منع وجود الوصف المدعى أنه علة ٣ - س منع كون الوصف علة ٤ - منع وجود ما ادعى كونه علة في الفرع.
- وهذه أمثلة لكل قسم من هذه الأقسام:
- مثال القسم الأول: الكفارة عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل والشرب.
- والجواب: أنا لا نسلم أنها متعلقة بالجماع، بل هي متعلقة بما يكون جنائية، والفرق بين الممانعة في نفس الوصف وبين الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف: أن الممانعة في نفس الوصف هو منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع، مع تسليم تعلقه به في الأصل، فهي مختصة بالفرع، أما في نسبة الحكم إلى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور. بديع النظام لابن الساعاتي ٦٤٦/٢.
- مثال القسم الثاني: إن علة الولاية على الصغيرة هي البكارة، وبمعنى آخر: أن الولاية للأب بوصف البكارة؛ لأن الصغيرة جاهلة بأمر النكاح؛ لعدم الممارسة.
- والجواب: أنا لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم، وهو إثبات الولاية على الصغيرة؛ لأنه أي إثبات الولاية يظهر له تأثير في موضع آخر سوى محل النزاع في الصغيرة الثيب، وإنما تصح هذه الممانعة؛ لأن الوصف بنفسه غير صالح لإثبات الحكم،

(ومنه^(١)): المعارضة^(٢)، واعلم أن المعارض^(٣) إما أن يبطل دليل المعلن ويسمى مناقضة، أو يسلمه لكن يقيم الدليل على نفي مدلوله ويسمى معارضة وتجري في الحكم وفي علته، والأولى تسمى معارضة في الحكم، والثانية في المقدمة)، فقله: واعلم أن

وكونه حجة ما لم يظهر تأثيره في إيجاب الحكم.

مثال القسم الثالث: السلم الحال الذي قال به الشافعي ومنعه الحنفية فهو أحد عوزي البيع، فكان كضمن المبيع، فيعترض على السلم الحال بأنه غير حكم النص، وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، وهنا غير حكم النص، وهو الشرط أن يكون مؤجلا، والشرط هنا متفق عليه، وعدل به عن سنن القياس.

مثال القسم الرابع: قال الحنفية: إن صلاح الوصف لإثبات الحكم لا يصلح إلا بواسطة التأثير كالجرح لما كان سببا لوجوب القصاص بوصف السراية، ولما لم يثبت هذا الوصف وهو السراية للموت لا يجب القصاص، وإذا قال الخصم: التأثير عندي ليس بشرط، بل الطرد هو الحجة بدون التأثير فلا حاجة إلى بيان التأثير.

والجواب: إن الوصف لا بد له من التأثير عند الخصم، فلا يصح الاحتجاج بالوصف بدون التأثير، ومثال ذلك: كمثل كافر، مثلها بقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) من الآية ١١ سورة الشورى، الكاف في قوله تعالى: (كمثله) للنأكيد، أي: على مثال الكافر أقام بينة كفار على مسلم أن عليه كذا لم تقبل؛ وذلك لأن هذا لا يعتبر حجة عند الخصم، وأما إذا قلنا: إن صلاح الوصف يشترط فيه التأثير بمثال الممانعة فيه تعليل الأشياء الستة، منها الذهب والفضة بالثمنية، والباقي بالطعم؛ وذلك لإثبات شرط المماثلة، والتقابض فيها باعتبار أن كلا من الوصفين لشدة الحاجة إليه ينبئ على الخطر والعزة، فيختص جواز البيع في هذه الأشياء بزيادة شرط إظهارها للخطر. بديع النظام ٦٤٦/٢، كشف الأسرار للبخاري ١٥٧/٤ - ١٧٠، المذهب ٢٤٨/٢ - ٢٥٣.

(١) أي: ومن دفع العلل المؤثرة، فالضمير يعود على الدفع.

(٢) المعارضة في اللغة: المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة. المصباح المنير ٤٠٣/٢ والمعارضة في الاصطلاح: تسليم المعارض دلالة ما ذكره المستدل من الوصف على مطلوبه، وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه. كشف الأسرار للبخاري ٥١/٤.

(٣) هذا تنبيه من المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - على أن مرجع جميع الاعتراضات إلى المنع والمعارضة؛ لأن غرض المستدل الإلزام بإثبات مدعاه بدليله، وغرض المعارض عدم الإلزام بمنعه عن إثباته بدليله.

المعتراض هذا تقسيم الاعتراض على المناقضة والمعارضة لا تقسيم المعارضة، فإذا علل المعلن فلمعتراض أن يمنع مقدمات دليله ويسمى هذا ممانعة، فإذا ذكر لمنعه سنداً يسمى مناقضة، كما يقول: ما ذكرت لا يصلح دليلاً؛ لأنه طرد مجرد من غير تأثير إلى آخر ما عرفت في الممانعة^(١)، وله أن يسلم دليله، فيقول: ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما ذكرت من المدلول، لكن عندي ما ينفي ذلك المدلول، ويقيم دليلاً على نفي مدلوله، سواء كان المدلول هو الحكم أو مقدمة من مقدمات دليله، الأول: يسمى معارضة في الحكم، والثاني: يسمى معارضة في المقدمة، كما إذا أقام المعلن دليلاً على أن العلة للحكم هي الوصف الفلاني، فلمعتراض أن لا ينقض دليله، بل يثبت بدليل آخر أن هذا الوصف ليس بعلة، فهذا معارضة في المقدمة ثم شرع في تقسيم المعارضة في الحكم فقال:

(أما الأولى فإما بدليل المعلن، وإن كان بزيادة شيء عليه^(٢)، وهي معارضة مناقضة^(٣)، فإن دل على نقيض الحكم بعينه فقلب^(٤)، كقوله: صوم رمضان صوم

(١)، وهي: ١- منع حكم الأصل ٢- منع وجود الوصف المدعى أنه علة ٣- منع كون الوصف علة ٤- منع وجود ما ادعي كونه علة في الفرع.

(٢) يعني زيادة تفيد تقريراً وتفسيراً لا تبديلاً وتغييراً.

(٣) لأنه وجد فيها معنى المعارضة والمناقضة؛ إذ المعارضة إتيان دليل آخر يوجب خلاف ما أوجبه دليل المستدل في بعض السور من غير إقامة دليل مبتدأ به يبطل علته، فلما تضمن هذا النوع من المعارضة إحدى خاصتي المعارضة، وهي إظهار علة مبتدأ، وإحدى خاصتي المناقضة وهي إبطال الدليل سميت معارضة فيها مناقضة. شرح السراج الهندي ص ٣١٥

(٤) المناقضة التي فيها معارضة على قسمين: قلب وعكسه؛ لأنه إن دل على نقيض الحكم بعينه فقلب، وإن دل على حكم آخر يلزم منه ذلك النقيض فعكسه وسيذكرهما المصنف في كلامه التالي. أصول السرخسي ٢/٢٣٨.

والقلب في اللغة يستعمل لمعنيين: أحدهما جعل الشيء منكوساً، أي: جعل اعلاه أسفله و أسفله اعلاه، فقلب الإناء ويقوم به ضرب من الاعتراض.

فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كالقضاء، فنقول: صوم فرض فيستغنى عن التعيين بعد تعيينه كالقضاء، لكن هنا التعيين قبل الشروع، وفي القضاء بالشروع، أي: تعيين الصوم في رمضان تعيين قبل الشروع بتعيين الله وفي القضاء إنما يتعين بالشروع بتعيين العبد^(١).

(وكقوله: مسح الرأس ركن، فيسن تثليثه كغسل الوجه، فنقول: ركن فلا يسن تثليثه بعد إكماله بزيادة على الفرض في محله وهو الاستيعاب كغسل الوجه، وإن دل على حكم آخر يلزم منه ذلك النقيض يسمى عكساً^(٢)، كقوله في صلاة النفل: عبادة لا تمضي في فاسدها، فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فنقول: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه النذر والشروع كالوضوء)، اعلم أن كل عبادة تجب بالشروع

ثانيهما: هو مأخوذ من قلب الشيء ظهر البطن، فقلب الجراب، أي: جعل ظهره بطناً وبطنه طهراً، ويقوم به ضرب من الاعتراض أيضاً. وكلا المعنيين يرجع إلى معنى واحد وهو: تغيير هيئة الشيء عما كان عليه مع بقاء ذاته وقد اختلف العلماء في القلب عامة على مذهبين:

المذهب الأول: أن القلب مقبول وهو قادح في العلية وهو مذهب أكثر الأصوليين. المذهب الثاني: أن القلب غير مقبول وهو لا يقدر في العلية وهو مذهب بعض الأصوليين. راجع: كشف الاسرار للبخاري ٥٢/٤، قواطع الأدلة ٢٢٢/٢، إرشاد الفحول ص ٣٣٨

(١) أي: إن تعيين الصوم في رمضان تعيين من قبل الشرع، وتعيين الصوم في القضاء تعيين من قبل العبد.

(٢) العكس في اللغة: مأخوذ من عكست الشيء: ورددته إلى ورائه على طريقه الأول، وقيل: رد أول الشيء إلى آخره و آخره إلى أوله. وفي الاصطلاح: هو إنتفاء الحكم لإنتفاء علته، وقيل: هو تعليق نقيض الحكم المذكور لنقيض العلة المذكورة وردة إلى أصل آخر. كشف الاسرار للبخاري ٥٩/٤. وقد اختلف العلماء في قبوله فذهب أكثر العلماء إلى قبوله، وذهب آخرون إلى عدم قبوله. التبيين للإتقان ٩٧/٢. شرح المنار وحواشيه ص ٨٦١.

لا بد أن يجب المضي فيها إذا فسدت كما في الحج^(١)، فيلزم أن كل عبادة إذا فسدت لا يجب المضي فيها لا تجب بالشروع، فنقول: لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر، كما في الوضوء فإنه لا يمضي في فاسده فلا يجب بالشروع والنذر، فيلزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم^(٢).

(والأول أقوى من هذا)، أي: القلب أقوى من العكس؛ (لأنه جاء بحكم آخر وبحكم مجمل وهو الاستواء)، أي: المعارض جاء في العكس بحكم آخر، وفي القلب جاء بنقيض حكم يدعيه المعلن، فالقلب أقوى؛ لأنه في العكس اشتغل بما ليس هو بصدده، وهو إثبات الحكم الآخر، وفي القلب لم يشتغل بذلك، وأيضا جاء بحكم مجمل وهو الاستواء^(٣)؛ إذ الاستواء يكون بطريقتين والمعارض لم يبين أن المراد أيهما،

(١) أساس اختلاف العلماء في هذا المثال الذي أورده المصنف -رَحْمَةُ اللَّهِ- هو اختلافهم في النفل هل يلزم بالشروع فيه أم لا؟ قالحنفية والمالكية يقولون: يلزم النفل بالشروع فيه، فلو صلى تطوعا أو صام تطوعا فأفطر أو قسدت صلاته لزمه القضاء، وذهب الجمهور من العلماء إلى القول بعدم لزوم النفل، فلو أفسد صلاته أو أفطر من غير عذر لا يلزمه القضاء. فواتح الرحموت ١١٤/١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٣٨.

(٢) هذا من قبيل المعارضة التي فيها معنى المناقضة؛ لتضمنها إبطال عليّة الوصف، لكن لا دليل على أن عدم وجوب المضل في الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر. التلويح ٣ / ٢٠.

(٣) حيث إن القلب أقوى من العكس بوجوه:

الأول: أن المعارض بالعكس جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلن، وهو اشتغال بما لا يعنيه، بخلاف المعارض بالقلب، فإنه لم يجيء إلا بنقيض حكم المعلن.
الثاني: أن العاكس جاء بحكم مجمل، وهو الاستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم، والقالب جاء بحكم مفسر هو نفي دعوى المعلن.

الثالث: أن من شروط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، ولم يراع هذا في العكس إلا من جهة الصورة واللفظ؛ لأن الاستواء في الأصل - أعني الوضوء - إنما هو بطريق شمول العدم، أعني عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع، وفي الفرع - أعني صلاة

وإثبات الحكم المبين أقوى من إثبات الحكم المجمل، وأيضا الاستواء الذي في الفرع غير الاستواء الذي هو في الأصل وهذا هو قوله^(١).

(ولأنه مختلف في الصورتين، ففي الضوء بطريق شمول عدم، وفي الفرع بطريق شمول الوجود، وإما بدليل آخر) عطف على قوله: إما بدليل المعلل

(وهو معارضة خالصة^(٢))، وهو إما أن يثبت نقيض حكم المعلل بعينه، أو بتغيير، أو حكما يلزم منه ذلك النقيض^(٣)، كقوله: المسح ركن في الضوء فيسن ثلثيته كالغسل، فنقول: مسح فلا يسن ثلثيته كمسح الخف، وهذا)، أي: الوجه الأول من الوجوه الثلاثة من المعارضة (أقوى الوجوه)^(٤)، فقوله: المسح ركن نظير الوجه الأول من المعارضة.

(وكقولنا في الصغيرة التي لا أب لها: صغيرة فتتكح كالتى لها أب^(٥))، فيقال:

النفل - إنما هو بطريق شمول الوجود، أعني الوجوب بالنذر والشروع جميعا، فلا مماثلة. التلقيح شرح التنقيح ص ٣٨٩.

(١) أي في اعتباره القلب أقوى من العكس.

(٢) أي: خالصة عن معنى المناقضة، فلا بد فيها من أصل آخر وعلة أخرى، فإن كان الأصل والعلة واحدا كان مما فيه مناقضة، وهي نوعان: معارضة في علة الأصل، ومعارضة في حكم الفرع. التقرير والتحبير ٢٨١/٣.

(٣) اعلم أن المعارضة في حكم الفرع على نوعين:

إحدهما: بدليل المعلل، ولو بزيادة، وقد تقدم ذكره قلبا وعكسا.

وثانيهما: بدليل آخر، وهو على خمسة أوجه على ما ذكره في المغني وغيره، ثلاثة منها ذكرها المصنف رَحِمَهُ اللهُ، ورابعهما في المعارضة في المقدمة، أعني ما جعل فيه العلة معلولا، والمعلول علة، وخامسها: هو المعنى الأول من العكس على ما ذكرناه آنفا، والمصنف رَحِمَهُ اللهُ ترك الخامس رأسا؛ لعدم كونه قادحا لتعليل المعلل، وذكر الرابع في المارضة في المقدمة؛ لكونه أنسب بها على ما سيظهر لنا. حاشية الأزميري ٣٥٩/٢.

(٤) لدلالته صريحا على ما هو المقصود بالمعارضة، وهو إثبات نقيض حكم المعلل بعينه.

(٥) هذا مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغيير ما في إثبات ولاية

صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال^(١)، فلم ينف مطلق الولاية بل ولاية بعينها، لكن إذا انتفت هي ينتفي سائرهما بالإجماع)، أي: لعدم القائل بالفصل فإن كل من ينفي الإجماع بولاية الإخوة ينفي الإجماع بولاية العمومة^(٢) ونحوها، فهذا نظير الوجه الثاني من المعارضة^(٣) (وكالتي) نظير الوجه الثالث (نعي إليها زوجها، فنكحت، وولدت، ثم جاء الأول، فهو أحق بالولد عندنا؛ لأنه صاحب فراش صحيح^(٤))، فيقال: الثاني صاحب فراش فاسد فيستحق النسب، كمن تزوج بغير شهود فولدت فالمعارض وإن أثبت حكماً آخر) وهو ثبوت النسب من الزوج الثاني، لكن يلزم من ثبوته للثاني نفيه من الأول، فإذا ثبت المعارضة فالسبيل الترجيح بأن الأول صاحب فراش صحيح وهو أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضراً.

وأما الثانية^(٥) فمنها ما فيه معنى المناقضة، وهو أن تجعل العلة معلولاً والمعلول علة، وهي قلب أيضاً^(٦) وإنما يرد هذا إذا (كانت العلة حكماً لا وصفاً)؛ لأنه إذا كان

تزوج الصغيرة التي لا أب لها ولا جد لغيرهما من الأولياء. التلخيص شرح التنقيح ص ٣٩٠.

(١) فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة؛ لقصور الشفقة، فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر.

(٢) المعلن أثبت مطلق الولاية، والمعارض لم ينفها، بل نفى ولاية الأخ، فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلن من جهة أن الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه، وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة وجه صحة. فواتح الرحموت ٢/٣٥٥.

(٣) هذا النوع ليس من المعارضة الخالصة كما ذكره الشيخ البخاري في كشفه ٦١/٤.

(٤) لأن صحة الفراش توجب حقيقة النسب، والفاصد شبهته، وحقيقة الشيء أولى بالاعتبار من شبهته.

(٥) أي: المعارضة الثانية التي هي أحد نوعي المعارضة في علة الحكم، وتسمى معارضة في المقدمة. مرآة الأصول ٣/٣٦٠.

(٦) لأن العلة أصل وهو أعلى، والمعلول فرع وهو أسفل، فتبديلها بمنزلة جعل الكوز

وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علة (نحو: الكفار جنس يجلد بكرهم مائة، فيرجم ثيبهم كالمسلمين)؛ لأن جلد المائة غاية حد البكر والرجم غاية حد الثيب، فإذا وجب في البكر غايته وجب في الثيب غايته أيضا؛ فإن النعمة كلها كانت أكل فالجناية عليها تكون أخفش فجزاؤها يكون أغلظ، فإذا وجب في البكر المائة يجب في الثيب أكثر من ذلك وليس هذا إلا الرجم، فإن الشرع ما أوجب فوق جلد المائة إلا الرجم.

(والقراءة تكررت فرضا في الأوليين، فكانت فرضا في الآخرين^(١) كالركوع والسجود، فنقول: المسلمون إنما يجلد بكرهم مائة؛ لأنه يرجم ثيبهم) يعني لو جعل المعلل جلد البكر علة لرجم الثيب، فنقول: لا نسلم هذا بل رجم الثيب علة لجلد البكر، وإنما تكرر الركوع والسجود فرضا في الأوليين؛ لأنه يتكرر فرضا في الآخرين.

والمخلص^(٢) عن هذا، أي: التعليل بوجه لا يرد عليه هذا القلب (أن لا يذكر على سبيل التعليل، بل يستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر إذا ثبت المساواة بينهما نحو: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع إذا صح كالحج)، فتجب الصلاة والصوم بالشروع تطوعا وفيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فقالوا الحج إنما يلزم بالنذر؛ لأنه يلزم بالشروع، فنقول: الغرض الاستدلال من لزوم المنذور على لزوم ما شرع؛ لثبوت التساوي بينهما، بل الشروع أولى؛ لأنه لما وجب رعاية ما هو سبب القرية وهو النذر، (فلأن يجب رعاية ما هو القرية أولى، ونحو: الثيب الصغيرة يولى عليها في مالها، فكذا في نفسها كالبكر الصغيرة) فيثبت إجبار الثيب الصغيرة على النكاح وفيه منكوسا.

(١) المراد بالأوليين مقدمة الصلاة وهما الشفع الأول، وبالأخريين الشفع الثاني.

(٢) لا يريد بالمخلص الجواب عن هذا القلب ودفعه، بل الاحتراز عن وروده. شرح المنار وحواشيه ص ٨٥٦.

خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -

(فقالوا: إنما يولى على البكر في مالها؛ لأنه يولى في نفسها، فنقول: الولاية شرعت للحاجة، والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء)، أي: لا نقول: إن الولاية^(١) في المال علة للولاية في النفس، بل نقول: كلتاها شرعتا للحاجة فتكونان متساويين، فإذا ثبتت إحداها ثبتت الأخرى؛ لأن حكم المتساويين واحد

(وهذه المساواة غير ثابتة في المسألتين الأوليين على ما ذكروا) وهما مسألة رجم الكفار والقراءة في الشفع الأخير فأراد أن يبين أنه يمكن لنا في مسألة الشروع في النفل، وفي الثيب الصغيرة المخلص عن القلب ولو يمكن للشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - هذا في مسألة الرجم والقراءة، أما في مسألة الرجم فلأن الرجم والجلد ليسا بسواء في أنفسهما؛ لأن أحدهما قتل والآخر ضرب ولا في شروطهما حيث يشترط لأحدهما ما لا يشترط للآخر فلا يمكن الاستدلال بوجود أحدهما على وجود الآخر، وأما في مسألة القراءة فلأن الشفع الأول والثاني ليسا بسواء في القراءة؛ لأن قراءة السورة ساقطة في الشفع الثاني وأيضاً الجهر ساقط فيه فقوله على ما ذكروا إشارة إلى هذا.

ومنها خالصة^(٢) فإن أقام الدليل على نفي عليه ما أثبتته المعلن فقبولة^(٣) وإن أقام

(١) الولاية لغة: الولاية بكسر الواو معناها السلطان، وبفتح الواو وكسرها معناها النصرة.

وفي اصطلاح فقهاء المسلمين، بانها: (تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى)

(٢) أي: ليس فيها معنى المناقضة، وهذا هو النوع الثاني من أنواع المعارضة الخالصة، وهي المعارضة في علة الأصل.

(٣) شرع المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - في بيان أقسام المعارضة في علة الأصل؛ حيث سيذكر لها أقساماً أربعة أولهما صحيحة، وهي التي أقام المعارض الدليل على نفي عليه ما أثبتته المعلن، والثلاثة الأخرى باطلة.

على علية شيء آخر فإن كانت قاصرة لا يقبل عندنا^(١) وكذا إن كانت متعدية إلى مجمع عليه^(٢).

كما يعارضنا مالك بأن العلة الطعم والادخار، وهومتعد إلى الأرز وغيره، فلا فائدة له إلا نفي الحكم في الجص؛ لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك؛ لأن الحكم قد ثبت بعلة شتى. وإن تعدى إلى مختلف فيه^(٣) يقبل عند أهل النظر؛ للإجماع على أن العلة أحدهما فقط، فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، لا عند الفقهاء؛ لأنه ليس لصحة أحدهما تأثير في فساد الآخر.

(١) هذا أول الثلاثة من المعارضة الخالصة المردودة في علة الأصل؛ وهو أن يأتي المعارض بعلة قاصرة؛ لأن التعليل لا يكون إلا للتعدية.

(٢) هذا ثاني الثلاثة من المعارضة الخالصة المردودة في علة الأصل، كما لو قال المعلن: علة الربا في الحنطة هي الكيل والجنس، فعارض السائل بأن المعنى في الأصل ليس ما ذكرت، وإنما هو الاقتيات والادخار، وقد فقد في الفرع، فهذا معنى يتعدى إلى مجمع عليه، وهو الأرز.

(٣) هذا ثالث الثلاثة من المعارضة الخالصة المردودة في علة الأصل، ومثاله: ما إذا علل المجيب في حرمة بيع الجص بجنسه متفاضلا، بأنه مكيل قوبل بجنسه، فيحرم بيعه به متفاضلا كالحنطة والشعير، فيعارضه السائل بأن يقول: ليس المعنى في الأصل ما ذكرت ولكنه الطعم ولم يوجد في الفرع.

(فصل في دفع العلل الطردية)^(١)

لما عرفت أن العلة نوعان: إما علة مؤثرة، وهي المعتبرة عندنا، وإما علة تثبت عليها بالدوران دون التأثير، وهي المعتبرة عند البعض، وليست بمعتبرة عندنا، وتسمى علة طردية، ففي هذا الفصل تذكر الاعتراضات الواردة على القياس بالعلة الطردية.

(وهو أربعة: الأول^(٢): القول بموجب العلة^(٣)، وهو: التزام ما يلزمه المعلن مع بقاء الخلاف، وهو يلجئ المعلن إلى العلة المؤثرة)، أي: يجعل المعلن مضطرا إلى

(١) الاحتجاج بالطرد وإن كان فاسدا - كما يقول الشيخ عبد العزيز البخاري رَحْمَةُ اللَّهِ - إلا أنه لما عم بين الجدليين، ومال إليه عامة أهل النظر، ذكر العلل الطردية في التقسيم؛ لبيان الاعتراضات الواردة عليها. كشف الأسرار ٤/٣٤.

(٢) أي: الاعتراض الأول من الاعتراضات الواردة على العلل الطردية.

(٣) الموجب بفتح الجيم، وذكر العلامة صدر الشريعة تعريف القول بالموجب، وله ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن يلزم المعلن بتعليقه ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه مع أنه لا يكون محل النزاع ولا ملازمه، إما بصريح عبارة المعلن، كما إذا قال: القتل بالمثل قتل بما يقتل غالبا؛ فلا ينافي القصاص، كالقتل بالحرق، فيجيب: بأن النزاع ليس في عدم المنافاة، بل في إيجاب القصاص، وإما بحمل المعارض عبارته على ما ليس بمراده، كما في مسألتي تثليث المسح، وتعيين النية، اللتين ذكرهما العلامة صدر الشريعة رَحْمَةُ اللَّهِ.

الوجه الثاني: أن يلزم المعلن بتعليقه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم، وهذا لم يمثل له المصنف - رَحْمَةُ اللَّهِ - كما فعل في الأول والثالث (على ما ذكره الفري رَحْمَةُ اللَّهِ) ومثاله: كما إذا قال المعلن في السرفة: أخذ مال الغير بلا اعتقاد إباحة وتأويل، فيوجب الضمان كالغصب، فيقال: نعم إلا أن استيفاء الحد بمنزلة الإبراء في إسقاط الضمان، وأكثر القول بالموجب يتحقق في هذا القسم، كما ذكره البخاري في كشفه.

الوجه الثالث: أن يسكت المعلن عن بعض المقدمات لشهرته، فالسائل يسلم المقدمة المذكورة، ويبقى النزاع في المطلوب؛ للنزاع في المقدمة المطوية، وربما يحمل المقدمة المطوية على ما ينتج مع المقدمة المذكورة نقيض حكم المعلن، فيصير قلبا، كما في مسألة غسل المرفق التي ذكرها المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ. كشف الأسرار للبخاري ١٠٣/٤، فواتح الرحموت ٣٥٦/٢.

القول بمعنى مؤثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف^(١)، (كقوله: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، فنقول: يسن عندنا - أيضا- لكن الفرض البعض؛ لقوله تعالى ﴿برءوسكم﴾^(٢)، وهو إما ربع أو أقل، فلاستيعاب تثليث وزيادة، وإن غير وقال: يسن تكراره نمنع ذلك في الأصل، بل المسنون في الركن التكميل، كما في أركان الصلاة بالإطالة، لكن الغسل لما استوعب المحل لا يمكن التكميل إلا بالتكرار، وهنا المحل متسع)، أي: في مسح الرأس المحل - وهو الرأس - متسع يمكن الإكمال بدون التكرار (على أن التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع، فالاعتراض على التقدير الأول قول بموجب العلة وعلى تقدير التغيير ممانعة)، فالحاصل أن نقول: إن أردتم بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض فنحن قائلون به؛ لأن الاستيعاب تثليث وزيادة، وإن أردتم بالتثليث التكرار ثلاثة مرات نمنع هذا في الأصل، أي: لا نسلم أن الركنية توجب هذا، بل الركنية توجب الإكمال كما في أركان الصلاة^(٣)، فالاعتراض على تقدير أن يراد بالتثليث جعله ثلاثة أمثال الفرض يكون قولاً بموجب العلة، وعلى تقدير التغيير- وهو أن يراد بالتثليث التكرار- فالاعتراض ممانعة.

(وكقوله: صوم رمضان صوم فرض، فلا يتأدى إلا بتعيين النية، فنسلم موجهه لكن الإطلاق تعيين، وكقوله: المرفق لا يدخل في الغسل؛ لأن الغاية لا تدخل

(١) حيث إن حقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع، وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالى: (ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) سورة المنافقون من الآية ٨، أي: صحيح ما يقولون من أن الأعز يخرج الأذل، والنزاع باق؛ فإن العزة لله ولرسوله، فالله ورسوله يخرجانكم. رفع الحاجب ٤/٤٧٢.

(٢) من الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٣) كالقيام، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعود الأخير.

تحت المغيا. قلنا: نعم، لكنها غاية للإسقاط فلا تدخل تحته^(١).

(الثاني^(٢)): الممانعة^(٣) وهي إما في الوصف)، أي: تمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل عليته في الفرع^(٤)، (كقوله في مسألة الأكل والشرب: عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل والشرب كحد الزنا، فلا نسلم تعلقها بالجماع، بل هي متعلقة بالفطر^(٥)، وكقوله في بيع التفاحاة بالتفاحتين: إنه يبيع مطعوم بمطعوم مجازفة^(٦) فيحرم كالصبرة بالصبرة^(٧)، فنقول: إن أراد المجازفة بالوصف أو بالذات بحسب الأجزاء فهي

(١) حاصله: أن المرفق غاية للغسل، والغاية لا تدخل تحت المغيا، فالمرفق لا يدخل في الغسل؛ لأن الأصل أن الغاية قد تذكر لمد الحكم إليها، وقد تذكر لقصر الحكم عما وراءها، وإنما يتبين ذلك بالنظر إلى صدر الكلام، إن كان صدر الكلام لا يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر على ذلك الصدر، فذكر الغاية لإثبات الحكم ومداه إليها - فيجعل غاية الإثبات، ومتى كان صدر الكلام يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر عليه يعلم أن ذكر الغاية لقصر الحكم، فيجعل الغاية للإسقاط. حاشية الوجيزة ص ٤٨٩.

(٢) أي: الاعتراض الثاني من الاعتراضات الواردة على العلل الطردية.

(٣) وهي: منع ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع، أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو الفرع، أو منع صلاحية الوصف للحكم، أو منع نسبة الحكم إلى الوصف.

(٤) هذا هو الوجه الأول من أوجه الممانعة، وهو منع ثبوت الوصف في الأصل أو الفرع، وقد اقتصر المصنف على ذكر النوع الثاني الذي يتعلق بالفرع.

(٥) هذا مثال لمنع ثبوت الوصف في الفرع، وحاصله: أن كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع، فلا تجب بالأكل، كحد الزنا، فيقال: لا نسلم أنها عقوبة متعلقة بالجماع، بل بنفس الإفطار على وجه يكون جنائية متكاملة، فالأصل: حد الزنا، والفرع: كفارة الصوم، والحكم: عدم الوجوب بالأكل، والوصف: العقوبة المتعلقة بالجماع، وقد منع السائل صدقه على كفارة الصوم. حاشية الوجيزة النافعة ص ٤٨٩.

(٦) وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد، وإنما بالحزر والتخمين بعد المشاهدة أو الرؤية له. والجذف في الأصل: الأخذ بكثرة، مأخوذ من قولهم: جذف له في الكيل: إذا أكثر، ومرجعه إلى المساهلة. وعرف الشوكاني هذا البيع بقوله: هو ما لم يعلم قدره على التفصيل. الفقه الإسلامي وأدلته ٣٣٣/٥.

(٧) هذا مثال آخر لمنع ثبوت الوصف في الفرع، وحاصله: أن يقال: بيع التفاحاة بالتفاحتين

جائزة؛ لجواز الجيد بالردىء) هذا دليل على جواز المجازفة بالوصف، (وللجواز عند تفاوت الأجزاء) هذا دليل على جواز المجازفة بالذات بحسب الأجزاء (وإن أرادها)، أي: المجازفة (بحسب المعيار فتختص بما يدخل فيه)، أي: في المعيار.

(وإما في الحكم)^(١) عطف على قوله: وهي إما في الوصف (كما في هذه المسألة إن ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم إمكانها في الفرع وإن ادعيتها غير متناهية لا نسلم في الصبرة) فقوله: كما في هذه المسألة إشارة إلى مسألة بيع التفاحة بالتفاحتين.

فالممانعة في الحكم أن يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع، وقوله: لا نسلم إمكانها في الفرع إشارة إلى هذا، أو يمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلن بالوصف المذكور في الأصل، وقوله: لا نسلم في الصبرة إشارة إلى هذا (وكقوله: صوم فرض فلا يصح إلا بتعيين النية كالقضاء، فنقول: أبعد التعيين؟ فلا نسلم في الأصل، أو قبله؟ فلا نسلم في الفرع)، أي: إن ادعيت أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا، فلا نسلم هذا في القضاء، وإن ادعيت أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية قبل صيرورته متعينا، فلا نسلم هذا في المتنازع فيه؛ لأن تعيين النية قبل صيرورته متعينا ممتنع في المتنازع فيه؛ لأن الصوم متعين في المتنازع بتعيين الشارع فلا تكون صحة الصوم في المتنازع موقوفة على تعيين النية قبل صيرورته متعينا؛

بيع مطعوم بمطعوم مجازفة، فيحرم كبيع السبرة بالصبرة مجازفة، فيقال: إن أردتم المجازفة مطلقا، أو في الصفة، أو في الذات بحسب الأجزاء، فلا نسلم تعلق الحرمة بها؛ فإن بيع الجيد بالردىء جائز، وكذا بيع القفيز بالقفيز مع كون عدد حبات أحدهما أكثر، وأن المجازفة بحسب المعيار، فلا نسلم ثبوتها في الفرع، أعني بيع التفاحة بالتفاحتين؛ لأنها لا تدخل تحت الكيل والمعيار، فمنع الوصف في الفرع في المثال الأول متعين، وفي الثاني مبني على أحد التقادير. حاشية الوجيزة النافعة ص: ٤٩٠.

(١) هذا هو الوجه الثاني من أوجه الممانعة، وهو منع ثبوت الحكم في الأصل أو في الفرع.

لأنه حينئذ تكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل.

(وإما في صلاح الوصف للحكم^(١))، فإن الطرد باطل عندنا كما مر، وإما في نسبة الحكم إلى الوصف^(٢)، كقوله في الأخ: لا يعتق على أخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم أن العلة في الأصل هذا)، أي: لا نسلم أن علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية؛ فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق^(٣)؛ لجواز أن توجد علة أخرى للعتق، بل إنما لم يعتق ابن العم؛ لعدم القرابة المحرمة.

(وكقوله: لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنه ليس بمال، كالحد، فلا نسلم أن العلة في الحد عدم المالية^(٤))، وكذا في كل موضع يستدل بعدم على العدم) فإنه يمكن أن يقول: عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم؛ فإن الحكم يمكن أن يثبت بعلة أخرى.

(الثالث^(٥): فساد الوضع، وقد مر تفسيره، وهو فوق المناقضة؛ إذ يمكن الاحتراز عنها بتغيير الكلام، أما هو فيبطل العلة أصلاً) فإن المعلل إذا تمسك بالعلة الطردية، ويرد عليها مناقضة، فربما يغير الكلام، ويجعل علة مؤثرة، فحينئذ تندفع المناقضة، كما سيأتي في المناقضة في قوله: "الوضوء والتيمم طهارتان"^(٦)، أما فساد

(١) هذا هو الوجه الثالث من أوجه الممانعة، وهو منع صلاحية الوصف للحكم.

(٢) هذا هو الوجه الرابع من أوجه الممانعة، وهو منع نسبة الحكم إلى الوصف.

(٣) لأن العدم لا يجوز أن يكون موجبا حكما.

(٤) لأن كونه ليس بمال لا يصلح علة لامتناع ثبوته بشهادة النساء مع الرجال، بل لأن في هذه الشهادة شبهة زائدة، والحدود تدرأ بالشبهات، فكيف تثبت بما فيه شبهة؟

(٥) أي: الاعتراض الثالث من الاعتراضات الواردة على العلل الطردية.

(٦) كما يقال: الوضوء طهارة كالتيتم، فيشترط فيه النية، فينقض لتطهير الخبث، فيجواب:

بأن المراد أنهما تطهيران حكمان، فلا يرد النقص بتطهير الخبث. التلويح ٢٧/٣، الوجيزة

الوضع فإنه يبطل العلة بكليتها؛ إذ لا يندفع بتغيير الكلام، (كتعليله لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين)، أي: أحد الزوجين الذميين إذا أسلم قبل الدخول، فعند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - بانت في الحال، وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقرأء، فقد جعل الإسلام علة لإيجاب الفرقة^(١)، وعندنا يعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم فهي له، وإن أبى يفرق بينهما في الحال سواء كان بعد الدخول أو قبله (ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحدهما)، أي: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقرأء عند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فيجعل الردة^(٢) علة لبقاء النكاح، بمعنى أنه لا يجعلها قاطعة للنكاح، وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده، ثم في المتن يقيم الدليل على أن تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله: (فإن الإسلام لا يصلح قاطعا للنعمة، والردة لا تصلح عفوا^(٣))، وكقوله: إذا حج بإطلاق النية يقع عن الفرض، فكذا بنية النفل^(٤)، فإن بعض العلماء حملوا المطلق

(١) من غير توقف على قضاء القاضي.

(٢) الردة في اللغة: فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره، قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين [المائدة: ١٢١]. وأما الردة في الشرع فهي: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر.

(٣) يعني: لو أبقينا النكاح مع الردة التي هي منافية له لزم أن يجعل الردة عفوا، أي: في حكم المعلوم؛ ليمكن الحكم ببقاء النكاح، فكان التعليل لإبقاء النكاح إلى انقضاء العدة بعد تحقق الارتداد فاسدا في وضعه؛ لأنه تعليل الشيء مع ما ينافيه. الوجيزة النافعة ص٤٩٢.

(٤) اختلف الفقهاء فيمن أحرم بالحج، ونوى النفل بإحرامه، وعليه حجة الإسلام: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن حجه ينقصد نفلا، والفرض باق عليه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن إحرامه ينصرف إلى حجة الإسلام، وإن نوى به النفل. ينظر: فتح القدير مع الهداية ٤٤/٢، الشرح الكبير للشيخ الدردير ٥/٢، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤٦٢/١، كشف القناع ٣٨٢/٢.

على المقيد، فأما هذا فحمل المقيد على المطلق وهو باطل^(١)، وكقوله: المطعوم شيء ذو خطر فيشترط لملكه شرط زائد) وهو التقابض^(٢) (كالنكاح) فإنه يشترط له الشهود، (فيقال: ما كان الحاجة إليه أكثر جعله الله أوسع).

(الرابع^(٣)): المناقضة، وهي تلجئ أهل الطرد إلى المؤثرة، كقوله: الوضوء والتميم طهارتان، فيستويان في النية، فينتقض بتطهير الخبث، فيضطر إلى أن يقول: الوضوء تطهير حكيم كالتميم، بخلاف تطهير الخبث، فنقول: نعم)، أي: الوضوء تطهير حكيم^(٤) (بمعنى: النجاسة حكمية، أي: حكم الشرع بالنجاسة في حق الصلاة، فجعلها كالحقيقة، فيزيلها الماء كما يزيل الحقيقة، فهي غير معقولة) الضمير يرجع إلى النجاسة، وهذا الجواب هو الذي أحاله في فصل شرائط القياس إلى فصل المناقضة.

(لكن تطهيرها بالماء معقول، بخلاف التراب فلا يحتاج إلى النية في ذلك)،

أي: في التطهير، فتحصل الطهارة، سواء نوى أو لم ينو، (بل في صيرورته قربة)، أي: يحتاج إلى النية في صيرورة الوضوء قربة، (والصلاة تستغني عنها)، أي: عن

(١) أي: اعتبارهم نية النفل بمطلق النية فاسد في الوضع؛ لأنه من حمل المقيد على المطلق، وهو باطل.

(٢) لأن الطعام يتعلق به قوام النفس وبقاء الشخص، والنكاح يتعلق به بقاء النوع، فكثرة الاحتياج إلى الطعام بالإطلاق والتوسعة أنسب منه بالتحريم والتضييق؛ ولهذا كان طريق الوصول إلى الماء والهواء أيسر؛ لكون الحاجة إليهما أكثر، ففي ترتيب اشتراط التقابض في تملك المطعوم على كونه ذا خطر عظيم فساد الوضع؛ لأنه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتيسير. أصول السرخسي ٢/٢٧٧، كشف الأسرار للنسفي ٢/٣٣١.

(٣) أي: الاعتراض الرابع من الاعتراضات الواردة على العلل الطردية.

(٤) أي: تعبدية غير معقول المعنى؛ لأن معنى التطهير: إزالة النجاسة، وليس على أعضاء المتوضيء نجاسة تزال؛ ولهذا لا يتنجس الماء بملاقاته، وإنما عليها أمر مقدر اعتبره الشارع مانعا لصحة الصلاة عند عدم العذر، وحكم بأن الوضوء يرفعه، فيشترط النية تخقيقاً لأمر التعبد، بخلاف تطهير الخبث، فإنه حقيقي لما فيه من إزالة النجس بالماء، سواء نوى أو لم ينو، التلويح ٣/٣٠، الوجيزة النافعة ص ٤٩٣.

صيورة الوضوء قربة، كما في سائر شرائط الصلاة، بل تحتاج إلى كون الوضوء طهارة، وأما المسح فملحق بالغسل تيسيراً.

جواب عن سؤال مقدر، وهو: أنكم قلتم: إن الغسل تطهير معقول فلا يحتاج إلى النية، لكن مسح الرأس تطهير غير معقول؛ فيجب أن يحتاج إلى النية كالتيمم.

فأجاب: بأن مسح الرأس ملحق بالغسل، ووظيفة الرأس كانت هي الغسل، لكن لدفع الحرج اقتصر على المسح، فيكون خلفاً عن الغسل، فاعتبر فيه أحكام الأصل^(١).

(فإن قيل: غسل الأعضاء الأربعة غير معقول) هذا إشكال على قوله: لكن تطهيرها بالماء معقول.

(قلنا: لما اتصف البدن بها اقتصر على غسل الأطراف في المعتاد؛ دفعا للحرج وأقر على الأصل في غير المعتاد كالمني والحيض)، أي: لما اتصف البدن بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل جميع البدن؛ لأن الشرع لما حكم بسرية النجاسة - وليس بعض الأعضاء أولى بالسرية من البعض - وجب غسل جميع البدن، لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للحرج، وبقي غسل الأطراف الأربعة التي هي أمهات الأعضاء، فلا يكون غسل الأعضاء الأربعة غير معقول، فلا تجب النية.

واعلم أن الإمام نخر الإسلام - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ذكر أن تغير وصف محل الغسل من الطهارة إلى الخبث غير معقول، وقوله في التنقيح: فهي غير معقولة إشارة إلى هذا، ويرد عليه: أنه لما كان غير معقول لا يصح قياس غير السبيلين على السبيلين

(١) أي: أحكام الغسل؛ لأنه الأصل.

في هذا الحكم^(١)، وقد ذكر في الهداية^(٢): أن مؤثرية خروج النجاسة في زوال الطهارة أمر معقول^(٣)، فعلى تقدير الهداية لا يرد هذا الإشكال، لكن يرد عليه إشكال آخر وهو: أنه لما كان هذا الحكم معقولا ينبغي أن يقاس سائر المائعات^(٤) على الماء في تطهير الحدث، كما قد قيس في تطهير الخبث^(٥). وجوابه: أنه إنما قيس في الخبث باعتبار أنها قالة لا باعتبار أنها مطهرة، فلا يقاس في الحدث.

واعلم أنه يمكن التوفيق بين قول نخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - وصاحب الهداية أن مراد نخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - بكونه غير معقول: أن العقل لا يستقل بدركه^(٦)، ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا: أنه إذا علم أن هذا الوصف قد وجد وأن الشرع قد حكم بهذا الحكم يحكم العقل بأن هذا الحكم إنما هو لأجل هذا الوصف، وشرط صحة القياس كون الحكم معقولا بهذا المعنى وهو أعم من الأول

(١) أي: كون الخارج النجس منه سببا للحدث؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون الأصل مخالفا للقياس.

(٢) "الهداية" كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني من أكابر فقهاء الحنفية، توفي سنة ٥٩٣ هـ، والكتاب مطبوع متداول، تعج به المكتبات في شتى بقاع الأرض. ينظر: الفوائد البهية ص١٤١، معجم المؤلفين ٤٥/٧.

(٣) لأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، وهذا القدر في الأصل معقول، والاقتصار على الأعضاء الأربعة معقول، لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول. الهداية مع البناية ٢٠٤/١.

(٤) كالماء المعتصر من الشجر والثمر.

(٥) حاصل الإشكال: أن المرغيناني يوجب صحة قياس سائر المائعات على الماء في رفع الحدث، كما صح قياسها عليه في رفع الخبث؛ إذ لا مانع سوى عدم معقولية النص. الوجيزة النافعة ص٤٩٥.

(٦) حاصله: أن الشارع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروج النجس من السيلين، أدرك العقل أن هذا الحكم إنما هو لأجل هذا الوصف، وأنه ليس بتعبد محض لا يقف العقل على سببه، ولا منافاة بين عدم استقلال العقل بدرك شيء وبين إدراكه إياه بمعونة الشرع بعد وروده، كذا في (التلويح). المرجع السابق

فاندفع عن قول نخر الإسلام - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ما ذكرنا من الإشكال، وهو أنه يلزم أن لا يصح قياس غير السبيلين على السبيلين^(١) (وفي هذا الفصل فروع أخر طويتها مخافة التطويل).

(١) لأن من شروط القياس المساواة في العلة والحكم بين الأصل والفرع.

(١) فصل في الانتقال

أي: الانتقال من كلام إلى آخر، (وهو إنما يكون قبل أن يتم إثبات الحكم الأول، فلا يخلو إما أن ينتقل إلى علة أخرى لإثبات علته، أو لإثبات الحكم الأول، أو لإثبات حكم آخر يحتاج إليه الحكم الأول، أو ينتقل إلى حكم كذلك)، أي: حكم يحتاج إليه الحكم الأول، والانتقال منحصر في هذه الأربعة^(١)؛ لأنه إما في العلة فقط، وهو على قسمين: لإثبات علته وهو الأول، أو لإثبات حكمه وهو الثاني حتى لو لم يكن لشيء منهما كان كلاما حشوا، وإما في الحكم فقط وهو الرابع ولا بد أن يكون حكما يحتاج إليه الحكم الأول، وإلا لكان كلاما حشوا، وإما فيهما وهو الثالث، (فيثبت الحكم بالعلة الأولى، فالأول صحيح)^(٢)، كما إذا قال: الصبي المودع إذا استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك.

فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته، فهذا لا يسمى انتقالا حقيقة؛ لأن الانتقال أن يترك الكلام الأول بالكلية ويشتغل بآخر، كما في قصة الخليل - - وإنما أطلق الانتقال على هذا القسم؛ لأنه ترك هذا الكلام واشتغل بكلام آخر، وإن كان هو دليلا على الكلام الأول.

(١) إذا ثبت دفع الاعتراضات التي ترد على العلل بنوع من الدفع السابق ذكرها، كانت غاية ذلك وثمرته أن يلجئ المعلن إلى الانتقال. شرح المنار وحواشيه ص ٨٢.

(٢) الأول: الانتقال إلى علة أخرى لإثبات علة القياس، والثاني: الانتقال إلى علة لإثبات حكم القياس، والثالث: الانتقال إلى علة أخرى لإثبات حكم آخر يحتاج إليه حكم القياس، والرابع: الانتقال إلى حكم يحتاج إليه حكم القياس بأن يثبت بعلة القياس. التلخيص شرح التنقيح ص ٤٠٤.

(٣) أي: النوع الأول من الانتقال صحيح، وهو الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات الأولى، كالمثال المذكور.

(وكذا الثاني عند البعض^(١))، كقصة الخليل - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حيث قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾^(٢)، ولأن الغرض إثبات الحكم فلا يبالي بأي دليل كان، لا عند البعض^(٣)؛ لأنه لما لم يثبت الحكم بالعلة الأولى يعد انقطاعا في عرف النظار^(٤)، وأما قصة الخليل فإن الحجة الأولى (وهو قوله تعالى: ﴿رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾^(٥)) كانت ملزومة، واللعين عارضه بأمر باطل) وهو قوله تعالى: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾^(٦)، (فالخليل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لما خاف الاشتباه والتلبس على القوم انتقل إلى العلة التي لا يكون فيها اشتباه أصلا^(٧)).

(١) أي: النوع الثاني، وهو الانتقال إلى علة لإثبات حكم القياس صحيح عند البعض أيضا، وقد نسبته البخاري في كشفه (١٣٢/٤) إلى بعض أهل النظر، ومن أدلتهم ما ذكره المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - من محاجة الخليل إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نمرود بن كنعان، وكان يدعي الألوهية، كما ذكرت الآية.

(٢) من الآية رقم ٢٥٨ من سورة البقرة.

(٣) نسبته الرهاوي في حاشيته على شرح المنار (ص ٨٨٣) والأنصاري في الفواتح (٢/ ٣٣٦) إلى الجمهور.

(٤) يعني أن ذلك من مصطلحات أهل المناظرة، وآدابهم في البحث؛ كي لا يطول الكلام بالانتقال من دليل إلى دليل آخر، وإلا فالانتقال من علة إلى علة لإثبات حكم شرعي بمنزلة الانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى لإثبات حقوق الناس، وهو مقبول بالإجماع. التلويح ٣/ ٣٥.

(٥) من الآية رقم ٢٥٨ من سورة البقرة.

(٦) من الآية رقم ٢٥٨ من سورة البقرة.

(٧) جَوَابٌ عَنْ تَمَسُّكِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ وَتَقْرِيرِهِ أَنَّ كَلَامَنَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا بَانَ بَطْلَانُ دَلِيلِ الْمُعَلَّلِ وَانْتَقَلَ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ أَمَّا إِذَا صَحَّ دَلِيلُهُ وَكَانَ قَدْ حُجِّجَ الْمُعْتَرِضُ فَاسِدًا إِلَّا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى تَلْبِيسٍ رُبَّمَا يَشْتَبِهُ عَلَى بَعْضِ السَّامِعِينَ فَلَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ الْإِنْتِقَالِ كَمَا فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَإِنَّ مُعَارَضَةَ اللَّعِينِ كَانَتْ بَاطِلَةً؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْمَسْجُونِ وَتَرْكَ إِزَالَةِ حَيَاتِهِ لَيْسَ بِأَحْيَاءٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِعْطَاءُ الْحَيَاةِ وَجَعْلُ الْجَمَادِ حَيًّا إِلَّا أَنَّ الْخَلِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - انْتَقَلَ إِلَى دَلِيلٍ أَوْضَحَ وَحُجَّةٍ أَبْهَرَ لِيَكُونَ نُورًا عَلَى نُورٍ وَإِضَاءَةً غَبَّ إِضَاءَةً وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ انْتِقَالُهُ خُلُوءًا عَنْ تَأْكِيدٍ لِلأَوَّلِ وَتَوْضِيحٍ وَتَبْكِيتٍ لِلْخَصْمِ وَتَفْضِيحٍ كَأَنَّهُ

والثالث^(١): كقولنا: الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة^(٢)، فلا تمنع الصرف إلى الكفارة)، أي: إن أعتق المكاتب بنية الكفارة يجوز (كالباع بالخيار والإجارة)، أي: باع عبدا بشرط الخيار يجوز إعتاقه بنية الكفارة، وكذا إذا آجر عبدا ثم أعتقه بنية الكفارة

(فإن قيل: عندي لا يمنع هذا العقد، بل نقصان الرق)، أي: نقصان الرق يمنع الصرف إلى الكفارة عندي، (فنقول: الرق لم ينقص وثبت هذا)، أي: عدم نقصان الرق (بعلة أخرى) وهي قوله: الكتابة عقد يحتمل الفسخ فيجوز صرفه إلى الكفارة، كما نقول: الكتابة عقد معاوضة، فلا توجب نقصانا في الرق

(وإن أثبتناه بالعلة الأولى فهو نظير الرابع^(٣))، كما نقول: احتمال الفسخ دليل على أن الرق لم ينقص، وكلاهما صحيحان، والرابع أحق؛ لأن العلة التي أوردتها تكون تامة في قطع الشبهات بلا احتياج إلى شيء آخر، وإن انتقل إلى حكم لا حاجة إليه، أو إلى علة لإثبات حكم كذلك، فهو باطل^(٤).

قَالَ الْمُرَادُ بِالْإِحْيَاءِ إِعَادَةَ الرُّوحِ إِلَى الْبَدَنِ فَالشَّمْسُ بِمَنْزِلَةِ رُوحِ الْعَالَمِ لِإِضَاءَتِهِ بِهَا وَإِظْلَامِهِ بِغُرُوبِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى فَأَعِدْ رُوحَ الْعَالَمِ إِلَيْهِ بِأَنْ تَأْتِيَ الشَّمْسُ مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ. التلويح ١٢١/٢.

(١) أي: النوع الثالث من وجوه الانتقال، وهو: الانتقال إلى علة أخرى لإثبات حكم آخر يحتاج إليه حكم الفياس، وعابه ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحبير ٢٥٥/٣.

(٢) الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبين للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص.

(٣) أي: نظير الوجه الرابع من وجوه الانتقال، وهو: الانتقال إلى حكم يحتاج إليه حكم القياس، لأن يثبت بعلة القياس. التلويح ١٢٢/٢.

(٤) لأنه حشو في القياس خارج عن المقصود.

(فصل في الحجج الفاسدة)^(١)

الاستصحاب^(٢) حجة عند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كل شيء ثبت وجوده بدليل، ثم وقع الشك في بقاءه^(٣)، وعندنا حجة للدفع لا للإثبات^(٤).

له^(٥): أن بقاء الشرائع بالاستصحاب^(٦)، ولأنه إذا تيقن بالوضوء ثم شك في

(١) قال صاحب التلويح: "عَقَّبَ مباحث الأدلة الصحيحة بالأدلة الفاسدة التي يحتج بها البعض في إثبات الأحكام؛ ليتبين فسادها؛ فيظهر انحصار الأدلة الصحيحة في الأربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وهذا غير التمسكات الفاسدة؛ لأنها تمسك بالكتاب والسنة، لكن بطرق فاسدة غير صالحة للتمسك التلويح ٣/ ٣٦، المرأة ٢/ ٣٦٦.

(٢) الاستصحاب في اللغة: طلب الصحة، وهي الملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، ويقال: استصحب الكتاب، وغيره: حملته صحبتي. ومن هنا قيل: استصحب الحال: إذا تمسكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة، غير مفارقة. مختار الصحاح ص ٣٥٦، لسان العرب ٤/ ٢٤٠٠ مادة "صحب"

و الاستصحاب في الاصطلاح: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول. الوجيزة النافعة ص ٤٩٩.

(٣) هذا هو المذهب الأول، القائل: إن الاستصحاب حجة صالحة لإبقاء الأمر على ما كان عليه، سواء كان الثابت به نفيّاً أصلياً، أو حكماً شرعياً، أي: أنه حجة في النفي والإثبات. الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٤٧

(٤) هذا هو المذهب الثاني، القائل: إن الاستصحاب حجة في النفي الأصلي دون إثبات الحكم الشرعي، أي: إنه يصلح للابتداء والدفع، لا للإثبات. تقويم الأدلة ص ٣٢٤، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٣.

وهناك مذهب ثالث لكثير من الحنفية، وبعض أصحاب الشافعي، وأبي الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين إلى أنه: ليس بحجة أصلاً، لا لإثبات أمر لم يكن، ولا لبقاء ما كان على ما كان. ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/ ٣٢٥، أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٣/ ٣٧٧، وما بعدها، المستصفى للغزالي ١/ ٢١٧، وما بعدها، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، نهاية السؤل ومعه مناهج العقول ٣/ ١٧٧

(٥) أي: أدلة الإمام الشافعي ومن وافقه.

(٦) بدأ المصنف - رَحِمَهُ اللهُ - في ذكر أدلة الإمام الشافعي ومن وافقه، وهذا دليلهم الأول، و معناه: أن الاستصحاب لو لم يكن حجة لما وقع الجزم، بل الظن ببقاء الشرائع؛ لاحتمال

الحدث يحكم بالوضوء وفي العكس بالحدث، وإذا شهدوا أنه كان ملكاً للمدعي فإنه حجة عنده^(١).

ولنا^(٢): أن الدليل الموجب لا يدل على البقاء^(٣)، وهذا ظاهر ببقاء الشرائع بعد وفاته - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ليس بالاستصحاب، بل لأنه لا نسخ لشريعته وفي حياته فقد مر جوابه في النسخ^(٤)، والوضوء والبيع والنكاح، ونحوها يوجب حكماً ممتداً إلى زمان ظهور مناقض، فيكون البقاء للدليل، وكلامنا فيما لا دليل على البقاء، كحياة المفقود^(٥) فيرث عنده، لا عندنا؛ لأن الإرث من باب الإثبات - فلا يثبت به ولا

طريان الناسخ، واللازم باطل للقطع ببقاء شرع عيسى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلى زمن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبقاء شرعه أبداً.

(١) هذا دليلهم الثاني، ومعناه: وقوع الإجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع، مثل: بقاء الوضوء، والحدث، والملكية، والزوجية فيما إذا ثبت ذلك ووقع الشك في طريان الضد.

(٢) أي: أدلتنا على أن الاستصحاب حجة في النفي لا في الإثبات، وهي أجوبة عن ما استدل به الإمام الشافعي ومن وافقه.

(٣) هذا جواب الحنفية على الدليل الأول من أدلة الإمام الشافعي.

(٤) وهو: أن النص يدل على شرعية موجبة قطعاً إلى زمان نزول الناسخ، وعدم بيان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للناسخ دليل على عدم نزوله؛ إذ لو نزل لبينه قطعاً؛ لوجوب التبيين والتبليغ عليه. الوجيزة النافعة ص ٤٩٩.

(٥) اختلف الأئمة في المفقود - الذي لا تعلم حياته أو موته - هل يعتبر كالميت، فتوزع تركته على وارثيه، وإذا مات أحد ممن يرثهم هو لا يحتفظ له بنصيب، أو أنه يعتبر حياً؛ فلا توزع تركته، وإذا مات أحد ممن يرثهم هو احتفظ له بنصيبه؟

فذهب الإمامان مالك والشافعي - رحمهما الله - إلى: أنه يعتبر حياً في حق نفسه؛ لا يرثه أحد، وكذلك في حق غيره، فإذا مات من يرثه احتفظ له بنصيبه إلى أن يعلم حياته أو موته، أو يمضي من الزمان ما لا يعيش إلى مثله غالباً.

وذهب الإمام أبو حنيفة، وأصحابه - رحمهم الله - إلى: أنه يعتبر حياً في حق نفسه، فلا توزع تركته حتى يعلم حياته، أو موته، أو يمضي زمن التعمير، وأما في حق غيره، فيعتبر

يورث؛ لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به. والصلح على الإنكار لا يصح عنده^(١) فيجعل براءة الذمة - وهي الأصل - حجة على المدعي، فلا يصح الصلح كما بعد اليمين، وعندنا يصح؛ لما قلنا: إن الاستصحاب لا يصح حجة للإثبات، فلا يكون براءة الذمة حجة على المدعي فيصح الصلح، و (تجب البينة على الشفيع عندنا على ملك المشفوع به إذا أنكره المشتري)؛ لأن ملك الشفيع الدارالمشفوع بها ثابت بالاستصحاب، فلا يكون حجة على المشتري، فتجب البينة على الشفيع على ملك المشفوع به^(٢) لا عنده^(١)، (وإذا قال لعبده: إن لم تدخل الدار- اليوم - فأنت حر ولا

ميثاً؛ فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب، ولا يعتد به في توزيع التركة على ورثة المتوفى.

وذهب الإمام أحمد- رَحِمَهُ اللهُ- إلى: أنه يعتبر حياً في حق نفسه وحق غيره مدة أربع سنين من غيابه، فإذا مضت اعتبر ميتاً في حق نفسه وحق غيره؛ فتوزع تركته، ولا يرث من أحد مات ممن يرثهم.

ينظر: المبسوط ٥٤/٣٠، الهداية مع شرح فتح القدير ٤٤٦/٤، الدر المختار ٥٠٩/٥، الشرح الكبير للشيخ الدردير ٤٨٧/٤، بداية المجتهد ٤٣٢/٥، الأم ٤/٤، المنهاج مع مغني المحتاج ٢٧/٣، المغني ٢٠٥/٧.

(١) صور الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ- مسألة الصلح على الإنكار في كتابه الأم، فقال: "وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى في العبد، أو غيره، أو ادعى عليه جناية -عمداً أو خطأ - فصالحه مما ادعى من هذا كله، أو من بعضه على شيء قبضه منه، فإن كان الصلح - والمدعى عليه يقر- فالصلح جائز بما يجوز به البيع، كان الصلح نقداً أو نسيئة، وإذا كان المدعى عليه ينكر؛ فالصلح باطل، وهما على أصل حقهما، ويرجع المدعي على دعواه، والمعطي بما أعطى"، الأم ٣ / ١٩٦، فرأى الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ- أن الصلح على الإنكار باطل، بينما ذهب الأئمة أبوحنيفة، ومالك، وأحمد -رحمهم الله إلى أن الصلح على الإنكار جائز. ينظر: بدائع الصنائع ٥٦/٦، ملتنقى الأبحر ٣١٣/٢، الشرح الكبير للشيخ الدردير ٣١١/٣، مغني المحتاج ١٧٩/٢، المغني لابن قدامة ٩/٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٧٣.

(٢) إذا ادعى رجل على رجل شفعة في شقص -أي: النصيب أو الجزء من الشئ- اشتراه، فقال: ليس له ملك في شركتي؛ فعلى الشفيع إقامة البينة أنه شريك، وبه قال الأئمة:

يدري أنه دخل أم لا فالقول قول المولى عندنا^(٢) فإن العبد تمسك بالأصل، وهو أن الأصل عدم الدخول فلا يصلح حجة لاستحقاق العتق على المولى.

(ومنها)، أي: من الحجج الفاسدة (التعليل بالنفي)^(٣) كما ذكرنا في شهادة النساء^(٤)، أي: في الممانعة في دفع العلل الطردية، والأخ فإنه يمكن الوجود بعلّة أخرى إلا أن يثبت بالإجماع أن له علة واحدة فقط، كقول محمد^(٥) في ولد الغصب:

أبوحنيفة، ومحمد، والشافعي، وأحمد؛ لأن الملك لا يثبت بمجرد اليد، وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة، لم تثبت الشفعة، وقال القاضي أبو يوسف والإمام زفر: إذا كان في يده استحق به الشفعة لذلك؛ لأن الظاهر من اليد الملك، فالمقصود بقوله: "عندنا" رأي القاضي أبي يوسف والإمام زفر رحمهما الله. ينظر في ذلك: الهداية مع فتح القدير ٤٢٤/٧، ٤٢٥، المبسوط ١٦٢/١٤، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣٠٤/٢، المغني لابن قدامة ٥١٩/٥.

(١) لأن الظاهر عند الإمام الشافعي يصلح للدفع والإلزام جميعاً. الوجيزة النافعة ص ٥٠٠.
(٢) أي: جمهور الحنفية، خلافاً للإمام زفر؛ لتمسكه بما هو الأصل، وهو: عدم الدخول، والتمسك به لا يصلح حجة للإلزام على الغير، فلا يبطل به إنكار المولى عدم الدخول، فيجعل كأن العبد أقام البيئة على ذلك فيعتق، ويكون القول قوله. ينظر في ذلك: تقويم الأدلة ص ٣٢٢، أصول البزدوى مع كشف الأسرار للبخاري ٣٧٩/٣، المبسوط للسرخسي ٥/٥، ١٦٣/١٠، رد المحتار على الدر المختار ١٢٥/٣.

(٣) قال صاحب أنوار الحلك في تعريفه التعليل بالنفي: المفهوم من كلام القوم أنه عبارة عن: تعليل عدم الحكم بعدم علة وجدت له. فهذا لا يصح إلا أن تكون العلة متحدة. ويسمى التعليل بالعدم - أيضاً - والحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقاً، والشافعية يجوزون تعليل العدمي بالعدمي اتفاقاً وكذا الوجودي عند أكثرهم. أنوار الحلك مع شرح المنار لابن ملك ص ٧٩٤، فتح الغفار ٤٣/٣.

(٤) كما في قول الشافعي: لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال، كالحدود، وعند الحنفية عدم المالية لا يوجب الحكم بعدم الثبوت بشهادة النساء مع الرجال؛ لجواز أن يتحقق بعلّة أخرى. الوجيزة النافعة ٥٠٠.

(٥) هو الإمام: محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، من أصحاب الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - وتفقه أيضاً على أبي

إنه غير مضمون؛ لأنه لم يغضب الولد^(١).

ومنها^(٢): الاحتجاج بتعارض الأشباه^(٣)، كقول زفر^(٤): إن غسل المرافق ليس بفرض؛ لأن من الغايات ما يدخل وما لا يدخل، فلا يدخل بالشك، فإن هذا جهل محض^(٥)؛

يوسف، والتقى بالإمام الشافعي، وناظره، ولاه الرشيد القضاء بالرقعة ثم عزله، من آثاره: الجامع الصغير، والكبير، والمبسوط، وغيرهم، توفي -رَحِمَهُ اللهُ- بالري سنة ١٨٧هـ وقيل سنة ١٨٩هـ. الفوائد البهية ص ١٦٣.

(١) ذهب بعض الفقهاء إلى: أنه إذا غصب إنسان حيواناً حاملاً أو أمة، فالولد مضمون، وكذلك لو غصب حائلاً فحملت عنده، وولدت، ضمن ولدها، وبهذا قال: الإمامان الشافعي وأحمد، وقال الإمامان أبوحنيفة ومالك: لا يجب ضمان الولد في الصورتين؛ لأنه ليس بمغصوب، إذ الغصب فعل محذور، ولم يوجد، فإن الموجود ثبوت اليد عليه، وليس ذلك من فعله؛ لأنه انبنى على وجود الولد، ولا صنع له فيه. المبسوط للسرخسي ٥٣/١١، ٥٤، شرح فتح القدير مع الهداية ٣٨٨/٧، المغني لابن قدامة ٤١٩/٥.

(٢) أي: من الحجج الفاسدة.

(٣) قال الشيخ البخاري في كشفه: "الاستدلال بتعارض الأشباه، وهو: إبقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض الأصليين اللذين يمكن إلحاقه بكل واحد منهما، وهو فاسد؛ لأنه في الحقيقة احتجاج بلا دليل " أ.هـ. كشف الأسرار للبخاري ٣٨٣/٤.

(٤) هو: الإمام زفر بن الهزيل بن قيس العنبري، أبو الهذيل، من تميم، فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أصله من أصبهان. أقام بالبصرة، وولي قضاءها، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث، فغلب عليه الرأي، وهو: قِيَّاس الحنفية، وكان يقول: "نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي" توفي -رَحِمَهُ اللهُ- سنة ١٥٨هـ. الفوائد البهية ص ٧٥.

(٥) أي: من الغايات ما يدخل في المغيا، كقوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) (من الآية ١ سورة الإسراء) فإن المسجد الأقصى يدخل في الإسرائ، ومنها ما لا يدخل في المغيا، كقوله تعالى: (ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (من الآية ١٨٧ سورة البقرة) ولهذه الغاية المذكورة في المثال شبه بكل واحد من القسمين بدخول حرف الغاية عليها، فلشبهها بالقسم الأول يدخل في المغيا؛ ويجب الغسل، ولشبهها بالقسم الثاني لا يجب، وليس أحد الشبهين أولى من الآخر، ولم يكن الغسل واجباً، فلا يجب بالشك، وهذا عمل بغير دليل؛

لأنه لم يعلم أن هذه من أي القسمين^(١).

لأن الشك حادث؛ فلا يثبت بغير علة. كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٧٢.
 (١) أي: ما يدخل في المغييا، وما لا يدخل فيها.

(بَابُ^(١) الْمُعَارَضَةِ^(٢) وَالتَّرْجِيحِ^(٣))

(إِذَا وَرَدَ دَلِيلَانِ يَقْتَضِي أَحَدُهُمَا عَدَمَ مَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ^(٤)، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ^(٥)،)

(١) الباب من الكتاب: القسم منه يجمع مسائل من جنس واحد. لسان العرب ٢٢٣/١. عقب صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - مباحث الأدلة بباب المعارضة والترجيح؛ لأن الأدلة الظنية قد تتعارض فيما بينها، ولا يمكن إثبات الحكم بهما إلا بعد الترجيح؛ لذا ناسب مجيء التعارض والترجيح عقب مباحث الأدلة، ثم الناظر في الأدلة الشرعية قد يجد بعض النصوص يعارض بعضها بعضاً، فيما دل عليه في الظاهر، ولكن في حقيقة الأمر لا تعارض بينها، فالتعارض ظاهر فقط وليس في الواقع ونفس الأمر. يقول الشاطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، فالشريعة لا تعارض فيها البتة. ينظر: الموافقات ٢٩٤/٤.

(٢) المعارضة لغة: الممانعة، فتعارض الدليلين يعني ممانعتهما للآخر من الوصول إلى وجهته حين تقابلا. ويسمى التعارض لغة بالتعادل أيضاً؛ لأن الدليلين إذا تعادلا وتساويا، وكان أحدهما يدل على ثبوت أمر والآخر يدل على انتفائه تعارضا وتمانعا عند تقابلهما على شيء واحد في زمان واحد. مختار الصحاح ١٧٩ والمعارضة اصطلاحاً: تقابل أمرين على وجه يمنع كلا منهما مقتضى صاحبه.

(٣) الترجيح لغة: جعل الشيء راجحاً، بزيادة في جانب على جانب آخر، أي: فاضلاً زائداً. لسان العرب ٤٤٥/٢. والترجيح اصطلاحاً: بيان القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر.

(٤) ذكر المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - حقيقة التعارض، وركنه، وشرطه، أما حقيقته، فهي: التضاد والتدافع بين الدليلين في حق الحكم.

وأما ركنه، فهو: تقابل الحجتين على سبيل المدافعة؛ حيث إن كل دليل منهما يوجب خلاف ما يوجبه الآخر، كأن يثبت أحد الدليلين الحل، والآخر الحرمة.

وأما شروطه فقد بدأ في أهمها، وهذا الشرط الأول، وهو: اتحاد المحل، بأن يكون الدليلان المتعارضان واردين على محل واحد، كقولك: زيد قائم قاعد، واتحاد المحل احتراز من قول القائل: زيد قائم، ومحمد قاعد، فهذا لا تعارض فيه؛ لاختلاف المحل. ينظر: أصول السرخسي ١٢/٢، التلويح ٢٨٨/٢.

(٥) هذا هو الشرط الثاني، وهو: اتحاد الزمان، بأن يرد الدليلان المتعارضان في محل واحد في زمان واحد، كقولك: الخمر حلال حرام الآن، فهذا تعارض واضح، لكن لو قال: الخمر حلال حرام، فذا تعارض باعتبار المحل، وليس باعتبار الزمان؛ لأنه يحتمل أن

فَإِنْ تَسَاوَيَا قُوَّةً^(١)، أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِوصفٍ هُوَ تَابِعٌ فَبَيْنَهُمَا الْمُعَارَضَةُ، وَالْقُوَّةُ الْمَذْكُورَةُ رُجْحَانٌ، وَإِنْ كَانَ أَقْوَى بِمَا هُوَ غَيْرُ تَابِعٍ لَا يُسَمَّى رُجْحَانًا، فَلَا يُقَالُ: النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقِيَاسِ، مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «زَنْ وَأَرْحُ»^(٢) وَالْمُرَادُ الْفَضْلُ الْقَلِيلُ؛ لِثَلَا يَلْزَمَ الرَّبَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ عَفْوًا؛ لِأَنَّهُ لِقَلَّتِهِ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَابِلِ.

(وَالْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَتَرْكُ الْآخِرِ وَاجِبٌ فِي الصُّورَتَيْنِ)، أَيُّ: فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِوصفٍ هُوَ تَابِعٌ وَفِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِمَا هُوَ غَيْرُ تَابِعٍ^(٣) (وَإِذَا تَسَاوَيَا قُوَّةً) وَعَلِمَ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةً^(٤):

الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ أَقْوَى مِنَ الْآخَرِ بِمَا هُوَ غَيْرُ تَابِعٍ، كَالنَّصِّ مَعَ الْقِيَاسِ^(٥).

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى بِوصفٍ هُوَ تَابِعٌ، كَمَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَدْلٌ فَتَقِيهِ، مَعَ خَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَدْلٌ غَيْرُ فَتَقِيهِ^(٦).

يحمل الحل على حلها في صدر الإسلام، والحرمة بعد ثبوت تحريمها بالأدلة.

(١) هذا هو الشرط الثالث، وهو: تساوي الدليلين المتعارضين في القوة؛ لأن التعارض لا يقع بين قوي وضعيف، فلا يتصور وقوعه بين النص والقياس؛ لأن الأول أقوى.

(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٤٥٢/٢، كتاب: البيوع، باب: الرجحان في الوزن (حديث رقم ٣٣٣٦)، وابن ماجه في سننه ٤٧٤/٢، كتاب: البيوع، باب: الرجحان (حديث رقم ٢٢٢٠).

(٣) هنا إشارة إلى حكم القسمين الأولين، وسيوضح بيان الأقسام جميعها تباعاً.

(٤) أي: أقسام الأدلة التي يتصور وقوع التعارض بينها.

(٥) أي: أن النص أقوى من القياس، ولذا لا يتصور وقوع التعارض بين قوي وضعيف.

(٦) ومثاله: ما روي عن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَصْبَحُ جَنِبًا وَهُوَ صَائِمٌ)، فَهُوَ مُعَارِضٌ بِمَا رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَصْبَحَ جَنِبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ)، فَالتَّعَارُضُ وَاضِحٌ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ، فَتَرْجَحُ رَوَايَةُ عَائِشَةَ

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيَيْنِ قُوَّةً^(١)، فَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَتَرْكُ
الْآخِرِ وَاجِبٌ^(٢)، وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَيَأْتِي حُكْمُهُ هُنَا^(٣)، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: (فَإِنْ
تَسَاوَايَا قُوَّةً)، فَالْمُعَارَضَةُ تَخْتَصُّ بِالْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ^(٤)، أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَمْعَزِلُ
عَنْهَا^(٥) وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْأَقْوَى وَاجِبًا، لَكِنْ لَا يُسَمَّى هَذَا تَرْجِيحًا،
فَالْتَرْجِيحُ إِثْمًا يَكُونُ بَعْدَ الْمُعَارَضَةِ، فَيَخْتَصُّ^(٦) بِالْقِسْمِ الثَّانِي^(٧).

(فَفِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)^(٨)، أَي: فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ السُّنَّةِ (يُحْمَلُ

على رواية أبي هريرة؛ لأنها أقرب إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أبي هريرة، ثم إنها
موصوفة بوصفي العدالة والفقه، أما أبو هريرة فهو موصوف بوصف العدالة فقط.
(١) كالتعارض الواقع بين آيتين، أو بين حديثين كليهما آحاد، وسيأتي التمثيل لذلك عند ذكر
طريقة الحنفية في دفع التعارض.

(٢) شرع المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بيان حكم الأقسام المذكورة، فالقسمان الأولان يجب العمل
بالأقوى وترك الأضعف، وهذا وجه اتفاقهما، ولكنهما يختلفان من حيث وقوع التعارض
والترجيح فيهما، ففي القسم الأول لا تعارض ولا ترجيح بين نص وقياس، وفي القسم
الثاني تعارض وترجيح.

(٣) وهو وقوع التعارض دون الترجيح؛ حيث لا يتصور ترجيح بين متساويين قوة.

(٤) وهذا واضح فيما أشير إليه من قبل.

(٥) أي: بعيد عن المعارضة.

(٦) أي: الترجيح.

(٧) وجملة القول في ذلك: أن القسم الأول ليس فيه تعارض ولا ترجيح، والقسم الثاني فيه
تعارض وترجيح، والقسم الثالث فيه تعارض وليس فيه ترجيح.

(٨) هذه طريقة الحنفية في دفع التعارض، وهي كالتالي: نسخ المتأخر للمتقدم، وإلا فيرجح
بين المتعارضين، وإلا فيجمع بينهما، وإلا حكم بتساقط الدليلين واللجوء لما دونهما في
المرتبة، وإلا فتقرير الأصل. وهذه الطرق في حالة عدم تساوي الدليلين المتعارضين،
فإن تساويا فلا وجه للدفع بالترجيح ويكون حينئذ بالنسخ، أو الجمع، أو التساقط، أو
تقرير الأصل، على الترتيب المذكور في المتن. أما جمهور العلماء فطريقتهم في دفع
التعارض هي: الجمع، الترجيح، النسخ، التساقط، تقرير الأصل.

ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، إِذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ أدَلَّةِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ^(١) دَلِيلُ الْجَهْلِ).
وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَقِيقَةَ التَّعَارُضِ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ
التَّعَارُضُ إِذَا اتَّحَدَ زَمَانٌ وَرُودُهُمَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الشَّارِعَ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ - مُنْزَهُ عَنْ
تَنْزِيلِ دَلِيلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، بَلْ يُنْزَلُ أَحَدُهُمَا سَابِقًا وَالْآخَرُ مُتَأَخِّرًا نَاسِخًا
لِلأَوَّلِ، لَكِنَّا لَمَّا جَهِلْنَا الْمُتَقَدِّمَ وَالْمُتَأَخِّرَ تَوَهَّمْنَا التَّعَارُضَ، لَكِنِ فِي الْوَاقِعِ لَا تَعَارُضَ،
فَقَوْلُهُ: (يُحْمَلُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَى التَّعَارُضِ، وَالْمُرَادُ صُورَةُ التَّعَارُضِ، وَهِيَ:
وُرُودُ دَلِيلَيْنِ يَقْتَضِي أَحَدُهُمَا عَدَمَ مَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ.

(فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ) جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٍ، أَيُّ: يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ^(٢)

(١) أي: لأن التناقض دليل الجهل عند من يظنه واقعا بين أدلة الشرع.
(٢) مثال ذلك من الكتاب: آيتا المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة، في قوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...﴾ [من
الآية رقم ٢٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ...﴾ [من الآية رقم ٢٤٠]، فالآية الأولى تقضي بأن عدة المتوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا، والثانية تقضي بأن عدتها حول كامل، وحيث علم أن الآية
الأولى نزلت متأخرة عن الثانية، حكم بنسخها للثانية، فتعدت المرأة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرا.

ومثال ذلك من السنة: حديث قيس بن طلق، مع حديث جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
في مس الذكر. مسألة: قال: ومس الفرج. الفرج اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر
والدبر وقبل المرأة، وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره؛ فنذكره إن
شاء الله مفصلا: ونبدأ بالكلام في مس الذكر، فإنه أكدها. فعن الإمام أحمد فيه
روايتان: إحداهما: ينقض الوضوء.

وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان، وعروة وسليمان بن
يسار والزهري والأوزاعي والشافعي، وهو المشهور عن مالك، وقد روي أيضا عن
عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية.

والرواية الثانية: لا وضوء فيه، روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران
ابن حصين وأبي الدرداء، وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر، وأصحاب الرأي لما روي

(وَالَا يُطَلَّبُ الْمُخْلَصُ) ^(١)، أَي: يَدْفَعُ الْمُعَارَضَةَ (وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمَكَنَ وَيُسَمَّى عَمَلًا بِالشَّهْبَيْنِ) ^(٢)، فَإِنْ تَبَسَّرَ فِيهَا، وَلَا يَتْرَكَ وَيُصَارُ مِنَ الْكِتَابِ إِلَى السُّنَّةِ، وَمِنْهَا إِلَى

قيس بن طلق، عن أبيه، قال: «قدمنا على نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك» رواه أبو داود والنسائي، والترمذي، وابن ماجه؛ ولأنه عضو منه، فكان كسائرهم، ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» وعن جابر مثل ذلك وعن أم حبيبة، وأبي أيوب قالوا: سمعنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن ماجه. وقال أحمد حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان. وقال الترمذي حديث بسرة حسن صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة أيضا صحيح وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة - رضوان الله عليهم - . فأما خبر قيس فقال أبو زرعة، وأبو حاتم: قيس ممن لا تقوم بروايته حجة ثم إن حديثنا متأخر؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام، صحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربع سنين، وكان قدوم طلق على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة، فيكون حديثنا ناسخا له.

والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه؛ لأن ظاهر الكف ليس بألة للمس، فأشبهه ما لو مسه بفخذه.

واحتج أحمد بحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ» وفي لفظ: «إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي في مسنده وظاهر كفه من يده، والإفضاء: اللمس من غير حائل؛ ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد، فأشبهه باطن الكف. ينظر: المغني لابن قدامة ١/١٣١ - ١٣٣ الناشر: مكتبة القاهرة

(١) أي: إن لم يعلم التاريخ يطلب المجتهد المخلص، وهو الجمع بين المتعارضين، وسماه المصنف (عملا بالشبهين)، ومراده: حمل كل من المتعارضين على وجه غير الآخر، كقولك مثلا: أعط فقيرا، ولا تعط فقيرا، فالأمر بالإعطاء يحمل على الفقير المتعفف، والنهي عن الإعطاء يحمل على الفقير المتسول.

(٢) العمل بالشبهين يرجع إلى عدم تحقق شروط التعارض؛ لأنه لا يثبت التنافي بين الحكمين متى أمكن الجمع بينهما، ويكون ذلك باختلاف المحل، أو الحال، أو حمل أحد

الْقِيَاسِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إِنْ أَمَكْنَ ذَلِكَ^(١)، وَإِلَّا يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأَصْلِ عَلَى مَا كَانَ^(٢)، كَمَا فِي سُورِ الْحَمَارِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْآثَارِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ نَجَسُ^(٣)، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ طَاهِرُ^(٤)،

الدليلين على الحقيقة والآخر على المجاز، أو التقييد والإطلاق، إلى غير ذلك، فمثلاً: لا تناقض بين حل الميتة في حال الاضطرار وحرمتها في حال الاختيار؛ لاختلاف الحالين، والعمل بكل واحد من الدليلين إذا تعارضا وأمكن العمل بكل منهما من وجه دون وجه، فإنه أولى من العمل بأحدهما؛ لأن الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. ينظر: تقويم الأدلة ٩٧، ميزان الأصول ٦٩٠

(١) أي: إن لم يتيسر الجمع، لجأ المجتهد إلى ما يسمى بتساقط الدليلين، فإن كان التعارض بين آيتين وتعذر الجمع بينهما، أسقط المجتهد العمل ولجأ إلى السنة، وإن كان بين سنتين وتعذر الجمع بينهما لجأ إلى القياس. فمثال تعارض الآيتين واللجوء إلى السنة: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فهذه الآية تقتضي عدم وجوب القراءة على المأموم، وقوله تعالى: ﴿..... فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...﴾ [المزمل: ٢٠] يقتضي وجوب القراءة على المأموم، فتعارضتا ولم يمكن الجمع بينهما، فيلجأ إلى السنة، وهي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)، وبه أخذ الحنفية؛ حيث لم يوجبوا القراءة على المأموم. ومثال تعارض السنتين واللجوء إلى القياس: ما روي عن أم المؤمنين عائشة، والنعمان بن بشير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في صلاة الكسوف، فرواية عائشة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجعات، ورواية النعمان أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاها ركعتين بركوعين وأربع سجعات، وتعذر الجمع بينهما، فتلجأ إلى القياس، وهو قياس صلاة الكسوف على سائر الصلوات العادية، وهي كون الركعة بها ركوع وسجدة، وهو ما أخذ به الحنفية في صلاة الكسوف.

(٢) أي: إن تعذر كل ما سبق، أخذ المجتهد بما يسمى تقرير الأصل، وهو الاستصحاب.
(٣) روي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والأوزاعي، وحمام، وإسحاق وعن أحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: أنه قال في البغل والحمار: إذا لم يجد غير سؤرها تيمم معه. وهو قول أبي حنيفة، والثوري. ينظر: المغني لابن قدامة ٣٦/١.

(٤) وهذه الرواية تدل على طهارة سؤره؛ لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به. المرجع السابق.

وَأَيْضًا قَدْ تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ فِي حُرْمَةِ لَحْمِهِ وَحِلِّهِ^(١)، فَلَمَّا تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ بَيَقَى الْحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا^(٢)، فَيَكُونُ طَاهِرًا^(٣)، وَلَا يُزِيلُ الْحَدَّثُ؛ لَوْ قُوعَ الشَّكِّ فِي زَوَالِ الْحَدَّثِ، فَلَا يُزُولُ بِالشَّكِّ^(٤).

(١) فقد ورد في صحيح البخاري، باب: لحوم الحمر الإنسية، وقد اشتمل على سبعة أحاديث، عارض آخرها أولها. منها: عن عبدالله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر - رقم ٥٥٢١ - ومثله عن علي - كرم الله وجهه - وجابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في نفس الباب، وعن أنس بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر منادياً فنادى في الناس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس، فَأُكْفِيتَ القدور، وإنها لتفور باللحم - رقم ٥٥٢٨، وعارض ذلك حديث عمرو - قال - قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، لكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (الأنعام: من الآية ١٤٥) رقم ٥٥٢٩. هذه الأحاديث رواها البخاري ٤٥٣/٣ كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية. كما عورضت بحديث غالب بن أبجر قال: قلت يا رسول الله: أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي، أن أُطْعِمَ أهلي إلا سِمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أطعم أهلَكَ من سَمِينِ حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. رواه أبو داود، باب: لحوم الحمر الأهلية ٦٣/٢ - رقم ٣٨٠٩، وبناء على هذا التعارض اختلف الفقهاء في أكل لحوم الحمر الأهلية: فقال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية في إحدى الروايتين: إنه لا يحل تناول الحمر الأهلية، لوصفها بأنها رجس، فتحريمها كان البتة، كما قال سعيد بن جبير، وفي ذلك ترجيح للآثار الموجبة للحرمة، وقال ابن عباس، وأم المؤمنين عائشة - رضی الله عنهم - يحل أكله بناء على الآية المذكورة، وحديث أبجر بن غالب وقد رُدَّ على ما استدلا به. وللإمام مالك رواية تقضى بکراهة أكل لحمه كراهة مغلظة. والراجح: قول الجمهور بتحريم لحمه، لقوة أدلتهم. ينظر: الأم للشافعي ٣٧٠ / ٢، المبسوط للسرخسي ٢٥٥، ٢٥٦/١١، بداية المجتهد ٣٨١/١، روضة الطالبين للنووي ٥٣٧ / ٢، أسهل المدارك ٣٦٠ / ١.

(٢) أي: قبل شرب الحمار منه.

(٣) أي: بعد شرب الحمار منه؛ استصحاباً للأصل، وهو طهارة الماء.

(٤) القول بالشك في طهورية سؤر الحمار، يتحقق فيه تقرير الأصول، وذلك بالامتناع عن الحكم فتبقى الطهارة في الماء، والحدث في المتوضيء، فيكون الماء طاهراً في نفسه غير

(وهو)، أي: التعارض في الكتاب والسنة^(١) (إما بين آيتين، أو قراءتين، أو سنتين، أو آية، أو سنة مشهورة. والمخلص^(٢) إما من قبل الحكم، أو المحل، أو الزمان، أما الأول^(٣) فإما أن يوزع الحكم^(٤) كقسمة المدعى بين المدعين،^(٥) أو بأن يحمل على تغاير الحكم^(٦)، كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾^(٧)، وفي موضع آخر: ﴿لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ

مُطهر لغيره؛ لأن الحدث ثابت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، لذلك شرط لاستعمال سوره، ضم التيمم إليه عند عدم غيره، لحصول اليقين، لذلك سمي سوره مشكلاً. أما القول بطهوريته فليس فيه تقرير للأصول، بل إنه أهدر أحد الدليلين بالكلية. وأسباب الشك في طهوريته متعددة، منها الآثار السابقة المتعارضة في حرمة لحمه وحله، وكذلك اعتبار سوره بعرقه يدل على الطهارة، واعتباره بلبنه يدل على النجاسة. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ١٣١-١٣٤، التلويح ٢ / ٢٩٤.

(١) بدأ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في ذكر ما يقع فيه التعارض، فبدأ بالكتاب والقراءات منه؛ وذلك لأن القراءات السبع ثابتة متواترة عند الأئمة الأربعة، وعلماء السنة، ولا يحل لمسلم إنكارها؛ لأنها من الأحرف التي نزل بها القرآن الكريم وهي باقية. ينظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٩٤، شرح العضد ٢ / ٢١، فواتح الرحموت ٢ / ١٥.

(٢) أي: من وقوع التعارض ظاهراً.

(٣) وهو المخلص من قبل الحكم، وهو شقان: الأول: توزيع الحكم، الثاني: تغاير الحكم، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم يقبل التبعض أو التعدد، أو يعم فيوزع، وقد شرط صاحب المحصول لذلك أن يكون المدعى قابلاً للاشتراك والتوزيع قبل التعارض، وتقرير الإمام القرافي في ذلك إذا تعارضت البيئات فيما لا يقبل التوزيع كالقذف والقتل، فإنه لا يبيعض، والذي يقبل التوزيع كقسمة الدار ونحوها، فإنه يبيعض. ينظر: المحصول للرازي ٢ / ٤٤٩، نفائس الأصول ٤ / ٤٤٢.

(٤) هذا هو الشق الأول من المخلص من قبل الحكم.

(٥) هذا مثال توزيع الحكم، فلو تنازع شخصان في ملكية دار - مثلاً - ومع كل منهما سند الملكية، حكم بقسمة الدار بينهما.

(٦) هذا هو الشق الثاني من المخلص من قبل الحكم، والمقصود بتغاير الحكم: أن يكون الحكم المستفاد من أحد الدليلين المتعارضين مغايراً للحكم المستفاد من الدليل الآخر.

(٧) من الآية رقم ٢٢٥ من سورة البقرة.

الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ... ﴿١﴾، الْلَّغْوُ فِي الْأُولَى ضِدُّ كَسْبِ الْقَلْبِ، أَيْ: السَّهْوُ^(٢)، بِدَلِيلِ اقْتِرَانِهِ بِهِ، أَيْ: بِكَسْبِ الْقَلْبِ؛ حَيْثُ قَالَ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، (وَفِي الثَّانِيَةِ ضِدُّ الْعَقْدِ)، أَيْ: فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾^(٣)، الْلَّغْوُ ضِدُّ الْعَقْدِ^(٤)، بِدَلِيلِ اقْتِرَانِهِ بِالْعَقْدِ^(٥)، وَالْعَقْدُ قَوْلٌ يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ^(٦)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٧)، فَاللَّغْوُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَخْلُو عَنْ الْفَائِدَةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّغْوُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ^(٨)، فَاللَّغْوُ يَكُونُ شَامِلًا لِلْغُمُوسِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَتَقْتَضِي هَذِهِ الْآيَةُ عَدَمَ الْمُوَاخَذَةِ فِي الْغُمُوسِ، وَالْآيَةُ الْأُولَى تَقْتَضِي الْمُوَاخَذَةَ فِي الْغُمُوسِ؛ لِأَنَّ الْغُمُوسَ مِنْ كَسْبِ الْقَلْبِ وَالْمُوَاخَذَةُ ثَابِتَةٌ فِي كَسْبِ الْقَلْبِ فَوْقَ التَّعَارُضِ فِي الْغُمُوسِ^(٩)، وَهَذَا مَا قَالَهُ فِي الْمَتْنِ.

(١) الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.

(٢) أي: أن اللغو في آية سورة البقرة بمعنى السهو.

(٣) من الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.

(٤) فيه إشارة إلى اليمين المعقودة، وهي التي تجب فيها الكفارة عند الحنث.

(٥) فالمواخذة تكون واجبة في المعقودة وتلزم فيها الكفارة، بخلاف اللغو، فلا شيء فيها.

(٦) هذه حقيقة العقد في اصطلاح الفقهاء؛ لما فيه من ربط أحد الحكمين بالآخر، فاليمين على أمر في المستقبل يسمى عقداً في عرف الشرع، فصار حقيقة شرعية؛ لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء باليمين المعقودة على فعل أمر في المستقبل، أو تركه، والوفاء بالعقود لا يتصور إلا بهذا، وفيه رد لما أورده التفتازاني من نظر، إذ اعتبر أن العقد ليس حقيقة في المعاني، بل مجازاً. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١٣٩/٣، حاشية الفري على التلويح ٤٥/٣، حاشية الأزميري على مرآة الأصول ٣٧٥ / ٢، المبسوط للسرخسي ١٣٦ / ٨، تفسير القرطبي ٢١٣١/٣، تفسير الألوسي ٤٦٩/٢.

(٧) من الآية رقم ١ من سورة المائدة.

(٨) بأن يحمل على تغاير الحكم.

(٩) الغموس: صفة أطلقت على اليمين الفاجرة الكاذبة؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم،

(فَاللَّغْوُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ يَشْمَلُ الْغُمُوسَ؛ إِذْ هُوَ مَا يَخْلُو عَنْ الْفَائِدَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾^(١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾^(٢)، فَأَوْجَبَ عَدَمَ الْمُؤَاخَذَةِ فَوْقَ التَّعَارُضِ، فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا^(٣) بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْأُولَى فِي الْآخِرَةِ^(٤)، بِدَلِيلِ اقْتِرَانِهِ بِكَسْبِ الْقَلْبِ وَفِي الثَّانِيَةِ فِي الدُّنْيَا، أَيْ: بِالْكَفَّارَةِ، فَقَالَ: فَكَفَّارَتُهُ^(٥). (وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْمِلُ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ فِي الثَّانِيَةِ، أَيْ: فِي الدُّنْيَا)، أَيْ: يَحْمِلُ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ الْمُؤَاخَذَةُ فِي الدُّنْيَا حَتَّى أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ فِي

وتوقعه فيه، ثم في النار إلا من تاب، وأصله من: غَمَسَ وَاغْتَمَسَ وَانْغَمَسَ فِي الْمَاءِ وَنَحْوِهِ إِذَا مَقَلَّ فِيهِ، وَغَامَسَ الْأَمْرَ: دَخَلَ فِيهِ. راجع: لسان العرب، مادة: غمس ١٥٦/٦، المصباح المنير، كتاب: الغين ص ٢٧٠. والغموس في اصطلاح الفقهاء: اليمين المعقودة التي يحلف بها على أمر في الماضي، أو الحال متعمداً الكذب، كقوله: والله ما فعلت وقد فعل. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٣٤/٨، بداية المجتهد لابن رشد ٣٣١/١

- (١) من الآية رقم ٦٢ من سورة مريم.
- (٢) من الآية رقم ٥٥ من سورة القصص.
- (٣) هذا ما ذهب إليه جمهور الحنفية، فقد أثبتوا أن حكم كل من النصين غير حكم الآخر، وحيث لم يتحد محل النفي والإثبات بطل التدافع. فالغموس يؤخذ به في الآخرة، ولا يؤخذ به في الدنيا بالكفارة. ينظر: أصول السرخسي ١٩/٢، جامع الأسرار للكاكي ٧٩٧/٣، الوجيزة النافعة ص ٥٠٥.

- (٤) وهو الذي ورد في آية سورة البقرة.
- (٥) الآية نصت على الكفارة قال تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) (من الآية ٨٩ من سورة المائدة) والعلماء يخبرون الحانث في يمينه بين الإطعام والكسوة والإعتاق، للتنصيص على حرف (أو) ، ولأن البداية كانت بالأخف فالأغلظ، ولو كانت على الترتيب، لكان العكس. ينظر: المبسوط ٨/١٣٦، تفسير الألوسي ٥٧/٥، بداية المجتهد ٣٣٨/١.

الْغُمُوسِ^(١). (وَالْعَقْدَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْأُولَى)، أَي: يَحْمِلُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْعَقْدَ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى كَسْبِ الْقَلْبِ حَتَّى يَكُونَ اللَّغْوُ هُوَ عَيْنُ اللَّغْوِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى، وَهُوَ السَّهْوُ، فَلَا يَكُونُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا^(٢)، لَكِنْ مَا قُلْنَا أَوْلَى مِنْ هَذَا^(٣)؛ لِأَنَّ عَلَى مَذْهَبِهِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَقْدُ مُجْرَى عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ^(٤).

وَأَيْضًا^(٥) الدَّلِيلُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمُواخَذَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى هِيَ الْمُواخَذَةُ الْأُخْرَوِيَّةُ، بِدَلِيلِ اقْتِرَانِهَا بِكَسْبِ الْقَلْبِ، وَهُوَ يَحْمِلُهَا عَلَى الدُّنْيَوِيَّةِ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا^(٦) فَإِنَّ اللَّغْوَ جَاءَ لِمَعْنَيْنِ^(٧)، فَيَحْمِلُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا هُوَ أَلْيَقُ بِهِ، وَيَحْمِلُ الْمُواخَذَةَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا هُوَ أَلْيَقُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَوِيَّةِ، أَوِ الْأُخْرَوِيَّةِ.

(١) نص على ذلك في كتاب - الأم - فقال: لو أقسم لقد كان، وما كان، فهذا آثم، وعليه الكفارة وحجته: أن الله تعالى جعل الكفارات في عمد المأثم، ككفارة الظهار ونحوها، كما أنها يمين معقودة مقصودة. وأما جمهور الفقهاء فقالوا: لا كفارة في الغموس؛ لأنه لم يصادف محله من الصدق والخير، بل هو يمين مكر وخديعة، وهو كبيرة محظورة وأغلظ من أن تستره الكفارة. ينظر: الأم للشافعي ٨٩/٧، المبسوط للسرخسي ١٣٤/٨، ١٣٥، أسهل المدارك ٣٣٥/١، الإنصاف ١٤/١١، ١٥.

(٢) هذا نفي للتعارض الذي أثبتته جمهور الحنفية، حيث اعتبروا اللغو في سورة البقرة هو: السهو، وفي سورة المائدة: ما لا فائدة فيه، ونفى الإمام الشافعي هذا التغاير، فلم يقر وقوع التعارض من الأصل. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١٣٨/٣.

(٣) أي: ما قاله الحنفية أولى مما قاله الإمام الشافعي، وكلامهم جواب عن قوله.

(٤) هذا تعليل لقوله: "ما قلنا أولى..." ومعناه: أن على مذهب الشافعي يلزم العدول عن الحقيقة من غير ضرورة؛ لأن حقيقة العقد ربط الشيء بالشيء، بخلاف عزم القلب، وهذا هو الجواب الأول عما قاله الإمام الشافعي.

(٥) هذا هو الجواب الثاني عما قاله الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٦) المقصود به: مذهب الحنفية.

(٧) وهما: السهو في آية سورة البقرة، والكلام الخالي عن الفائدة في آية سورة المائدة.

وَأَقُولُ^(١): لَا تَعَارُضُ هُنَا، وَاللَّغْوُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ ضِدُّ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ مِنَ الشَّارِعِ أَنْ يَقُولَ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْغُمُوسِ، وَالْمُؤَاخَذَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي الْآخِرَةِ، لَكِنْ فِي الثَّانِيَةِ سَكَتَ عَنِ الْغُمُوسِ وَذَكَرَ الْمُنْعَدَّةَ وَاللَّغْوَ، وَقَالَ: الْإِثْمُ الَّذِي فِي الْمُنْعَدَّةِ يُسْتَرُّ بِالْكَفَّارَةِ، لَا أَنَّ الْمُرَادَ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ الْكَفَّارَةُ هَذَا وَجْهٌ وَقَعَ فِي خَاطِرِي لِدَفْعِ التَّعَارُضِ، وَاللَّغْوُ فِي الْآيَتَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ السَّهْوُ^(٢) أَمَّا فِي الْآيَةِ الْأُولَى^(٣) فَبِدَلِيلِ اقْتِرَانِهِ بِكَسْبِ الْقَلْبِ، وَأَمَّا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ مِنَ الشَّارِعِ أَنْ يَقُولَ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الْخَالِي عَنِ الْفَائِدَةِ الَّذِي يَدْعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعٍ^(٤)، أَعْنِي الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ، بَلْ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالسَّهْوِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾^(٥)، وَالْمُرَادُ بِالْمُؤَاخَذَةِ: الْمُؤَاخَذَةُ الْأُخْرَوِيَّةُ^(٦)؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْجَزَاءِ وَالْمُؤَاخَذَةُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾^(٧) لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمُؤَاخَذَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ^(٨)؛ لِأَنَّ مَعْنَى

(١) هذا رأي صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في المسألة، وقد وافق جمهور الحنفية، والإمام الشافعي من وجه، وخالفهما من وجه، كما نص على ذلك في توضيحه.

(٢) وافق صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - رأي الإمام الشافعي في تفسير اللغو في الآيتين.

(٣) وهي: آية سورة البقرة، وهذا بيان لسبب تفسير اللغو بالسهو في الآيتين عند المؤلف.

(٤) البلاقع: جمع ومفرده البَلَقْع، وهو المكان الخالي عن الخير، والبَلَقْعَةُ الأرض القفر التي لا ينبت فيها زرع ولا شجر، وتطلق البلاقع على اليمين الفاجرة؛ وذلك لأن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الخير ويفرق الله شمله علاوة على ما ادخر له من الإثم في الآخرة. ينظر: لسان العرب، باب: العين، مادة: بلقع ٢١/٨، مختار الصحاح ص ٢٦.

(٥) من الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٦) في الآيتين، وصدر الشريعة وافق مذهب الحنفية وخالف مذهب الشافعي.

(٧) من الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.

(٨) هذا رد صدر الشريعة على ما قال به الحنفية: إن المراد من المؤاخذة في آية سورة المائدة هي المؤاخذة الدنيوية.

الْكُفَّارَةُ: السَّتَارَةُ، أَيُّ: الْإِثْمُ الْحَاصِلُ بِالْمُنْعَدَةِ يُسْتَرُّ بِالْكُفَّارَةِ^(١).

وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْيَمِينِ السَّهْوِ، وَعَلَى الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْمُنْعَدَةِ، وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَنِ الْغُمُوسِ^(٢) فَانْدَفَعَ التَّعَارُضُ^(٣) وَثَبَّتَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ مَذْهَبِنَا^(٤)، وَهُوَ عَدَمُ الْكُفَّارَةِ فِي الْغُمُوسِ^(٥).

(وَأَمَّا الثَّانِي) وَهُوَ الْمُخْلَصُ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلِّ (فَبِأَن يُحْمَلَ عَلَى تَغَايُرِ الْمَحَلِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾^(٦) بِالتَّشْدِيدِ، وَالتَّخْفِيفِ، فَبِالتَّخْفِيفِ يُوجِبُ الْحِلَّ بَعْدَ الطُّهْرِ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ^(٧)، وَبِالتَّشْدِيدِ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ،

(١) أي: الكفارة تستر الإثم الحاصل بالمنعقدة.

(٢) خالف صدر الشريعة كلا من الحنفية والشافعية في اليمين الغموس، فليست داخلة في المنعقدة كما قال الشافعي، ولا في اللغو كما قال الحنفية.

(٣) يفهم من كلام صدر الشريعة أن هناك تعارضاً وتم دفعه، وهذا مخالف لما سبق له ذكره في قوله: "وأقول: لا تعارض هنا..."; لأنه على قول المصنف يفهم أن آية سورة البقرة أوجبت المؤاخذه (الإثم) على الغموس، وآية سورة المائدة لم تتعرض للغموس لا نفيًا ولا إثباتًا، فلا تعارض لها أصلاً.

(٤) لأن المؤاخذه التي توجبها آية سورة البقرة على الغموس هي المؤاخذه الأخروية، والتي تنفيها آية سورة المائدة هي المؤاخذه في الدنيا، أي: لا يؤاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويؤاخذكم بها في المعقودة، ولما تغايرت المؤاخذتان اندفع التعارض. ينظر: الوجيزة النافعة ص ٥٠٥.

(٥) صرح التفਤازاني بأن اعتبار الغموس مسكوتاً عنه لا وجه له، ولا يقال: قد علم حكمه بالأولى؛ لأن اللغو قد علم حكمه أيضاً، وذكر في الثانية. ويجب على ذلك: بأن اليمين الغموس ليس يميناً حقيقة؛ لأنها لم تشرع، بل هي يمين فاجرة وإطلاق اسم اليمين عليها مجاز، باعتبار استعمال صورة اليمين، كاستعمال صيغة عقد البيع في بيع الحر. ينظر: التلويع ٢/ ٣٠٠، المبسوط للسرخسي ١٣٤/٨.

(٦) من الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقرة، وهذا مثال للتعارض بين قراءتين.

(٧) أي: بعد انقطاع الدم، سواء انقطع على أكثر مدة الحيض أو على ما دونه؛ لأن الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض، يقال: طهرت المرأة إذا خرجت من حيضها. نظر: الوجيزة النافعة ص ٥٠٦.

فَحَمَلْنَا الْمُخَفَّفَ عَلَى الْعَشْرَةِ وَالْمُشَدَّدَ عَلَى الْأَقَلِّ) وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْعَكْسِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا طَهِّرَتْ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ حَصَلَتْ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ؛ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْعُودِ^(١)، وَإِذَا طَهِّرَتْ لِأَقَلِّ مِنْهَا يُحْتَمَلُ الْعُودُ، فَلَمْ تَحْصُلِ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ فَاحْتِجَ إِلَى الْإِغْتِسَالِ لِتَتَأَكَّدَ الطَّهَارَةُ.

(وَأَمَّا الثَّلَاثُ)، أَيُّ: الْمُخْلِصُ مِنْ قِبَلِ الزَّمَانِ (فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ صَرِيحَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ يَكُونُ الثَّانِي نَاسِخًا لِلأَوَّلِ^(٢)، فَكَذَا إِنْ كَانَ دَلَالَتُهُ^(٣)، كَنَصِّينِ أَحَدُهُمَا مُحَرَّمٌ وَالْآخَرُ مُبِيحٌ، يُجْعَلُ الْمُحَرَّمُ نَاسِخًا؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ^(٤)، وَالْمُبِيحُ وَرَدَ لِإِبْقَائِهِ، ثُمَّ الْمُحَرَّمُ نَسَخَهُ، وَلَوْ جَعَلْنَا عَلَى الْعَكْسِ يَتَكَرَّرُ النَّسْخُ)، أَيُّ: لَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْمُحَرَّمُ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمُبِيحِ فَالْمُحَرَّمُ كَانَ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ ثُمَّ الْمُبِيحُ يَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُحَرَّمِ فَيَتَكَرَّرُ النَّسْخُ، فَلَا يَثْبُتُ التَّكَرُّارُ بِالشَّكِّ^(٥). وَفِيهِ نَظَرٌ^(٦)؛ (لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ

(١) لأن أقصى مدة الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام عند الحنفية، أما الجمهور: فاقصى الحيض عندهم خمسة عشر يوماً، وأقله يوم وليلة عند الإمامين الشافعي وأحمد، وعند الإمام مالك - لا أقل لحده، ولكل أدلته. راجع: المبسوط ١٦٣/٣-١٦٤، روضة الطالبين ٢٤٧/١، أسهل المدارك ٨٧/١، الإتصاف في الراجح من الخلاف ٢٥٦/١.

(٢) لأن المتأخر ينسخ المتقدم.

(٣) فاختلاف الزمان إما أن يكون صريحاً، وأمثله لا تخفى على طالب العلم، وإما أن يكون دلالة، ومثل له المصنف بالنصين اللذين أحدهما محرم والآخر مبيح، وذلك مثل: ما روي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ: (أَحْلَتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَمَتْهُمَا آيَةٌ) والتحرير أولى، وكذا من طلق إحدى نسائه أو أعتق إحدى إماءه ونسيها، يحرم عليه وطء جميعهن بالاتفاق؛ ترجيحاً للحرمة. ينظر: الوجيزة النافعة ص ٥٠٧.

(٤) اختلف العلماء في الأشياء التي تحتل أن يرد الشرع بإباحتها وحظرها أنها قبل ورود الشرع على الإباحة أم على الحظر، فذهب أكثر الحنفية خصوصاً العراقيون منهم، وكثير من أصحاب الشافعي إلى أنها على الإباحة، وأنها هي الأصل فيها، حتى إن من لم تبلغه الدعوة أبيح له أن يأكل ما شاء من المطعومات. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٩٥/٣، الوجيزة النافعة ص ٥٠٧.

(٥) لأن نسخ حكم الإباحة بالحظر متفق عليه، وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة فمحتمل،

الأصلية لَيْسَتْ حُكْمًا شَرْعِيًّا، فَلَا تَكُونُ الْحَرْمَةُ بَعْدَهُ نَسْخًا، وَبَيَانُهُ: أَنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُحْرَمَ لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا لَكَانَ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ نَاسِخًا لَهَا إِنْ قَدْ وَرَدَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ دَالٌّ عَلَى إِبَاحَةِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، فَيَلْزَمُ - حِينَئِذٍ - كَوْنُ الْمُحْرَمِ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْمُبِيحِ، لَكِنْ وَرَدَ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُسَلَّمٍ، فَلَا يَكُونُ الْمُحْرَمُ نَاسِخًا لِذَلِكَ الْمُبِيحِ لَمَّا عَرَفْتَ مِنْ تَعْرِيفِ النَّسْخِ^(٢). وَيُمْكِنُ إِتِّمَامُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ^(٣) عَلَى وَجْهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ هَذَا النَّظَرُ، وَهُوَ: أَنَّهُ إِذَا انْتَفَعَ الْمُكَلَّفُ بِشَيْءٍ قَبْلَ وُرُودِ مَا يُحْرِمُهُ، أَوْ يُبِيحُهُ، فَإِنَّهُ لَا يِعَاقِبُ بِالْإِنْتِفَاعِ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٤)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٥)، فَإِنَّ هَذَا الْإِخْبَارَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنْ انْتَفَعَ بِمَا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ وُرُودِ مُحْرَمِهِ، أَوْ مُبِيحِهِ لَا يِعَاقِبُ، ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ الْمُحْرَمُ فَقَدْ غَيَّرَ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِقَابِ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ، ثُمَّ إِذَا وَرَدَ الْمُبِيحُ فَقَدْ نَسَخَ ذَلِكَ الْمُحْرَمَ فَيَلْزَمُ هُنَا تَغْيِيرَانِ، وَأَمَّا عَلَى الْعَكْسِ فَلَا يَلْزَمُ إِلَّا تَغْيِيرٌ وَاحِدٌ، فَانْدَفَعَ الْإِيرَادُ^(٦) الْمَذْكُورُ بِهَذَا التَّقْرِيرِ فَتَقَرَّرَ الدَّلِيلُ

وبالاحتمال لا يثبت النسخ، فكان العمل بما هو ناسخ بيقين أولى. أصول السرخسي ٢١/٢.

(١) القول بأن دليل التحريم مقدم على دليل الإباحة مما يلزم معه تكرار النسخ قول غير سليم.

(٢) معنى ذلك: أنا لو سلمنا أن دليل التحريم مقدم على دليل الإباحة، فإن الدليل المحرم لا يكون ناسخًا للإباحة الأصلية؛ لأنها لم تثبت بدليل شرعي، ومن ثم لا يصح تسمية ذلك نسخًا؛ لأن النسخ على ما عرف هو: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه.

(٣) وهو: أن دليل التحريم مقدم على دليل الإباحة.

(٤) من الآية رقم ١٥ من سورة الإسراء.

(٥) من الآية رقم ٢٩ من سورة البقرة.

(٦) الإيراد: خلاف الإصدار، وهو: من ورد الشيء يَرُدُّ وُرُودًا إِذَا حَضَرَهُ وَبَلَّغَهُ وَوَفَاهُ، مِنْ غَيْرِ دُخُولِ فِيهِ، وَقَدْ يَحْصُلُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (من الآية رقم ٧١ من سورة مريم) والموارد: المناهل والطرق، وتطلق على الخير والشر تقول: أوردته موارد

بِهَذَا الطَّرِيقِ، أَوْ نَقُولُ: عَيْنًا بِتَكَرُّرِ النَّسْخِ هَذَا الْمَعْنَى ^(١) لَا النَّسْخَ بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْتُمْ ^(٢).

وَقَدْ قَالَ نَفَرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا، أَيُّ: تَكَرَّرَ النَّسْخُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ أَصْلًا وَلَسْنَا نَقُولُ بِهَذَا فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْبَشَرَ لَمْ يَتْرَكُوا سُدَى فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّمَانِ، وَإِنَّمَا هَذَا، أَيُّ: كَوْنُ الْإِبَاحَةِ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى زَمَانِ الْفَتْرَةِ ^(٣) قَبْلَ شَرِيعَتِنَا، فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَانِ الْفَتْرَةِ، وَذَلِكَ ثَابِتٌ إِلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُحَرَّمُ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِاخْتِلَافِ الشَّرَائِعِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَوُقُوعِ التَّحْرِيفَاتِ فِي التَّوْرَةِ ^(٤)، فَلَمْ يَبْقَ الْإِعْتِمَادُ وَالْوُثُوقُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، فَظَهَرَتْ الْإِبَاحَةُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَهُوَ عَدَمُ الْعِقَابِ عَلَى الْإِثْنَيْنِ بِهِ مَا لَمْ يَوْجَدْ لَهُ مُحَرَّمٌ، وَلَا مُبِيحٌ ^(٥).

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَوْجَدُ لَهُ مُحَرَّمٌ، وَلَا مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَ الْإِنتِفَاعُ بِهِ ضَرْوِيًّا كَالْتَنَفُّسِ وَنَحْوِهِ فَغَيْرُ مَمْنُوعٍ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرْوِيًّا ^(٦) كَأَكْلِ الْفَوَاحِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ ^(٧)، فَإِنْ أَرَادُوا بِالْإِبَاحَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِإِبَاحَتِهِ

التهلكة. ينظر: لسان العرب، مادة: ورد ٤٥٧/٣، ٤٥٨، مختار الصحاح ص ٢٩٨

(١) وهو أنه لا يسمى نسخا، بل تغييرا.

(٢) أي: تكرر التغيير سواء كان تغيير حكم شرعي، أو لا، فإن تكرار التغيير زيادة على نفس التغيير، فلا يثبت بالشك.

(٣) والمراد بها المدة التي بين نبي الله عيسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ونبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٤) تحريف التوراة: الميل بها عن المواضع التي أرادها الله تعالى، وذلك إما بتأويل الأمر على غير وجهه، وإما بتغيير الحرف، أو الكلمة عن معناها بالمحو، أو التبديل.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٥٠٣، تفسير ابن كثير ٢/ ٥٨.

(٥) حيث إن الموجب للحظر متأخر في شريعتنا. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢١.

(٦) بأن كان اختياريًا.

(٧) وهذا ما عليه جماهير أهل السنة؛ وذلك لأن الله خلق كل ما في الوجود من أجل ابن

فِي الْأَزْلِ فَهَذَا غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَإِنْ أَرَادُوا عَدَمَ الْعِقَابِ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ بِهِ فَحَقٌّ.

وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى الْحَظَرِ^(١)، فَإِنْ أَرَادُوا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - حَكَمَ بِحَظَرِهِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ، وَإِنْ أَرَادُوا الْعِقَابَ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ بِهِ فَبَاطِلٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٢)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(٣)، وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى الْوَقْفِ^(٤)، فَفَسَّرَ الْوَقْفَ تَارَةً بِعَدَمِ الْحُكْمِ، وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا مَمْنُوعٌ مِنَ اللَّهِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، أَوْ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ، وَالْأَوَّلُ حَظَرٌ، وَالثَّانِي إِبَاحَةٌ، وَلَا خُرُوجَ عَنِ النَّقِیْضَيْنِ^(٥).

وَأَجَابَ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ^(٦) عَنْ هَذَا: بِأَنَّ الْمُبَاحَ هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ الشَّارِعُ فَاعِلُهُ أَوْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ. وَهَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِشَيْءٍ^(٧)؛

أَدَمَ ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ مِنَ الْآيَةِ رَقْم ٢٩ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَالْإِذْنُ فِي الِاسْتِعْمَالِ حَاصِلٌ، وَبِهِ قَالَ الْجَبَائِيَانِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ مِنْ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ.

(١) لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مُلْكٍ الْغَيْرِ بَدُونِ إِذْنِهِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى إِذْنِ اللَّهِ فِيهِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتْ مُعْتَزِلَةُ بَغْدَادَ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ وَأَبُو عَلِيٍّ بَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.

(٢) مِنَ الْآيَةِ رَقْم ١٥ مِنْ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ. وَالْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَبْطَلَ أَقْوَالَ الْمُعْتَزِلَةِ الثَّلَاثَةِ، لِكُونِهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْصِيقِ الْعَقْلِيِّ، وَكُلُّ مَا يَبْنِي عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ بَاطِلًا، فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمْ وَقَعَ فِيمَا لَمْ يَدْرِكِ الْعَقْلُ حَسَنَهُ وَقَبِيحَهُ. وَمَذْهَبُ أَصْحَابِ الْحَظَرِ ظَاهِرُ الْبَطْلَانِ، إِذْ لَا يُعْرَفُ الْحَظَرُ بِضُرُورَةِ الْعَقْلِ وَلَا بِدَلِيلِهِ، كَمَا أَنَّ الْحَظَرَ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ الْعِقَابِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ بِدَلَالَةِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ. يَنْظُرُ: الْمُسْتَصْفَى ٦٤/١، ٦٥، جَامِعُ الْأَسْرَارِ لِلْكَافِي ٨٠٤/٣.

(٣) مِنَ الْآيَةِ رَقْم ٢٩ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(٤) لِتَعَارُضِ دَلِيلِي الْحَظَرِ، وَ الْإِبَاحَةِ. انْظُرْ: الْمُعْتَمَدُ ٢/ ٨٦٨، الْمُسْتَصْفَى ١/ ٦٣، نَهَايَةُ السُّؤَالِ ١٢٤/١.

(٥) بِأَنَّ كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ مَمْنُوعًا مِنْهُ تَعَالَى.

(٦) انْظُرْ: الْمَحْصُولُ ٥٠/١، نَفَائِسُ الْأُصُولِ ١٧٢/١.

(٧) رَدُّ التَّفْتَازَانِيِّ اعْتِرَاضَ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ: إِنْ مَعْنَى كَلَامِ الْإِمَامِ الرَّازِيِّ، لَا غِبَارَ عَلَيْهِ،

لأنَّ الْخِلَافَ فِي شَيْءٍ لَمْ يُعْلَمْ الشَّارِعُ بِالْحَرْجِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَعَدَمِهِ، فَعَنَى كَلَامِهِ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ الشَّارِعُ بِالْحَرْجِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَعَدَمِ الْحَرْجِ لَمْ يُعْلَمْ الشَّارِعُ بِعَدَمِ الْحَرْجِ فِيهِ، وَهَذَا كَلَامٌ حَشْوٌ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا. وَقَدْ فُسِّرَ الْوَقْفُ تَارَةً بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ حُكْمٌ، فَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ حَظَرٌ أَوْ إِبَاحَةٌ، أَمَّا عَدَمُ الْعِلْمِ بِأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا أَمْ لَا فَبَاطِلٌ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حُكْمًا لَازِمًا^(١) إِمَّا بِالْمَنْعِ، أَوْ بِعَدَمِهِ^(٢)، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ حَظَرٌ، أَوْ إِبَاحَةٌ فَحَقٌّ. فَالْحَقُّ عِنْدَنَا أَنَّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى الْحَظَرُ أَوْ الْإِبَاحَةُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، فَعِلْمُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَظَرُ أَوْ الْإِبَاحَةُ، وَبَيْنَ مَنْ يَقُولُ بِالْإِبَاحَةِ؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَى الْفِعْلِ أَوَّلَتَرِكِ^(٣)، وَهَذَا حَاصِلٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ أَيُّهُمَا، وَلِقَوْلِهِ: -

لأن معناه جواز الانتفاع بالشيء، خالياً عن أمانة المفسدة، وفي ذلك نفي للأحكام الشرعية قبل البعثة، فكلامه مستقيم المعنى حيث إنه نفى أن تدرك الإباحة بالعقل. ينظر: حاشية البنانى على جمع الجوامع ٢/٣٥٣، التلويح ٢/٣٠٥.

(١) هذا دليل بطلان ما ذهب إليه المعتزلة؛ لأن الحكم قديم، وما ثبت قدمه يمتنع عدمه، والاتفاق قائم على أن التكليف ثابت قبل حدوثه، والتعلق حادث؛ ولذلك صح أن يوصف بعدم الحكم، وهذا بخلاف نفي ذات الحكم وقدمه، وذلك كتعلق وجود الصلاة على أسبابها، فالظهر - مثلاً - لا يجب قبل الزوال، وهذا من جهة التعلق، وهذا لا ينافي أنه ثابت في الأزل، متعلق بما بعد الزوال، فالخلاف في الحدوث والقدم باعتبار طرفين، وأصل الخلاف في أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أم من الأمور الاعتبارية؟ ينظر: نفائس الأصول ١/١٧٩، التلويح ٢/٣٠٥، سلاسل الذهب ص ٩٥، حاشية الفنري على التلويح ٣/٤٩.

(٢) دعوى التناقض لا تصح؛ لأن الحكم بالمنع، والحكم بعدم المنع، يمنع ارتفاع النقيضين، وترتب الثواب والعقاب متوقف على الشرع، عند الجمهور، وعند المعتزلة على العقل، وهذا ١ موضع الخلاف بيننا وبينهم. ينظر: التلويح ٢/٣٠٥، إرشاد الفحول ص ١٢.

(٣) بذلك جمع المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بين قول من قال بالإباحة، وبين قول من قال بالتوقف،

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- « مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ »
الحديث^(١).

(وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُثَبَّتًا^(٢) وَالْآخَرُ نَافِيًا^(٣)، فَإِنْ كَانَ النَّفْيُ يُعْرِفُ بِالِدَّلِيلِ
كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرِفُ بِهِ بَلْ بِنَاءٍ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ فَلَمْ تُثَبِّتْ أُولَى؛
لَمَّا قُلْنَا فِي الْمَحْرَمِ وَالْمُبِيحِ، وَإِنْ اخْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ يُنْظَرُ فِيهِ)، أَيْ: إِنْ اخْتَمَلَ النَّفْيُ
أَنْ يُعْرِفَ بِدَلِيلٍ وَأَنْ يُعْرِفَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ بِنَاءٍ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ النَّفْيِ،
فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يُعْرِفُ بِالِدَّلِيلِ يَكُونُ كَالْإِثْبَاتِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بِنَاءٍ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ
فَالْإِثْبَاتُ أُولَى^(٤)).

لاتحاد المعنى، من جهة اتفاقهما على نفي العقاب، وكذا قال الغزالي في المستصفى،
وأثبت التفتازاني فرقا، وهو: أن التوقف أعم من نفي العلم بالعقاب، وعدمه، والقول
بالإباحة نفي العقاب فقط، فكيف يتساويان؟. والإمام القرافي قال: الأشعرية لم يجزوا
بالإباحة إلا بناء على الأدلة السمعية، والحق أن المصنف حمل - بذلك - حالهم على
الصلاح، وذلك منه حسن، لكونه تقريبا وتسديدا. ينظر: المستصفى ٦٥/١، نفائس الأصول
١٧٨/١، حاشية الأزميري على مرآة الأصول ٣٧٩/٢.

(١) الحديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وقيل موقوف عليه،
ونقل ابن السبكي عن البيهقي أن فيه ضعفا وانقطاعا. وقال الزين العراقي: لا أصل له.
ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢٥٤/٢، تخريج أحاديث المنهاج ص ٨٤.

(٢) المثبت: هو الدليل الذي يثبت أمراً عارضاً، وهو من ثَبَّتَ الأمر وأثبتته: إذا حققه
وصححه، وأقام حجته، والإثبات حكم بثبوت شيء آخر. ينظر: لسان العرب ١٩/٢، مادة:
ثَبَّت، كشف الأسرار للبخاري ١٤٨/٣.

(٣) النافي: هو الدليل الذي ينفي الأمر العارض، ويبقيه على حاله الأول، فالنفي إخبار عن
ترك الفعل، أو عدم صدوره من الفاعل أصلاً، تقول: نفى الشيء عنه: إذا دفعه عنه
وَنَحَاهُ، ولم يثبتته، وتقول: نفى السيل الغناء، ونفى الصفة عن الموصوف. ينظر: لسان
العرب ٣٣٦/١٥، مادة: نفى، كشف الأسرار للبخاري ١٤٨/٣.

(٤) لأنه لو جعل النافي أولى يلزم تكرار النسخ بتغيير المثبت للنفي الأصلي، ثم النافي
للإثبات، وكذلك احتمال المثبت على الزيادة في العلم. ينظر: التلويح ١٠٩/٢.

(فَمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ حَلَالٌ» مُثْبِتٌ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ نَافٍ، فَإِنَّهُ اتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحِلِّ الْأَصْلِيِّ، وَالْإِحْرَامُ حَالَةٌ مَخْصُوصَةٌ تُدْرِكُ عَيْنًا، فَكِلَاهُمَا سَوَاءٌ، فَرَجَّحَ بِالرَّأْيِ، وَرَاوِيَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا يَعْدِلُهُ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ^(١) وَنَحْوُهُ) هَذَا نَظِيرُ النَّفْيِ الَّذِي يُعْرَفُ بِالِدَّلِيلِ.

اعْلَمْ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ جَائِزٌ عِنْدَنَا^(٢) تَمَسُّكًا بِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»^(٣) وَتَمَسُّكَ الْخَصْمِ بِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَزَوَّجَ، وَهُوَ حَلَالٌ»^(٤) وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحِلِّ الْأَصْلِيِّ^(٥)، فَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ

(١) هو: يزيد بن الأصم بن معاوية البكاء العامري، كنيته أبو عمرو، وهو: ابن أخت السيدة ميمونة وكان صغيراً عند زواجها بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توفي سنة ١٠٣ هـ، وقيل ١٠٤ هـ، قال عنه - أبو نُعَيْمٍ: عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَبَانَ: وَالْمُسْتَغْفِرِيُّ لَهُ صَحْبَةٌ. ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٥/٤٧٧، ٤٧٨، الإصابة ٦/٥٢٨، تاريخ الإسلام للذهبي ٣/٣٣٣.

(٢) مسألة نكاح المحرم خالف الحنفية فيها، جمهور العلماء؛ حيث قالوا: لا يُنْكَحُ المحرم ولا يُنْكَحُ، وإن فعل فالنكاح باطل، وهو مذهب عمر، وعلى، وزيد بن ثابت، والأوزاعي، وذلك أخذاً بالنصوص الدالة على المنع، ولأن العقد دأب إلى ما أجمع على النهي عنه، وهو - الوطء - وعند الإمام أبي حنيفة: لا بأس بعقد النكاح، إذ ليس فيه إرتفاق، ومثله كمثل شراء الطيب واللباس واستأنس بالقصة الواردة في كتب السيرة. ينظر: الأم للشافعي ٥/٢٥٤، المبسوط ٤/٢١١، ٢١٢، بداية المجتهد ٢/٣٨، روضة الطالبين للنووي ٤/٤١٨، أسهل المدارك ١/٣١٥ مختصر سيرة ابن هشام ٢١٢.

(٣) هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بنت حزن، تزوجها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في عُمره القضاء، وبنى بها بسرف، في قبة لها، وكانت آخر الزوجات، وتوفيت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سنة ٥١ هـ. ينظر: الإصابة ٨/٣٢٤، ٣٢٢، تاريخ الإسلام للذهبي ٢/٣١٨.

(٤) أخرجه البخاري ٤٧٥/١ كتاب: جزاء الصيد، باب: تزويج المحرم (حديث رقم ١٨٣٧)، وأبو داود في سننه ٣٤/٢ كتاب: المناسك، باب: المحرم يتزوج (حديث رقم ١٨٤٤)، وابن ماجه في سننه ١/٦٣٣ كتاب: المناسك باب: المحرم يتزوج (حديث رقم ١٩٦٥).

(٥) أخرجه أبو داود في سننه ٢٤/٢ كتاب: المناسك، باب: المحرم يتزوج (حديث رقم ١٨٤٣)، وابن ماجه في سننه ١/٦٣٣ كتاب: المناسك باب: المحرم يتزوج (حديث رقم ١٩٦٤)، نيل الأوطار للشوكاني ٥/١٤.

كَانَ فِي الْإِحْرَامِ، أَوْ فِي الْحِلِّ الَّذِي بَعْدَ الْإِحْرَامِ، فَمَعْنَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِحْرَامِ: أَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرَ الْإِحْرَامُ بَعْدُ، وَمَعْنَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْحِلِّ الَّذِي بَعْدَ الْإِحْرَامِ: أَنَّ الْإِحْرَامَ تَغَيَّرَ إِلَى الْحِلِّ، فَلِأَوَّلِ نَافٍ وَالثَّانِي مُثَبِّتٌ، لَكِنَّ الْإِحْرَامَ حَالَةً مُخْصِصَةٌ مُدْرَكَةٌ عَيْنَانًا، فَتَكُونُ كَالْإِثْبَاتِ فَرَحْنًا بِالرَّأْيِ^(٢)، وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(وَنَحْوُ: «أُعْتَقْتُ بَرِيرَةَ وَزَوْجَهَا حُرًّا» مُثَبِّتٌ، «وَأُعْتَقْتُ وَزَوْجَهَا عَبْدًا» نَافٍ، وَهَذَا النَّفْيُ مِمَّا يُعْرَفُ بِظَاهِرِ الْحَالِ، فَالْمُثَبِّتُ أَوْلَى) هَذَا نَظِيرُ النَّفْيِ الَّذِي لَا يَكُونُ بِالْدَّلِيلِ.

أَعْلَمُ أَنَّ الْأَمَّةَ الَّتِي زَوَّجَهَا حُرًّا إِذَا أُعْتِقَتْ يَنْبُتُ لَهَا خِيَارُ الْعِتْقِ عِنْدَنَا^(٣) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَنَا: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ^(٤)

(١) كَأَنَّ الْمَصْنَفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَرِيدُ اتِّفَاقَ الْفَرِيقَيْنِ. يَنْظُرُ: التَّلْوِيحُ ١١٠/٢.

(٢) مَسْأَلَةُ التَّرْجِيحِ بِالرَّوَايِ يَقُولُ بِهَا الْحَنْفِيَّةُ: فَقَدْ رَجَحُوا بِفَقْهِ الرَّوَايِ، وَعِلْمُهُ، فِي حِينِ أَنَّ الْجُمْهُورَ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ مَرْجَحاً فِي الرَّوَايَةِ، وَلِكُلِّ أَدْلَةٍ، وَهَذَا النُّوعُ يَعِدُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّرْجِيحِ بِأَمْرِ مِنَ الْخَارِجِ، وَلِذَلِكَ صُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مُخْتَلِفَةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِبَحْثِ الْمُجْتَهِدِ، وَظَنِّهِ، وَالْعَبْرَةُ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ وَبِهِ يَتِمُّ التَّرْجِيحُ. يَنْظُرُ: كَشَفُ الْأَسْرَارِ لِلْبُخَارِيِّ ١٥٣/٣، نَفَائِسُ الْأَصُولِ ٦٠١/٣، ٦٠٢، مِفْتَاحُ الْوُصُولِ لِلتَّلَمْسَانِيِّ ص ١١٨، شَرْحُ الْكَوْكَبِ الْمُنِيرِ/ ٦٨٥، إِرْشَادُ الْفُحُولِ ص ٤١٢.

(٣) اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْأَمَةِ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، فَذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْأَمَةِ الْخِيَارَ مُطْلَقاً، خِلَافاً لِلْجُمْهُورِ، وَالْخِلَافُ وَقَعَ هُنَا، لِتَعَارُضِ الرَّوَايَاتِ وَتَعَدُّدِ احْتِمَالَاتِ الْعِلَّةِ الْمَوْجِبَةِ لِلْخِيَارِ. فَالْحَنْفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ رَفْعٌ لِلْجَبْرِ مُطْلَقاً، وَالْجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْجَبْرُ عَلَى تَزْوِجِ الْعَبْدِ فَقَطْ، وَخِيَارُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، وَالْحَنْفِيَّةُ: عَلَى أَنَّ خِيَارَهَا فِي الْمَجْلِسِ. يَنْظُرُ: الْأُمُّ ١٧٥/٥، الْمَبْسُوطُ ٩٣، ٩٤، بَدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ٤٤، أَسْهَلُ الْمَدَارِكِ ٣٨٧/١، الْإِتِّصَافُ ١٣١/٨، سَبِيلُ السَّلَامِ لِلصَّنْعَانِيِّ ١٣٠/٣.

(٤) هِيَ: بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَتْ مَوْلَاةً لِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقِيلَ لِبَنِي هَلَالٍ، وَكَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَ سَنَنِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِبْطَالُ كُلِّ شَرْطٍ يَنَافِي الشَّرْعَ،

وَزَوْجُهَا حُرٌّ^(١)، وَيُرْوَى أَنَّهَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ^(٢)، فَلِأَوَّلِ مُثْبِتٌ، وَالثَّانِي نَافٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ رِقَّتَهُ لَمْ تَتَّغَيَّرْ بَعْدُ، وَهَذَا نَفْيٌ لَا يُدْرِكُ عَيْنًا بَلْ بَقَاءً عَلَى مَا كَانَ، فَلِثَبُتِ أَوَّلَى.

(وَإِذَا أَخْبَرَ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ^(٣) فَلِطَهَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ نَفْيًا لَكِنَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمَعْرِفَةَ بِالِدَّلِيلِ، فَيُسْأَلُ فَإِنْ بَيَّنَّ وَجْهَ دَلِيلِهِ كَانَ كَالِإِثْبَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَبَيِّنْ فَالْنَّجَاسَةُ

وخيار العتق، فاختارت نفسها، وأبت أن ترجع لزوجها مغيث، حتى بعد شفاعته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - له عندها، وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية، والقصة في البخاري. ينظر: الإصابة ٨ / ٥٠، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٠٣، أسد الغابة ٧ / ٣٩، صحيح البخاري ٢ / ١٢٩ (حديث رقم ٢٥٣٦).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ١٤٧/١٠ كتاب: اللعان والملاعنة، باب: أن الولاء لمن اعتق، وأبو داود في سننه ١٣٦/٢ كتاب: الطلاق، باب: من قال كان حراً (حديث رقم ٢٣٣٥) و ابن ماجه في سننه ٦٧/١ كتاب: ، باب: خيار الأمة إذا اعتقت (حديث رقم ٢٠٧٤).

(٢) الحديث متفق عليه، صحيح البخاري ٣٩٤/٣ كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تحت العبد (حديث رقم ٥٢٨٠ - ٥٢٨١)، صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٦/١٠ كتاب: اللعان والملاعنة، باب: أن الولاء لمن اعتق.

(٣) قال -شمس الأئمة: الخبران يتعارضان، وهذا النوع هو المشتبه، والترجيح فيه يكون بالأصل، إذا ثبت النفي بالدليل؛ وذلك بناءً على الضابط، الذي قرره الحنفية، ومن وافقهم،

وهو: أن النفي إذا كان مما يحتمل معرفته بالدليل، كان كالإثبات، فيتعارضان، فإذا تبين وجه دليله ترجح النفي وإن كان النفي مبنيًا على العدم الأصلي ترجح الإثبات، كما في مثال الإخبار من عدلين: أحدهما أخبر بنجاسته، والآخر بطهارته، وهذا مبني على أن علماء الحنفية فصلوا في الترجيح بين المثبت والنافي بحسب الدليل الخارجي، فرجحوا رواية ابن عباس النافية لزواجه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ميمونة وهو حلال على ضدها؛ لفقهه، ولكون الإحرام حالا يدرك بالعين، وعلى العكس رجحوا الرواية المثبتة لحرية زوج بريره عندما أعتقت وخيرت. ينظر: أصول السرخسي ٢ / ٢٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ /

أُولَى) هَذَا نَظِيرُ النَّفْيِ الَّذِي يُحْتَمَلُ مَعْرِفَتُهُ بِالِدَّلِيلِ وَتُحْتَمَلُ بِنَاءٌ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَاءِ قَدْ تُدْرَكُ بِظَاهِرِ الْحَالِ، وَقَدْ تُدْرَكُ عَيْنًا بِأَنْ غَسَلَ الْإِنَاءَ بِمَاءِ السَّمَاءِ، أَوْ بِالْمَاءِ الْجَارِي وَمَلَأَهُ بِأَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ أَصْلًا، وَلَمْ يُلَاقِهِ شَيْءٌ نَجِسٌ، فَإِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَالْآخَرُ بِطَهَارَتِهِ، فَإِنْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْحَالِ فَإِخْبَارُ النَّجَاسَةِ أُولَى، وَإِنْ تَمَسَّكَ بِالِدَّلِيلِ كَانَ مِثْلُ الْإِثْبَاتِ، (وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَتَفَرَّعُ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ) ^(١).

(وَأَمَّا فِي الْقِيَاسِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَعْنَاهُ: إِذَا تَعَارَضَ قِيَاسَانِ (فَلَا يُجْعَلُ عَلَى النَّسخِ) ^(٢)، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ ^(٣) فِيمَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ كَالْقِيَاسِ فَيَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ) مِنَ الْقِيَاسَيْنِ، وَكَذَا يَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَالْقِيَاسِ (بَعْدَ شَهَادَةِ قَلْبِهِ) ^(٤)، وَلَا يَسْقُطَانِ بِالتَّعَارُضِ كَمَا يَسْقُطُ النَّصَانِ حَتَّى يَعْمَلَ بَعْدَهُ

(١) الأصل الذي قرره الحنفية في الرواية، قرروه في الشهادة في حال تعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح عند الأكثرية؛ لأنه هو المثبت؛ حيث اشتمل على زيادة علم، لم يطلع عليها المعدل، ولم ينهها، فكان الجرح مؤسس، وهو مقدم على المؤكد، والمختار عند الحنفية: أن النفي مثل الإثبات، إذا كان مستنداً إلى دليل، فيتعارضان، ويلزم الترجيح، وبذلك تنتفي أولوية المثبت. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٢، نفائس الأصول ٣/ ٥٩٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٩٣، إرشاد الفحول ص ١٠٥.

(٢) لأن القياس لا يُنسخُ، ولا يُنسخُ به؛ إذ لا دخل للرأي في معرفة انتهاء أمد الحكم، ولا يُتَصَوَّرُ فيه التقدم والتأخر، كما أن شرط وجوب العمل به: أن لا يظهر له معارض راجح أو مساوٍ. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ١٣.

(٣) هذا مبني على ترتيب الأدلة، وفيه إشارة إلى أنه اعتبر القياس وقول الصحابي في مرتبة واحدة؛ فيعمل بأيهما بشرط النحري، وهناك من قدم قول الصحابي على القياس حيث جعله في الترتيب يلي ضعيف السنة. ينظر: المستصفى ٢/ ٣٩٢، كشف الأسرار للبخاري ٣/ ١٢١، حاشية الأزميري على مرآة الأصول ٢/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥.

(٤) شهادة القلب: فإشارة إلى تحقق لقلب المؤمن، بنور يقع فيه، فيطمئن ويعد ذلك إلهاماً. والأصل أن ذلك ليس بحجة، إلا عند الصوفية، ودليلنا: أن هذه خواطر، ليست لمعصوم،

بِظَاهِرِ الْحَالِ؛ إِذْ فِي الْأَوَّلِ)، أَيْ: فِي تَعَارُضِ النَّصِّينِ (إِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ لِلْجَهْلِ الْمُحْضِ بِالنَّاسِخِ مِنْهُمَا، فَلَا يَصِحُّ عَمَلُهُ بِأَحَدِهِمَا مَعَ الْجَهْلِ وَهُنَا) أَيْ: فِي الْقِيَاسَيْنِ (لَيْسَ)، أَيْ: التَّعَارُضُ (لِجَهْلٍ مُحْضٍ؛ لِأَنَّهُ)، أَيْ: الْمُجْتَهِدُ^(١)، وَهُوَ لَمْ يُذَكَّرْ لَفْظًا بَلْ دَلَالَةً (فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاجْتِهَادَيْنِ مُصِيبٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصِيبًا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَذْلُولِ عَلَى مَا يَأْتِي، فَكُلُّ وَاحِدٍ دَلِيلٌ لَهُ^(٢) فِي حَقِّ الْعَمَلِ).

فلا تسلم من دسائس الشيطان، غير أن اعتبارها حجة هنا؛ لكونها لم تستقل بإثبات حكم، بل هي حجة في الترجيح بين قياسين، كل منهما دليل في حق العمل، وحيث إن الحق عند الله واحد معين، فهو غيب لم نكلف به، فصح اعتبارها بهذا، فإنه لا يجوز له العمل بأحدهما، من غير مرجح، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم لا تسقط بالتعارض ولا يجري فيها النسخ، فهي بمنزلة القياس؛ لأن قوله فيما يدرك بالقياس يكون بناء على الرأي فكأنه بمنزلة القياس. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ١٥، كشف الأسرار للبخاري ٣/ ١٢٤، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٦، جامع الأسرار للكاكي ٣/ ٧٩٢.

(١) سيأتي تعريفه، وشروطه، وحكمه في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.

(٢) أي: كل واحد من هذه الأدلة دليل للمجتهد في حق العمل بالاجتهاد.

(فَصْلٌ: مَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ)

(فَعَلَيْكَ اسْتِخْرَاجُهُ مِنْ مَبَاحِثِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَتْنًا وَسَنَدًا) أَمَّا الْمَتْنُ، فَكَتَرَجِيحِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ^(١)، وَالْمُفَسِّرِ عَلَى النَّصِّ^(٢)،

(١) النص في اللغة: بمعنى الظهور، فهو من: نَصَّ الشيءَ يَنْصُعه نَصًّا إذا رفعه وأظهره، ومنه: نصت الدابة إذا أظهرت سيرها، ونص على الشيء عينه وحدده، ونص الحديث: رفعه وأسنده. ينظر: لسان العرب ٩٧/٧، مادة: نصص، المعجم الوسيط ٢/ ٩٦٣. والنص في الاصطلاح: هو ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم، ويكون بسوق الكلام لهذا المعنى.

ومثاله: قوله الله تعالى: (فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) من الآية رقم ٣ من سورة النساء. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١/ ٧٣، ٧٤، الحدود للباجي ص ٤٢ - ٤٣، التلويح ١/ ٣١١، نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٢٧، ٢٨.

والظاهر في اللغة: الواضح الجلي الذي تبين وجوده، وهو ضد الخفي، تقول: ظهر الحمل إذا تبين وجوده. ينظر: لسان العرب ٥٢٠/٤، مادة: ظهر، مختار الصحاح ص ١٧١. والظاهر في الاصطلاح: ما ظهر المراد منه للسامع، بنفس الصيغة، فهو ما دل على المعنى بالوضع الأصلي، أو العرف مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً.

ومثاله: قوله تعالى بعد ما عدد المحرمات: (وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) من الآية رقم ٢٤ من سورة النساء، فالآية ظاهر في إباحة ما زاد على الأربع، وقد عُوِرِضَ ذلك بقوله تعالى: (فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) من الآية رقم ٣ من سورة النساء، فالآية من قبيل النص على تحريم الزيادة على الأربع، فترجح النص على الظاهر. ينظر: أصول السرخسي ١/ ١٦٣، ١٦٤، كشف الأسرار للبخاري ١/ ٧٢، التلويح ٢/ ٣٠٨.

(٢) المفسر في اللغة: مأخوذ من الفسر والتفسير وهو البيان والكشف والإيضاح. ينظر: لسان العرب ٥٥/٥، مادة: فسر، المصباح المنير ص ٢٨١.

والمفسر في الاصطلاح: هو اسم للمكشوف، الذي يعرف به المراد على وجه لا يبقى معه احتمال التخصيص والتأويل. وقُدِّمَ المفسر على النص عند التعارض بناء على تقديم الأقوى على الأضعف، فالمفسر قد ازداد وضوحاً على النص.

ومثال ذلك: ترجيح قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» أخرجه: أبو داود في سننه ١/ ٨٠ - (حديث رقم ٢٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهر، والترمذي في سننه ١/ ١٨٧ - (حديث رقم ١٢٦)، أبواب: الطهارة، باب: ==

وَالْمُحْكَمَ عَلَى الْمَفْسَرِ^(١)، وَالْحَقِيقَةَ عَلَى الْمَجَازِ^(٢)،

ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وابن ماجه في سننه ٢٠٤ / ١ - (حديث: ٦٢٥) ، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم - على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»، قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا، وإنما في حديث أم سلمة أن امرأة سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتستتفر بثوب، وتتوضأ لكل صلاة - فالأول: نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة؛ لأنه يفهم من لفظه ومقصود من سياقه، والثاني: مفسر لا يحتمل تأويلاً؛ لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد، أو لوقت كل صلاة، ولو أدى في الوقت عدة صلوات، ولكن الثاني قطع هذا الاحتمال، فيرجع، وصار الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت، وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض، والنوافل. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٥١ / ١، التلويح ٢٤١ / ١، فصول البدائع ١٠٢ / ٢، الدراية لابن حجر ٨٩ / ١.

(١) المحكم في اللغة: المتقن الموثق، تقول: أحكم الأمر: امتنع نقضه، واستحكم: صار محكماً، فهو من إحكام البناء، والآيات المحكمات: الممتنع نسخها. ينظر: لسان العرب ١٤٠ / ١٢ مادة: حكم، المصباح المنير ص ٩٠.

وفي الاصطلاح: ما أحكم المراد به، فُعِلِمَ مَعْنَاهُ، وأدرك فحواه، فصار غايةً في الوضوح، فلم يحتمل إلا وجهاً واحداً ولم يقبل التبديل.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ...﴾ سورة الطلاق من الآية (٢) ، وقوله تعالى: ﴿... وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة النور من الآية (٤) ، فإن الأول: مفسر في قبول شهادة العدول؛ لأن الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء وهو لا يحتمل معنى آخر والثاني: محكم؛ لأن التأبيد التحق به، والأول بعمومه يوجب قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، والثاني يوجب رده، فيرجع على المفسر. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٣٤ / ٢، فصول البدائع ١٠٢ / ٢، الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ٩٥ / ٢.

(٢) الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له

وفي الاصطلاح: هي اسم لكل لفظ موضوع في الأصل لشيء معلوم به و مستعمل فيه. وحكمها: وجود ما ثبت بها أمراً كان أو نهياً، وتُقَدَّمُ الحقيقة على المجاز عند التعارض اتفاقاً؛ لأنها الأصل في الكلام عند الإطلاق

المجاز: هو اسم لكل لفظ استعمل لغير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة، وسمي مجازاً؛ لأن

وَالصَّرِيحُ عَلَى الْكِنَايَةِ^(١)،

المُسْتَعْمَلُ له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره.

حكمه: وجود ما استعير له، وثبوته خاصاً كان أو عاماً والمجاز، واقع في لغة العرب، وهناك أمور تفصل الحقيقة عن المجاز، وذلك يقع بالتنصيص أو الاستدلال فيرتبط المجاز دائماً بالقرينة.

مثال ذلك: إذا ورد لفظ الصراط المستقيم مما يستعمل في المعنى الحقيقي الذي هو الطريق المستقيم المحسوس الذي يمر عليه السالكون، ويستعمل في المعنى المجازي الموصل سالكه المقصود، فهل يحمل على المعنى الحقيقي، أو على المعنى المجازي؟ فعند أهل اللغة: لا يوجد تعارض بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛ لأنه إن وجدت قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له فهو مجاز، وإلا فهو حقيقة.

وأما الأصوليون: فلم يشترطوا وجود القرينة المانعة عن المعنى اللغوي، فهم متفقون مع أهل البلاغة في تقديم المعنى الحقيقي متى كان ممكناً، فلو حلف لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل السمك، وإن كان أطلق عليه في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً...﴾ سورة النحل من الآية (١٤)، وبه تمسك الإمام مالك في أنه يحنث بأكل السمك، وعند الحنفية لا يحنث لأجل مأخذ اللفظ، ولأن بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحم، وإمكان الحمل على المعنى الحقيقي، فلا يحمل على المجازي. ينظر: كشف الأسرار للنسفي ١/ ٢٦٨، التلويح ١/ ١٧٧، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦١.

(١) الصريح في اللغة: المكشوف البين، والتصريح ضد التعريض، تقول: صرح بالأمر: بينه وأظهره، ومنه سمي القصر صرحاً؛ لظهوره. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٠٩، مادة: صرح، مختار الصحاح ص ١٥١، المصباح المنير ص ٢٠٢.

وفي الاصطلاح: هو ما يكون مفهوم المعنى بنفسه؛ لظهور المراد منه وانكشافه، حقيقة كان أو مجازاً.

حكمه: ثبوت مَوْجِبِهِ بنفسه، دون افتقار إلى إضمار، ونية، أو تأويل، وهو المحض الخالص فلو قال لزوجته: يا طالق طَلَّقْتُ نَوَى إيقاعه أو لم ينو؛ لكونه صريحاً، وكذا ألفاظ العتاق.

ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١/ ١٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٣.

الكناية خلاف الصريح وهي: ما يكون المراد بها مستور المعنى، ولا يعرف إلا بقرينة تدل على المعنى المراد؛ لأن المعنى لا يفهم منها إلا بذلك؛ لتعددده في نفسه.

وَالْعِبَارَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ^(١)، وَالْإِشَارَةُ عَلَى الدَّلَالَةِ^(٢)،

حكمها: لا تثبت إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، وعند تعارض الصريح والكناية يقدم الصريح؛ لأنه الأصل في الكلام، و موضوع للإفهام. والصريح والكناية مما اختص به أهل البيان، لكن لما اختلف في حقيقة الكناية؛ لدورانها بين الحقيقة والمجاز ذُكرت في علم الأصول لتعرف أحكامها، كالألفاظ التحريم والبيّنونة، فإنها عند الفقهاء من كنايات الطلاق، لأنه كلام يحتمل وجوهاً، لذلك كان المرجع في ذلك إلى النية، وعليها يبنى الحكم وهذا بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة؛ لأن المجاز قبل أن يصير متعارفاً يكون بمنزلة الكناية، ومنه أخذت الكنية بالولد المعروف بالنسب إليه. ينظر: تقويم الأدلة ص ١٢٢ - ١٢٣، أصول السرخسي ١/ ١٨٨ - ١٨٩، كشف الأسرار للبخاري ١/ ١٠٣ - ١٠٤، ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

(١) العبارة في اللغة: هي الكلام المُعَبَّر به عن المراد، يقال: عَبَّرَ عما في نفسه: إذا أفصح عنه بالعبارة بلفظ يدل على ما بداخله، وفلان مُعَبِّر: حسن العبارة والبيان، وَعَبَّرَ الرؤيا يَعْبُرُهَا عَبْرًا وعبارة: فسرّها وأخبر بتأويلها. ينظر: لسان العرب ٤/ ٥٢٩، مادة: عبر، المصباح المنير ص ٢٣٢، المعجم الوسيط ٢/ ٦٠١. والمراد: عبارة النص، سميت بذلك؛ لأن المُسْتَدَلَّ يَغْبِرُ منها إلى المعنى بموجب عين النص، وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام سوقاً أصلياً، ويدخل تحتها كل حكم أثبت بظاهر، أو مفسر، أو خاص، أو عام، أو صريح، أو كناية. ينظر: تقويم الأدلة ص ١٣٠ - أصول السرخسي ١/ ٢٣٦، كشف الأسرار للبخاري ١/ ١٠٦، التلويح ١/ ٣٢٤. إشارة النص: وهي العمل بما لم يسق له الكلام سوقاً أصلياً، وهي دلالة التزامية ثابتة بلازم متأخر ومدارها الفكر والتأمل في معنى اللفظ، وتتفاوت فيها الأفهام، وعند التعارض تُقدّم العبارة على الإشارة؛ لأن دلالتها بنفس النص، وقد قال كل من: شمس الأئمة، وفخر الإسلام البزدوي: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من الصريح، والمشكل من الواضح؛ لذلك قدم حكم القصاص في الدنيا بالنص عليه، على الإشارة المستفادة من جعل جزائه جهنم فحسب في قوله تعالى: (فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ) (من الآية رقم ٩٣ من سورة النساء). ينظر: تقويم الأدلة ص ١٢٧ - ١٣٠، أصول السرخسي ١/ ١٣٦، كشف الأسرار للبخاري ١/ ١٠٨، التلويح ١/ ٣٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، أصول الفقه للبرديسي ٣٧٠.

(٢) الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و الشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول.

وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْإِقْتِضَاءِ^(١)، وَأَمَّا السَّنَدُ^(٢) فَكَتَرَجِيحُ الْمَشْهُورِ

أما دلالة النص: فهي ما ثبت بمعنى النص لغة، لا إجتهاذاً، ولا إستنباطاً، وتسمى بفحوى الخطاب، ولحنه، أى: مقصوده ومعناه، ويسمى بها الإمام الشافعي -رَحْمَةُ اللَّهِ- مفهوم الموافقة؛ لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق بمعناه اللغوي.

حكمها: تعمل عمل النص، إذا كان المعنى معلوماً قطعاً، فتكون الدلالة قطعية، كما في تحريم الضرب لمعنى التأفيف، وأما إن احتمل المعنى لخفائه، تكون دلالة ظنية نظرية، وتقدم دلالة الإشارة على دلالة النص عند التعارض، لذلك منع الحنفية إخراج الكفارة فى القتل العمد، بإشارة قوله تعالى: (فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) فى حين أوجب الشافعى الكفارة بناء على وجوبها فى القتل الخطأ.

ومن العلماء من جعلها ثابتة بالقياس، واعتبروها قياساً جلياً، وقد رجح جمهور العلماء خلاف ذلك. ينظر: البرهان ٢/ ٦١، تقويم الأدلة ص ١٣٢، ١٣٥، أصول السرخسي ١/ ٢٤٢، كشف الأسرار للبخاري ١/ ١١٥، ١١٦، فواتح الرحموت ١/ ٤٠٨، ٤٠٩.

(١) دلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه، أو صحته الشرعية، أو العقلية.

ترجح دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة لترجيحها بقصد المتكلم، وعلى دلالة التنبيه والإيماء، لتوقف صدق المتكلم، أو مدلول منطوقه عليه، بخلاف دلالة التنبيه والإيماء، وذلك لأن المدلول فى دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق، أو الصحة؛ لجمع دلالاته بين الوضع وقصد المتكلم، فيكون أقوى من الإشارة والإيماء؛ لأن الإشارة غير مقصودة بإيراد اللفظ، والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم.

وترجح دلالة الإشارة والإيماء على دلالة مفهوم الموافقة؛ لجواز أن لا يكون المسكوت عنه أولى أو مساوياً.

وترجح دلالة الإشارة والإيماء على دلالة مفهوم المخالفة؛ للاتفاق على دلالة الاقتضاء والخلف فى المخالفة. يراجع: كشف الأسرار للبخاري ٢/ ٢٣٥، التلويح ١/ ٢٦٢، نشر البنود للشنقيطي ٢/ ٢٩٨، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٢.

(٢) السند: هو طريق الإخبار عن ثبوت المتن، لمعرفة مرتبة دلالاته من تواتر، ومشهور، وآحاد، وذلك متصل الإسناد، والترجيح بالسند يرجع إلى أمور أربعة:

١ - الراوي ٢- نفس الرواية ٣- المروي ٤- المروي عنه.

ينظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٢، التلويح ٢/ ٣٠٨، الغيث الهامع ٣/ ٨٣٩.

عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ^(١)، وَالتَّرْجِيحِ بِفَقْهِ الرَّاَوِيِّ^(٢)، وَبِكَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِالرَّوَايَةِ^(٣).
(وَالْقِيَاسِ) عَطْفٌ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَا عُرِفَ عَلَيْهِ نَصًّا صَرِيحًا^(٤) أَوَّلَى مِمَّا
عُرِفَ إِيمَاءً^(٥)،

(١) هذا من باب الترجيح بالرواية، وعلل ذلك شمس الأئمة: بأن المشهور فيه قوة الاتصال بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٥١، التلويح ٢/ ١٠٩.

(٢) هذا من باب الترجيح بالراوي، أي: تقدم رواية الفقيه على من دونه في الفقه؛ لأنه أعرف بما سمع، ولتمييزه بين ما يجوز وما لا يجوز.

مثال ذلك: تقديم رواية السيدة عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أخرجه: البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ١/ ٦٦ - (حديث: ٢٩١) - كتاب: الغسل - باب: إذا التقى الختانان، ومسلم في صحيحه ١/ ٢٧١ - (حديث: ٣٤٨، ٣٤٩) - كتاب: الحيض - باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، فإنها ترجح على رواية أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» أخرجه: مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ١/ ٢٦٩ - (حديث: ٣٤٣) - كتاب: الحيض - باب: إنما الماء من الماء، وسبب الترجيح هو: كون السيدة عائشة أفقه من سيدنا أبي هريرة، وكونها المباشرة.

ينظر: الإحكام للأمدى ٤/ ٢٤٤، البحر المحيط ٨/ ١٧٣، التقرير والتحبير ٣/ ٢٧
(٣) هذا من باب الترجيح بالمروى عنه، فترجح رواية من لم يثبت إنكار لروايته على من ثبت إنكارها، ورواية من عُرِفَ حفظه، وحَسُنَ ضبطه وإتقانه، مقدمة على من ليس كذلك؛ لأنه بذلك يَقْوَى معنى الاتصال. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٥١، ميزان الأصول ص ٧٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٧، الواضح في أصول الفقه ٥/ ٨١.

(٤) المراد بعلية النص الصريح: ما وضع لإفادة التعليل، بحيث لا يحتمل غير العلة، كتعليل الحكم بـ: كي، أو - لأجل كذا، أو بسبب كذا.

واعتبر الإمام أبو حامد الغزالي جريان الترجيح في مثل هذا ضعيف؛ حيث إن دلالته قطعية، فلا تُعَارَضُ بظني، وعدّه إمام الحرمين " في البرهان " : المرتبة العليا، وقدمه على ما بعده على كل حال؛ لأنه قياس في معنى الأصل، وهذا النوع من الترجيح بحسب الدليل الدال على الوصف بالعلية، وفيه ترجيحات عدة. ينظر: البرهان ٢/ ٢٠٥، المستصفى ٢/ ٤٠٠، حاشية الأزميري ٢/ ٣٨٤، معراج المنهاج ٢/ ٢٧٩، إرشاد الفحول ص ٣١٥.

(٥) الإيماء في اللغة: التنبيه والإشارة من ومأ إلى الشيء، وأومأ إليه: أشار، ومنه: أومأ برأسه

وَمَا عُرِفَ إِيمَاءٌ فَبَعْضُهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْبَعْضِ^(١)، ثُمَّ مَا عُرِفَ إِيمَاءٌ أَوْلَىٰ مِمَّا عُرِفَ بِالْمُنَاسِبَةِ^(٢)، وَإَيْضًا مَا عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ تَأْثِيرُ نَوْعِهِ فِي نَوْعِهِ أَوْلَىٰ مِمَّا عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ تَأْثِيرُ الْجِنْسِ فِي النَّوعِ، وَهَذَا أَوْلَىٰ مِنْ عَكْسِهِ^(٣)،

ويده. ينظر: لسان العرب ٢٠١/١، مادة: وما، المصباح المنير ص ٤٠٠.

وفي الاصطلاح: اقتران الوصف بحكم يدل على العلية على وجه لولاه، لُبْعَدَ كلام الشارع عن الفصاحة والفائدة.

وعليه: يعين كون هذا الاقتران لفائدة، فيكون علة، أو جزء علة، أو شرطاً كما في تعليق الحكم على العلة بالفاء، مثل قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) من الآية ٣٨ المائدة، وللإيماء أنواع لمعرفتها ينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٣٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٢٥، نشر البنود ٢/ ١٠٠، ١٠١، إرشاد الفحول ص ٣١٥.

(١) لأن إيماء الدلالة اليقينية راجح على إيماء الدلالة الظنية، وقد اتفق الجمهور على ترجيح ما ظهرت عليته بالإيماء، على ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة، والدوران، والسبب، غير أن جمهور المتكلمين اعتبروا هذه الثلاثة أصلاً للإيماءات، فقدموها عليها؛ لكونها من فروعها، وقد اختلف في تقديم بعضها على بعض. ينظر: البرهان ٢/ ٢٣٠، المحصول ٢/ ٤٧٧، ٤٧٨، معراج المنهاج ٢/ ٢٧٥، ٢٧٦، سلاسل الذهب ص ٣٧١ - ٣٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٦، نهاية السؤل ٣/ ٢٥٤، إرشاد الفحول ص ٤١٦.

(٢) المناسبة، معناها: الملائمة، والمناسب: الملائم لأفعال العقلاء، ويتلقاه العقل بالقبول، وهي عند الأصوليين: وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم على وفقه، حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم.

ويعبر عن المناسبة بالإحالة، وبالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد، كما يسمى استخراجها، تخريج المناط، وللعلماء تفصيلات في هذه المسميات، فالحنفية لا يقولون بالإحالة - مثلاً - والسبب في هذا الخلاف: أن أنواع المناسبة، عليها مدار الشريعة، وهي تتفاوت من حيث العموم والخصوص والخفاء والظهور في إدراك المصلحة.

ينظر: البرهان ٢/ ٢٩، ٣٠، الإحكام للآمدي ٣/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٠٠ - ٣٠١، مفتاح الوصول ص ١٤٩، حاشية البناي ٢/ ٣٧٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٥٢، ١٥٣.

(٣) هذا التقسيم باعتبار شهادة الشرع للمناسب بالملائمة، والتأثير، وعدمهما، وذلك كقياس القتل بالمثل على القتل بالمحدد، بجامع أن كليهما قتل عمد عدوان، فأثرت العلة في عين الحكم، وهذا أولى من عكسه، وعكسه: كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فوصف المشقة جعل جنساً، والإسقاط نوعاً، فالشارع اعتبر المشقة في

وَكُلُّ مِنْهُمَا أَوَّلَى مِنَ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ^(١)، ثُمَّ الْجِنْسُ الْقَرِيبُ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ أَوَّلَى مِنْ غَيْرِ الْقَرِيبِ، ثُمَّ الْمُرَكَّبُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَوَّلَى مِنَ الْمَفْرَدِ^(٢)، وَأَقْسَامُ الْمُرَكَّبَاتِ بَعْضُهَا أَوَّلَى مِنْ بَعْضٍ، وَمَنْ أَتَقَنَّ الْمُبَاحِثُ السَّابِقَةَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

(وَالَّذِي ذَكَرُوا فِي تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ: قُوَّةُ الْأَثَرِ)، أَيُّ: قُوَّةُ التَّأْثِيرِ^(٣) كَمَا مَرَّ فِي الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ^(٤)، وَكَمَا فِي مَسْأَلَةِ طَوْلِ الْحَرَةِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: يَرِقُّ مَاءُوهَ مَعَ غُنْيَةٍ عَنْهُ^(٥)، فَلَا يَجُوزُ^(١) كَالَّذِي نَحْتَهُ حَرَةً وَقُلْنَا:

عين إسقاط الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض.

ينظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٧٥، إرشاد الفحول ص ١٢٢.

(١) لأن المرجحات فيه لا تنحصر؛ لأن مرجعها إلى غلبة الظن، فجنس الوصف يعتبر في جنس الحكم، وذلك كتعليل كون حد الشرب ثمانين جلدة؛ لأنه مظنة القذف، فإيجاب الصحابة - الثمانين لا لكونه شرباً، بل لكون الشرب مظنة القذف. ينظر: التلويح ٢/ ٣١٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٧٥، إرشاد الفحول ص ٣٢٣.

(٢) ذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم العلل البسيطة على المركبة؛ لأن المفرد يوجد بتمامه بخلاف العلة المركبة، كما أن البسيطة يكثر فروعها، ولم يجر فيها الخلاف الذي جرى في المركبة. ينظر: نهاية السؤل ٣/ ٢٤٨، البحر المحيط ٤/ ٤٧٧، معراج المنهاج ٢/ ٢٧٤.

(٣) الأثر، هو: المعنى الذي به صار الوصف حجة، فتظهر قوته عند المقابلة، على وجه لا يمكن إنكاره، وهذا في الأقيسة نظير الخبر المُرَجَّح بما يقوي اتصاله بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والتأثير لغة: إبقاء الأثر في الشيء. ينظر: مختار الصحاح ص ١٣، تاج العروس ١٠/ ١٤. واصطلاحاً: كون الوصف مؤثراً في جنس الحكم دون وصف آخر، فيكون أولي بأن يكون علة من الوصف الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم، ولا في عينه. ينظر: المحصول ٥/ ١٩٩، نفائس الأصول ٧/ ٣٣٢١، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٦٤.

(٤) وذلك في مسألة طهارة سؤر سباع الطير، أو ما يعرف بالقياس الخفي.

(٥) أي: يكون ذريته من الأمة عبيداً، والتعبير بالماء - عما تكون منه الذرية - كثير في الشرع، ومنه قوله تعالى: (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ) (الآية ٢٠ من سورة المرسلات).

هَذَا نِكَاحٌ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَهْرًا يَصْلَحُ لِلْحُرَّةِ وَلِلْأَمَةِ، (وَقَالَ: تَزَوَّجَ مَنْ شِئَتْ، فَيَمْلِكُهُ الْحُرُّ^(٢)، وَهَذَا أَقْوَى أَثَرًا)، أَيُّ: قِيَاسُنَا أَقْوَى تَأْثِيرًا مِنْ قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (إِذْ زِيَادَةُ مَحَلِّ حِلِّ الْعَبْدِ عَلَى حِلِّ الْحُرِّ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ)^(٣) وَتَضْيِيعُ الْمَاءِ بِالْعَزْلِ بِإِذْنِ الْحُرَّةِ يَجُوزُ فَلِلْإِرْقَاقِ دُونَهُ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ تَضْيِيعَ الْأَصْلِ^(٤) وَفِي الثَّانِي تَضْيِيعَ الْوَصْفِ، وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ^(٥) جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْعِلَّةِ، وَكَأَنَّ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكُتَابِيَّةِ، فَإِنَّهُ^(٦) يَقُولُ: الرِّقُّ مِنَ الْمَوَانِعِ، وَكَذَا الْكُفْرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا يَصِيرُ كَالْكَفْرِ^(٧) بِلَا تَكَاثُفٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ^(٨)

(١) وبهذا قال المالكية، والحنابلة أيضاً، واشتروطوا لحل الأمة:

أ - عدم طول الحرة، بالعجز عن صداقتها، والنفقة عليها.

ب - خوف العنت، وهو الزنا، فالضرورة هي التي أباحت نكاحها، فلم يثبت حلها في مواطن اللذة والتشهوي. ينظر: الأم ٥/ ١٣، بداية المجتهد ٢/ ٣٥، روضة الطالبين ٥/ ٤٦٦، اسهل المدارك ١/ ٢٨٠، الإنصاف ٨/ ١٠٣.

(٢) هذا قول الحنفية، فنكاح الأمة جائز للحر، غير أنه خلاف الأولى عندهم؛ لأن نكاحها ليس بدلاً، ولا لضرورة، وهي محللة بملك اليمين فتحل بالنكاح، كما أن المانع من نكاحها هو عين وجود الحرة ولو كانت صغيرة.

والراجح: هو قول الجمهور؛ لأن فيه بعداً عن معنى الرق، الذي عمل الإسلام على تخليص البشرية منه. ينظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠٢، ١٠٣، البناية على الهداية للعيني ٤/ ٨٣، الاختيار ٣/ ١٠٠.

(٣) هذا هو الوجه الأول في كون قياس الحنفية أقوى أثراً من قياس الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٤) هذا هو الوجه الثاني في كون قياس الحنفية أقوى أثراً من قياس الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٥) السُّرِّيَّةُ: جمع سَرَارِي، وهي: فعيلة من السر؛ وذلك للإسرار بوطء الجارية المملوكة، واخفائه عن زوجته غالباً، وقيل: هي مفعولة من السرور؛ لأن بها يحصل سرور الرجل، تقول: استسر الرجل جاريته اتخذها سرية. ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٥٨، مادة: سرر، مختار الصحاح ص ١٢٤، المصباح المنير ص ١٦٥.

(٦) الضمير يعود على الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٧) كما في النكاح من المجوسية.

(٨) حكم نكاح الأمة الكتابية: قال المالكية والشافعية - وهو الصحيح عند الحنابلة - بعدم

وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَرْتَفِعُ بِإِحْلَالِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، قُلْنَا: هُوَ نِكَاحٌ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، فَكَذَا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ عَلَى مَا مَرَّ.

وَيْضًا هُوَ دِينَ يَصِحُّ مَعَهُ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْحُرَّةِ (فَكَذَا يَصِحُّ لِلْحُرِّ نِكَاحُ الْأَمَةِ)، أَي: دِينَ الْكِتَابِيِّ دِينَ يَصِحُّ مَعَهُ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَى هَذَا الدِّينِ فَكَذَا يَصِحُّ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى هَذَا الدِّينِ (فَهَذَا أَقْوَى أَثَرًا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنْصَفٌ لَا مُحَرَّمٌ) كَمَا فِي الطَّلَاقِ^(١)، وَالْعِدَّةِ^(٢)، وَالْقَسَمِ^(٣)،

حَلْ نِكَاحِهَا، وَاشْتَرَطُوا لِحُلِّ نِكَاحِ الْأَمَةِ: أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي مُحَصِّنَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَذَلِكَ عَمَلًا بِمَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ الْحَنْفِيَّةُ، الَّذِينَ أَخَذُوا بِتَسْوِيَةِ الشَّرْعِ بَيْنَ حُكْمِ النِّكَاحِ وَالذَّبِيحَةِ، فَقَدْ حَلَّتْ دُونَ تَفْرِقَةٍ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، وَالْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ. يَنْظُرُ: الْأَمُّ ٥/ ٧، ٨، ٢٢٦، الْمَبْسُوطُ ٥/ ١٠٤، ١٠٥، رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٥/ ٤٦٩، أَسْهَلُ الْمَدَارِكِ ١/ ٣٨١، الْإِنْصَافُ ٨/ ١٠٣.

(١) الطَّلَاقُ فِي حَقِّ الرِّقِّ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي حَقِّ الرِّقِّ ثَنَانٌ، تَحْصُلُ بِهِمَا الْبَيِّنَةُ الْكُبْرَى، وَحُكِيَ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعٌ خَالَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَاخْتَلَفُوا، أَي: الْفُقَهَاءُ هَلِ الْمَعْتَبَرُ رِقُّ الزَّوْجِ أَوْ رِقُّ الزَّوْجَةِ، فَقَالَ الْحَنْفِيَّةُ: الْعَبْرَةُ بِحَالِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَهُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمَطْلُوقَةِ، كَالْعِدَّةِ.

وَذَهَبَ الْإِمَامَانِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ الْعَبْرَةَ بِحَالِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا، فَيُعْتَبَرُ بِهِ. يَنْظُرُ: الْأَمُّ ٥/ ٣٧٢، الْمَبْسُوطُ ٦/ ٤٥، بَدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ٢/ ٥١، ٥٢، رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦/ ٦٦، أَسْهَلُ الْمَدَارِكِ ٢/ ٣، الْإِنْصَافُ ٩/ ٥.

(٢) عِدَّةُ الْأَمَةِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِيمَا لَهُ نِصْفٌ، فَذَاتُ الْحَيْضِ تَعْتَدُ بِقَرَيْنِ، وَالْمَتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسٌ، وَالْحَامِلُ عِدَّتُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ كَالْحُرَّةِ.

وَالْمُعْتَدَةُ بِالشَّهْرِ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَالْإِمَامُ مَالِكٌ قَالَ: تَعْتَدُ بِالشَّهْرِ الثَّلَاثَةَ كَالْحُرَّةِ، مُخَالَفًا بِذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: تَعْتَدُ بِشَهْرَيْنِ، وَقِيلَ: بِثَلَاثٍ وَقِيلَ: بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ كَمَا قَالَ الْحَنْفِيَّةُ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَصْلِ التَّنْصِيفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَعَلِيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ) مِنَ الْآيَةِ ٢٥ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ. يَنْظُرُ: الْمَبْسُوطُ ٦/ ٣٧، ٤٥، بَدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ٢/ ٧٧، رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦/ ٣٤٣، أَسْهَلُ الْمَدَارِكِ ٢/ ٣٢، ٣٦، الْإِنْصَافُ ٩/ ٢٠٤، ٢٠٧.

(٣) أَي: الْقِسْمُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي عِدَّةِ الْأَيَّامِ، وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ لِلْأَمَةِ، وَالْمَكَاتِبَةَ،

وَالْحُدُودِ^(١)؛ لِأَنَّ الرِّقِيقَ لَهُ شَبَهُ بِالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ بِوَاسِطَةِ الْكُفْرِ، فَمِنْ هَذَا الشَّبهِ قُلْنَا: إِنَّهُ مَالٌ، ثُمَّ لَهُ شَبَهُ بِالْحَرِّ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ، فَأَوْجَبَ هَذَانِ الشَّبَهَانِ التَّنْصِيفَ فِي اسْتِحْقَاقِ النِّعَمِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالْإِنْسَانِ.

(فَطَرَفُ الرِّجَالِ يَقْبَلُ الْعَدَدَ بِأَنْ يَحِلَّ لِلْحُرِّ أَرْبَعٌ وَلِلْعَبْدِ ثِنْتَانِ، لَا طَرَفُ النِّسَاءِ فَيَنْتَصِفُ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ فَتَحِلُّ الْأُמَّةُ مُقَدِّمَةً عَلَى الْحُرَّةِ لَا مُؤَخَّرَةً، فَأَمَّا فِي الْمُقَارَنَةِ فَقَدْ غَلَبَتْ الْحُرْمَةُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْقُرْءِ)، أَيُّ: لَمَّا كَانَ الرِّقُّ مُنْصَفًا وَطَرَفُ الرِّجَالِ يَقْبَلُ التَّنْصِيفَ بِالْعَدَدِ فِي حِلِّ النِّكَاحِ بِأَنْ يَحِلَّ لِلْعَبْدِ ثِنْتَانِ وَلِلْحُرِّ أَرْبَعٌ، أَمَّا طَرَفُ النِّسَاءِ، فَلَا يَقْبَلُ التَّنْصِيفَ بِالْعَدَدِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا زَوْجٌ وَاحِدٌ، فَلَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُ الزَّوْجِ الْوَاحِدِ، فَاعْتَبَرْنَا التَّنْصِيفَ بِالْأَحْوَالِ^(٢) بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى

والمدبرة، وأم الولد عند تزوج الحرة عليها أن يكون للحرة يومان، وللأمة يوم واحد؛ لأن حق الأمة على النصف من حق الحرة. ينظر: المبسوط ٥/ ٢٠٥، الإنصاف ٨/ ٢٦٩.

(١) أي: الحدود بالنسبة للرقيق: اتفق العلماء على أنه لا رجم على الرقيق؛ لأن الرجم لا ينصف، والجلد ينصف، ولا تغريب عليهم في الراجح؛ لأن في ذلك تضييعاً لحق السيد، واتفقوا على أن الأمة المحصنة، تجلد خمسون جلدة إن زنت، وكذلك العبد قياساً على النص الوارد في الأمة، وخالف في ذلك أهل الظاهر، فأوجبوا جلده مائة، كما اتفقوا على أن حده في السرقة القطع كالحُرِّ، وأما حد القذف فيجلد ثمانون جلدة عند الظاهرية وبعض الصحابة والتابعين كابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز، والجمهور على أنه يجلد أربعون جلدة، وحد الشُّرب أربعون.

وعند الإمام الشافعي يجلد عشرون، وعند من اعتبره ثمانين جلدة، يُجلد أربعون، وهذا التنصيف مبني على فقدان نعمة الحرية، فيرجح ما فيه موافقة لهذا الاعتبار.

ينظر: الأم ٦/ ٢٠٠، ٢٢٣، المبسوط ٩/ ٤٦، بداية المجتهد ٢/ ٣٦٥.

(٢) هذه الأحوال قد ظهر فيها أثر التنصيف، مما يدل على أنه وصف قوي التأثير، حيث حلت الأمة في حال الانفراد دون الانضمام، وهذا أمر بَيِّنٌ بالنظر إلى الأصول، ليظهر بذلك شرف الحرية الذي ظهر في طرف الرجال في العدد، وفي طرف النساء، بالأحوال؛ لأنها تتعدد. ينظر: تقويم الأدلة ص٣٤٢، أصول السرخسي ٢/ ٢٥٥ -

الْحُرَّةُ يَصِحُّ نِكَاحُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً لَا يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً^(١) لَا يَصِحُّ أَيْضًا، تَغْلِيْبًا لِلْحُرْمَةِ، كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقْرَاءِ^(٢)، فَتُبِتَ بِهَذَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يَصِحُّ لِلْحُرَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِلْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَأَخِّرَةً عَنِ الْحُرَّةِ، أَوْ مُقَارِنَةً لَهَا، فَيَصِحُّ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْحُرَّةِ.

وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي الطَّلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ^(٣) فَإِنْ كَوَّنَ طَلَاقِ الْأُمَةِ اثْنَيْنِ لَيْسَ تَغْلِيْبُ الْحُرْمَةِ بَلْ تَغْلِيْبُ الْحِلِّ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِلطَّلَقَيْنِ عَلِيًّا، فَإِنَّ الْحِلَّ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ مَالِكًا لِلطَّلَاقِ الْوَاحِدَةِ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: وَكَمَا فِي نِكَاحِ الْأُمَةِ الْكِتَابِيَّةِ قَوْلُهُ: (وَكَأَيُّ مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّ الْمَسْحَ فِي التَّخْفِيفِ^(٤) أَقْوَى أَثَرًا مِنْ الرُّكْنِ فِي التَّثْلِيثِ^(٥)). وَالثَّانِي: قُوَّةُ ثَبَاتِهِ عَلَى الْحُكْمِ، وَالْمَرَادُ مِنْهُ: كَثَرَةُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ هَذَا الْوَصْفَ فِي هَذَا الْحُكْمِ، كَالْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفِ فِي كُلِّ تَطْهِيرٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ، كَالْتِمِمْ، وَمَسْحِ الْخُفِّ، وَالْجَبِيْرَةِ، وَالْجَوْرِبِ، بِخِلَافِ الرُّكْنِ فَإِنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تُوجِبُ التَّكَرَّارَ كَمَا فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، بَلْ الْإِكْمَالُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ)، أَيُّ: بِالْإِكْمَالِ، وَهُوَ الْإِسْتِيعَابُ.

(١) أي: في حال المقارنة، وهو: الجمع بين الحرة والأمة في عقد النكاح.

(٢) لأن طلاق الأمة شتان، وعدتها حيضتان. كما علمت في حكم الخاص.

(٣) هذا اعتراض من المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - على قياس نكاح الأمة الكتابية على الطلاق.

(٤) المراد بالتخفيف: المعنى الذي ظهر بالرجوع إلى الأصول، حيث وجد الاكتفاء بالإصابة مع إمكان الإساءة، لا سيما الاكتفاء بمسح بعض الرأس وعليه فالتخفيف أصبح وصفاً موضوعاً للفرقة بين جنس الغسل والمسح، فأثر في الحكم بنفسه. ينظر: أصول السرخسي ٢٥٨ / ٢، كشف الأسرار للنسفي ٣٧٤ / ٢.

(٥) استحباب تكرار مسح الرأس ذهب إليه الإمام الشافعي؛ بناء على أن المسح ركن، فيسن تثليثه بمياه مختلفة اعتباراً بالمغسول، وذهب الفقهاء إلى عدم استحباب ذلك بل يستوعب رأسه بالمسح مرة واحدة، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستحب الذهاب بالمسح، ورده لمن له شعر يرد. ينظر: الأم ٦٥ / ١، بداية المجتهد ١٠ / ١، روضة الطالبين ١٧٠ / ١، الهداية ٨ / ١، أسهل المدارك ٥٦ / ١، الإنصاف ١٢٢ / ١.

(وَقَوْلُنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ: إِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ، فَلَا يَجِبُ التَّعْيِينُ، وَهَذَا الْوَصْفُ اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ فِي الْوَدَائِعِ^(١)، وَالْمَغْضُوبِ، وَرَدَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا^(٢) وَالْأَيْمَانَ وَنَحْوَهَا^(٣) فَإِنَّ رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَالْمَغْضُوبِ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يَعَيَّنَ أَنَّ هَذَا الرَّدَّ رَدُّ الْوَدِيعَةِ وَالْمَغْضُوبِ، وَكَذَا لَا يَجِبُ التَّعْيِينُ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَكَذَا فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ الْبَرَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ أَنَّهُ فَعَلَهُ لِأَجْلِ الْبَرِّ.

(وَكَمَنَافِعِ الْغَضَبِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: مَا يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ تَحْقِيقًا لِلْجَبْرِ بِالْمِثْلِ تَقْرِيبًا^(٤) وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، فَهُوَ عَلَى الْمُتَعَدِّي)، أَيْ: إِنْ كَانَ الْمِثْلُ التَّقْرِيبِيُّ، وَهُوَ الضَّمَانُ مُمَثِّلًا فِي الْحَقِيقَةِ لِتِلْكَ الْمَنَافِعِ، فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَثِّلًا فِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُ الْمِثْلُ التَّقْرِيبِيُّ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَافِعِ، لِأَنَّ الْأَعْيَانَ الْبَاقِيَةَ خَيْرٌ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْغَيْرِ بَاقِيَةٍ، وَهَذَا الْفَضْلُ عَلَى الْمُتَعَدِّي أَوْلَى مِنْ إِهْدَارِ حَقِّ الْمَظْلُومِ

(١) الوديعه في الشرع: توكيل في حفظ مملوك محترم قصداً على سبيل الأمانة.

وأركانها: الحفظ، العاقدان، الصيغة، ولكل ضوابط وقد اتفق العلماء على أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي إلا ما حكى عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه جعلها كالعارية. ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٢٦١، روضة الطالبين ٥/ ٢٨٦، الاختيار ٣/ ٢٧ - ٢٨، أسهل المدارك ٢/ ١٧٦.

(٢) الرد في هذه الأمور الثلاثة، يكون بأي طريق يوصل إلى إيقاع الحق في الجهة المُسْتَحِقَّة؛ وذلك لتعيين المحل، لا لأجل الوديعه أو الغصب، بل لأن سقوط التعيين لازم لوصف التعيين، ولو كان ديناً، لكان التعيين فيه شرطاً. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٥٩، كشف الأسرار للنسفي ٢/ ٣٧٥، كشف الأسرار للبخاري ٤/ ١٣٢.

(٣) كالتصدق بالنصاب على الفقير دون نية الزكاة، وإطلاق النية في الحج، فإنها أمور تعينت، فكان شرطها هو وجودها. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٤/ ١٣٣.

(٤) لأن المنفعة مال كالعين، والتفاوت الحاصل بالعينية ولعرضية مجبور بكثرة الأجزاء في جانب المنفعة؛ لظهور أن منفعة شهر واحد أكثر أجزاء من درهم واحد فاستويا قيمة وبقي التفاوت فيما وراء القيمة بمنزلة التفاوت في الحنطة من حيث الحبات واللون، وهذا بمعنى المثل تقريبا. ينظر: الوجيزة النافعة ص ٥١٨.

اللَّازِمُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُوبِ الضَّمَانِ^(١)، (وَلِأَنَّ إِهْدَارَ الْوَصْفِ أَسْهَلُ مِنْ إِهْدَارِ الْأَصْلِ) يَعْنِي إِنْ أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إِهْدَارُ كَوْنِ الْمُثَالَةِ تَامَةً، وَإِنْ لَمْ نَوْجِبِ الضَّمَانَ يَلْزَمُ إِهْدَارُ حَقِّ الْمَغْضُوبِ مِنْهُ فِي الْمِثْلِ بِالْكُلِّيَّةِ فِي الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ فَالْأَوَّلُ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا.

(قُلْنَا: التَّقْيِيدُ بِالْمِثْلِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ بَابٍ، كَالْأَمْوَالِ كُلِّهَا، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا، وَوَضْعُ الضَّمَانِ عَنِ الْمَغْضُومِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ)، أَيُّ، عَدَمُ إِجْبَابِ الضَّمَانِ فِي إِتْلَافِ الْمَالِ الْمَغْضُومِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ (كَإِتْلَافِ الْعَادِلِ مَالَ الْبَاغِي وَالْحَرَبِيِّ مَالَ الْمُسْلِمِ وَالْفَضْلُ عَلَى الْمُتَعَدِّي غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَصْلًا)^(٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٣)، (وَيَلْزَمُ مِنْهُ)، أَيُّ: مِنْ إِجْبَابِ الْفَضْلِ عَلَى الْمُتَعَدِّي (نِسْبَةُ الْجَوْرِ ابْتِدَاءً إِلَى صَاحِبِ الشَّرْعِ) الْمُرَادُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ: أَنَّ يَكُونَ بِلَا وَاسِطَةٍ فَعَلِ الْعَبْدُ، وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنِ إِجْبَابِ الْقِيَمَةِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ قِيَمَةٌ عَدْلٍ^(٤)، وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفَاوُتُ إِنَّمَا يَقَعُ لِعَجْزِنَا عَنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ

(١) الغاصب يضمن الشيء المتولد، كالولد مع الأم، لاتفاقهما في النوع والصورة، وعامة أهل العلم يثبتون الضمان - أيضاً - في المتولد على غير صورته، كالثمر، ولبن الماشية، ووقع الخلاف في غير المتولد، وهي المنافع، كالأكرية فقال الشافعية والحنابلة: يضمنها سواء أكرى، أو انتفع، أو عطل، وروى أن للإمام أحمد رواية بالتوقف، وذهب الحنفية إلى: أن المنافع ليست مضمونة؛ لأنها زوائد تحدث من العين شيئاً فشيئاً، فلم تأخذ صفة المالية للتقويم بالمثلية.

والراجح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه، وذلك لما فيه من حفظ الحقوق، وردع المعتدي؛ حيث إن الاعتداء يستوجب التشديد. ينظر: الأم ٣ / ٣٧١، المبسوط ١١ / ٨٤، بداية المجتهد ٢ / ٢٦٩، روضة الطالبين ٤ / ١٠٢، ١٠٣، الإنصاف ٦ / ١٤٨، ١٤٩.

(٢) أي: إيجاب الفضل على المعتدي غير مشروع؛ لأننا لم نجد تعدياً أوجب زيادة على المثل بعذر من الأعذار في الدنيا والآخرة. ينظر: الوجزة النافعة ص ٥١٨.

(٣) من الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.

(٤) العدل: التسوية، تقول: عادلته هذا بذاك إذا قومته به وسويته، ومنه: عدل الموازين

الوَاجِبُ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ جَوْرٌ، فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَبْدِ، أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فِي التَّفَاوُتِ فِي نَفْسِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْمُتَقَوِّمَ لَا يُمَاطِلُ الْمُنْفَعَةَ، فَلَوْ وَجَبَ يَكُونُ التَّفَاوُتُ مُضَافًا إِلَى الشَّارِعِ وَذَا لَا يَجُوزُ.

(أَمَّا عَدَمُ الضَّمَانِ فَمُضَافٌ إِلَى عَجْزِنَا عَنْ الدَّرَكِ)، أَيُّ: إِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الضَّمَانِ فَإِنَّمَا نَقُولُ بِهِ لِعَجْزِنَا عَنْ دَرَكِ الْمِثْلِ، فَإِنْ وَقَعَ جَوْرٌ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْنَا لَا إِلَى الشَّارِعِ فَهَذَا أَوَّلَى، ثُمَّ أَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ: وَلِأَنَّ إِهْدَارَ الْوَصْفِ أَسْهَلُ إِنْخِ بِقَوْلِهِ: (وَلِأَنَّ الْوَصْفَ وَإِنْ قَلَّ فَائَتْ أَصْلًا بِلَا بَدَلٍ، وَالْأَصْلُ وَإِنْ عَظُمَ فَائَتْ إِلَى ضَمَانٍ فِي دَارِ الْجَزَاءِ، فَكَانَ هَذَا تَأْخِيرًا وَالْأَوَّلُ إِبْطَالًا) وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْوَصْفَ، وَهُوَ كَوْنُ الْمُمَاطِلَةِ تَامَةً يَفُوتُ عَلَى تَقْدِيرِ وَجُوبِ الضَّمَانِ بِلَا بَدَلٍ، وَالْأَصْلُ وَهُوَ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي الْمِثْلِ يَفُوتُ إِلَى بَدَلٍ يَصِلُ إِلَيْهِ فِي دَارِ الْجَزَاءِ، فَهَذَا الْقَوْتُ تَأْخِيرٌ وَالْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْتُ الْوَصْفِ إِبْطَالٌ فَالتَّأْخِيرُ أَوَّلَى.

(وَضَمَانُ الْعَقْدِ قَدْ يَثْبُتُ بِالتَّرَاضِي مَعَ عَدَمِ الْمُمَاطِلَةِ) جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ قَوْلُهُ: مَا يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، فَلَا مِثْلَةَ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: كَالْمَسْحِ فِي التَّخْفِيفِ، وَكَقَوْلِنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَكَمَنَافِعِ الْغَضَبِ، أَوْرَدْنَاهَا لِتَرْجِيحِ الْقِيَاسِ عَلَى الْقِيَاسِ بِكَثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْوَصْفَ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فِقِيَاسُنَا، وَهُوَ قَوْلُنَا: مَسَحَ فَلَا يُسَنُّ ثَلَاثَتُهُ رَاجِحٌ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ قَوْلُهُ: رُكْنٌ فَيُسَنُّ ثَلَاثَتُهُ؛ لِكَثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْمَسْحَ

في التَّخْفِيفِ^(١).

وَأَمَّا الثَّانِي: فَقِيَاسُنَا، وَهُوَ قَوْلُنَا صَوْمُ رَمَضَانَ مُتَعِينَ، فَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُتَعِينَاتِ رَاجِحٌ عَلَى قِيَاسِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمٌ فَرَضٌ فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ كَالْقَضَاءِ؛ لِكَثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ التَّعِينَ فِي سُقُوطِ التَّعْيِينِ^(٢).

وَأَمَّا الثَّلَاثُ: فَقِيَاسُنَا، وَهُوَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمِثْلِ وَاجِبٌ فِي غَضَبِ الْمَنَافِعِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُدَوَانَاتِ لَكِنَّ رِعَايَةَ الْمِثْلِ غَيْرُ مُمَكِّنٍ فِي الْمَنَافِعِ، فَلَا يَجِبُ رَاجِحٌ عَلَى قِيَاسِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: مَا يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ إِخْلَافٌ؛ لِكَثْرَةِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْمُمَاطِلَةَ فِي جَمِيعِ صُورِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا وَجَمِيعِ الْعُدَوَانَاتِ^(٣).

(١) سبب الرجحان: أن الركنية وصف لم يظهر ثباته على الحكم، فلم يؤثر في التكرار، بل لا تختص به، فهناك ما ليس بركن ويتكرر، كالمضمضة، والإستنشاق، وإنما تأثير الركنية يتمثل في تحقيقه، وتحصيله، وإكماله. ينظر: أصول السرخسي ٢ / ٢٥٩، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ٣٧٤، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣١، حاشية الفنري على التلويح ٣ / ٥٥.

(٢) اعتبر الحنفية التعيين وصفا قويا ثابتا في إسقاط اشتراط نية التعيين في صوم رمضان؛ لأن وصف الفرضية لا يقتضي إلا الامتثال والإتيان بالمفروض، وتعيين الفرض بوقت مخصوص، يقوم مقامه، فيكفي فيه اعتقاد فرضه، كما في الوضوء، فإنه يكفي فيه اعتقاد رفع الحدث، مع القول باستحباب النية، وأما الإمامان الشافعي وأحمد فالعتمد عندهما وصف الفرضية، فاشتراطا تعيين النية في كل صوم واجب مفروض، وتجديد النية لكل يوم كالصلوات. ينظر: أصول السرخسي ٢ / ٢٥٩، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ٣٧٥، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣٢.

(٣) أجاب الإمام في البرهان: بأن اعتداء اليد الغاصبة منع الحق عن مستحقه؛ فصار الضياع الذي وقع يشبه الإلتلاف، فوجب الضمان، وقال التفتازاني في تلويحه: " لا ريب أن المنفعة لها قيمة ظاهرة مقدرة، فإذا كانت المنفعة تساوي درهما، وجب أن يكون الخلاف فيما وراء القيمة " وهذه المسألة متعلقة بضمان غلة المغصوب. ينظر: البرهان ٢ / ١١٤، التلويح ٢ / ٣١٥، ٣١٦.

(وَالثَّلَاثُ: كَثَرَةُ الْأُصُولِ^(١)، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الثَّانِي^(٢). وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الْعَكْسُ، أَيُّ: الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ)، أَيُّ: عَدَمُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ (كَقَوْلِنَا مَسْحُ)، أَيُّ: مَسْحُ الرَّأْسِ مَسْحُ (فَلَا يُسْنُ تَكَرَّارَهُ) كَمَسْحِ الْخُفِّ (فَإِنَّهُ يَنْعَكِسُ) فَإِنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ بِمَسْحٍ فَإِنَّهُ يُسْنُ تَكَرَّارَهُ.

(بِخِلَافِ قَوْلِهِ: رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الْمَضْمَنَةَ مُتَكَرِّرَةً وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ)، أَيُّ: مَسْحُ الرَّأْسِ رُكْنٌ، وَكُلُّ مَا هُوَ رُكْنٌ يُسْنُ تَكَرَّارُهُ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ؛ لِأَنَّ عَكْسَهُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ لَا يُسْنُ تَكَرَّارُهُ، وَهَذَا غَيْرُ صَادِقٍ؛ لِأَنَّ الْمَضْمَنَةَ وَالِاسْتِنشَاقَ لَيْسَ بِرُكْنَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ يُسْنُ تَكَرَّرُهُمَا.

وَأَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ عَدَمَ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ عَكْسًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَكْسِ مَا هُوَ مُتَعَارِفٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَهُوَ جَعْلُ الْمَحْكُومِ بِهِ مُحْكُومًا عَلَيْهِ مَعَ رِعَايَةِ الْكُلِّيَّةِ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ كُلِّيًّا^(٣).

(١) الترجيح بكثرة الأصول: وهو أن يشهد لأحد الوصفين أصلاً أو أصول فيرجح على الوصف الذي لم يشهد له إلا أصل واحد، مثل وصف المسح في مسألة التثليث، فإنه لما شهد لصحة التيمم، ومسح الخف، ومسح الجبرة، وغيرها، ولم يشهد لصحة وصف الخصم - وهو الركنية - إلا الغسل ترجح عليه؛ وذلك لأن كثرة الأصول توجب زيادة توكيد، ولزوم الحكم بذلك الوصف، فيحدث فيه قوة مرجحة كما يحصل للخبر بكثرة الرواة قوة، وزيادة اتصال فيصير مشهوراً مع أن الحجة هو الخبر لا كثرة الرواة. ينظر: التلويح ٢/ ٢٢٦، أصول السرخسي ٢/ ٢٥٩، كشف الأسرار للبخاري ٤/ ٩٥، الوجيزة النافعة ٥٢٠.

(٢) الثلاثة راجعة إلى قوة التأثير، لكن شدة الأثر بالنظر إلى الوصف، وقوة الثبات بالنظر إلى الحكم، وكثرة الأصول بالنظر إلى الأصل، فلا اختلاف إلا بحسب الاعتبار.

ينظر: التلويح ٢/ ٢٢٦، أصول السرخسي ٢/ ٢٦١، التقرير والتحبير ٣/ ٢٣٥.

(٣) قال الطوفي: فإن لم يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة؛ لأن المشترك بينهما في شرط الصحة هو الاطراد وهو موجود، والانعكاس غير مشروط، فوجوده كالعدم.

كما يُقال: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ، وَلَا يَنْعَكُسُ، أَي: لَا يَصْدُقُ كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَعَدَمُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ صُورِ عَدَمِ الْوَصْفِ لَا زِمٌ لِهَذَا الْعَكْسِ فَسَمَاهُ عَكْسًا لِهَذَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَا زِمٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ، وَهُوَ قَوْلُنَا كُلُّمَا وَجَدَ الْوَصْفُ وَجَدَ الْحُكْمُ وَعَكْسُهُ كُلُّمَا وَجَدَ الْحُكْمُ وَجَدَ الْوَصْفُ، وَمِنْ لَوَازِمِ هَذَا كُلُّمَا لَمْ يُوْجَدْ الْوَصْفُ لَمْ يُوْجَدْ هَذَا الْحُكْمُ فَسَمِيَّ هَذَا عَكْسًا^(١).

(وَقَوْلُنَا فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ: مَبِيعٌ عَيْنٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ)، أَي: كُلُّ مَبِيعٍ مُتَعَيِّنٌ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمَبِيعَاتِ الْمُعَيَّنَةِ.

(وَيَنْعَكُسُ بَدَلُ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ) فَإِنَّ كُلَّ مَبِيعٍ غَيْرِ مُتَعَيِّنٍ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ، كَمَا فِي الصَّرْفِ^(٢)

مثال ذلك: قياس الشافعية النبذ على الخمر بجامع كونهما فيه شدة مسكرة، فإن الشدة وصف يناسب التحريم؛ لأنه يفضي إلى الاستجراء على محارم الله، والاستهانة بأمره إلا أنه لا ينعكس؛ لأن عدم الشدة لا يشعر بالتحليل، وقياسه عليها بجامع الإسكار، فإنه يؤدي إلى إزالة العقل، والعقل مدار التكليف وجوداً وعدمًا، فهذا أولى. ينظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٧١٩، أصول السرخسي ٢ / ٢٦٣، شرح العضد ٣ / ٦٧٣، الوجيز في أصول الفقه للكرامستي ص ٢١٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٧٢٢.

(١) لأنه يقع به الترجيح إذا تعلق الحكم بوصف، ثم عُدَّ عند عدمه؛ حيث دار معه وجوداً وعدمًا، وحجتيه ثابتة عند جمهور الأصوليين على صحة المنعكس المطرد، وقد نقل الإمام الرازي في "المحصول" إجماع عامة الأصوليين على صحة المنعكس المطرد؛ لأنها بذلك أشبهت العلل العقلية، ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، وبعض المتأخرين، من اعتبار حجية قياس العكس، لأن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم ولا يتعلق به حكم. ينظر: المحصول ٢ / ٤٧٨، غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص ١٢٨، ١٢٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣٧، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢١٩.

(٢) الصرف في اللغة: اسم لنوع من أنواع البيع. ينظر: لسان العرب ٩ / ١٩٠ مادة: صرف، مختار الصحاح ص ١٥٢، المعجم الوسيط ١ / ٥٣٣.

و الصرف في الشرع: هو بيع الأثمان ومبادلتها بعضها ببعض. ينظر: المبسوط ١٤ / ٣،

وَالسَّلَامُ^(١) (فَإِنَّهُ أَوَّلَى مِنْ قَوْلِهِ: كُلُّ مَنْهَا مَالٌ لَوْ قُبِلَ بِجِنْسِهِ حَرَمَ رَبَا الْفَضْلِ)، أَيْ: كُلُّ مَنْ الطَّعَامَيْنِ مَالٌ لَوْ قُبِلَ بِجِنْسِهِ حَرَمَ رَبَا الْفَضْلِ، فَكُلُّ مَالٍ لَوْ قُبِلَ بِجِنْسِهِ حَرَمَ رَبَا الْفَضْلِ، فَإِنَّهُ يَشْتَرُطُ التَّقَابُضُ فِيهِ (فَإِنَّهُ لَا يَنْعَكِسُ لِاشْتِرَاطِ قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَامِ فِي غَيْرِ الرَّبْوِيِّ) وَذَلِكَ لِأَنَّ عَكْسَ الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ قَوْلُنَا: كُلُّ مَالٍ لَوْ قُبِلَ بِجِنْسِهِ لَا يَحْرُمُ رَبَا الْفَضْلِ، فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرُطُ قَبْضُهُ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلَامِ يَشْتَرُطُ قَبْضُهُ، وَإِنْ كَانَ مَالًا لَوْ قُبِلَ بِجِنْسِهِ لَا يَحْرُمُ رَبَا الْفَضْلِ، فَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الرَّبْوِيِّ فِي الْمَتْنِ هَذَا الْمَالُ، كَالثِّيَابِ مَثَلًا^(٢)، وَهَذَا الْعَكْسُ هُوَ أَوْفَى وَجْهُ التَّرْجِيحِ؛ أَمَّا كَوْنُهُ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ فَلِأَنَّهُ إِذَا وَجِدَ وَصْفَانِ مُؤَثِّرَانِ أَحَدُهُمَا بِحَيْثُ يُعَدُّ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدَمِهِ فَإِنَّ الظَّنَّ بِعِلَّتِهِ أَغْلَبُ مِنَ الظَّنِّ بِعِلَّتِهِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ^(٣)، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْفَى فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعِلَّةِ التَّأْثِيرُ، وَلَا اعْتِبَارَ لِلْعَدَمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ

الاختيار ٢ / ٤٠، التعريفات ص ١٣٦.

(١) السلم في اللغة: السلف وزنا ومعنى، غير أن السلف أعم فيشمل القرض، تقول: أسلمت إليه، أى: أسلفته. ينظر: لسان العرب ١٢/٢٩٥ مادة: سلم، المصباح المنير ص ١٧٢، المعجم الوجيز ص ٣١٩.

والسلم في الشرع: عقد بيع على عين موصوفة في الذمة إلى أجل بتسليم عوض حاضر بشروط مخصوصة فيوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي الثمن آجلاً. ينظر: روضة الطالبين ٣ / ٢٤٢، أسهل المدارك ٢ / ١١٠، الإنصاف ٥ / ٦٦، الاختيار ٢ / ٣٥.

(٢) القبض ليس بشرط في المجلس عند الحنفية؛ لأن كل واحد من البديلين مبيع متعين. وذهب الإمام الشافعي إلى أن القبض شرط باعتبار أنه من ربا الفضل مع الجنس. قال صاحب التقويم: إن علتنا أولى؛ لأن الحكم ينعدم بعدمها، وعلتهم لا توجب العدم؛ لعدمها. ينظر: تقويم الأدلة ص ٣٤٧، ٣٤٨، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ٣٧٩، ٣٨٠، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣٨، ١٣٩، حاشية الفنري على التلويح ٣ / ٥٨.

(٣) قال شمس الأئمة: في ذلك دلالة على تأكيد اتصال الحكم بالعلة، وهذا الوجه صالح لأن يكون مرجحاً. أصول السرخسي ٢ / ٢٦١.

الْحُكْمُ يَثْبُتُ بِعِلَلٍ شَتَّى^(١) فَمَا يَرْجِعُ إِلَى تَأْثِيرِ الْعِلَلِ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى أَقْوَى مِنَ الْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ.

(مَسْأَلَةٌ: إِذَا تَعَارَضَ وَجْهُ التَّرْجِيحِ، فَمَا كَانَ بِالذَّاتِ أَوَّلَى مِمَّا كَانَ بِالْحَالِ، أَيُّ: التَّرْجِيحُ بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ أَوَّلَى مِنَ التَّرْجِيحِ بِالْوَصْفِ الْعَارِضِيِّ، كَمَا إِذَا تَعَارَضَ جِهَتَا الْفَسَادِ وَالصَّحَّةِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ لَمْ يُبَيِّتْهُ)، أَيُّ: لَمْ يَنْوَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَصِحُّ عِنْدَنَا.

(هُوَ يَرْجُحُ الْفَسَادَ بِكَوْنِهِ عِبَادَةً، وَنَحْنُ نَرْجُحُ الصَّحَّةَ بِكَوْنِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ الْيَوْمِ فَالتَّرْجِيحُ بِالْكَثَرَةِ تَرْجِيحٌ بِالذَّاتِ وَذَلِكَ بِالْعَارِضِيِّ)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ الصَّوْمِ وَقَعَ فَاسِدًا؛ لِعَدَمِ النِّيَّةِ فَإِنَّهُ لَا عِبَادَةَ بِدُونِ النِّيَّةِ، وَبَعْضُ وَقَعَ صَحِيحًا لِوُجُودِ النِّيَّةِ لَكِنَّ الصَّوْمَ لَا يَجْزَأُ، فِيمَا أَنَّ يَفْسُدَ الْكُلُّ وَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ الْكُلُّ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ^(٢)، فَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَرْجُحُ الْفَاسِدَ عَلَى الصَّحِيحِ بِوَصْفِ الْعِبَادَةِ،

(١) وعلى ذلك فإن عدم العكس لا يكون قادحاً إلا عند من منع تعدد العلل، وجمهور الأصوليين جوزوا التعليل بأكثر من علة، فلا يشترط الانعكاس، والواقع يشهد بذلك، فإن البول، والغائط، والمذي، والرعاف، والمس كل يوجب الحدث، وهو ممتنع في العلل العقلية، كما نص عليه الغزالي. ينظر: المستصفى ٢/ ٣٤٢، البرهان ٢/ ٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٨٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٨، ٧١، نشر البنود ٢/ ١٣٨.

(٢) قال الإمام السرخسي: "إذا قام دليل الترجيح لمعنى في ذات أحد المتعارضين، وعارضه دليل الترجيح لمعنى في حال الآخر على مخالفة الأول، فإنه يرجح المعنى الذي هو في الذات على المعنى الذي هو في الحال؛ لأن: الترجيح قد وقع لمعنى فيه، فلا يتغير بما حدث من معنى في حال الآخر بعد ذلك بمنزلة ما لو اتصل الحكم باجتهاد فتأيد به، ثم لم ينسخ بما يحدث من اجتهاد آخر بعد ذلك، ولأن: الأحوال التي تحدث على الذات تقوم به، فكان الذات بمنزلة الأصل وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع، والأصل لا يتغير بالتبع على أي وجه كان".

الوجه الأول من أوجه الترجيح بالذات على الترجيح بالحال وهو: أن الذات أسبق وجوداً من الحال فيقع به الترجيح أولاً، فلا يتغير بما يحدث بعده كاجتهاد أمضي حكمه، كما

فَإِنَّ وَصْفَ الْعِبَادَةِ يُوجِبُ الْفَسَادَ، وَهُوَ وَصْفٌ عَارِضِيٌّ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْعِبَادَةِ لِلْإِمْسَاكِ عَارِضِيٌّ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، بَلْ صَارَ عِبَادَةً بِجَعَلِ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِمْسَاكِ^(١).

وَنَحْنُ نَرْجِّحُ الصَّحِيحَ عَلَى الْفَاسِدِ بِكَوْنِ النِّيَّةِ وَاقِعَةً فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ وَالتَّرَجُّحُ بِالْكَثْرَةِ تَرْجِيحٌ بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ وَصْفٌ يَقُومُ بِالْكَثِيرِ بِحَسَبِ أَجْزَائِهِ فَيَكُونُ وَصْفًا ذَاتِيًّا^(٢)؛ إِذِ الْمُرَادُ بِالْوَصْفِ الذَّاتِيِّ وَصْفٌ يَقُومُ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ ذَاتِهِ^(٣)، أَوْ بِحَسَبِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ^(٤)، وَالْوَصْفُ الْعَارِضِيُّ وَصْفٌ يَقُومُ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ أَمْرِ خَارِجٍ عَنْهُ^(٥)، (وَذَكِّرُوا لَهُ أَمْثَلَةً أُخْرَى وَفِيمَا ذَكَّرْنَا كِفَايَةً).

إذا حكم بشهادة مستورين بالنسب، أو النكاح لرجل لم يتغير بشهادة عدلين لآخر. الوجه الثاني من أوجه الترجيح بالذات على الترجيح بالحال وهو: أن الأحوال التي تحدث على الذات تقوم به، فكان الذات بمنزلة الأصل، وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع، والأصل لا يتغير بالتبع على أي وجه كان. ينظر: أصول السرخسي: ٢/ ٢٦٢، ميزان الأصول: ١/ ٧٤١، كشف الأسرار: للبخاري ٤/ ٩٨، التلويح: ٢/ ٢٢٩، فصول البدائع: ٢/ ٤٧٠. (١) ما أثبتته الحنفية - هنا - يناقض ما ألزموا به أنفسهم من تبييت النية في صيام القضاء، والكفارات، والندور؛ حيث لم يُجيزوا الصيام فيها، إلا بتبييت النية.

وما ذكره الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيه احتياط لأمر العبادة، وخروج من العهدة بيقين، كما أن ما يقتضيه الاحتياط مقدم على ما ليس كذلك. ينظر: المنحول من تعليقات الأصول ص ٥٥٥، التقرير والتحبير ٣/ ٣٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٩٢، حاشية الفنري على التلويح ٣/ ٥٨.

(٢) لأن الوصف الذاتي بمنزلة الأصل، وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع، والأصل لا يتغير بتغير التبع على أي وجه كان. ينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٦٢.

(٣) كالجسمية مثلاً.

(٤) كالألوان، والطعوم، حيث إنها لا تدخل في الذات.

(٥) كحمرة الخجل، وصفرة الوجل.

فصل: وَمِنْ التَّرَاجِيحِ الْفَاسِدَةِ: التَّرْجِيحُ بِغَلْبَةِ الْأَشْبَاهِ^(١)

كَقَوْلِهِ (أَي: كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَنَّ الْأَخَ الْمُشْتَرَى لَا يَعْتَقُ عِنْدَهُ^(٢)) (الْأَخُ يُشْبَهُ الْوَلَدَ بِوَجْهِ، وَهُوَ الْمُحَرَّمَةُ وَابْنُ الْعَمِّ بِوَجْهِ كَحِلِّ الزَّكَاةِ وَحِلِّ زَوْجَتِهِ وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَهَذَا بَاطِلٌ^(٣))؛ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ مُؤَثِّرٌ فِي الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ أَقْوَى مِنْهَا (، أَي: مِنْ الْمُشَابَهَةِ) فِي أَلْفٍ وَصْفٍ غَيْرٍ مُؤَثِّرٍ.

وَمِنْهَا: التَّرْجِيحُ بِكَوْنِ الْوَصْفِ أَعَمَّ، كَالطَّعْمِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، وَلَا

(١) وهو: أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد، وبالأصل الآخر الذي يخالف أصل الأول شبه من وجهين أو من وجوه. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١٠١/٤. قال التفتازاني: كما ختم مباحث الأدلة الصحيحة بالأدلة الفاسدة تكميلاً للمقصود، كذلك ختم بحث الترجيحات المقبولة بالترجيحات المردودة والمذكورة منها هاهنا ثلاثة: الأول: الترجيح بغلبة الأشياء؛ لإفادتها زيادة الظن بكثرة الأصول. الثاني: الترجيح بعموم الوصف؛ لزيادة فائدته.

الثالث: الترجيح ببساطة الوصف؛ لسهولة إثباته والاتفاق على صحته. والكل فاسد؛ لأن العبرة في باب القياس بمعنى الوصف، وهو قوته وتأثيره لا بصورته بأن يتكرر الوصف أو يتكرر محال الوصف، أو تقل أجزاؤه. ينظر: التلويح ٢٣٠/٢. (٢) من ملك أخاه: فعند الحنفية، والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، أن الأخ يعتق عليه، وعمم الحنفية والحنابلة هذا الحكم، حتى شمل كل ذي رحم محرم، استحقاقاً للصلة الواجبة، والتي يحرم قطعها، أما المالكية فاقترضوا على الفروع المشاركة له في أصله القريب، فلا يعتق عليه ابن الأخ مثلاً، وحكى اتفاق عامة العلماء في عتق الأصول والفروع، غير أن أهل الظاهر خالفوا في أنه لا يُعْتَقُ عليه قبل أن يُعْتَقَ لثبوت ملكه. وسبب الخلاف هو اختلافهم في ثبوت الأحاديث الواردة في هذا الباب، وتعدد وجوه القياس فقاسه الشافعي على ابن العم، وقاسه غيره على الأب. والراجح: قول الجمهور، لما فيه من المصلحة، والتعظيم لصلة الرحم. ينظر: المبسوط ٧/ ٧٤، ٧٥، الأم ٧/ ٥٣٥، بداية المجتهد ٢/ ٣١٠، روضة الطالبين ٨/ ٤٠٨، الإنصاف ٧/ ٢٩٩.

(٣) لأن وصف المحرمية وحده مؤثر في إعتاقه، ولا عبرة بسواه من الأشياء.

اعتبار لهذا^(١)؛ إذ الترجيح بالقوة، وهو التأثير لا بصورته. ومنها: الترجيح بقلّة الأجزاء^(٢) فإنّ علة ذات جزء أولى من ذات جزأين، ولا أثر لهذا.

(مسألة: يرحح بكثرة الدليل عند البعض^(٣)؛ لغلبة الظن بها (، أي: لأجل حصول غلبة الظن بالحكم بسبب كثرة الدليل. (ولأنّ ترك الأقلّ أسهل من ترك الكلّ، أو الأكثر)، أي: إذا تعارض الأدلة الكثيرة والقليلة، ولا يمكن الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين، فإنّما أن يترك الجميع، أو الأكثر، أو الأقل، وترك الدليل خلاف الأصل، فترك الأقلّ أسهل من ترك الكلّ، أو الأكثر.

(لا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبي يوسف، هما: أنّ كلّ دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر، فوجود الغير وعدمه سواء، وأيضا القياس على الشهادة)

(١) هذا وجه من وجوه الترجيحات الفاسدة عند الحنفية، لكنه صحيح عند أصحاب الشافعي ويسمونه "الترجيح بعموم الوصف" مثل: ترجيح التعليل بوصف الطعم في الأشياء الأربعة على التعليل بالكيل والجنس؛ لأن وصف الطعم يعم القليل، وهو الحفنة مثلا والكثير، وهو المكيل، والتعليل بالكيل والجنس لا يتناول الكثير فكان أولى؛ لأن المقصود من التعليل تعميم حكم النص. ينظر: كشف الأسرار للنسفي ٢ / ٣٨٤، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٠٢، فتح الغفار ٣ / ٦٣.

(٢) مثال ذلك: قول الإمام الشافعي - رحمه الله - في مذهبه الجديد: إن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بَعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ أَزْدَادَ، فَقَدْ أَرَبَى» هي الطعم، وقوله في مذهبه القديم هي: الطعم والتقدير. ينظر: الإحكام: للأمدى ٤ / ٢٧٣، رفع الحاجب: ٤ / ٦٤٠، فصول البدائع: ٢ / ٤٦٨.

(٣) لعله أراد بالبعض من خالف الشيخين في المذهب، وهو الإمام محمد بن الحسن؛ لأن هذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى. ينظر: أصول السرخسي ٢ / ٢٤، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٣٤، الغيث الهامع ٣ / ٨٣٥.

فَإِنَّهُ لَا يُرْجَحُ بَكَثَرَةِ الشُّهُودِ إِجْمَاعًا، فَقَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ ثُمَّ عَطْفَ عَلَى الْقِيَاسِ قَوْلُهُ: (وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ تَرْجِيحِ ابْنِ عَمٍّ هُوَ زَوْجٌ، أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ فِي التَّعْصِيبِ) فَإِنَّهُ لَا يُرْجَحُ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَالِ (عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَسْتَحِقُّ بِكُلِّ سَبَبٍ عَلَى انْفِرَادِهِ)، وَلَوْ كَانَ التَّرْجِيحُ بِكَثَرَةِ الدَّلِيلِ ثَابِتًا كَانَ التَّرْجِيحُ بِكَثَرَةِ دَلِيلِ الْإِرْثِ ثَابِتًا وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ.

(خِلَافًا لِابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأَخِيرِ) ^(١)، أَي: فِي ابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ رَاجِحٌ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَيْسَ كَذَلِكَ، أَي: يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ وَيَجِبُ الْآخَرُ. (بِخِلَافِ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُرْجَحُ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ بِالْأُخُوَّةِ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجِهَةَ) أَيِ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ لِأُمٍّ (تَابِعَةً لِلْأُولَى) أَيِ لِلْأُخُوَّةِ لِأَبٍ (وَالْحِزِّ مُتَحِدٍ) أَيِ حِزِّ الْقَرَابَةِ مُتَحِدٍ؛ لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ لِأَبٍ وَالْأُخُوَّةَ لِأُمٍّ كُلُّهُمَا أُخُوَّةٌ (فَيَحْصُلُ بِهِمَا) أَيِ بِأُخُوَّةِ لِأَبٍ وَالْأُخُوَّةِ لِأُمٍّ (هَيْئَةُ اجْتِمَاعِيَّةٌ بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ) ^(٢)، فَيَصِيرُ مَجْمُوعُ الْأُخُوَّتَيْنِ قَرَابَةً وَاحِدَةً قَوِيَّةً فَيَتَرَجَّحُ عَلَى الْأَضْعَفِ (فَلَا يُرْجَحُ بِكَثَرَةِ الرُّوَاةِ مَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشُّهْرَةِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ حِينَئِذٍ هَيْئَةُ اجْتِمَاعِيَّةٌ).

هَذِهِ تَفْرِيعَاتٌ عَلَى عَدَمِ التَّرْجِيحِ بِكَثَرَةِ الدَّلِيلِ، فَالرُّوَاةُ إِذَا لَمْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ ^(٣) لَمْ تَحْصُلْ هَيْئَةُ اجْتِمَاعِيَّةٌ أَمَا إِذَا بَلَّغُوا فَقَدْ حَصَلَ هَيْئَةُ اجْتِمَاعِيَّةٌ تَمْنَعُ التَّوَافُقَ عَلَى الْكُذْبِ وَقَبْلَ بُلُوغِ هَذَا الْحَدِّ يُحْتَمَلُ كُذْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

(١) بتوريث ابن العم الذي هو أخ لأُم قال الإمام أبو ثور، وشريح، والحسن، وعطاء، والنخعي، وعمر في إحدى الروايتين.

وذهب جمهور الصحابة، والأئمة الأربعة إلى التسوية بينهما في العصوبة، بعد أخذ الأخ لأُم فرضه. ينظر: المبسوط ٢٩ / ١٩٦، ١٩٧، بداية المجتهد ٢ / ٢٩٥، المغني لابن قدامة ٩ / ٣٠، المجموع شرح المذهب ١٨ / ٣٩٥، ٣٩٦.

(٢) الْأُخُوَّةُ لِأَبٍ وَالْأُخُوَّةُ لِأُمٍّ.

(٣) فلا يفيد خبرهم العلم اليقيني، كما عرفت في دراستك لأقسام السنة من حيث السند.

وَأَعْلَمُ أَنَّا نَرْجِّحُ بِالْكَثْرَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَالْتَرَجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ وَكَتَرَجِيحِ الصَّحَّةِ عَلَى الْفَسَادِ بِالْكَثْرَةِ فِي صَوْمٍ غَيْرِ مُبَيَّنٍّ، وَلَا نَرْجِّحُ بِالْكَثْرَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا لَمْ نَرْجِّحْ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَلَنَّا فِي ذَلِكَ فَرْقٌ دَقِيقٌ.

وَهُوَ أَنَّ الْكَثْرَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَحْصُلُ بِهَا هَيْئَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مَنْوُطًا بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْمَجْمُوعُ^(١) وَأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَحْصُلُ بِالْكَثْرَةِ هَيْئَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مَنْوُطًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا بِالْمَجْمُوعِ وَاعْتَبَرَ هَذَا بِالشَّاهِدِ فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَنْوُطٍ بِالْكَثْرَةِ كَحَمْلِ الْأَثْقَالِ وَالْحُرُوبِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ الْأَكْثَرَ فِيهِ رَاجِحٌ عَلَى الْأَقْلَى وَكُلُّ أَمْرٍ مَنْوُطٍ بِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٌ كَالْمُصَارَعَةِ مَثَلًا فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَا يَغْلِبُ الْقَلِيلَ فِيهَا بَلْ رُبَّ وَاحِدٍ قَوِيٍّ يَغْلِبُ الْآلَافَ مِنَ الضَّعَافِ فَكَثْرَةُ الْأُصُولِ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا دَلِيلُ قُوَّةٍ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِيهِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْقُوَّةِ فَتُعْتَبَرُ وَكَثْرَةُ الْأَدِلَّةِ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ دَلِيلٌ هُوَ مُؤَثِّرٌ بِنَفْسِهِ بَلَا مَدْخَلٍ لَوْجُودِ الْآخَرِ أَصْلًا فَإِنَّ الْحُكْمَ مَنْوُطًا بِكُلِّ وَاحِدٍ لَا بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْمَجْمُوعُ بِخِلَافِ الْكَثْرَةِ الَّتِي هِيَ فِي الصَّوْمِ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِالْأَكْثَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْأَكْثَرُ لَا بِكُلِّ وَاحِدٍ، مِنْ الْأَجْزَاءِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فَأَحْكَمُهُ وَفَرَّغَ عَلَيْهِ الْفُرُوعَ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَا الْقِيَاسُ بِقِيَاسِ آخَرَ) عَطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي قَوْلِهِ: فَلَا يُرَجِّحُ

(١) حاصل هذا التفريق يرجع إلى أمرين:

الأول: إن أدت الكثرة، إلى حصول هيئة اجتماعية، تصح وصفاً واحداً قوياً الأثر، فيكون بذلك المرجح هو القوة لا الكثرة....

الثاني: كون الحكم منوطاً بالمجموع، لا بالجميع، كما في الكثرة الحاصلة بشهادة أصليين أو أكثر للوصف المنوط به الحكم على معارضه الذي ليس كذلك. ينظر: التقرير والتحبير ٣/ ٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤، ٢٠١، نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٤٥٨.

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي أَحَدِهِمَا مُغَايِرَةً لِلْعِلَّةِ فِي الْآخَرِ لَكِنَّهُمَا أَدْيَا إِلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ عِلَّةَ الرَّبَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الطَّعْمُ، وَعِنْدَ مَالِكٍ الطَّعْمُ وَالْإِدْخَارُ^(١)، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَتَيْنِ يُوجِبُ حُرْمَةَ بَيْعِ الْحَفْنَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ بِحَفَّتَيْنِ مِنْهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِمَا شَيْئًا وَاحِدًا لَكِنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ قِيَاسَانِ بَلْ قِيَاسٌ وَاحِدٌ مَعَ كَثْرَةِ الْأُصُولِ، وَهَذَا يَصْلَحُ لِلتَّرْجِيحِ.

(وَلَا الْحَدِيثُ بِحَدِيثٍ آخَرَ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يَصْلَحُ عِلَّةً لَا يَصْلَحُ مُرْجَحًا، وَكَذَا إِذَا جُرِحَ أَحَدُهُمَا جِرَاحَةً وَالْآخَرُ عَشْرَ جِرَاحَاتٍ فَالِدِيَّةُ نِصْفَانِ، وَكَذَا الشَّفِيعَانِ^(٢) بِشَفِصَيْنِ مُتَفَاوَتَيْنِ^(٣)). وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُرَجِّحُ صَاحِبَ الْكَثِيرِ أَيْضًا^(٤))

(١) وأما عند الحنفية، فالعلة هي الوزن، أو الكيل مع الجنس، وللحنابلة روايتان: إحداهما: أن العلة في الأربعة، كونها مكيلات جنس، وحكي في المذهب أيضاً، أن العلة في الستة لا تُعَرَّفُ لخفائها، فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا، والراجح هو: قول الحنفية؛ لعموم الأدلة في المكيلات والموزونات.

وعلى هذا فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبوصف الادخار حرم التفاضل عند الإمام مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وباتحاد الوزن أو الكيل مع الجنس حرم التأخير والمفاضلة عند الإمام أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ. ينظر: المبسوط ١٢/ ١٣٣ - ١٣٤، الأم ٣/ ٣٣، بداية المجتهد ٢/ ١١١، الإنصاف ٥/ ١٣ - ٣٦.

(٢) استدل الحنفية بهذا الفرع، على أن ما يصلح بانفراده علة، لا يصلح مرجحاً، حيث قسمت الدية نصفين دون النظر إلى عدد الجراحات، وهذا بخلاف ما لو خدشه أحدهما، وجرحه الآخر، وفي ذلك دليل على أن العبرة بقوة التأثير لا الكثرة. ينظر: تقويم الأدلة ص ٣٩، أصول السرخسي ٢/ ٢٥١، كشف الأسرار للنسفي ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧، كشف الأسرار للبخاري ٤/ ١١٥.

(٣) الشقص: النصيب من الشيء، تقول: أعطاه شقصاً من ماله ومن أرضه، والشقص: هو القليل من الكثير، والجمع: أشقاص، وقيل: الشقص: الحظ والنصيب. ينظر: لسان العرب ٧/ ٤٨ مادة: شقص، المصباح المنير ص ١٩٢.

(٤) إذا كان لرجل حصة في دار فمات شريكه، وهو غائب، فباع ورثته قبل القسّم، أو بعده، فهو على شفيعته، ولا يقطع ذلك القسّم؛ لأنه كان شريكاً لهم، غير مقاسم.

بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ دُونَ الْآخِرِ (وَلَكِنْ يُقَسَّمُ بِقَدْرِ الْمَلِكِ^(١))؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمَلِكِ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ، فنَقُولُ: حُكْمُ الْعِلَّةِ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، وَلَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ هَاهُنَا الْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي يَحْصُلُ الْمَعْلُولُ بِهَا فَإِنَّ الْمَعْلُولَ غَيْرُ مُتَوَلَّدٍ مِنْهَا وَغَيْرُ مُنْقَسِمٍ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْعِلَّةِ الْمَادِّيَّةِ وَهِيَ الَّتِي يَحْصُلُ الْمَعْلُولُ مِنْهَا فَالْمَعْلُولُ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا وَيَنْقَسِمُ عَلَيْهَا كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ فَاسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ غَيْرُ مُتَوَلَّدٍ مِنَ الدَّارِ الْمَشْفُوعِ بِهَا بَلْ هُوَ ثَابِتٌ بِهَا لَا مِنْهَا، فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا.

ينظر: الأم ٤ / ٥، روضة الطالبين ٤ / ١٦٠.

(١) وبه قال المالكية، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقيل: يقسم على عدد الرؤوس، أما الحنفية فالتقسيم عندهم بالتساوي، والترجيح في مثل ذلك يرجع إلى الأحوال ورعاية المصالح، ومرد ذلك إلى تقدير القاضي. ينظر: المبسوط ١٤ / ١١٩، بداية المجتهد ٢ / ٢١٨، الإنصاف ٦ / ٢٠٢.

(بَابُ الاجْتِهَادِ)^(١)

(شَرْطُهُ)^(٢): أَنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الْكِتَابِ^(٣) بِمَعَانِيهِ لُغَةً^(٤) وَشَرْعًا^(٥) وَأَقْسَامَهُ الْمَذْكُورَةَ^(٦)، وَعِلْمَ السَّنَةِ مَتْنًا وَسَنَدًا^(٧)، وَوُجُوهَ الْقِيَاسِ كَمَا ذَكَرْنَا^(٨).

(١) ختم صدر الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - مباحث الأدلة بباب الاجتهاد؛ لأن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة من حيث استنباط الأحكام منها، ولا يمكن ذلك الاستنباط إلا عن طريق الاجتهاد، وهو لغة: تحمل الجهد، أي: المشقة، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. ومعنى الاستفراغ: بذل تمام الطاقة، بحيث يشعر من نفسه العجز عن المزيد، ولم يذكر المصنف تعريف الاجتهاد لشهرته عند الفقهاء.

(٢) أي: شرط الاجتهاد، والمراد به هنا المجتهد؛ حيث أطلق المصدر (الاجتهاد) وأراد به اسم الفاعل.

(٣) المراد بالكتاب: القرآن الكريم.

(٤) بأن يعرف معاني المفردات والمركبات، فيحتاج إلى علم اللغة العربية، التي استمد منها علم أصول الفقه، فيما سبق لك دراسته في الفرقة الأولى.

(٥) بأن يعرف المعاني المؤثرة في الأحكام، كقوله تعالى: ﴿... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ...﴾ [سورة النساء من الآية رقم ٤٣]، فالمراد بالغائط: الحدث، وأن خروج النجاسة علة لوجوب الطهارة.

(٦) أي: أقسام الكتاب، والمراد بها: العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وغير ذلك، مما سبق لك دراسته في الفرقتين الأولى والثانية.

(٧) عطفًا على علم الكتاب، والمراد بالمتن: لفظ الحديث، وبالسند: طريق وصولها إلينا، من كونها متواترة أو مشهورة أو آحادًا. والعلم بالكتاب والسنة لا يعني حفظهما عن ظهر قلب، وإنما المراد قدر ما يتعلق بمعرفة الأحكام، بحيث يتمكن من الرجوع إليهما عند طلب الحكم.

وهنا سؤال، هو: لماذا لم يذكر المصنف الإجماع ضمن الشروط التي ذكرها للمجتهد؟ والجواب: أن الإجماع مستمد من الكتاب والسنة، ولا يستقل بإنشاء الأحكام كمصدر ذاتي كما هو الحال في الرأي العام الذي يسن القوانين والتشريعات دون الاستناد إلى شيء.

(٨) أي: معرفة أركان القياس، وشروط كل ركن، وأحكامه. ثم هذه الشروط السابقة إنما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام، وأما المجتهد في حكم دون حكم، فعليه معرفة ما تعلق بذلك الحكم.

وَحُكْمُهُ^(١): غَلْبَةُ الظَّنِّ عَلَى احْتِمَالِ الْخَطَا^(٢)، فَالْمُجْتَهِدُ عِنْدَنَا^(٣) يُخْطِئُ وَيُصِيبُ^(٤)، وَعِنْدَ الْمُعْتَزَلَةِ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ^(٥)، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَادِثَةٍ حُكْمًا مُعَيَّنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَعِنْدَهُمْ لَا، بَلْ الْحُكْمُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ، فَإِذَا اجْتَهَدُوا فِي حَادِثَةٍ فَالْحُكْمُ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى - فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مُجْتَهِدٍ^(٦). لَهُمْ^(٧): أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ كَلَفُوا بِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وَلَوْلَا تَعَدُّدُ الْحَقُوقِ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ

(١) حكم الاجتهاد، أي: الأثر المترتب عليه بالنظر إلى الفروع هو: غلبة الظن، مع احتمال الخطأ، فلا يجري الاجتهاد في القطعيات، وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين.

(٢) أي: مع احتمال الخطأ، ف (على) هنا بمعنى مع.

(٣) أي: عند أهل السنة والجماعة.

(٤) ولذلك سمي هؤلاء بالمخطئة، وهم: القائلون بأن المجتهد يخطيء ويصيب، وأن القياس يكون صحيحاً معتبراً من الأدلة الشرعية إذا وافق الواقع، ويكون فاسداً وغير معتبر من الأدلة إذا لم يوافق. ينظر: نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص ٢٦، رسالتنا للماجستير (تحقيق ودراسة باب القياس من شرح القطب الشيرازي على مختصر ابن الحاجب) ص ٩٢.

(٥) ولذلك سمي هؤلاء بالمصوبة، وهم: القائلون بأن كل مجتهد مصيب، وأن المدار في الأحكام الشرعية على ما أدى إليه نظر المجتهد حتى لو تغير اجتهاده وعدل عن قياس إلى دليل آخر لا يحكم على القياس الأول بالفساد، بل هو دليل انتهى حكمه كالمسوخ. نبراس العقول ص ٢٦، رسالتنا للماجستير ص ٩٣.

(٦) هذا الكلام بيان لسبب الخلاف في المسألة، ويعنون لها البعض ب: التصويب والتخطئة فالمجتهد عندما يجتهد في مسألة ما، ويصل إلى حكم معين في تلك الحادثة، فهل اجتهاده هذا صواب لا يحتمل الخطأ، أو أنه صواب يحتمل الخطأ، فعلى الأول يكون كل مجتهد مصيباً، وبه قال المعتزلة ومن وافقهم، ويسمون بالمصوبة، وبناء عليه ليس لله تعالى حكم معين في المسألة قبل الاجتهاد، ويكون الحق متعددًا، وعلى الثاني المجتهد يخطيء ويصيب، وبه قال بعض الحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة، وبناء عليه يكون لله تعالى حكم معين في كل واقعة قبل الاجتهاد، إن وافقه المجتهد كان مصيباً، وله أجران، وإن لم يوافقه كان مخطئاً وله أجر واحد، فيكون الحق واحداً.

(٧) أي: أدلة المعتزلة ومن معهم، وهؤلاء يسمون بالمصوبة كما عرفنا.

بِمَا لَيْسَ فِي وَسْعِهِمْ، وَهَذَا كَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ^(١) فَإِنَّ الْقِبْلَةَ جِهَةٌ التَّحَرِّي حَتَّى إِنْ الْمُخْطِئُ يَخْرُجُ عَنْ عُهُدَةِ الصَّلَاةِ. وَاخْتِلَافُ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْمَيْنِ جَائِزٌ كَمَا كَانَ فِي إِرْسَالِ رَسُولَيْنِ عَلَى قَوْمَيْنِ^(٢). (ثُمَّ اخْتَلَفُوا)^(٣) فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَسَاوِي الْحَقُوقِ^(٤)؛ لِأَنَّ دَلِيلَ التَّعَدُّدِ لَا يُوجِبُ التَّفَاوُتَ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَاحِدٌ مِنْهَا أَحَقُّ^(٥)؛ لِأَنَّهَا لَوْ

(١) يعني أن اجتهاد المجتهد في الحكم كاجتهاد المصلي في أمر القبلة، والحق فيه متعدد اتفاقاً، فكذا ههنا؛ لعدم الفرق، وإنما قلنا: إن الحق فيه أن يكون الشيء واجباً على مجتهد وعلى من التزم تقليده، وغير واجب على آخر وعلى مقلديه. الوجزة النافعة ص ٥٢٨.

(٢) هذا جواب عن القول بأن تعدد الحقوق يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، وهما الحل والحرمة، والصحة والفساد في شيء واحد، وحاصل الجواب: أن الحق يكون متعدداً إذا كان الحظر والإباحة حقاً عند قيام الدليل على التعدد كما صح التعدد عند اختلاف الرسل، فقد قال الله تعالى (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) (من الآية رقم ٤٨ من سورة المائدة) فتقتصر رسالة كل واحد على قومه، وكذلك المقلد لمجتهد، يلزمه اتباع إمامه. انظر: تقويم الأدلة ص ٤٠٨، كشف الأسرار للبخاري ٢٧/٤ - ٢٨، التلويح ٣٣١/٢ - ٣٣٣.

(٣) القائلون بأن كل مجتهد مصيب، وهم المعتزلة ومن وافقهم اختلفوا على أربعة مذاهب باعتبارات مختلفة في تقرير هذا القول وما يترتب عليه، بذكرها المصنف فيما يلي.

(٤) وهؤلاء هم الذين قالوا: بأن الحكم ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وليس لله - تعالى - فيها حكم، قبل الإجتهد في المسألة، وهذا القول من المغالاة، قاله ابن برهان، وعده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني سفسطة، ودليلهم على عدم التفاوت: أن التكليف بإصابة الحق، يوجب أن يكون ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد حقاً، وعليه: فلا يمكن الترجيح. ينظر: المحصول ٥٠٣/٢، الوصول إلى الأصول ٣٤١/٢، كشف الأسرار للبخاري ٢٨/٤، التلويح ٣٣١/٢.

(٥) وهؤلاء هم الذين يقولون بالاشبة، وهو مطلوب المجتهد، ولم يكلف به، لأن الحكم لم يتعلق بالمسألة قبل الإجتهد، والحكم قديم، وبذلك فسرهم الإمام الأشعري والغزالي، وقال صاحب التقويم: إن التسوية في ذلك تُبطل مراتب الفقهاء ومنازل المجتهدين وتقطع التكليف به وتبطل المناظرة. ينظر: تقويم الأدلة ص ٤٠٨، المعتمد ٣٧١/٢، المستصفى ٣٦٣/٢، كشف الأسرار للبخاري ٢٨/٣ - ٢٩، التلويح ٣٣١/٢.

اُسْتُوتَ لِأَصِيبَتْ بِمُجَرَّدِ الْاِخْتِيَارِ وَلَسَقَطَ الْاِجْتِهَادُ. وَفِيهِ نَظَرٌ^(١)؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْاِجْتِهَادِ لَا يُعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ الْاِجْتِهَادَاتِ تَتَّفِقُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ الْحَقُّ وَاحِدًا، أَوْ تَخْتَلِفُ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُتَعَدِّدًا).

(وَلَنَا^(٢)): قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾^(٣)، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ»^(٤) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ "جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُصِيبِ أَجْرَيْنِ وَلِلْمُخْطِئِ وَاحِدًا"^(٥) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - "إِنْ أَصَبْتَ

(١) هذا اعتراض على ما استدل به القائلون: إن كل مجتهد مصيب.

(٢) أي: استدل أصحابنا على أن الحق واحد، و المجتهد يخطيء ويصيب بأدلة من الكتاب، والسنة، والأثر، ودلالة الإجماع، والمعقول.

(٣) من الآية رقم ٧٩ من سورة الأنبياء.

هذا دليلنا من الكتاب، والضمير "ها" في الآية يرجع إلى الحكومة - بفتح الحاء - أو الفتوى.

ووجه الاستدلال: أن نب الله داود عَلَيْهِ السَّلَامُ حكم بالغنم لصاحب الحرث، وبالحرث لصاحب الغنم، ونبى الله سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ حكم بأن يكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها، ويقوم أصحاب الغنم على الحرث حتى يرجع كما كان، فيرد كل إلى صاحبه لتخصيص سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ با لذكر جهة؛ فإنه وإن لم يدل على نفي الحكم عما عداه، لكنه في هذا المقام يدل عليه - كما لا يخفى على من له معرفة بخواص التراكيب، وهذا مبني على جواز اجتهاد الأنبياء عليهم السلام وجواز خطئهم فيه. الوجيزة النافعة ص٥٢٨-٥٢٩، التلخيص ص٤٣٩

(٤) هذا الحديث رواه الدارقطني عن عمرو بن العاص، ومثله عن عقبة بن عامر حين قضى بين رجلين عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإسناده ضعيف؛ لأن فيه فرح بن فضالة، وهو ضعيف. سنن الدارقطني ٣/٤، كتاب: الأقضية والأحكام، التلخيص الحبير ١٨٠/٢ رقم ٢٠٧٢.

(٥) هذا الحديث مروى عن عمرو بن العاص قال: قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر". أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ٤/٤٠٦ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد - رقم ٧٣٥٢-، أبو داود في سننه ٥٠٦/٢ كتاب: الأقضية، باب: طلب

فَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ «^(١)، وَلِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْقِيَاسِ ثَابِتٌ بِمَعْنَى النَّصِّ^(٢)، وَإِنْ وَرَدَ نَصَانٌ صِغَةً فِي حَادِثَةٍ لَا يَتَعَدَّدُ الْحَقُّ اتِّفَاقًا، فَكَيْفَ إِذَا وَرَدَا مَعْنًى، أَيْ: كَيْفَ يَتَعَدَّدُ الْحَقُّ إِذَا وَرَدَا مَعْنًى^(٣).

نَظِيرُهُ^(٤) حُلِّي النِّسَاءِ فَإِنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى الْمَضْرُوبِ، وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ قِيَاسًا عَلَى الثِّيَابِ، فَإِنَّ كَلًّا مِنْهُمَا^(٥) مَضْرُوفٌ لِحَاجَتِهِ، فَعَنَى الْقِيَاسِ أَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَارِدٌ فِي الْمَقِيسِ مَعْنًى^(٦)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِدًا صَرِيحًا، فَلَوْ كَانَ النَّصَانِ وَارِدَيْنِ فِيهِ صَرِيحًا كَانَ الْحَقُّ

القضاء، ونصه فأخطأ- رقم ٣٥٧٤ -، ومسلم في صحيحه بشرح النووي ١٣/١٢ كتاب: الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد.

(١) هذا الأثر قاله ابن مسعود في مسألة المفوضة، فعن عبدالله بن عتبة قال: أتى عبدالله بن مسعود رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، ولم يسم لها صداقاً، فاختلفوا إليه في ذلك شهراً، فقال: " أقضي أن لها صداق امرأة من نساءها، لا وكس، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يكن صواباً، فمن الله، وإن يكن خطأً، فمن نفسي، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك ". ينظر: سنن البيهقي، باب: التفويض ٢٤٣/٧.

(٢) هذه دلالة الإجماع؛ لأن القياس مظهر لا مثبت، فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنى، وإن لم يكن ثابتاً به صريحاً، وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير. التلخيص ص ٤٣٩.

(٣) هذا هو دليلنا من المعقول؛ لأن كون الفعل محظوراً ومباحاً، أو صحيحاً وفاسداً أو واجبا وغير واجب ممتنع؛ لاستلزامه اتصاف الشيء بالنقيضين، والممتنع لا يكون حكماً شرعياً. التلخيص ص ٤٤٠.

(٤) أي: شبيه هذه المسألة التي اختلف فيها المعتزلة مع أهل السنة والجماعة الخلاف في حلي النساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟.

(٥) أي: قياس حلي النساء على المضروب كما عند الحنفية، وقياسه على الثياب كما عند الشافعية.

(٦) والإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يقول: بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء، وبهذا قال

وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ فِي أدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا وَالْآخَرُ نَاسِخًا، فَإِذَا كَانَ النَّصَّانِ وَهُمَا النَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْمَضْرُوبِ وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الثِّبَابِ وَارِدَيْنِ فِي الْحَلِيِّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ مَدْلُولِي كُلِّ مِنْهُمَا؛ إِذْ دَلَّاهُمَا مَعْنَى لَا تَزِيدُ عَلَى دَلَّاتِهِمَا صَرِيحًا، وَلَوْ وَجِدَتْ دَلَّاتُهُمَا صَرِيحًا لَا يَكُونُ مَدْلُولُ كُلِّ مِنْهُمَا حَقًّا، فَكَذَا إِذَا وَجِدَتْ دَلَّاتُهُمَا مَعْنَى بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ^(١)، (وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُظْرِ وَالْإِبَاحَةِ مُمْتَنِعٌ، وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْمَيْنِ فِي شَرِيعَتِنَا، وَالتَّكْلِيفُ بِالِاجْتِهَادِ يُفِيدُ).
جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الْمُعْتَزَلَةِ: إِنَّ الْمُجْتَهِدِينَ كَلَّفُوا (لِأَنَّهُ إِنْ أَخْطَأَ، فَهُوَ مُصِيبٌ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ وَلَهُ الْأَجْرُ^(٢)).

الإمام مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد أيضاً، حيث اعتبروا أن حلي المرأة، يشبه العروض التي يقصد منها المنافع، وأما الحنفية، فقد أوجبوا الزكاة في حلي النساء، متى بلغ النصاب، لا فرق في ذلك بين ما كان للرجال، أو النساء، مصوغاً صياغة تحل، أو لا تحل، قياساً على المضروب، لكونها أثماناً، هذا ولا خلاف في الحلي المدخر، والمحرم، وحلي الصيارف، وما شابه ذلك، ففيه الزكاة. ينظر: الأم ٦١/٢، ٦٢، المبسوط ٢٥٧/٧، بداية المجتهد ٢٣٠/١، ٢٣١، روضة الطالبين ١٢١/٢، ١٢٢، أسهل المدارك ٢٢٧/١، ٢٢٨، الإنصاف ١٠٠/٣، ١٠١.

(١) وجه الأولوية هنا من حيث إثبات عدم تعدد الحق يرجع إلى اعتبار أن القياس مُظهر لا مثبت، فيكون الثابت بالقياس ثابت بالنص معنى. والإجماع قائم على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير، فيكون الحق في المقيس واحداً أيضاً، كما أنه واحد في المقيس عليه. وفيه نظر: لأن القياس عند المعتزلة مثبت لا مُظهر، ولأن الحكم الاجتهادي أعم من أن يكون ثابتاً بالقياس بل هو متعلق بكثير من الأدلة الظنية التي جرى فيها الخلاف، والإجماع على اتحاد الحق إنما وقع فيما لم يقع فيه خلاف. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٣٣/٤، التلويح ٣٣٣/٢-٣٣٤، التلخيص ص ٤٣٩.

(٢) بذلك سقطت دعوى المعتزلة، وهي: أن التكليف بالاجتهاد، تكليف بما ليس بالوسع، حيث قد ثبت للمخطيء أجر دل على التماس العذر؛ لأنه يكفي في المأمور به أن يكون حقاً بالنظر إلى الدليل، وبحسب ظن المجتهد، وإن كان خطأ عند الله تعالى. ينظر: تقويم الأدلة ص ٤١٠، كشف الأسرار للبخاري ٢٧/٤، التلخيص ص ٤٤٠.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ فَسَادَ صَلَاةٍ مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ عَالِمًا يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا^(١).
فَأَمَّا عَدَمُ إِعَادَةِ الْمُخْطِئِ لِلْكَعْبَةِ^(٢)؛ فَلِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، لَكِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهَا وَسِيلَةً
إِلَى الْمَقْصُودِ، وَهُوَ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى، فَأُقِيمَ غَلْبَةُ ظَنِّ إِصَابَتِهَا مَقَامَ إِصَابَتِهَا^(٣) (ثُمَّ
اِخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي الْمُخْطِئِ، فَعِنْدَ الْبَعْضِ مُخْطِئٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، أَيْ: بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ
وَبِالنَّظَرِ إِلَى الْحُكْمِ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ إِطْلَاقِ الْخَطَا فِي الْحَدِيثِ، وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
«فِي أُسَارَى بَدْرٍ»^(٤) حِينَ نَزَلَ: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ الْآيَةُ^(٥)، «لَوْ نَزَلَ بِنَا عَذَابٌ
مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ»^(٦)، (هَذَا هُوَ الْمَقُولُ لِقَوْلِهِ^(٧) -

(١) وهو: أن المجتهد يخطيء ويصيب؛ إذ لو كان كل مجتهد مصيباً، لصحت صلاة من خالف الإمام عالماً بحاله؛ لإصابتها جميعاً في جهة القبلة. الوجيزة النافعة ص ٥٣٠.

(٢) عدم إعادة المخطيء للكعبة، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إذا تبين الخطأ، غير أن الإمام مالك استحب له الإعادة، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه متى تبين الخطأ، وجب عليه الإعادة، أما إذا لم يتبين الخطأ، فصلاته صحيحة، بناء على اجتهاده، وظنه. ينظر: الأم ٨٧/١، ٨٨، المبسوط ١٠/١٩٨-١٩٩، بداية المجتهد ٨٧/١-٨٨، أسهل المدارك ١١٠/١، الإنصاف ٥/٢.

(٣) أي: المقصود هي الجهة التي رضىها الله - تعالى - وأمر بها، وعند حصول المقصود لا بأس بفوات الوسيلة. ينظر: الوجيزة النافعة ص ٥٣٠.

(٤) غزوة بدر الكبرى أول موقعة بين المسلمين والكفار، في السنة الثانية للهجرة النبوية.

(٥) رقم ٦٨ من سورة الأنفال.

(٦) هذا الحديث أورده الإمام القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: (مَا كَانَ لِإِنبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) (من الآية رقم ٦٧ من سورة الأنفال) ، ونصه: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ كَانَ لِيَصِينَا - في خلاف ابن الخطاب - عذاب، ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر)، ومثله في الدر المنثور للسيوطي. وفي صحيح مسلم: (قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر بن الخطاب: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة). راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ٨٦/١٢، ٨٧ كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، تفسير القرطبي ٣/٢٩٦٠-٢٩٦١، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ١١٠/٤.

(٧) مقول القول هو: القول المفيد التام، الذي يأتي بعد فعل القول المذكور أو المحذوف، أو

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُخْطِئَ مُخْطِئٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَوْ كَانَ مُصِيبًا مِنْ وَجْهِ لَمَّا كَانُوا مُسْتَحَقِّينَ لِزُورِ الْعَذَابِ وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَقِصَّتُهُ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ.

(وَعِنْدَ الْبَعْضِ مُصِيبٌ ابْتِدَاءً^(١) مُخْطِئٌ انْتِهَاءً^(٢))، وَهَذَا مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَالْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدًا لَا يُرَادُ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحُكْمِ بَلْ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ أَقَامَ الدَّلِيلَ كَمَا هُوَ حَقُّهُ مُسْتَجْمَعًا لِشَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ، فَيَكُونُ آتِيًا بِمَا كَلَّفَ بِهِ مِنْ الْإِعْتِبَارِ، وَلَيْسَ فِي وَسْعِهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ الْقَطْعِيِّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ حَتَّى يَكُونَ مَذْلُومُهُ قَطْعِيًّا أَبْتَدَءَ^(٣)؛ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾^(٤))، فَسَمِيَ عَمَلُ كُلِّهِمَا حُكْمًا وَعِلْمًا^(٥)، لَكِنَّ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خُصَّ بِإِصَابَةِ الْحَقِّ الْمَطْلُوبِ وَتَنْصِيفِ الْأَجْرِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا، أَيْ: عَلَى أَنَّهُ مُصِيبٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ آخَرَ. (وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُكُمْ﴾^(٦))، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْأُسَارَى مِنْ قَبْلُ كَانَ إِمَّا الْقَتْلُ، أَوْ الْمَنُ^(٧) وَرَخَّصَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْفِدَاءِ أَيْضًا، فَلَوْلَا الْكِتَابُ

يَأْتِي بَعْدَ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقَوْلِ.

(١) أي: بالنظر إلى الدليل.

(٢) أي: بالنظر إلى الحكم؛ لأنه لا يمتنع في الأقيسة الشرعية والأدلة الظنية أن تتناقض المطالب والأحكام مع رعاية الشرائط قدر الوسع والطاقة؛ ولذلك وصف الله تعالى اجتهد داوود - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بالحكم والعلم في مقام الشاء عليه والامتنان مع كونه خطأ، بدلالة سوق الكلام في تخصيص سليمان - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بإصابة الحق، فلو كان خطأ من كما وجه لما كان حكما وعلمًا، بل جهلا وخطأ. ينظر: الوجيزة النافعة ص ٥٣١.

(٣) لأنه يلزم العمل بالظن في كل ما هو مظنون شرعا.

(٤) من الآية رقم ٧٩ من سورة الأنبياء.

(٥) رغم إصابة أحدهما وعدم إصابة الآخر.

(٦) من الآية رقم ٦٨ من سورة الأنفال.

(٧) القائلون بأن المجتهد المخطيء مخطيء ابتداء وانتهاء تمسكوا بوجهين: الوجه الأول:

السَّابِقُ بِإِبَاحَةِ الْفِدَاءِ، - وَهُوَ الرُّخْصَةُ - لِمَسْكُمُ الْعَذَابُ عَلَى تَرْكِ الْعَزِيمَةِ، فَزُورُ الْعَذَابِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ سَبْقِ الْكِتَابِ لَكِنْ سَبْقُ الْكِتَابِ كَانَ وَقِعًا، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ وَقِعًا بِسَبَبِ الْخَطَأِ فِي الْاجْتِهَادِ بَعْدَ سَبْقِ الْكِتَابِ.

(وَالْمُخْطِئُ فِي الْاجْتِهَادِ لَا يُعَاقَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ الصَّوَابِ يَبِينُ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ). والله أعلم.

إطلاق الخطأ في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ "، ومن حكم المطلق أن ينصرف إلى الكامل، وهو الخطأ ابتداء وانتهاء. ويجاب عنه: بأن هذا ضعيف؛ لأن الاستدلال بالإطلاق على الكمال مما لا يعتد به في مسائل الأصول. التلخيص ص ٤٤٢.

الوجه الثاني: قوله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق) من الآية وقم ٦٨ من سورة الأنفال، أي: لولا ما كتب في اللوح أن لا يعذب أهل بدر، أو أن يحل لهم الغنائم، أو أن لا يعذب قوما إلا بعد تأكيد الحجة وتقدير النهي لمسكم عذاب عظيم في اتباع الاجتهاد الخطأ، الذي هو أخذ الفدية، فلو كان صوابا من وجه لما استحقوا باتباعه العذاب العظيم؛ لوجود امتثال الأمر في الجملة.

ويجاب عنه: بأن العزيمة في حكم الأسارى كان هو المن أو القتل، وقد رخص للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الفداء أيضا، فالمعنى: لولا سبق الحكم بإباحة الفداء والرخصة فيه لمسكم العذاب في ترك العزيمة، فوجوب العذاب معلق بعدم سبق الكتاب، لكن المعلق عليه غير واقع؛ لتحقيق سبق الكتاب، فلا يتحقق وجوب العذاب بسبب الخطأ في الاجتهاد. ينظر: التلخيص ص ٤٤٢، الوجيزة النافعة ص ٥٣١.

(١) أي: أن من اجتهد وبذل وسعه وأخطأ في اجتهاده، فإنه لا يعاقب ولا ينسب إلى الضلال، بل يكون معذورا ومأجورا؛ إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل، فلم ينل الحق؛ لخفاء دليله، إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب بينا، فأخطأ المجتهد لتقصير منه وترك مبالغة في الاجتهاد، فإنه يعاقب.

وقوله: (المخْطِئُ فِي الْاجْتِهَادِ) احتراز من الخطأ في الأصول والعقائد، فإن المخْطِئَ فيها يعاقب، بل يضل أو يكفر؛ لأن الحق فيها واحد إجماعا، والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية؛ إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه، وجواز رؤية الصانع وعدمه، فالمخْطِئُ فيها مخْطِئٌ ابتداء وانتهاء. ينظر: التلخيص ص ٤٤٣.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المنهج المقرر	٤
أولاً: الدراسة الموضوعية.....	٥
أولاً: الحاكم.....	٦
ثانياً: المحكوم فيه	١١
أقسام المحكوم فيه:.....	١٦
أنواع حقوق الله تعالى	٢٥
ثالثاً: المحكوم عليه	٤٧
رابعاً: الحكم.....	٥١
تقسيم الحكم الشرعي	٥٩
أولاً: أقسام الحكم التكليفي	٦٣
القسم الأول ما أعتبرت فيه المقاصد الدنيوية اعتباراً أولياً.....	٦٦
القسم الثاني ما أعتبرت فيه المقاصد الأخروية اعتباراً أولياً.....	٧٣
أولاً: العزيمة (الحكم الأصلي):	٧٣
أولاً: الفرض:.....	٧٧
ثانياً: الواجب:	٨١
ثالثاً: السنة:.....	٩٧
رابعاً: النفل:	١٠٣
خامساً: الحرام:.....	١٠٩
سادساً: المكروه:.....	١١٤
سابعاً: المباح:	١١٧
ثانياً: الرخصة (الحكم غير الأصلي):.....	١٢١
الحكم التعليقي (الوضعي).....	١٤٢
أولاً: الركن:.....	١٤٣
ثانياً: العلة:.....	١٤٥
ثالثاً: السبب:.....	١٦٢
رابعاً: الشرط:.....	١٧٩
خامساً: العلامة:.....	١٨٤
الأهلية وعوارضها	١٨٨

أولاً- أهلية الوجوب	١٨٨
ثانياً- أهلية الأداء	١٩٠
عوارض الأهلية	١٩٦
أولاً: العوارض السماوية	١٩٨
١- الصغر	١٩٨
٢- الجنون	٢٠٥
٣- العتله	٢١٦
٤- النسيان	٢٢٠
٥- الغفلة	٢٣٤
٦- النوم	٢٣٩
٧- الإغماء	٢٤١
٨- المرض	٢٤٥
٩- الحيض	٢٤٨
١٠- النفاس	٢٤٩
ثانياً: العوارض المكتسبة	٢٥١
١- الجهل	٢٥١
٢- السكر	٢٥٨
٣- السفه	٢٦٠
٤- السفر	٢٦٢
٥- الهزل	٢٦٦
٦- الخطأ	٢٧٣
٧- الإكراه	٢٧٧
ثانياً: الدراسة النصية	٢٨٣
(فصل في: دفع العلل المؤثرة)	٢٨٣
(فصل في دفع العلل الطردية)	٣١٢
(فصل في الانتقال)	٣٢٢
(فصل في الحجج الفاسدة)	٣٢٥
(بَابُ الْمُعَارَضَةِ وَالتَّرْجِيحِ)	٣٣١
(فَصْلٌ: مَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ)	٣٥٥
(فَصْلٌ: وَمِنْ التَّرْجِيحِ الْفَاسِدَةِ: التَّرْجِيحُ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ)	٣٧٦
(بَابُ الاجْتِهَادِ)	٣٨٢